

D.17.2.63 pr.) (iv) el marido que debía devolver la dote por la *actio rei uxoriae* (Inst., 4.6.37), etc.

b) Si el acreedor tiene varios créditos similares (así, de dinero) contra el mismo deudor, corresponde en principio al deudor indicar a cuál de ellos debe imputarse el pago (Ulp., D.46.3.1; Paulo, D.46.3.101.1). Si no lo hace el deudor, la imputación la realizará el acreedor (Caracalla, C.8.43(42).1, año 212).

En esta misma constitución se indica que si ni uno ni otro expresó su voluntad, corresponde imputar lo pagado primero a los intereses y luego al capital. Todo esto motivó una amplia casuística (Ulp., D.46.3.1-8); así, se debía imputar el pago primero a la obligación vencida antes que a la aun pendiente; entre varias deudas vencidas, la imputación debía ser al pago de la más gravosa: p.ej., primero a la que arrastre la infamia; luego, a la que tenga una pena; en tercer lugar, la garantizada con *pignus*; etc. (v. Pap., D.46.3.97).

§ 472. ¿Quién puede hacer el pago? En principio, el pago le corresponde al deudor. Pero también puede hacerlo un tercero, siempre y cuando que el cumplimiento de la obligación no requiera cualidades personales especiales (p.ej., en una locación de obra, la pintura de un cuadro). Fuera de este caso, el pago efectuado por el tercero extingue la obligación. Se debe tratar de alguien capaz de enajenar (Inst., 2.8.2) y si se trata de la propiedad de una cosa, ser el *dominus* de ella, puesto que de lo contrario, ante la *rei vindicatio* triunfante del verdadero dueño, el pago no surte efectos. Se pueden dar los siguientes supuestos:

a) Que el tercero pague por "orden" del deudor. En este caso media entre el deudor y el tercero un mandato. El tercero puede ejercer la *actio mandati contraria* si el mandante no le restituye lo que pagó.

b) Que el tercero pague "en ausencia" o "sin saberlo" el deudor. Siempre que no haya habido *animus donandi*, y simplemente se haya querido realizar una "gestión útil" en favor del deudor, se da acá el supuesto de la *negotiorum gestio* (Inst., 3.27.1; Gayo, D.3.5.38(39)). El tercero tiene la *actio negotiorum gestorum contraria*, para recobrar el monto de lo "útil" que le ha sido al *dominus negotii*.

c) Que el tercero pague "en contra de la voluntad del deudor". En este caso el pago es válido y el tercero carece de acción para recobrar lo pagado (Inst., 3.29 pr.). Sin embargo, el que paga puede obtener la cesión de acciones por parte del acreedor a quien ha pagado.

Con posterioridad, considerando la figura del "enriquecimiento injusto" que obtendría el deu-

dor beneficiado por la liberación de la obligación, se le concederá la *actio neg. gest. contraria*, ejercida útilmente (Gayo, D.3.5.38(39)), y en los tiempos del Bajo Imperio, también la *actio de in rem verso*, extendida por analogía y como *actio utilis*.

§ 473. ¿A quién se debe pagar? En primer lugar corresponde pagar al acreedor. Pero también se puede válidamente pagar al mandatario —*procurator*— de éste, el cual puede revocar la permisión en cualquier momento (Ulp., D.46.3.12 pr.; D.46.2).

1. Aunque no se pague al verdadero *procurator*, el pago es válido siempre que fuera ratificado por el mandante (Ulp., D.46.3.12.4).

2. Si el acreedor es un pupilo, hay que pagar al tutor, o al pupilo con la *auctoritas* del tutor. De lo contrario, el pago no libera, si bien el deudor que pagó tiene la *exceptio doli* hasta el monto del enriquecimiento patrimonial del pupilo (Pomp., D.46.3.11; Ulp., D.44.4.4.4).

3. En la *stipulatio* se podían dar dos casos: a) Que se designe a una persona para recibir el pago (así, "Prometes darme a mí o a Ticio?", *adiectio solutionis causa*). El pago efectuado a Ticio es válido (Gayo, 3.103a, Ulp., D.46.3.12.1). Ticio sólo está habilitado para recibir el pago, pero no tiene acción contra el deudor (Pomp., D.46.3.81 pr.). b) El otro caso es el del *adstipulator* (Gayo, 3.110 y ss.), quien no sólo puede recibir el pago, sino además tiene acción para el cobro de lo debido.

4. Si el acreedor rechaza, en forma injustificada el pago, entonces incurrirá en mora (*mora creditoris*), por lo que el deudor puede depositar la prestación. Generalmente la sella (*obsignatio*) y la deposita (*depositio*) en un templo o en un edificio público (v. supra, § 463).

§ 474. ¿Dónde se debe pagar? Lo común es que el lugar de cumplimiento de la obligación esté determinado en el propio negocio (Gayo, D.13.4.1). Si nada se estableció al respecto, lo ordinario es que el acreedor reclame el pago allí donde lo puede exigir judicialmente (Gayo, D.13.3.4; Jul., D.12.1.22). Pero también atendiendo a la naturaleza de las prestaciones y a las circunstancias del caso.

1. El lugar oportuno para el pago, cuando no se lo ha fijado en el negocio, nos conduce a una casuística donde impera lo razonable y práctico de las prestaciones. Así, si es un inmueble, hay que darlo o prestarlo en el lugar donde está ubicado; si se trata de una cosecha, lo normal es exigirla allí donde ésta se levante; y en general, allí donde tenga las cosas el deudor, siempre y cuando que éste dolosamente no las haya trasladado (Licinio Rufo, D.5.1.38).

De todos modos, el acreedor tiene la *actio ad exhibendum* para lograr que el deudor traiga ante sí la cosa debida (D.10.4).

2. Si el acreedor debe reclamar lo debido por una *stipulatio* en un lugar determinado, y ya sea que el deudor no estuviera en él, ya lo hiciera en forma intencional o por necesidad, el pretor, para evitarle al acreedor que incurra en una *plus petitio loco*, le concede la *actio de eo quod certo loco* (D.13.4). Se trata de una *actio arbitraria*, por la cual el juez podía apreciar el mayor o menor interés o perjuicio que la condena podía traer a las partes, el tener que cumplir la obligación en un lugar distinto (Ulp., D.13.4.2 pr., D.46.8).

§ 475. ¿Cuándo se debe pagar? Generalmente, el tiempo para exigir la obligación está determinado en el negocio. Si no es así, en principio puede exigirse inmediatamente, atendiendo la naturaleza de la obligación y las circunstancias del caso.

§ 476. Prueba del pago. La prueba del pago corresponde al deudor y en la época clásica puede hacerse por cualquier medio. En la época posclásica, siguiendo las costumbres bizantinas, se utilizaban recibos escritos (*apochae*). Justiniano dispuso que si la deuda figuraba por escrito, el pago sólo puede acreditarse con otro documento escrito o mediante cinco testigos (C.4.22.18, año 528: Nov.90.2).

§ 477. Casos especiales de pago. Hay ciertas formas de *solutio* que resultan formales:

A) *Solutio per aes et libram*. Entre los modos de contraer una obligación en el derecho antiguo estaba el *nexum*, cuyas formalidades se corresponden al de los actos *per aes et libram*. Como la regla general es que "todo lo que se contrae por un *ius* determinado, se extingue por un *ius* contrario" (Gayo, D.40.17.100), para considerar extinguida la responsabilidad obligacional del *nexum* era necesario que se celebrara otro acto *per aes et libram*, denominado precisamente *solutio per aes et libram*.

1. Es decir, no bastaba con pagar la deuda (*debitum*), sino que además había que romper el vínculo de la "responsabilidad" mediante esta forma particular solemne de *solutio*. Sólo así quedaba liberado el deudor.

2. El acto (análogo a la *manipatio*) se debía celebrar en presencia de no menos de cinco testigos, además del *libripens*, estando presentes el acreedor y el deudor. Hablaba este último: "Puesto que estoy obligado a darte tantos sestercios, yo me libero de tí por medio de este cobre y de esta balanza de bronce. Pesa tú esta balanza por primera y última vez de acuerdo con la ley pública" (Gayo, 3.174).

En la época clásica, cuando el *nexum* ha desaparecido, y la *manipatio*, de forma efectiva y real se ha convertido en una "venta imaginaria", que se realizaba por una sola moneda (*nummo uno*), así también la *solutio per aes et libram*, pasa a ser una forma de extinguir la obligación usada para condonar o remitir una deuda (*imaginaria solutio*). Gayo nos habla de su uso respecto del pago de lo debido por una condena judicial, así como también para liberar al heredero de la obligación nacida de un legado *per damnationem* (Gayo, 3.173-175). Como todos los actos *per aes et libram* esta forma desapareció en la época posclásica. Ni siquiera es mencionada por Justiniano.

B) *Acceptilatio*. Este modo sirve para extinguir las obligaciones nacidas verbalmente (*verbis*); así, por una *sponsio*, una *stipulatio*, un *iusiurandum liberti* o una *dictio dotis* (Gayo, 3.169; Inst., 3.29.1). En cuanto a su forma, corresponde con su pregunta y su respuesta al reverso de la *stipulatio*. En este caso, quien pregunta es el deudor: "¿Tienes tú por recibido cuanto te he prometido?", y el acreedor contestaba: "Lo tengo" (Gayo, *ibid.*; Inst., *ibid.*).

(i) En un principio, la *acceptilatio* (de *acceptum ferre* = "tener por recibido") era la forma normal de extinguir, por un pago efectivo, la responsabilidad habida por una *sponsio* o una *stipulatio*, resultando lógico que "una obligación nacida por palabras pueda ser disuelta por medio de otras palabras" (Gayo, 3.170).

(ii) Al igual que lo que ocurrió con la *solutio per aes et libram*, se convirtió en una forma de "pago imaginario" (*imaginaria solutio*; Gayo, 3.169), pudiendo servir para extinguir obligaciones "aunque no se hubiera pagado la deuda" (Ulp., D.46.4.19.1). De este modo era una forma *ipso iure* de remitir una obligación. Funcionaba como un recibo formal oral.

1. En principio, sólo sirve para extinguir obligaciones nacidas *verbis*. Pero se podía recurrir al procedimiento de extinguir cualquier obligación "novándola" por medio de una *stipulatio*. Este procedimiento es el generalmente denominado *stipulatio Aquiliana**, por medio de la *stipulatio* se transforma la anterior obligación (que podía ser *re* o *consensu*) en *verbis* y de este modo era susceptible de *acceptilatio* (Gayo, 3.170; Inst., 3.29.1-2; Florent., D.46.4.18.1).

2. En la época clásica una *acceptilatio* respecto de una obligación que no fuera *verbis* era absolutamente ineficaz. Los bizantinos interpretarán que en un acto así, hay en realidad una voluntad de condonar la deuda, de tal modo que si bien "por su naturaleza" no vale la *acceptilatio*, el acto es convertible en un *pactum de non petendo* y valdrá como tal (Paulo, D.2.14.27.9 itp.; Ulp., D.46.4.8; Juliano, D.18.5.5 pr.).

3. Por sus características de ser un acto formal del *ius civile*, la *acceptilatio* no admite ni condición (Pomp., D.46.4.4) ni plazo (Ulp., D.46.5).

Un pupilo podía aceptar en su favor una *acceptilatio* sin la *auctoritas* del tutor, porque lo beneficiaba. En cambio, no pueden liberar por la *acceptilatio* a un deudor sin dicha *auctoritas* (Ulp., D.46.4.2; C.8.44.1). Lo mismo ocurría con la mujer sujeta a tutela por razón de su sexo (Gayo, 3.171).

4. Se discutió sobre la validez de una *acceptilatio* parcial. En tiempos de Gayo (3.172) no había una doctrina segura. Pero más tarde se aceptó su posibilidad. Así: "¿Das por recibido en su mitad lo que te prometí?" (Paulo, D.45.9.9). E incluso respecto de un esclavo que ha sido prometido a dos herederos que tendrían el condominio, se le puede pedir la *acceptilatio pro parte* a uno de ellos (Pomp., D.46.10).

Pero no si se trata de una cosa indivisible; así, una servidumbre predial (Ulp., D.46.4.13.1), o habiéndose estipulado una casa, se pretendiera hacer la *acceptilatio pro parte* de los elementos componentes: así, las paredes, las puertas, etc. (Ulp., D.46.13.2).

La posibilidad de la *acceptilatio pro parte* está admitida como regla general por Justiniano (Inst., 3.29.1: "se puede hacer la *acceptilatio* por parte de lo debido").

§ 478. II. *Novación*. Ocurre la novación (*novatio*) cuando se transforma una obligación ya existente en otra nueva, de tal modo que queda extinguida la primera, quedando ahora subsistente la segunda.

1. Según la define Ulpiano (D.46.2.1 pr.): "La *novatio* es una trasfusión y una traslación (*transfusio atque traslatio*) de una deuda anterior a otra obligación; sea civil o natural, esto es, cuando por virtud de una causa precedente se constituye otra nueva, de modo que se extinga la primera; porque la novación recibió su nombre de "nuevo" (*novum*) y de "nueva" obligación".

2. La forma de realizarla es extinguir la obligación primera transfundiéndola por medio de una *stipulatio* en una obligación nueva. La *stipulatio* es la forma normal, y si bien se agrega en D.46.2.31.1 (Venuleyo, itp.) la *dictio dotis*, de todos modos se trataría de una promesa verbal, asimilable a la *stipulatio*.

Aunque discutida, cabe también aceptar que los *nomina transcripticia* (ya sea a *re in personam* o a *persona in personam*) tenían efectos novatorios.

§ 479. Pongamos un ejemplo: A ha vendido a B un esclavo por 10.000 sesteracios. El comprador B está obligado a pagar el precio convenido. Con posterioridad, ambos celebran una *stipulatio*. En ella A, el vendedor, pregunta: "¿Prométeme los 10.000 sesteracios que me debes por la venta del esclavo Stichus?", y B contesta:

"Te lo prometo". Como consecuencia de esta *stipulatio*, si bien el *debitum* (los 10.000 sesteracios) continúa, ahora la obligación nacida de la compraventa se ha extinguido, y ha quedado novada en la obligación nacida de la *stipulatio*. El efecto principal reside en que la primera era una obligación *bonae fidei*, que era exigible por la *actio ex vendito* (en un *bonae fidei iudicium*), mientras que ahora se ha novado en una obligación que tiene su causa en la *stipulatio*, reclamable por la *condictio (actio) certae creditae pecuniae*, que no es de "buena fe", sino de "derecho estricto".

En el ejemplo dado, lo que se ha novado es la "causa" de la obligación (por ello llamada por los modernos "novación objetiva"). Pero también se podían cambiar otros elementos, como, p.ej., las partes. Así, veamos este otro caso: B le debe 10.000 sesteracios a A por cualquier causa. Con posterioridad, se celebra una *stipulatio* entre A y C, por medio de la cual C asume la deuda de B y promete pagar a A dicha misma deuda. Aquí también hay una *novatio* (llamada en derecho moderno "novación subjetiva"). En virtud de ella la obligación primera entre B y A queda extinguida, subsistiendo ahora sólo la segunda, por la cual C es el deudor de A, que reemplaza a la primera.

1. Viendo estos ejemplos podemos comprender mejor la terminología empleada por Ulpiano. De la obligación primera continúa siempre el *debitum*, respecto del cual se ha operado una *transfusio*, así como una *translatio* a la segunda, al mismo tiempo que se ha operado una alteración de algún otro elemento distinto que el *debitum* en la segunda obligación.

2. Es decir, en la *novatio* hay algo que permanece en la segunda (la deuda), pero el vínculo obligacional está alterado. Esto podía ocurrir: a) cambiando la "causa" (ej. primero), b) agregando o eliminando algún elemento accidental (así, condición, plazo, lugar de pago); c) cambiando el acreedor (*delegatio*); y d) cambiando el deudor (*expromissio*; ej. segundo).

§ 480. *Requisitos para que haya novación*.

A) Ante todo debe haber una obligación anterior. Ello resulta elemental, puesto que no puede extinguirse lo que no existe. No importa la naturaleza de esta obligación primera: puede ser civil, pretoriana o meramente natural, ya sea que haya nacido *verbis*, o *re*, o *litteris* o *consensu* (Ulp., D.46.2.1.1; D.46.2).

B) Que exista una *stipulatio* realizada en forma regular, tendiente a la creación de una nueva obligación (civil o natural; Ulp., D.46.2.1.1). Lo que interesa es que la *stipulatio* novatoria sea regular, aunque resulte ineficaz por la no aparición de una nueva obligación. Lo

mismo se opera la extinción de la obligación precedente (Gayo, 3.176; Inst., 3.29.3).

1. Este efecto pleno que tiene la *stipulatio* aunque no haga nacer una obligación válida, parece deberse a una doctrina de Servio Sulpicio, según la cual se consideraba, en este caso, que el acreedor, al realizar la *stipulatio* es como si hubiera renunciado o abandonado la obligación anterior.

2. Sin embargo, para mitigar en algo la dureza de este principio, los juristas clásicos establecieron una distinción.

a) Si la *stipulatio* era manifestamente irregular (*stipulatio non existens*), entonces no surtía efectos novatorios. Así, si se trataba de la *stipulatio* prometida por un esclavo. Recordemos que el esclavo, ordenado por su *dominus*, podía actuar como *stipulator*, pero no como "promitente" (*promissor*), es decir, podía obligar a otro, pero no obligarse él. En consecuencia, en este caso se interpretaba que la *stipulatio* era irregular (*stipulatio non existens*) y no novaba la obligación anterior; era "como si no se hubiese estipulado de nadie" (Gayo, 3.176; Inst., 3.29.3).

Lo mismo ocurría si se había estipulado empleando la forma *Spondes*? (propia de la *sponsio*), con un extranjero a quien no se le había concedido la permisión de esta fórmula (Gayo, 3.179, *in fine*). No se producía la novación.

b) En cambio, si el promitente de la *stipulatio* era un pupilo que actuaba sin la *auctoritas* de su tutor, se interpretaba que había extinguido la obligación anterior, aunque la nueva fuera nula. Acá se consideraba que la *stipulatio* existía, puesta que el pupilo puede preguntar y responder en la *stipulatio*, aunque los efectos sobre la nueva obligación no se produzcan (Gayo, 3.176; Inst., 3.29.3).

C) En la *stipulatio* novatoria se debe conservar el mismo *debitum* de la obligación precedente. Por ello es que Ulpiano habla de "trasfusión y traslación de la deuda (*debitum*) anterior". Este requisito fue observado rigurosamente en la época clásica. Así, si se me debe un fundo determinado, no se puede novar la obligación estipulando que se me deba otra cosa (p.ej., otro fundo). De ocurrir así; acá habrían dos obligaciones, por cuanto la anterior no ha quedado extinguida en cuanto a la prestación debida, y la nueva es perfectamente válida (Jul., D.45.1.56.7; Ulp., D.46.2.9.2).

d) La *stipulatio* novatoria, si bien debe mantener la misma deuda que la obligación precedente (*idem debitum*), debe contener algún elemento nuevo (*aliquid novi*). Este "algo nuevo" que debía estar presente en la *stipulatio* podría ser:

(i) Un cambio de la "causa de la obligación". Ello ocurre en el ejemplo dado antes de que existiendo un contrato de compraventa, el com-

prador estipula del vendedor y éste promete pagar la suma del precio, o entregar la cosa vendida. Ahora la prestación debida no estará basada en la compraventa, sino en la *stipulatio* (Pap., D.22.1.4 pr.).

Acá hay que mencionar a la conocida *stipulatio Aquiliana*, creada por el jurista Aquilio Gallo, quien fue discípulo de Q. Mucio Scévola, maestro de Servio Sulpicio, amigo y colega de Cicerón en la pretura. El procedimiento que había ideado era muy simple y muy práctico, por cuanto permitía novar toda clase de obligaciones, aun en conjunto, mediante una sola *stipulatio* (Inst., 3.29.2).

(ii) Por un cambio en algunos de los elementos secundarios o accidentales de la obligación. Esto podía ocurrir, p.ej., si se agrega o quita un "plazo" a la obligación precedente (Gayo, 3.177; Inst., 3.29.3).

Igualmente, si se agrega o se quita una "condición". Así, las partes pueden transformar una obligación pura y simple en una obligación condicional. O viceversa, una obligación condicional en una que sea pura y simple, eliminando la condición.

1. Para Servio Sulpicio, la *novatio* se producía inmediatamente que se realizara la *stipulatio* novatoria, sin aguardar el resultado de la condición.

Pero según explica Gayo (3.179), prevaleció un criterio distinto. Si la obligación era pura y simple, y se la pretende novar con una *stipulatio* que agrega una condición, el efecto no es automático, sino que hay que esperar que la condición se cumpla. Si ello ocurre, acaece la *novatio*; de lo contrario, la primera obligación continúa existente. Este criterio será el que predominará, siendo aceptado por Justiniano (Ulp., D.46.2.14 pr.; Pomp., D.46.2.24; Inst., 3.29.3).

2. El caso inverso sería el de que la primera obligación fuera condicional y se estipulara su *novatio* como obligación pura y simple. Como lo indica Ulpiano (D.46.2.14.1), aunque pareciera que la novación debe surtir efectos inmediatos, hay que esperar que se cumpla la condición de la primera obligación. De lo contrario no se cumpliría el requisito de que para novar debe existir alguna obligación. De este modo, si no se cumplía la condición de la antigua obligación, quedaba ésta extinguida, por lo que no surtía efectos la estipulación novatoria. Y si en cambio se cumplía la condición de la primera obligación ésta existe ahora en forma plena, y de ahí que otorgue efectos novatorios a la segunda.

En cambio, fue controvertida la cuestión de si había o no novación por el agregado o la supresión de un fiador. Los sabinianos opinaron por la afirmativa, negando los proculeyanos los efectos novatorios, ya que no se alteraba la obligación principal si se agregaba algo accesorio

(Gayo, 3.177-178). Justiniano aceptó el efecto novatorio (Inst., 3.29.3).

(iii) Por cambio del acreedor. Así, A es acreedor de B y le ordena a éste que realice una *stipulatio* con C, prometiendo a éste la misma deuda debida a A. De este modo, el deudor B deja de serlo respecto de A y comienza a serlo respecto de C. En este caso se habla de *delegatio*, de tal modo que A es el "delegante", B el "delegado" y C el "delegatario".

1. Los motivos que puede tener A para dejar de ser acreedor de B y pedirle que lo sea de C pueden ser muy variados: así, para pagar una deuda que A tiene con C; para conceder un mutuo al nuevo acreedor (Jul., D.46.1.18); para constituir una dote; etc.

2. Supone siempre un *iussum* (mandado, orden, autorización) por parte del delegante. El deudor no está obligado a celebrar la *stipulatio* novatoria. Sin embargo, tratándose de la misma deuda, no tendrá mayormente razones para no realizar el negocio, que implicaba una liberación de su antiguo deudor.

(iv) Por cambio del deudor. Así, B es el deudor de A, supongamos por 100. C, un tercero, celebra una *stipulatio* con el acreedor A, prometándole dar los mismos 100 que debía B. De este modo, la obligación primitiva entre A y B se extingue, naciendo una nueva por la misma deuda de C respecto de A. En este caso se habla de *expromissio*.

1. No es necesario ningún *iussum* por parte del deudor B a C. Pero, obviamente, es necesaria la conformidad del acreedor, puesto que no se le puede obligar a cambiar de deudor. Esta conformidad la expresa desde el momento en que accede a la realización de la *stipulatio*, pudiendo poner como condición previa que el nuevo deudor sea solvente. O también hacerse dar del deudor antiguo un "mandato de hacer la novación", por lo que el nuevo acreedor podía demandar del deudor antiguo, por cualquier perjuicio sufrido por la *actio mandati contraria* (Inst., 3.26.2).

e) En la época posclásica se produce el agregado de un requisito nuevo, a los ya señalados en la época clásica: el *animus novandi*, o sea, la "intención de novar", que Justiniano termina por imponerle al ordenar que debía figurar de manera expresa por las mismas partes (C.8.42(41).8, año 530; Inst., 3.29.3). Si no ocurría así, subsistía la primera obligación y se le agregaba la segunda, de tal modo que habrá dos obligaciones.

1. En realidad, el elemento intencional, de alguna manera tuvo que estar presente en el derecho clásico, por cuanto sin él no se explicaría la voluntad de realizar la *stipulatio* novatoria.

El agregado del *animus novandi*, obedece en parte a la declinación de las formas verbis que se va operando en el derecho posclásico, y también a terminar con las cuestiones que en la época clásica provocaban dudas (así, el agregado de un fiador). Por ello es que se termina suplantando el efecto exclusivo de la forma verbal y determinando que lo que debía primar era la voluntad expresamente declarada por las partes.

De esta modo, se abre, para el derecho moderno, el camino por el cual en todo negocio obligacional, con la expresión del *animus novandi*, se podían producir efectos novatorios.

Igualmente, con la exigencia del *animus novandi*, que ahora pasa a ser el pivote de la novatio, se termina influyendo sobre el requisito clásico del *idem debitum*. Así, en la constitución Justiniana citada se habla de novatio cuando "se aumente o disminuya la cantidad" de la deuda.

2. Por ello se realizarán interpolaciones, tales como la del fragmento de Juhano (D.45.1.58). El jurista clásico excluía la novatio cuando se hacía una *stipulatio* prometiendo la servidumbre de *actus*, en lugar de la anterior de *iter*, o del *usus* en lugar del *usufructus*; o de "cinco" en lugar de "diez". Pero se le interpola: "a menos que en ellas se hubiera expresado especialmente que ello se hacía *animus novandi*".

Igualmente, el fragmento de Papiniano (D.46.2.28), donde se admite la novatio de la prestación de un fundo por su valor (*aestimatio*). Las expresiones *novandi causa* y *animus novandi* que están en el Digesto están siempre interpoladas.

§ 481. *Novatio necessaria*. Los autores modernos suelen hablar de "novación necesaria" para oponerla a la convenida por las partes ("novación voluntaria"). Ven como tal el caso de la *litis contestatio*. Sabemos que su principal efecto es la "consumición de la actio". Gayo la trata inmediatamente después de hablar de la novatio (3.180), pero no dice que sea una especie de novatio.

En dicho párrafo, Gayo reproduce el *dictum* republicano: "Antes de la *litis contestatio* el deudor debe pagar; luego de la *litis contestatio*, es menester que sea condenado; y una vez condenado debe cumplir con la condena pronunciada". Aparentemente hay una cierta aproximación con la novatio, pero no es lo mismo. El acercamiento se debe a que la obligación introducida en el *iudicium* (*legitimum*) se consume con la l.c., estando las partes sujetas al trámite posterior del juicio, y a la eventual condena.

Pero hay diferencias: (i) la novación purga la mora de la deuda primera; en cambio, la l.c. no sólo no la purga, sino que hasta la puede determinar (Pap., D.22.1.3 pr.; Paulo, D.1d.24

pr.); (ii) la novación extingue las garantías accesorias; en cambio, la l.c. deja subsistentes las prendas, hipotecas, etc. (Paulo, D.46.2.29); (iii) la novación interrumpe los intereses de la deuda anterior, cosa que no ocurre en la l.c. (Paulo, D.22.1.35; D.46.2.18).

1. El texto de Paulo (D.46.2.29) que diferencia la novatio voluntaria del *iudicium acceptum* (juicio aceptado) y el de Papiniano (FV, 263) que afirma que se podía novar por *delegatio* o por *actiones* introducidas en juicio, están ambos interpolados. Es Justiniano quien habla de *novare iudicati actione* (novar por la actio iudicati para hacer cumplir la condena; C.7.54.3.2, año 531).

§ 482. III. *Compensación*. Modestino la define como "la contribución entre sí de la deuda y del crédito" (D.16.2.1). Así, supongamos que en un *bonae fidei iudicium*, A es acreedor respecto de B por 100. Pero, como consecuencia del negocio que los liga, B resulta acreedor respecto de A por 50. Ello significa que ambos son al mismo tiempo acreedores y deudores en forma recíproca. Ahora bien, si A inicia el cobro de su crédito por 100, B le opondrá el suyo por 50. El *iudex*, en la sentencia procederá a "compensar" (*pendere cum*: "contrapesar" o "contrabalancear") el crédito de A con el de B, de tal modo que la condena será solamente por 50.

La compensación tiene un neto interés práctico, ya que se evita que el deudor demandado B tenga que pagar íntegra su obligación y luego tenga que repetir lo que le debía A. Como lo dice Pomponio, "nos interesa más no pagar, que repetir lo pagado" (D.16.2.3).

1. En realidad, la compensación no es estrictamente una causa de extinción de las obligaciones. En el ejemplo dado, ambas figuran como válidas y exigibles, y es por ello que se las puede "compensar". Se trata más bien de un procedimiento ágil y práctico para lograr, en forma equitativa, el cobro de ambos créditos. Así, Gayo la trata a propósito de los *bonae fidei iudicia* (4.61) y Justiniano no habla de ella en el capítulo de la extinción de las obligaciones (3.29), sino también a propósito de las condenas en las acciones (4.6.30 y 39).

2. Los juristas romanos irán forjando la noción de la *compensatio*, a propósito de casos determinados, pero sin llegar a construir un sistema unitario. Lentamente, luego de algunas reformas, en el sistema posclásico y sobre todo con Justiniano, se establecerá como institución jurídica más generalizada. Lo que debemos destacar es que no funciona en forma autónoma, sino solamente en el ámbito procesal.

§ 483. I. *Evolución*. En el Derecho clásico, según nos refiere Gayo, solamente en determi-

nados casos se podía operar la *compensatio*. Estos eran los siguientes:

a) En los *bonae fidei iudicia* *, en los cuales la fórmula permitía que el *iudex* tuviera la libre potestad de estimar el monto de la condena conforme a lo que estimaba *ex bono et aequo*, le estaba permitido —aunque no obligatoriamente, ya que era él quien debía apreciar la oportunidad, conveniencia, justicia y equidad— hacer aplicación de la compensación (Gayo, 3.63).

1. Así, si en una compraventa, al pedir el vendedor el precio, el demandado alegaba el desmedro sufrido en la guarda de la cosa, que tardó en ser entregada, el *iudex*, si lo consideraba conveniente (*conveniens videtur*), podía tener esa circunstancia en cuenta y disminuir el pago del precio en la condena.

2. Técnicamente no era una *exceptio*. Por ello, Gayo nos dice que no figuraba expresamente como tal en las palabras de la fórmula. Se la consideraba integrada en la naturaleza de los *bonae fidei iudicia*, pasando directamente al *officium* del *iudex*. Incluso el propio demandado podía preferir conservar el crédito y que no se efectuara la compensación (Ulp., D.27.4.14).

3. Si el *iudex* no había hecho la compensación, la parte gozaba de la acción pertinente a su crédito, y esto es así, por cuanto la *compensatio*, aunque se tratara de *bonae fidei iudicia*, no es sino una consecuencia del procedimiento y no un modo de extinción de las obligaciones (Ulp., D.3.5.8.2; D.27.4.1.4).

b) Si un banquero (*argentarius*) demandaba a su cliente, estaba obligado a incluir la *compensatio*, descontando la suma que él debiera al demandado. Si no lo hacía así, aun cuando reclamara "un solo sestercio de más", incurría en *plus petitio*, por lo que perdía el juicio (Gayo, 3.64 y 68).

1. Las relaciones entre los *argentarii* y sus clientes eran consideradas en forma especial. Es como si existiera entre ellos una cuenta corriente. Debido a ello es que debía actuar haciendo la previa *compensatio*.

Su efecto figuraba en la *intentio*. Así, si Ticio le debe 20.000 al *argentarius*, pero éste debe 10.000 a Ticio, la *intentio* estaba redactada así: "Si aparece que Ticio deba darle 10.000 más de lo que él debe al mismo Ticio" (Gayo, 4.64).

2. La compensación debía hacerla el *argentarius* respecto de cosas del mismo género y naturaleza, generalmente dinero (Gayo, 3.66) y sólo respecto de créditos exigibles, es decir, no estar sometidos a plazo (Gayo, 3.67).

3. Parece igualmente que el *argentarius* perseguido por su cliente, tenía una *exceptio* para obtener una reducción compensatoria (Ulp., D.22.3.19.3; EP, § 272).

c) El *bonorum emptor*, es decir, el comprador de los bienes en una *venditio bonorum*, debía efectuar el descuento (*agere cum deductione*) respecto de lo que se debiera al demandado, de tal modo que la condena fuera solamente por el resto (Gayo, 4.65).

1. Este *agere cum deductione* del *bonorum emptor* tenía diferencias con el *agere cum compensatione* del *argentarius*:

(i) En la *deductio* entran incluso obligaciones de distinto género (así, por un lado dinero y por el otro vino o aceite; se consideraba el valor en dinero de estas cosas; Gayo, 4.66). Igualmente se consideran las obligaciones no exigibles aún por estar sometidas a un plazo no vencido (Gayo, 4.67).

(ii) Además, si no se hace la *deductio* o se la hace por menos, el *bonorum emptor* no pierde el juicio, ya que figura, no en la *intentio*, sino en la *condemnatio incerta* de la fórmula, por lo que no incurre en *pluris petitio* (Gayo, 4.68).

§ 484. II. *Reforma de Marco Aurelio*. Una reforma importante se produce por un rescripto de Marco Aurelio. Según él, en los *iudicia stricti iuris* si el actor demandaba a alguien quien a su vez tenía a su vez un crédito contra él, el demandado podía interponer una *exceptio doli*, por la que se introducía la *compensatio* (Inst., 4.6.30).

1. El único texto por el que conocemos la existencia de este rescripto consiste en las escuetas palabras de las Institutas de Justiniano: "En los *iudicia stricti iuris*, en virtud de un rescripto del divino Marco (Aurelio), opuesta la *exceptio doli mali*, se introdujo la *compensatio*".

Como las *actiones stricti iuris* nacen de negocios que generan una obligación unilateral, resulta acá obvio que el crédito del demandado en el cual apoyaba su excepción, debía provenir de una causa distinta (*ex dispari causa*).

2. Dadas las características del proceso formulario, este texto plantea varios problemas. Por de pronto, si A tiene un crédito contra B y lo demanda, pese a saber que B tiene contra él otro, que es también exigible, ya de naturaleza civil o pretoriana, estando en la etapa *in iure*, es decir, antes de la *litis contestatio*, el actor se aparta de dicha circunstancia, por lo que puede libremente modificar el monto de lo demandado, deduciendo la suma del crédito alegado por el demandado.

Incluso el pretor, atendiendo a las circunstancias de la causa (así, p.ej., si el crédito del demandado podía ser probado inmediatamente), podía inducir al actor a que limite su pretensión al saldo compensado. De este modo, la *exceptio doli mali* tendría un efecto preventivo para el actor.

3. Pero si el actor se negaba a ello, por considerar

que el crédito de B no resultaba probado, entonces la *exceptio doli mali* era introducida en la fórmula.

Lo que no se ve claro es cómo se operaría entonces la *compensatio*, puesto que según las reglas del proceso formulario, en caso de probarse el crédito aducido por el demandado, lo normal es que probada en consecuencia la *exceptio doli*, el juez, por tratarse de un *iudicium stricti iuris*, no podía, basado en la equidad, alterar el monto de la condena. Debía, conforme a lo pedido en la *intentio* y lo ordeñado en la *condemnatio*, condenar o absolver. Y esto debía ocurrir ya fuera que el crédito del actor fuera mayor o menor que el opuesto por el demandado.

Esto puede parecer injusto para el caso, p.ej., que el actor demandara por 100 y el demandado le opusiera un crédito de 10, ya que según lo dicho, en caso de probarse este último, directamente se lo absolvía. Claro que se puede pensar que en un caso semejante el actor pensaría en la etapa *in iure* la posibilidad de no correr el riesgo de la fórmula con la *exceptio* y procediera a compensar el crédito alegado por el demandado.

Por otra parte, si bien se entiende que "comete dolo quien reclama algo que luego debe devolver" (Paulo, D.50.17.173.5), cabe preguntarse si había actuado con dolo el actor frente a un crédito muy dudoso, en cuyo caso ¿habría que rechazar la *exceptio doli*?

4. Se podría pensar, como lo hace parte de la doctrina, que el rescripto de Marco Aurelio podría estar referido no al procedimiento formulario sino a la *extra ordinem cognitio*. Pero ello no queda totalmente probado, atento al estado incompleto de las fuentes respecto de este rescripto.

Puede ser también que la introducción de la compensación por la *exceptio doli mali*, fuera una idea bizantina, precisamente para una época en que regía la *cognitio extra ordinem*, y a ello obedecería el texto citado de Justiniano, de tal modo que el juez podía moderar la condena compensando los créditos (Afric., D.16.1.17.2; Hermog., D.44.4.16 itps.).

5. También se podía plantear el problema de la compensación, bajo la forma de una *mutua petitio*, es decir, de demandas recíprocas (demanda y contrademanda, o reconvencción). Ello queda atestiguado por Marcelo (D.17.1.38 pr.; C.4.31.4, año 229). Y también por Papiniano (D.16.2.16.1), Macer (D.49.8.1.4, citando constituciones imperiales). Así, por una de Alejandro Severo, en estos casos había que actuar ante el mismo juez, no dándose por terminados los asuntos, sino en forma conjunta. Ulpiano admite este procedimiento ante los gobernadores (D.50.13.1.15).

§ 485. III. *Reformas de Justiniano*. Por una constitución del año 530 (C.4.31.14) Justiniano produce una unificación del sistema. Según las nuevas reglas:

c) La *compensatio* se aplica a toda clase de acciones, incluso sean acciones *in personam* o acciones *in rem* (C.cit.pr.).

1. La referencia a acciones *in personam* resulta en principio sorprendente. Se debe entender que la compensación se operaba respecto de las condenaciones pecuniarias accesorias, así por frutos, pérdida total o parcial de la cosa, etc.

b) Opera *ipso iure* (C.cit. pr.). Esto ha dado lugar a muchas discusiones, sobre todo entre los glosadores. Algunos han hablado de compensación *ope legis* (por obra de la ley), otros de que debía ser opuesta como defensa por el demandado. Pese a la oscuridad de la expresión, hay que entenderla como que no es necesaria para las acciones *stricti iuris* la intercalación de una *exceptio doli*. Pero siempre era el juez quien debía declararla, luego de analizar los créditos, estableciendo la condena por el saldo resultante. No pierde su carácter procesal.

1. Sin embargo, se tiene en cuenta el momento en que empezó la concurrencia de los créditos. Así, cesan los intereses en la medida en que concurren (C.4.31.5) y se extinguen las garantías (Javol., D.16.2.14).

c) No cualquier crédito podía ser compensado con otro: se debía tratar de obligaciones exigibles, de tal modo que si una fuera a plazo, no se lo podía compensar antes del vencimiento del mismo (Ulp., D.16.2.7 pr.).

Además, debían resultar de sumas "líquidas", es decir, totalmente identificables en cuanto a su monto, de tal modo que en cuanto a su existencia y a su monto, resulte evidente (*iure aperto*: Inst., 4.6.30), o al menos que el juez puede verificarlo fácilmente sin caer en expediente o subterfugios inútiles (C.cit.1).

1. Una cuestión que se presenta es saber si las cosas que se podían compensar debían ser, como en el caso del *argentarius* de la misma naturaleza y fungibles entre sí (*ex pari specie*).

Según un texto de Paulo (2.5.3): "La *compensatio* es admitida por deudas de la misma especie (*ex pari specie*) y causa distinta (*ex dispari causa*); así, si te debo dinero y tú me debes dinero, o trigo, u otras cosas así, es lícito compensar o deducir lo que debes, aunque el contrato sea por otra causa (*ex diverso contractu*)".

Pero se piensa que aquí Paulo se refiere a la compensación conñeñida por el rescripto de Marco Aurelio, la cual de hecho se debía operar respecto de cosas de la misma naturaleza y compensables entre sí. Por otro lado, el procedimiento formulario se presta a que este requisito, pese a algunos textos dudosos (Paulo, D.13.7.18; Marciano, D.20.1.13.2) no fuera exigido por cuanto la apreciación de las cosas más diversas es llevada por el juez a su estimación pecuniaria. Con la generalización del procedimiento *extra or-*

dinem el juez mismo es el que realiza la compensación, resolviendo la condenación en evaluaciones pecuniarias. Justiniano no expresa la necesidad de este requisito, aunque observando el principio de la liquidez, es decir que la *aestimatio* de lo que se quiere oponer en compensación resulta claro, y no intrincado.

El requisito de la misma naturaleza y fungibilidad compensable de los créditos (*ex pari specie*) es del derecho moderno, como consecuencia de entender *ipso iure* como "compensación legal".

d) Había casos en los cuales no se permitía la *compensatio*. Así, (i) respecto del depositario, ya que resultaría odiosa, dada la *bona fides* presente en este contrato, puesto que bajo este pretexto el depositario podría defraudar al depositante negándole la restitución de las cosas a él confiadas (Inst., 4.6.30, *in fine*; C.4.31.14.1, *in fine*; C.4.34.11, año 529); (ii) a los poseedores de cosas obtenidas por medio de la violencia (C.4.31.14.2).

III. Otras formas de extinción.

§ 486. *Remisión de la deuda*. La remisión de una deuda consiste en el perdón de la deuda por parte del acreedor. Habíamos visto que en la época clásica existían ciertos actos formales que implicaban la remisión. Así, la *solutio per aes et libram** y la *acceptilatio**. Pero, además de ellos, había un modo informal que era el *pactum de non petendo*, por el cual el acreedor convenía con el deudor ya el perdón total, ya el parcial, o también al establecer en favor del deudor un aplazamiento en el pago (Gayo, 4.116a; 122).

a) Si se trataba de una obligación nacida del delito de *furtum* y de *iniuriae*, ya desde antiguo se admite que el *pactum de non petendo* extingue *ipso iure* la pena que correspondía (Paulo, D.2.14.17.1).

b) En cambio, en las obligaciones civiles o pretorianas, incluidas las nacidas de los otros delitos, el *pactum de non petendo* no las extingue *ipso iure*. Por tratarse de un *pactum*, éste no genera una acción, pero sí, en derecho pretorio, una *exceptio pacti conventi* (Gayo, 4.119; 126).

1. El deudor beneficiado puede optar entre esta excepción y la *exceptio doli mali* (Gayo, 3.179; Ulp., D.44.4.2.4). En los *bonae fidei iudicia** no era necesaria la intercalación de ninguna excepción, puesto que el juez tenía potestad para tomar en consideración dicho pacto en el momento de sentenciar.

2. Si el pacto se refiere al otorgamiento de un plazo para que el deudor pague, él tendía no a perdonar la deuda, sino a otorgar un aplazamiento. Se habla de "excepción dilatoria" (Gayo, 4.122).

3. En el caso de que el *pactum de non petendo* se hubiera obtenido por una maniobra dolosa, el acreedor gozaba de una *replicatio agri* (C.8.35(36).3). Si luego de un pacto primero, éste se había variado por otro pacto posterior, el acreedor tendrá la *replicatio pacti* contra la pretensión del demandado de hacer valer el anterior (Gayo, 4.126; Paulo, D.2.14.27.2).

Justiniano, basado en algunos precedentes clásicos, distinguirá entre el *pactum de non petendo in personam* y el *p. de non p. in rem* (Ulp., D.2.14.7.3). Siendo *in personam*, se está perdonando la persona de un deudor, de tal modo que sólo aprovecha a éste, pero no a su heredero (Labéon-Paulo, D.2.14.25.1), ni tampoco a su fiador (Ulp., D.id.22). En cambio, siendo *in rem*, lo que se perdona es la deuda, de tal modo el pacto aprovecha, en principio, a todos los terceros cuya liberación interesa al acreedor.

4. Había que tomar en cuenta las distintas circunstancias. Si el pacto es *in rem*, respecto de un deudor solidario, sólo beneficia también a los otros en caso de que exista entre ellos una sociedad, pero no en caso contrario (Paulo, D.2.14.21.5; 25 pr.). Si se perdona *in rem* al deudor principal, también beneficia a los fiadores (Paulo, D.id.21.5). En cambio, si se perdona a un fiador, el *pactum in rem* no beneficia a los otros fiadores ni al deudor principal (Paulo, D.id.23).

5. Que se trate de un pacto *in personam* o *in rem*, depende de la intención expresada por las partes (Ulp., D.2.14.7.8).

§ 487. *Transacción*. Cuando se trata de obligaciones sometidas a juicio, que resultan dudosas, las partes pueden convenir poner fin al litigio, haciendo concesiones recíprocas. A ello se denomina *transactio* (D.2.15; C.2.4; Ulp., D.id.1).

1. En Derecho clásico la *transactio* es un pacto que genera la *exceptio* correspondiente en favor del demandado si el actor que había transigido pretende accionar contra él ignorando la "transacción". Pero también era costumbre el agregado de *stipulationes*, por lo que en este caso se generaba la *condictio* nacida de la promesa verbal (Paulo, 1.13).

2. Justiniano, quizá basado en precedentes posclásicos, termina por apartar la *transactio* de los pactos, admitiéndola como uno de los "contratos inno-minados", otorgando la *actio praescriptis verbis* para cumplir lo transado, aparte de la *actio* nacida de la *stipulatio* en su caso (Alej. Sev., C.2.4 6, año 230 itp.; Diocl., C.id.33(34).1 itp.).

§ 488. *Consentimiento contrario*. En las obligaciones nacidas de contratos consensuales (compraventa, locación, mandato y sociedad), así

como éstas han surgido por el mero consentimiento, cabe la extinción por una voluntad contraria (*contrarius consensus*). Con esto se cumple la regla de que "todo lo que se contrae por un *ius* determinado, se extingue por un *ius* contrario" (Gayo, D.50.17.100).

Ello es posible mientras las partes no hayan comenzado la ejecución de una de las obligaciones (*re integra*). Así, si Ticio y Seyo han convenido en la compraventa del fundo Tusculano por 100 aureos, y enseguida, antes de realizarse ningún hecho de ejecución, es decir, antes de que haya habido pago de precio o entrega del fundo, convienen en separarse de esta compraventa, quedan mutuamente libres (Inst., 3.29.4).

En cambio, si el contrato consensual había tenido "principio de ejecución" (*re secuta*), no era posible, en principio, que el *contrarius consensus* tuviera este efecto extintivo. Sin embargo, se admite que p.ej., en una compraventa, si se hubiere entregado ya la cosa, ya el precio y de común acuerdo hubiesen sido reintegrados, entonces, dada la *bona fides* que preside estos contratos era posible disolverlo por *contrarius consensus* (Aristón-Neracio, D.2.14.58). Pero si las partes convinieron apartarse de las condiciones ya fijadas en el negocio (así, p.ej., fijando un nuevo precio), se interpretaba que en realidad existía un negocio nuevo (Neracio, D.2.14.58, *in fine*).

1. Para el caso del mandato y de la sociedad, teniendo en cuenta la circunstancia de que en ellos interesa fundamentalmente la persona (*intuitu personae*), el apartamiento del negocio puede producirse por voluntad unilateral, con las consecuencias que hemos visto al tratar de ellos.

§ 489. *Confusión*. Toda obligación supone la existencia del acreedor y del deudor como personas distintas. Pero, si por alguna circunstancia, el crédito del acreedor y la deuda del deudor se confunden en una misma persona, entonces la obligación queda extinguida por "confusión" (*confusio*), puesto que nadie podría reclamarse a sí mismo. Así, A es acreedor de B. Supongamos que A viene a ser heredero de su deudor B, o a la inversa, B heredero de su acreedor A. La deuda quedaba extinguida, dado lo ilógico de ser acreedor o deudor de sí mismo (Pap., D.46.3.95.2).

1. Si bien se suele decir que la *confusio* extingue la obligación *ipso iure*, asimilándose al pago (*solutio*; Terencio Clemente, D.34.3.21.1), en realidad presenta diferencia. La obligación permanece más paralizada que extinguida. Así, si la *confusio* se producía en la cabeza de un heredero por testamento, y éste era

declarado inoficioso, la obligación recobra su fuerza (Paulo, D.5.2.21.2).

2. Si se trataba de la obligación nacida de una *stipulatio*, si se producía la *confusio* entre el estipulante y el promitente, o viceversa, la obligación se extinguía *civiliter* (Pomp., D.46.3.107; Modest., D.id.75).

Pero si había acreedores o deudores solidarios por la *stipulatio*, los efectos eran distintos respecto del pago. Así, p.ej., A es acreedor de B y de C *in solidum*. Si por causa hereditaria A confunde su cabeza con B, continúa vigente la obligación respecto de C; Paulo, D.46.1.71 pr. La *confusio* deja subsistente la otra obligación, a diferencia del pago, que la extingue.

3. Si la confusión se opera entre el acreedor y el deudor principal, al extinguirse la obligación principal las fianzas quedaban extinguidas, puesto que eran *accessorias* de aquella (Afric., D.46.3.8.5).

Pero si la *confusio* se produce entre el acreedor y el fiador, se extingue la fianza, pero no la obligación principal (Paulo, D.46.1.71 pr.; Afric., D.id.21.3). Si el fiador era el heredero tendrá acción contra el deudor principal, por ser una deuda de la herencia. Lo que se discutía era si correspondía la *actio mandati*, como ordenada por el causante (Pomp., D.17.1.11) o la *condictio* nacida de la *stipulatio* (Afric., D.16.1.21.5).

A su vez, si la *confusio* se producía entre el deudor principal y el fiador, en principio se extingue la fianza (Ulp., D.46.1.5; Scév., D.46.3.93.3). Pero ello puede ocasionar perjuicio al acreedor. En efecto, supongamos que A, el deudor principal, hubiera heredado a B, su fiador, y luego se produjo la *venditio bonorum* de los bienes hereditarios. Si la fianza hubiera subsistido, el acreedor podría haber pedido la *separatio bonorum*, derecho concedido al acreedor hereditario para separar el patrimonio de sus deudores del patrimonio del heredero. Acá, por efectos de la *confusio* no lo tendría, pero Papiniano (D.22.6.3 pr.) lo protege otorgando, al parecer, esta *separatio bonorum* aunque no fuera el acreedor hereditario, sino el acreedor del heredero.

4. Un caso particular se daba en algún supuesto de ejercicio de la *actio noxalis*. Así, un esclavo de A cometía un delito contra Ticio. Éste tenía contra A la "acción noxal". Pero si luego, por cualquier causa, Ticio se convierte en propietario de dicho esclavo, se discutía entre las escuelas si la *actio noxalis* se extinguía por *confusio* (tesis sabiniana), o se suspendía y despertaba en el supuesto de que el esclavo escapara de la potestas de Ticio (Gayo, 4.78). Justiniano se inclinó por la solución sabiniana (Inst., 4.8.6).

§ 490. *Concurso de causas* (*concursum causarum*). Ocurre esto cuando el acreedor obtiene por otra causa, la cosa que le es debida. Así, A hace una *stipulatio* con B, por la cual éste se obliga a darle el fundo Tusculano. Con

posterioridad, por otra causa (compra, herencia, legado, donación), A deviene propietario de dicho fundo. La obligación primera, en el derecho antiguo y también en el primer derecho clásico, quedaba extinguida, puesto que una vez ya adquirida la cosa, deja de ser debida y no podemos reclamar que se nos dé una cosa que ya es nuestra (Gayo, 4.4).

Más tarde, quizá a partir de Juliano, e indudablemente para la época justiniana, este principio primero queda alterado. Se establecerá una distinción entre "causa onerosa" (p.ej., una compraventa o una permuta) y "causa lucrativa", es decir, a título gratuito (p.ej., un legado o una donación). Se fijará el principio de que la obligación no se extingue si una de las dos causas es "onerosa", de tal modo que el acreedor puede demandar la *aestimatio* de la cosa. En cambio, siendo ambas causas "lucrativas" la obligación se extingue (Africano, D.30.108.4; Jul., D.44.7.17 itps.).

1. Respecto de la aplicación de la última versión ("concurso de dos causas lucrativas") en la época clásica, el tema está muy discutido. Algunos piensan que los clásicos no conocieron esta diferenciación entre "causa onerosa" y "causa lucrativa", sino que bastaba con que el acreedor p.ej., hubiera recibido la cosa por cualquier causa para que la obligación quedara extinguida.

Los casos mencionados en el Digesto están vinculados a cosas debidas por una *stipulatio* y un legado *per damnationem*. El caso era distinto para la compraventa, donde regía la *bona fides*. Así, si p.ej., tú me habías vendido una cosa, que yo obtuve por otra causa, no me puedes reclamar el precio por la *actio venditi* (Pomp., D.22.2.29 pr.), puesto que la obtuve por otra causa. Incluso, si te compré una cosa que luego me fue legada, podía reclamar el precio por la *actio empti* (Paulo, 2.17.8; Jul., D.30.84.5; Jul.-Ulp., D.19.1.13.5).

Quizá pudo haber ocurrido que este principio, vigente en la compraventa, se haya extendido a conceder una acción de recupero del precio, a quien compró una cosa que luego se legó (Ulp., D.30.34.7).

El párrafo fundamental, para dilucidar esta cuestión es el de Juliano (D.44.7.17): "Todos los deudores, que por causa lucrativa deben una cosa específica, quedan libres cuando esta cosa específica hubiese pasado por causa lucrativa a los acreedores", ya que para unos es auténtico, mientras que para otros es producto de una interpolación.

2. En época justiniana, la obligación sólo se extinguía si concurrían dos "causas lucrativas", pero no si una de ellas era "onerosa". Así se dice claramente en las Institutas (2.20.6). "Si la cosa de otro ha sido legada, y en vida del testador ha adquirido el legatario la propiedad de ella, puede a título de compra obtener el precio por la *actio ex testamento*,"

pero si ha sido por causa lucrativa, como p.ej., por donación o por cualquiera otra causa semejante, no tiene acción. Porque se halla recibido tradicionalmente que dos causas lucrativas no pueden acumularse para una misma cosa en un mismo individuo².

§ 491. Otras causas de extinción.

a) *Pérdida de la cosa debida.* Cuando se debe una cosa específica —no una genérica, puesto que el género nunca se extingue— y ésta perece en su totalidad (así, el caso de que se hubiera prometido entregar el esclavo Stichus en un plazo determinado, y éste muriera el día anterior a dicho plazo; Pomp., D.45.1.33), o si la cosa debida se hubiera hecho *sacra* o *religiosa* (Inst. 3.19.2), o el esclavo hubiere alcanzado la libertad (Paulo, D.45.1.83.5), el cumplimiento se torna imposible y, en consecuencia, de hecho se extingue la obligación, quedando el deudor liberado.

1. Para que ocurra este efecto es necesario que el acontecimiento haya sucedido, no solamente por el dolo o la culpa del deudor, sino también por cualquier hecho del deudor (*sine facto promissoris*; Inst. 3.19.2; Paulo, D.45.91 pr. y ss.). Sucede lo mismo si el acontecimiento ha sobrevenido estando el deudor en mora, ya que continúa obligado por haberse perpetuado la obligación (*perpetuatur obligatio*; Pomp., D.45.1.23 y 33; Ulp., D. id.82.1; Paulo, D. id. 91 pr.1 y 3).

2. ¿Qué pasa si, más tarde, la cosa *sacra* o *religiosa* entra en el comercio, o si el esclavo manumitido recae en la esclavitud? ¿La obligación renace? Supongamos este caso: Se deja por legado un esclavo ajeno. Antes de cumplimentarse dicho legado, el dueño de aquél lo manumite. Pero luego, por cualquier causa, recae en la esclavitud. Celso (D.32.79.3) opinaba que la obligación renacía. Este párrafo debió haber sido dejado inadvertidamente por los compiladores, puesto que luego se agrega otro de Paulo que nos dice que la opinión de Celso —anterior en más de un siglo— no fue la prevaleciente (*non admissum est quod Celsus ait*). Según él una vez manumitido dicho esclavo, la obligación se extinguía a perpetuidad, no pudiéndose entender renacida; se consideraba que dicho hombre, primero esclavo, y luego manumitido, al recaer en esclavitud, no era el anterior sino que se trataba de un nuevo hombre (Paulo, D.46.3.98.8; D.45.1.83.5. D.34.4.27.1). Para esta opinión predominante, la obligación se había extinguido.

De acuerdo con esta idea prevaleciente, lo que se trataba de averiguar era si se estaba o no ante una cosa nueva. Si la cosa podía ser considerada nueva, la obligación extinguida no renacía. Por ello, Paulo entra en una casuística tendiente a determinar si ocurría o no esta circunstancia. Así, si se trataba de la promesa de entregar una nave ajena, si el dueño

la había desclavado las tablas y maderas para luego volver a recomponerla, se trataba de la misma cosa. Pero si el dueño la hubiera deshecho con la intención de que sus tablas se aplicasen a otros usos, y luego cambió de opinión y volvió a rehacer la nave, se entiende que ésta es una nave nueva. Igualmente, con el caso de haber prometido una casa ajena. Si se removían las maderas para ser puestas otra vez, son de la misma casa. Pero si los materiales hubiesen sido demolidos hasta el suelo, aunque se vuelvan a poner los mismos materiales, se entiende que es una casa nueva (Paulo, D.46.3.98.8; D.45.1.83.5).

También si el esclavo prometido hubiera caído prisionero del enemigo, y luego fuera rescatado, por el *postliminium* volvía al dominio de su amo, y por tratarse del mismo esclavo, podía luego ser pedido (Paulo D.46.3.98.6).

b) *Muerte y capitis deminutio.* La muerte puede hacer cesar ciertas obligaciones, que son, en principio, intrasmisibles a los herederos (caso de las *actiones poenales*; v. sin embargo, *supra*, § 331.B), y mientras estuvieron vigentes las derivadas de fianzas como la *sponsio* y la *fidei-promissio* (Gayo, 3.120).

También la *capitis deminutio*, aun *minima* extinguió en principio las obligaciones (así, en el caso de la *adrogatio** y de la *conventio in manu** de una mujer *sui iuris*). Pero el pretor protegía a los acreedores (v. *infra*, §§ 506.II.a. y 536.1).

c) *Praescriptio.* Respecto de la prescripción liberatoria de las acciones por las cuales se podía exigir una obligación, nos remitimos a lo ya visto *supra*, § 93.

V. Transmisión de créditos y asunción de deudas.

§ 492. I. *Transmisión de créditos.* En principio, las obligaciones —tanto en su aspecto activo como pasivo, pueden ser transmitidas en caso de sucesión *per universitatem*. Ello ocurría en una herencia. Los créditos y las deudas del *de cuius* pasan directamente al *heres*, quien gozaba de los primeros y se tornaba responsable de las segundas. Igualmente, los créditos —no las deudas— eran adquiridos por parte del *pater adrogante*, en el caso de la *adrogatio**, como también por parte de quien celebraba una *conventio in manu** con una mujer *sui iuris*.

Pero en forma individualizada, las obligaciones no pueden ser transmitidas a otros. Se debía esto al carácter fuertemente personal de la obligación y de la responsabilidad que de ella nacía. Sin embargo, dadas las exigencias de la vida económica, hubo necesidad de crear las vías que

posibilitaran la transmisión de las obligaciones. Este camino fue lento, y aunque la eficacia de los modos encontrados resulta menguada respecto de los actuales, bastaron para satisfacer las necesidades romanas.

§ 493. a) *La delegatio.* En la época clásica, si un acreedor quería transmitir su crédito a otro, no podía hacerlo ni por *mancipatio*, ni por *in iure cessio*, ni por otro modo de adquirir (Gayo, 2.38). Pero podía recurrir a la *novatio* por cambio de acreedor (*delegatio*; ver *supra*, § 487.C.III). Así, A era acreedor respecto de B por 5.000 sestericios. Supongamos que quiere ceder su crédito a C. Entonces, acatando la invitación de A, B celebraba una *stipulatio* con C, a quien prometía pagar esos mismos 5.000 sestericios. En virtud de esta *delegatio* se extinguía la obligación entre A y B y nacía una nueva entre C como acreedor de B; Gayo, 2.38.

1. Esta forma podía valer económicamente como una cesión del crédito, pero en realidad el crédito primero se extinguía por la *novatio* y lo que tenía C era un crédito nuevo.

2. Tenía el inconveniente de que se necesitaba inevitablemente la cooperación del deudor, quien debía aceptar el *iussum* de A y celebrar la *stipulatio novatoria*.

Además, al extinguirse la obligación primera, se extinguían también con ella sus accesorios, es decir, las fianzas, prendas e hipotecas, las cuales sólo podían tener validez si son constituidas de nuevo, juntamente con la *stipulatio novatoria*.

§ 494. b) *La procuratio in rem suam.* Otro medio para operar los efectos de una cesión de créditos, consistía en utilizar la representación procesal, es decir, la figura del *cognitor**.

En este caso, el acreedor le otorga mandato a un tercero para accionar jurídicamente contra el deudor. En principio, actúa por cuenta del acreedor mandante, pero a diferencia del *cognitor* común, no lo hace en beneficio del mandante, sino en el suyo propio. Por eso en la época clásica será conocido como *cognitor in rem suam* (los compiladores bizantinos hablarán de *procurator in rem suam*); Gayo, 2.39; 4.82; 86.

1. Esta forma tenía la ventaja de que no se requería para nada la cooperación del deudor. Pero tenía el inconveniente de que antes de la *litis contestatio** la posición del cesionario no era segura. El acreedor cedente se podía arrepentir, y aceptar el pago del deudor o exigir el directamente el crédito al deudor.

En cambio, operada la *litis contestatio*, la *actio* del acreedor cedente se consumía, y él ya no puede exigir el pago del crédito. Éste era cobrado por el *cognitor* (o *procurator*) *in rem suam*, quien tenía in-

cluso la *actio indicati* para ejecutar al deudor (Gayo, 2.39; FV, 317). Jurídicamente, el crédito adquirido por el *cognitor*, por efectos de la *litis contestatio*, era nuevo, y no idéntico al que había tenido el cedente.

2. Otro inconveniente que traía esta práctica era que la muerte del cedente o del cesionario resolvía la cesión, que no pasaba a los herederos; si bien al final de la época clásica se otorgan *actiones utiles* en favor y en contra de los herederos (Gord., C.4.10.1).

§ 495. c) Una forma más importante, no vinculada al mandato procesal, lo ofrece la práctica empleada por los juristas de la Cancillería imperial en virtud de la cual el cesionario no obra como *cognitor* sino directamente a nombre propio, por medio de *actiones utiles*, que no pueden extinguirse por la muerte del cedente y que son transmisibles a los herederos.

1. En la época de Antonino Pio (siglo II d.C.) se comenzó a defender así al comprador de una herencia (Ulp., D.2.14.16 pr.), concediéndosele *actiones utiles* para reclamar en nombre propio los créditos de la herencia comprada.

2. Pero luego, en el siglo III, se amplió el cuadro: así, en favor de aquel a quien se cedía en prenda un crédito (C.8.16.4, año 225); en favor del marido a quien se había cedido un crédito en dote (Val.Galo, C.4.10.2, año 260); en favor de aquel a quien se le había pagado con un crédito (Diocl., C.4.15.5); en favor del legatario (Diocl., C.6.37.18), y, en general, respecto de quien compraba un crédito (Diocl., C.4.39.8). Justiniano lo ampliará al donatario de un crédito (C.8.53.33, año 528).

§ 496. d) En el Derecho posclásico se continuará considerando como válidas las cesiones de créditos, de tal modo que se admitía la compra o donación de un crédito, sin mayores formas. Pero será Justiniano quien acabará por ver en la cesión un negocio jurídico, sometido a reglas propias.

1. Para evitar el inconveniente que surge en las *actiones utiles*, que no se desligan, sino que se suman a las acciones directas del cedente, lo cual obligaba a celebrar *stipulationes* de resguardo entre cedente y cesionario, se establece el procedimiento de la *denuntiatio*. Consistía en la notificación al deudor de la cesión efectuada. Ésta le impedía pagar al cedente con efecto liberatorio (Alej.Sev., C.8.15(17).4 itp.; Gordiano, C.8.43(42).3 itp.).

2. Determinadas cesiones fueron prohibidas para evitar maniobras especulativas. Así, la cesión de créditos litigiosos (CTh., 4.5.1 = C.8.36.2, año 331; C.8.36.5); la cesión a personas de posición social superior (*potentiores*; Honorio y Theodosio, CTh.2.13.1 = C.2.13.2); la cesión al tutor de créditos respecto del pupilo (Nov.75.5).

3. Hay ciertos casos en los cuales la cesión aparece limitada. La preocupación se centraba en evitar la especulación por la compra de créditos difícilmente cobrables, y que se adquirían a bajo precio. Por una constitución de Anastasio (*lex Anastasiana*; C.4.35.22, completada por Justiniano, C.4.35.23;24) se estableció que el deudor se podía liberar pagando al cesionario la misma suma con que compró el crédito al cedente.

§ 497. II. *Asunción de deudas*. a) Se podía recurrir a la *novatio* (caso de la *expromissio*, v. *supra*, § 478.C.ii). A es acreedor de B. C un tercero pide asumir la responsabilidad de esa obligación. Para ello era necesaria la aceptación del acreedor A, quien por medio de una *stipulatio novatoria* con C, se hace prometer por éste el pago del *debitum* de la obligación. La obligación entre A y B se extingue, lo mismo que las fianzas, prendas e hipotecas, salvo que se las mantuvieran en la *stipulatio*, naciendo la nueva obligación por el mismo *debitum* entre A y C.

b) Otra forma era recurrir al mandato procesal por parte del deudor, quien nombraba un *cognitor in rem suam*, asumiendo por sí la obligación. Este tercero se dejaba demandar por el

acreedor y la sentencia se dictará contra él (FV, 317; 33).

1. El acreedor no estaba obligado a demandar al *cognitor in rem suam* del deudor; le podía exigir una garantía suficiente, bajo la forma de una *cautio iudicatum solvi* (Gayo, 4.102).

2. Esta forma es menos eficaz que la novación, por cuanto el deudor primero no se liberaba respecto del acreedor, y ésta no puede forzar al nuevo a ser parte en el proceso. Si el nuevo se negaba a actuar como demandado, el deudor originario era el que debía responder, pudiendo tener, según el negocio celebrado con el pretense asumidor de la deuda, una eventual acción de reembolso.

c) Para asumir deudas, podía valer también el *constitutio debiti alieni* (v. *supra*, § 379.B). Mediante él, un tercero asume, con consentimiento del acreedor, el pago de una deuda ajena, de tal modo que el deudor no queda liberado, ya que puede ser demandado por el acreedor. Éste puede a su vez actuar contra este tercero —en realidad está cumpliendo un papel de fiador— por la *actio de pecunia constituta*.

PARTE QUINTA

DERECHO DE FAMILIA

§ 498. *Concepto de familia*. La familia romana tiene sus características propias que son distintas del sentido que tiene en la actualidad. Ulpiano (D.50.16.195) diferencia entre *familia proprio iure* y *familia communi iure*.

a) La *familia proprio iure* tiene la característica de que todos sus integrantes están sometidos a una misma persona, el *paterfamilias* (o simplemente *pater*). Entre estos integrantes están los hijos o hijas, nietos o nietas sometidos a la *patria potestas*. También la mujer casada que estuviera sometida a la *manus*. Podían también estar otros terceros que están *in mancipio*. Y por último los esclavos sometidos a la *dominica potestas*.

El *pater* es el único *sui iuris* (tiene los derechos por sí mismo); los demás son todos *alieni iuris* (dependen de otro). Cuando fallece el *paterfamilias*, los *filiifamiliae* y la *uxor in manu*, se convierten en *sui iuris*. Los hijos varones pasan a ser cada uno de ellos *paterfamilias*, teniendo potestad sobre sus propios descendientes. Las mujeres, si bien serán *sui iuris* serán "cabeza y fin de su propia familia" (Ulp., D.1.5). Los esclavos seguirán sujetos al dominio de quien corresponda (Ulp., D.1.2).

b) La *familia communi iure* está formada por todos los agnados; así, los que al morir el *pater* pasan a formar una familia propia, están vinculados entre sí por la *adgnatio* (Ulp., *ibid.*). En los tiempos primeros esto iba conformando la institución de la *gens*, esto es, la "gran familia". Esta reconocía un fundador común, a partir del cual se van formando con las distintas generaciones, familias propias separadas, pero que por su descendencia de este autor común, resultan todos agnados entre sí.

1. El vocablo *familia* tiene también otras acepciones: c) para designar los "bienes patrimoniales" (Ulp., D.1.1); b) para nombrar al conjunto de esclavos pertenecientes al mismo dueño (Ulp., D.1.3).

2. La expresión *paterfamilias* significa "jefe de familia"; si bien sucede generalmente que es el que tiene hijos, la designación no hace referencia jurídica a ello. Así, el pupilo impúber que está en tutela es *pater*, lo mismo que el hijo emancipado (Ulp., D.1.2). Es sinónimo de *sui iuris*. La mujer puede ser *sui*

iuris, pero "es cabeza y fin de su familia" (Ulp., D.1.5), ya que no podía ejercer la *patria potestas*.

§ 499. *Parentesco*. Los romanos conocen dos vínculos de parentesco: la *adgnatio* y la *cognatio*. Por el primero, que es un vínculo artificial creado por el *ius civile*, están unidos como parientes agnados, en principio todos aquellos que estaban sometidos a la *potestas* del *pater* y hubieran continuado en ella si éste no hubiese fallecido. Y así, en las generaciones siguientes *in infinitum* (Ulp., D.38.16.2.1; Inst., 3, 2, 1). Igualmente todos los integrantes de la *gens*, mientras ésta se conservó, eran agnados entre sí. La *adgnatio* se transmite únicamente por vía de varón (Paulo, 4.8.13; Mod., D.38.10.4.2). En cambio, la *cognatio* es el parentesco de sangre, y, por tanto, es una vinculación natural (Ulp., D. 38.8.1.1) igual al que rige en el derecho actual.

El desenvolvimiento de la familia romana se puede resumir muy apretadamente así: a) En un principio, el único parentesco que se toma en cuenta, sobre todo en sus efectos patrimoniales hereditarios es la *adgnatio*. Así, cuando se habla de familia "civil" (conforme al *ius civile*) desde los inicios se hacía referencia al parentesco agnático. b) El pretor, atento a los cambios operados en la familia romana, es el que irá otorgando importancia al vínculo natural de la *cognatio*. c) Finalmente, en la última época, este parentesco será el único tomado en consideración.

1. La *adgnatio* se explica en la familia romana, que era una institución política monolítica, en la cual se practicaban los *sacra privata* (es decir, los ritos de la religión doméstica). Esto hace que la familia no se resume meramente en la familia del "hoy" (*familia proprio iure*) sino que se perpetúa hacia atrás, al "ayer" (como consecuencia de la reverencia debida a los antepasados, los Manes) y hacia el "futuro". Mientras esto rigió plenamente, la *gens*, como familia *communi iure*, tuvo vigencia. Al ir desapareciendo el lazo de la religión, esta forma de parentesco irá conociendo su lento ocaso. La *gens* decae hacia fines de la República y ya no se la cuenta en el Principado.

2. Normalmente, los hijos legítimos procreados por el *pater* son al mismo tiempo cognados y agnados.

A su vez, la mujer o el varón adoptados son agnados en la familia del *pater*, y a pesar de no existir propiamente vínculos de sangre, se los considerará también cognados. Esto es así porque la *agnatio* arrastra la *cognatio* (Paulo, D.1.7.23; Ulp., D.23.2.12.4). De este modo, todos los agnados son también cognados, pero no al revés. Así lo dice Paulo (4.8.14): "Entre los agnados y los cognados media esta diferencia: entre los agnados están comprendidos también los cognados; en cambio, entre los cognados no están comprendidos los agnados". Así, respecto de este último caso, si el *pater* emancipa al *filius*, deja de ser agnado, pese a continuar siendo cognado.

3. Para el cómputo del parentesco (tanto agnático como cognático) hay que tener en cuenta las líneas y los grados. Hay dos líneas: la "recta" que une a ascendientes y descendientes, en sus dos formas: la "descendiente" (hijos, nietos, bisnietos) y la "ascendente" (padres, abuelos), y la "colateral", que une a aquellos que reconocen un autor común, aunque entre ellos no están en línea recta (así, hermanos, tíos, primos, etc.). El "grado" es la posición generacional que se ocupa en la línea respectiva.

En la línea recta, a partir de cada generación, se cuenta un grado. Así, el hijo está en primer grado respecto de su padre; el nieto en segundo grado respecto de su abuelo.

En la línea colateral, hay que remontarse al tronco común. Así, mi hermano está en segundo grado, puesto que primero debo ascender al autor común, mi padre y luego descender a mi hermano; mi tío, en tercer grado (debo ascender hasta mi abuelo, dos grados y de éste descender a mi tío). Y así, los primos hermanos están en cuarto grado, etc.

PARTE PRIMERA

LAS POTESADES DEL PATERFAMILIAS

§ 500. En un comienzo, el *paterfamilias* ejerce un poder unitario y absoluto sobre todos los miembros de la familia, que habría recibido el nombre de *manus* (simbólicamente signo de poder: "estar sometido a la *manus*").

Con posterioridad se conforma también el vocablo *mancipium* (de *manum capere* = tomar la *manus*, es decir, el poder, ya sobre personas o cosas).

Luego, en la época republicana, y en el período clásico, se diferenciará este poder unitario, según las personas sobre las cuales él se ejercía. Así, se puede hablar de: a) la *patria potestas*, como el poder que se tiene sobre los *liberi* (*fili* y demás descendientes, incluidos los adoptivos); b) *manus* (ahora específicamente sobre la mujer casada que ingresa en la familia); c) *mancipium* como poder temporario sobre los *alieni iuris* de otra familia entregados *in causa mancipi*; y d) el *dominium* (sobre los esclavos y las cosas).

§ 501. 1. *Patria potestas*. Es la *potestas* que se ejerce sobre los hijos y las hijas que por razón de *agnatio* le están sometidos. A ella corresponden los *filiifamilias* que sean hijos engendrados legítimamente por el *pater*, los nietos y nietas y aquellos que hayan ingresado a la familia por adopción.

Constituía un *ius proprium Romanorum* (derecho peculiarísimo de los romanos; Gayo, 1.55). Esto no significa que en los otros pueblos los padres no tuvieran poderes sobre sus hijos, sino que la *patria potestas* presentaba características propias que la diferenciaban muy claramente:

Primero, por lo absoluto del poder del *pater* (según el derecho sucesorio, los *filiifamilias* son considerados herederos "suyos" del *pater*, como si fueran propiedad suya; Gayo, 2.157).

Segundo, porque la *patria potestas* es vitalicia, ya que no cesaba mientras viviera el *pater*, cualquiera que fuera la edad de los *fili*, salvo el caso de emancipación de éstos. Pero ni el matrimonio de ellos, ni el hecho de que ocuparan magistraturas, ponía fin a la *patria potestas*.

1. Sólo en casos excepcionales se sale de la *patria potestas* (fuera de la *emancipatio*), como p.ej. cuando el hijo es consagrado *flamen Dialis* (sacerdote de Júpiter), o la hija tomada como Vestal (Gayo, 1.190); y también cuando existían las colonias latinas, y el hijo se enrolaba en una de ellas, ya que se hacía ciudadano de otra ciudad (Gayo, 1.311).

2. Gayo (1.55) nos dice que entre los galatas (o quiso decir galos?) se mantenían principios semejantes a los de la *patria potestas* romana. Precisamente recuerda Julio César entre los galos (*de bello Gall.*, 6.9.3): los padres tienen la potestad de vida y muerte sobre las mujeres casadas y sobre los hijos.

§ 502. *Ejercicio de la patria potestas*. El *pater* tenía un poder extraordinario sobre sus *fili*. Fíjese que Cicerón pudo escribir en su época (siglo I a.C.) que el *pater* debía ser reverenciado como un dios (*pro Plancio*, 12.29). Si bien los *fili* son "libres", jurídicamente estaban en una condición equivalente a la de los esclavos (Servio, *ad Aen.*, 11.43, habla de *servi loco* = en el lugar de los esclavos). Pero el ejercicio de la *patria potestas* queda morigerado por el contexto de los *mores*, aparte de disposiciones jurídicas influidas por el estoicismo, y luego por el cristianismo.

Desde antiguo, constan varias facultades en el ejercicio de la *patria potestas*:

a) El derecho de vida y muerte (*ius vitae necisque*) figuraba en la Ley de las XII Tablas (4.2) y aún nos lo recuerda Papiniano, respecto de todos los miembros de la *domus* (Coll., 4.8). Esta *potestas* era el ejercicio del poder doméstico para imponer penas, incluso la capital, a los

miembros de la familia, sin estar obligado a ocurrir ante el magistrado. Todo esto estaba regido por los *mores*, existiendo el uso de consultar a los parientes y amigos (*iudicium domesticum*), para recabar de éstos su opinión en orden a la falta cometida y el castigo que corresponde aplicar (así, casos concretos en Valerio Máximo, 5.8.2; Salustio, *de bello Catil.*, 39). Igualmente el censor tenía la facultad de vetar, por medio de una nota censoria, las arbitrariedades del *paterfamilias*.

1. Con el correr del tiempo se fueron produciendo limitaciones. Así, si aún en la época republicana la *lex Pompeia de parricidis* (año 52 a.C.) no menciona al *pater* en la lista de personas culpables de *parricidium*, ya en la época imperial se va produciendo una reacción. Trajano obliga a emancipar al *filius* maltratado (Pap., D.37.12.5). Hadriano condenó a la deportación (*deportatio in insulam*), al *pater* que había matado, tendiéndole una trampa a su hijo culpable de adulterio con su suegra (Marciano, D.48.9.5), donde se menciona un bello principio de neta influencia estoica: "la *patria potestas* debe consistir en la *pietas*, no en la *atrocitas*".

2. Por constituciones posteriores, el *pater* puede castigar a su *filius* por faltas menores, pero si se trata de la pena capital debe acudir ante el magistrado (Ulp., D.48.3.2; Alej. Severo, C.8.47.3; año 227). La muerte del *filius* por el *pater* será considerada *parricidium* por Constantino (C.9.17.1; año 319). Valentiniano y Valente (C.9.15.1, año 365) permite la corrección normal de los hijos, aunque para el castigo de faltas graves, había que recurrir a los jueces. Finalmente, Justiniano declara abolido el "derecho de vida y muerte" (C.8.47(46).10 itp.).

b) El *pater* puede también "exponerlos", es decir, no admitirlos en la familia (*ius exponendi*), para el caso de no aceptar al recién nacido o no aceptar la atribución de paternidad.

1. Según las costumbres, una vez nacido el niño, la partera lo colocaba ante el *pater* en el suelo y éste, al levantarlo, lo estaba admitiendo como suyo (*liberum tollere, suscipere*; Plauto, *Amph.*, 1.3.3; Terencio, *And.* 3.1.6; Juv., 9.84). Si lo dejaba "expuesto" (*expositum*) era porque no lo consideraba hijo suyo, dejándolo abandonado (*liberum repudiare, negare*; Ulp., D.25.3.1.11).

A partir del siglo I d.C. se toman medidas para obligar al *pater* a reconocer al hijo expuesto (*infra*, § 504.I.4).

2. La ley de las XII Ts. (4.1; Cic., *de leg.*, 3.3.19) autorizaba la exposición de los hijos deformes. El abandono por exposición de los hijos lo encontramos común en Plauto (*Amph.*, 1.3.3). Constantino decidió que el hijo expuesto pasará a la *potestas* o al *dominium* de aquel que lo recogiera ya como hijo o como

esclavo (CTh., 5.57.1). Valentiniano castiga con una pena la exposición (C.8.52.2; año 374). Y finalmente Justiniano declaró ilícita la exposición, y al hijo expuesto libre; *sui iuris* e ingenuo respecto de quien lo recogiera (C.8.52.3; C.1.4.24).

c) También el *pater* podía enajenar al hijo. Como castigo, podía venderlo como esclavo en el extranjero (*trans Tiberim*; Cic., *pro Coec.* 34; *de orat.*, 1.40). Pero si lo hacía en Roma, entonces se entendía que lo estaba dando *in mancipio*. Así, (i) para evitar la responsabilidad por delito cometido por el hijo (abandono noxal*); (ii) para otorgarle una cierta *potestas* (el *mancipium*) por parte de un tercero sobre el *filius* mediando un precio en dinero; p.ej., para que trabajara a las órdenes de un tercero; c) otras veces, por pura forma, a los efectos de poder realizar la adopción* y la emancipación*.

El negocio utilizado era la *mancipatio** (Gayo, 1.117). El adquirente lo tenía sometido a su *mancipium*, estando el hijo *in causa mancipi*. En esa situación, era libre en cuanto al *ius publicum*, permaneciendo como un esclavo respecto al *ius privatum* (Gayo, 1.116-7; 138; 141). Para liberarlo, el adquirente debía realizar una manumisión. En ese caso, regresa en principio a la *patria potestas* anterior (Gayo, 1.138-141).

1. La práctica de vender los hijos, en el sentido común de venta, parece haber sido más bien rara entre los romanos primitivos. Quizá, lo más probable era que el *pater* que se hallaba en necesidades económicas, conviniera con otro la cesión de dicho *filius* como locación de servicios. De este modo, el *pater* cobraba una suma por ella, y luego de un cierto tiempo lo recobraba tras la manumisión que hacía el adquirente de los servicios.

2. Precisamente, la ley de las XII Tablas estableció una limitación al disponer que si lo *mancipaba* por tres veces, el *filius* quedaba libre de la *patria potestas* (4.2; Gayo, 1.132: *Si pater filium ter venundit a patre filius liber esto*). Si hablamos directamente de venta, pareciera que basta con una sola. Pero acá se nos habla de tres, y aparece como una limitación. Esto significa que la palabra *venundare* no implicaba una venta que hiciera adquirir la propiedad, puesto que luego de la manumisión del hijo *in causa mancipi* por una manumisión regresaba a la *patria potestas* anterior. En cambio, la *mancipatio* debía referirse a una locación de servicios de dicho *filius*.

Así, se nos aclara la disposición decenvital, en el sentido de que tenía el propósito de que el hijo no trabajara toda su vida como un esclavo para satisfacer las necesidades de su *pater*. Nos podríamos preguntar cómo es que teniendo el *pater* el *ius vitae necisque*, estaba limitado en las posibilidades de venta de un hijo, pero acá hay que comprender que las dos facultades tienen un fundamento distinto: en la

primera está actuando como *pater* ejerciendo sus poderes de juez familiar, mientras que en la segunda se lo considera como *dominus* del hijo, y por ello existe la limitación legal.

Nada se dice de la *filia*, lo que permite suponer que no se la empleaba para locar sus servicios, como se hacía con el *filius*. La regla de que bastaba una sola *mancipatio* para liberarla de la *patria potestas*, es una interpretación pontifical, a los efectos de poder darla en adopción, es decir, se trataba de una *mancipatio formal* (Gayo, 1.132,135;4.79).

3. Ya en la época clásica, la *mancipatio* voluntaria de los hijos tenía principalmente en vista su utilización *pro forma* a los efectos de realizar la adopción o la emancipación, o para el caso de la entrega noxal (Gayo, 1.141).

Caracalla declaró ilícita la venta de hijos (C.7.15.1). Tampoco lo puede dar en *pignus* o en *fiducia*, castigándose al acreedor que lo sabe con la *deportatio* (Díocl., C.4.43.1; Paulo, 5.1.1).

Sin embargo, esta afirmación de la *humanitas* cedió bajo la presión de la crisis económica del siglo IV. Es así que será tolerada por Constantino sólo para el caso de extrema necesidad (FV, 34; CTh., 5.10.1), para evitar la exposición de hijos recién nacidos. Pero se le acuerda al *pater*, mediante el pago de una suma de dinero o la transmisión de un esclavo, redimir al hijo vendido.

Justiniano también la admite en caso de gran indigencia del padre, concediéndoles también el poder redimirlo por una suma de rescate o la transmisión de un esclavo (C.4.43.2; intp. del CTh., 5. 10.1).

e) Los *filiifamiliae* podían ser reivindicados (Gayo, 1.134; Ulp., D.6.1.1.2) respecto de quien los retuviera. En caso de secuestro, se comete el crimen de plagio, que es de carácter público; pero también la *actio furti* (Ulp., D.47.2.14.13; pero no la tiene la madre; Paulo, D.47.2.38(39) pr.).

El *pater* tiene los interdictos *de liberis exhibendis*, para que se exhiba ante el magistrado el hijo en cuestión (Ulp., D.43.30.1 pr.; EP, § 261) y *de liberis ducendis* (Ulp., D.43.30.3 pr.; EP, § 262), prohibiendo que se ejerza fuerza para evitar que el *pater* se lleve al hijo *in potestate*.

§ 503. *Modos por los cuales puede nacer la patria potestas*. Para poder adquirir la *patria potestas* de un *filius* o de una *filia* es necesario: a) que haya sido concebido en *iustae nuptiae*; o b) que haya sido adoptado por el *pater*; o c) ya en la época posclásica, que hubieran sido "legitimados" por el padre que los hubo de un concubinato.

En la época clásica existieron algunas formas especiales de tener la *patria potestas*. Así,

a) Si se concedía la ciudadanía romana a un extranjero, lo mismo que a su mujer encinta, el hijo

nace ciudadano romano, pero desde Hadriano debe pedir al emperador que el hijo quede sometido a la *patria potestas* (Gayo, 1.92; 94).

b) Si un latino Iuniano ha tomado mujer a una ciudadana romana, o una latina, atestiguado por siete testigos, conforme a la ley *Aelia Sentia*, y ha procreado un hijo, cuando el hijo alcanzara un año de edad, podía presentarse al magistrado y pedir la ciudadanía romana y la *patria potestas* sobre dicho hijo, aduciendo una causa justificativa (Gayo, 1.29; 66).

c) Si un ciudadano romano toma por mujer a una latina o a una extranjera ignorando su nacionalidad, creyéndola ciudadana romana, podía probar la causa del error (*erroris causa probatio*), la mujer como el hijo son ciudadanos romanos y éste queda sujeto a la *patria potestas* (Gayo, 1.67).

§ 504. (I) *Concepción en iustae nuptiae*. Se denomina "hijo legítimo" el concebido en un *matrimonium iustum*. Ante todo, se debe tratar de la unión matrimonial reconocida por el *ius civile* (*iustae nuptiae*); y además, la concepción debe haber ocurrido una vez comenzadas éstas. Si hubiera sido concebido antes, el hijo es ilegítimo y entonces no está bajo la *patria potestas*.

1. La única unión que permite inducir la certidumbre en cuanto a la paternidad, son las *iustae nuptiae*. Esto se expresa por la regla: *pater is est quem nuptiae demonstrant* (Paulo, D.2.4.5: "padre es aquel a quien las nupcias muestran como tal"). En cambio, en cualquiera de las otras uniones, esta inferencia no resulta admisible por no conocerse el *pater certus*. Por ello, estos hijos ilegítimos sólo tienen madre (regla: *pater semper certa est*: la madre siempre es cierta; Paulo, D.1.1; y en consecuencia siguen la condición jurídica de la madre (Celso, D.1.5.19).

La regla funcionará como presunción judicial en la época clásica. Será *iuris tantum*, es decir, que admite la prueba en contrario por parte del *pater* (así, si el padre estuvo ausente por largo tiempo y al volver se encuentra con que su mujer ha tenido un niño de corta edad, que resulta imposible haber sido concebido por él; Ulp., D.1.6.6).

2. Los hijos extramatrimoniales son denominados *spurii* (espurios; concebidos "esporádicamente", como semillas que se siembran: Gayo, 1.64). O también *vulgo concepti* (concebidos en forma vulgar). Entrar en esta categoría, no sólo los adulterinos y los incestuosos, sino también los habidos con esclavas (Pap., D.48.5.6 pr.) o con meretrices (Ulp., D.48.5.14.2), con "alcabuetas" (*lenae*) y "actrices" (Pap., D.48.5.11.2) o sus hijas (las *obscurae loco natae*: nacidas en lugar oscuro; Ulp., 13.1). Los habidos de un concubinato, entran también en esta denominación, pero a partir de Constantino se los llama *liberi naturales* (CTh., 4. 6).

Para poder determinar si la concepción ocurrió dentro de las *iustae nuptiae*, se tomarán en

cuenta, según datos de la medicina (Hipócrates), plazos mínimo y máximo de embarazo para que el niño nazca vivo. El plazo mínimo es de 180 días (6 meses cumplidos; o 181 o 182; si computamos el día de las nupcias y el del nacimiento) y se aplica para el caso dudoso del nacimiento cercano a las nupcias. Para ser legítimo y estar *in potestate* el hijo debía nacer luego de dicho plazo computado a partir de la celebración de las *iustae nuptiae* (Paulo, D.1.5.12; Ulp., D.38.16.3.12). Por supuesto, todos los hijos posteriores, mientras continúen las *iustae nuptiae* son legítimos.

El otro caso que podría provocar dudas es el hijo que tiene la mujer luego de cesadas las *iustae nuptiae*. Acá se toma el plazo máximo de 300 días (10 meses), computados desde el divorcio o la muerte del marido (Ulp., D.38.16.3.11).

3. El establecimiento de estos plazos no aparece en un comienzo. Así, en cuanto al plazo mínimo, el texto de Ulpiano menciona un rescripto en tal sentido de Antonino Pío (138-161).

4. Según el *ius exponendi* (*supra*, § 502 b.1), el *pater* podía negarse a admitir al hijo recién nacido. En el siglo I d.C., se determinó por un s.c. *Plautianum* el reconocimiento forzado del hijo legítimo, si la mujer divorciada le hubiera hecho saber a su ex marido el embarazo dentro de los 30 días contados a partir de la separación por divorcio (D.25.3). Por un s.c. de Hadriano se extendió este procedimiento para los hijos nacidos durante el matrimonio (D.1.3.1). Para implementar estas disposiciones el pretor concedía un *praedictum* (*de agnoscendis liberis*; EP, §117).

§ 505. (II) *Adopción*. La adopción es un acto solemne por el cual se toma el lugar de hijo (o de nieto) a aquel que no lo es por la naturaleza, es decir, no ha sido engendrado por el *pater* adoptante. La palabra *adoptio* puede abarcar dos supuestos distintos: ya la *adrogatio* o ya la simple *adoptio* (Gayo, 1.98-99; Inst., 1.11.1; Mod., D.1.7.1.1).

§ 506. A) *Adrogatio*. Ocurría cuando un *pater* adopta a un *sui iuris*, es decir, otro *pater*, de tal modo que si este último tiene descendientes, no sólo él sino también sus hijos y nietos ingresaban en la familia del adrogante (Gayo, 1.107).

1. La finalidad de la *adrogatio*, y en general también de la *adoptio*, es la constitución de la *patria potestas* sobre otro, a fin de contar con un heredero, y de este modo asegurar la continuidad de la familia y no dejar extinguido el culto familiar (*sacra privata*).

2. También tuvo un sentido político, tal como ocurre con Augusto, quien adrogó a Tiberio, luego que éste hubiese hecho lo mismo con Germánico, quien de este modo pasó a ser nieto de Octavio

Augusto, todo ello con la finalidad de ir preparando la sucesión imperial (Tac., Ann., 4.37; Suet., Tiberio, 15; Inst., 1.11.11).

a) *Formas*. Como este acto resultaba muy importante, tanto para la sociedad (una familia es absorbida por otra), como para la religión (cesan los *sacra privata* en la familia del adrogado), la *adrogatio* debía ser aprobada por el *populus* interrogado por el Pontífice. En la época antigua ocurría ante los *comitia curiata* presididos por un *pontifex* (Aulo Gell., 5.19.4 ss.). Éste debía proponer una *rogatio*, previo acuerdo del adrogante y del adrogado, y el *populus* la aceptaba. Ya más adelante, la costumbre era realizarla ante 30 *lictors*, que representaban las 30 *curias*, pero lo importante será la presencia e intervención del pontífice.

1. Si bien del texto de Gayo (1.99) parece deducirse una triple *rogatio* (a ambas partes y al *populus*), lo que debía ocurrir era que el consenso de los interesados era previo ante el pontífice. Y luego éste era el que dirigía la *rogatio* al *populus*. Por ello, Aulo Gellio (5.19.9) habla de una sola *rogatio* (al *populus*). "Expresa tu deseo y ordena que Lucio Valerio sea el hijo de Lucio Ticio, de acuerdo con el *ius* y las leyes, como si hubiera nacido del padre y de la madre de esa familia en cuya *potestas* desea estar, y que el *pater* tenga sobre él el *ius vitae necisque*. Por ello, luego de haber dicho esto, a vosotros, Quirites, os interrogo".

2. El acto debía ir acompañado de la *detestatio sacrorum*, es decir, la renuncia al culto familiar del adrogado.

Estas formalidades prosiguieron durante el Principado y el período clásico. Siendo el emperador *Pontifex Maximus*, éste podía designar a un delegado suyo. Ya en la época posclásica se reemplazaron las viejas formas, realizándose por medio de la voluntad imperial manifestada en un *rescriptum*, ante el pedido de las partes (Díocl., C.3.48(47).20). Éste pasó a ser el procedimiento normal (Inst., 1.11.1).

3. Con la forma del *rescriptum*, ya no existió la dificultad de que la *adrogatio* se tuviera que realizar en Roma donde se reunían los comicios (Gayo, 1.100; Ulp., 8.4). Ahora se extiende también a las provincias, puesto que sus habitantes pueden dirigirse directamente al Emperador.

b) *Requisitos de fondo para adrogar*. En la época republicana los pontífices, fueron creando una serie de reglas que valían como criterios para otorgar o rechazar la *adrogatio* pedida.

Así, (i) las mujeres no podían ni adrogar ni ser adrogadas.

1. Las mujeres no podían adrogar porque no tienen la *patria potestas*; tampoco podían ser adrogadas. Se piensa que ello era así por cuanto los comicios tienen un carácter viril. Pero curiosamente, Gayo (1.101) dice que ésta es la "opinión mayoritaria" (*id magis placuit*). Ello permite sostener que el inconveniente anotado podía ser salvado (probablemente si consideráramos que no era necesaria la presencia de las partes, siendo lo fundamental la *rogatio* del pontifex al *populus*). Pero la cuestión pasaba por otra parte: los pontífices republicanos rehusaban que hubiese familias sostenidas por la *adrogatio* de mujeres.

(ii) Tampoco la admitieron en la época republicana respecto de los impúberes.

2. Este criterio era para evitar los aprovechamientos pecuniarios por parte del adrogante. Esto continuó durante los comienzos de la época clásica. Antonino Pío (138-161) permitió la *adrogatio* de impúberes, si es que existía una "justa causa de adopción" (*iusta causa adoptionis*), pero se debían observar reglas tendientes a proteger al impúber, así como a los parientes herederos del adrogado, respecto de los bienes de este (Gayo, 1.102; Marcelo, D.1.7.13; C.8.48.2; C.10.69.3; Paulo, D.38.5.13; ver *infra*, este § II.b).

(iii) A su vez, el criterio de la edad, en cuanto a la diferencia entre la del adrogante y la del adrogado, pudo ser tenido en cuenta, pero no constituyó un inconveniente insalvable.

3. Precisamente Cicerón (*pro domo sua*, 13.35) intervino en la *adrogatio* de Clodio, mucho más viejo que su adrogante Fonteio, que podía, por su edad, ser el padre de este último.

(iv) Igualmente, se tenían en cuenta si el adrogante tenía o no descendientes, lo mismo que la edad y las causas de la *adrogatio*, aunque no rigieron reglas fijas (Cic., *pro domo sua*, 14).

Para la época posclásica, se va transformando la naturaleza de la *adrogatio* (lo mismo que la *adoptio*). Se integrará con la idea de *humanitas*, y no viendo tanto la existencia de un heredero, se busca dar un hijo o una hija a quien no lo tienen.

4. Por ello, se permitirá adrogar a las mujeres (Gayo, D.1.7.21 *itp.*) e incluso Diocleciano permitirá a la mujer adrogar a su hijastro, "para consuelo, por los hijos que ha perdido" (C.8.47.5); el efecto acá no era sujetarlo a la *patria potestas*, lo cual no podía ser, sino crear un vínculo legítimo de parentesco.

5. Con Justiniano se implanta la regla de que la adopción (tanto *adrogatio* como *adoptio*) "imita la naturaleza" (Inst., I.1.1.4). Por ello, se instauran normas precisas en relación con la edad, ya que "es cosa

monstruosa que el hijo sea mayor que el padre" (Inst., *ibid.*). El que adopta debe tener una diferencia de 18 años respecto del adoptado como hijo o de 36 del adoptado como nieto (Modest., D.1.7.40.1; Inst., *ibid.*). También el que adopta debe tener 60 años, "porque —de ser menor— debe atender preferentemente a la procreación de hijos, salvo si una enfermedad o la mala salud fuera el motivo, o si hubiese otra justa causa para adrogar, como si quisiese adoptar a una persona pariente suya" (Ulp., D.1.7.15.2 *itp.*). Si bien los "impotentes" (*spadones*) podían adoptar, ya desde la época clásica (Gayo, 1.103), no lo podrán hacer los *castrati* (Inst., I.1.1.9).

c) Efectos de la "adrogatio". I. Desde el aspecto personal, la *adrogatio* involucra una *capitis deminutio minima* para el adrogado. De ser *sui iuris*, pasa ahora a ocupar el lugar de *filius* en la nueva familia, en la cual será agnado. Por ello, él y sus hijos (y nietos), que también caen *in potestate* del *pater* adrogante, pasan a ser *heredes sui* de éste.

1. Incluso en cuanto a su nombre, en la época republicana, toma el del adrogante, guardando el *cognomen* de su familia natural, con el sufijo —*anus*. Así, Emilio Paulo, adoptado por Publio Cornelio Scipio, toma el nombre de *P.C.Scipio Aemilianus*. Ya en el Imperio se abandona este uso. El adrogado tomaba los nombres del adrogante, añadiendo casi siempre el *nomen* que tenía y alguna de las denominaciones que llevaba antes de la *adrogatio*.

II. a) En cuanto a lo económico, los bienes del adrogado pasan a integrar el patrimonio del adrogante, no así las deudas que se extinguen por la *capitis deminutio*. Para evitar este efecto inequitativo, el pretor concederá a los acreedores del adrogado, una *actio utilis* con una fórmula ficticia, como si la entrada en la nueva familia no hubiera ocurrido. Ello permitía a los acreedores cobrarlos con los bienes que eran del adrogado (Gayo, 4.84).

2. En los tiempos primitivos, la presencia del pontifex debía ser una garantía para impedir el fraude a los acreedores, de tal modo que si advertían una maniobra de este tipo, no permitían la *adrogatio*. Ya en la época imperial, el pretor se ve obligado a otorgar una protección jurisdiccional. Lo que ocurría era que las obligaciones del adrogado se extinguían por la *capitis deminutio* de éste; y el adrogante no se responsabilizaba de ellas por cuanto no habían sido contraídas por él ni con autorización suya.

3. La *actio utilis*, con fórmula ficticia, significaba una verdadera *restitutio in integrum* en favor de los acreedores (Paulo, D.1.7.2). El adrogante quedaba ante la disyuntiva de pagar dichas deudas o dejar los bienes aportados, de tal modo que se podía llegar a

la *venditio bonorum* de todos los bienes ingresados por el adrogado (Gayo, 3.84; Ulp., D.4.5.2.1).

4. En la época de Justiniano, los bienes del adrogado son conservados en el dominio de éste, teniendo el adrogante el usufructo de ellos (C.6.61.6, año 529; Inst., 3.10.2).

A su vez, en cuanto a las deudas, se concede a los acreedores acción directa contra el *pater* adrogante en nombre del hijo, y hasta el monto de los bienes ingresados. Se puede decir que se trataba de una verdadera *actio de peculio*, cuyo rastro inicial estaba en la época clásica, ya que Ulpiano (D.15.1.42) nos dice que según algunos correspondía, pero Sabino y Cassio opinaban lo contrario (cfr. Inst., 3.10.3).

b) Un caso particular acaecía con la *adrogatio* del impúber permitida desde Antonino Pío (v. *supra*, este § (ii).2). El adrogado impúber podía correr el peligro de que luego de producirse la *adrogatio* el adrogante lo emancipara o lo desheredara, quedándose con sus bienes. Por ello se debía comprometer a no hacerlo sin *iusta causa*. En caso contrario, no sólo debía devolver los bienes, sino además la cuarta parte de los suyos propios. Esta cuarta parte era conocida como *quarta Antonina* o *quarta divi Pii* (Paulo, D.38.5.13; Inst., 1.11.3).

5. Además, el que adrogaba a un impúber, debía probar que era por "causa honrosa y que conviene al pupilo", y dar fianza a los eventuales herederos del adrogado, ante una "persona pública" (en un principio la *stipulatio* de caución se celebraba ante un esclavo público, y con Justiniano ante un escribano —*tabularius*—; Marciano, D.1.7.18; C.8.48.2; C.10.69.3), de que si el adrogado muriese antes de alcanzar la pubertad, les restituiría a dichos herederos sus bienes (Inst., 1.11.3).

§ 507. Adopción hereditaria. Las fuentes literarias, no jurídicas, nos hablan de una forma especial de *adrogatio*. Esta ocurría cuando un *pater* hacía testamento *in calatis comitiis*. En esa ocasión instituía heredero a un extraño a la familia, pero con la condición de que tomase el nombre gentilicio (*nomen gentile*) del testador.

Se discuten mucho sus efectos: para unos se trataba de una verdadera *adrogatio*, mientras que para otros era una simple institución de heredero con el requisito de que el instituido tomara el nombre familiar. Aun iratándose de una adopción, lo curioso es que no se podía ejercer la *patria potestas* por cuanto ésta nacería después de la muerte del testador.

Habría sido conocida en el período antiguo y preclásico, pero no existen menciones de los juristas. En el Digesto nada se dice de ella, salvo el párrafo de Gayo (D.36.1.63.10), que habla de la institución de heredero con la condición de tomar el nombre del

testador. Pero curiosamente, afirma con Juliano que si rehusaba hacerlo, lo mismo se le concedían *actiones utiles*, así como la *bonorum possessio*; es decir, era heredero.

Un caso especial es el de la adopción de Octavio (luego el primer *Princeps*) por Julio César después de la muerte de éste, quien habría recurrido a este procedimiento testamentario con evidentes propósitos políticos. Ello apercibiría esta forma de adopción más al derecho público, lo que explicaría el silencio de los juristas.

§ 508. II. *Adoptio (stricto sensu)*. a) A diferencia de la *adrogatio* (donde se adopta a un *sui iuris*), acá la adopción propiamente dicha se refiere a un *alieni iuris*, o sea, a un *filiusfamiliae* de una familia, que pasa a ocupar ese mismo estado, pero bajo la *potestas* de otro *pater*. En la época clásica el procedimiento exigía dos pasos: (i) primero romper el vínculo de la *patria potestas* que el *filius* (o la hija o el nieto o la nieta) tenía con su primitivo *pater*, lo cual se realizaba mediante una triple *mancipatio*, seguida de dos manumisiones; y (ii) un acto ante el magistrado, en el cual el *pater* adoptante reclamaba a dicho *alieni iuris* como *filius* suyo (Gayo, 1.134).

1. Según la ley de las XII Tabas, si un *pater* "vendía" a su hijo mediante tres *mancipationes*, éste quedaba "libre" de la *potestas* paterna. Supongamos que A quiere dar en adopción a su *filius* Cayo. Lo mancipa entonces a B, el adoptante, de tal modo que ahora quedaba *in causa municipi* de B. Para hacerlo salir de ese estado, lo manumite *per vindictam*, con lo cual regresa a la *patria potestas* de A. Se vuelve a repetir el mismo paso mediante una segunda *mancipatio* y una segunda manumisión. Al efectuarse la tercera *mancipatio*, por efectos de la disposición decenvital, se ha roto el vínculo de la *patria potestas* que ejercía A.

Luego de ello, el *pater* adoptante, o lo remanipula al *pater* para luego reclamarlo, o directamente concurren ambos *patres* ante el pretor. Allí B vindica a Cayo como su *filius*, y ante el silencio de A, por la *addictio* del magistrado, Cayo queda como *filius* de B; Gayo, 1.134.

2. Como la regla de las XII Tabas había de *filius*, por una interpretación pontifical, se estableció que para el caso de la hija, o del nieto o de la nieta, el procedimiento se simplificaba, bastando una sola *mancipatio*, seguida del acto ante el magistrado (Gayo, 1.134 ss.). En provincias, el procedimiento se realizaba ante los gobernadores (Gayo, 1.134, *in fine*).

Estos formalismos resultaron luego bastante complicados. Los habitantes del Oriente romano se limitaron a presentarse ante el gobernador de provincia: el padre natural hacía una decla-

ración de "emancipación" del hijo aceptando que fuera adoptado por el nuevo *pater*, Justiniano termina por aceptar este procedimiento, prácticamente administrativo. Ante el asentimiento de las partes presentes, se levantaba un acta (C.8.48.11; año 530).

b) *Efectos de la "adoptio"*. En la época clásica, la *adoptio* produce la extinción de la *patria potestas* del padre natural y el nacimiento de ésta en favor del *pater* adoptante. Estos efectos serán modificados por Justiniano, quien distinguirá dos clases distintas: la *adoptio plena* y la *adoptio minus plena*.

3. Los motivos de esta distinción consistían fundamentalmente en la situación patrimonial en que quedaba el *adoptivus*. Al establecer el nuevo vínculo, conforme a la adopción clásica dejaba de pertenecer a la familia natural primera, quedando privado de todo derecho sucesorio en ella. Así, podía suceder que mientras el *pater* natural fuera rico, el adoptante fuera pobre, o también que en algún momento lo emancipara, si bien en este caso podía reclamar la *bonorum possessio unde liberi*.

a) *Adoptio plena*. Ocurre cuando quien adopta es un ascendiente, que por alguna circunstancia no tiene sobre el adoptado la *patria potestas*. Así, p.ej., el abuelo de un niño concebido luego de la emancipación del hijo, o también del propio padre que había sido emancipado, habiendo quedado el niño bajo la *potestas* del abuelo. En estos casos, la *adoptio* producía los plenos efectos que tuvo en la época clásica, teniendo el adoptante la *patria potestas* (Inst., 1.11.2; C.8.48(47).10).

b) *Adoptio minus plena*. Ocurre cuando quien adopta es un *extraneus*, es decir, alguien que no es ascendiente. Aquí la *adoptio* es más bien nominal. El *pater* que lo ha dado en adopción sigue conservando la *patria potestas*, y en consecuencia todas sus expectativas sucesorias. Pero, a su vez, como hijo adoptivo en la nueva familia, puede también heredar de ella, ya por haber sido instituido heredero por testamento, ya porque tiene derechos en la herencia *ab intestato* (Inst., 1.11.2; C.8.48(47).10).

§ 509. (III) *Legitimación*. La legitimación (*legitimatio*) es una institución que aparece tardíamente en Roma, en la época del Derecho posclásico. Por medio de ella, se podía dar categoría similar a la de los hijos legítimos, a los habidos de un concubinato, adquiriendo el padre la *patria potestas* sobre ellos.

1. Los hijos habidos de un concubinato son denominados en esta época posclásica "hijos naturales". Con anterioridad, *fili naturales* era la designación de

los hijos concebidos en *iustae nuptiae*, en oposición a los adoptivos.

2. Los únicos que pueden ser "legitimados" son los hijos naturales habidos de un concubinato. No así los meramente extramatrimoniales (*spurii* o *vulgo concepti*), ni tampoco los adulterinos ni los incestuosos.

(i) Quien introdujo la *legitimatio* fue Constantino, como modo de regularizar las situaciones concubinarias, al mismo tiempo que prohibía la *adrogatio* de los hijos naturales (C.Th.4.6.2; 3). En efecto, como nacían fuera de las *iustae nuptiae*, los hijos eran *sui iuris*, siguiendo la condición jurídica de la madre. La forma creada por Constantino era el matrimonio subsiguiente de los concubinos (*per subsequens matrimonium*).

3. Constantino la estableció como medida excepcional para los hijos ya nacidos al tiempo de la constitución imperial. El ejemplo fue seguido por Zenón (C.5.27.5, año 476); y ya Anastasio, en el 517, autorizó este modo de manera permanente (C.5.27.6). Luego fue abolido por su sucesor Justino (C.5.27.7), pero finalmente retomado por Justiniano (C.5.27.10, año 529).

4. Era necesario: a) que los padres se hubieran podido casar en el momento de la concepción, es decir, que no hubieran tenido impedimentos en dicho momento; ello, para evitar, p.ej., la legitimación de hijos adulterinos; b) que la conversión del concubinato en matrimonio fuera formalmente redactada en convenciones matrimoniales (*matrimonialia instrumenta*); y c) que el hijo consintiera, o al menos no se opusiera.

(ii) Había otra forma de legitimar, la *oblatio curiae* (ofrenda a la curia). Se trataba de la curia municipal, cuyos miembros (los "decuriones") se encargaban, en el Bajo Imperio, de cobrar los impuestos. Las dificultades de reclutamiento de estos decuriones eran ostensibles, pues el cargo era pesado y honorario. Fue así que se otorgaron diversos derechos a quienes ofrecieran sus hijos como "decurión" (era un cargo viril) o diera a sus hijas en matrimonio a decuriones. Estas medidas culminaron con la legitimación de dichos hijos e hijas.

5. En principio, Theodosio II y Valentiniano III, en el año 443 (C.5.27.3) permitieron al padre, en ausencia de hijos legítimos, dejar por testamento o dar en donación todo o parte de su patrimonio a los hijos naturales, con la condición de inscribir a los varones en la curia (ser "decurión" era un cargo viril), o casar las mujeres con decuriones.

6. Este primer procedimiento se irá encarrilando a una verdadera legitimatio. Así, se admitió que los hijos que entraran en la curia, sucedieran *ab intestato* a su padre (León, C.5.27.4, año 470). Justiniano

permitió este derecho aun teniendo hijos legítimos (C.5.27.9) y terminará reconociendo la *patria potestas* sobre ellos (Nov.89.11). También, en ausencia de hijos legítimos, se autorizó a los hijos naturales a legitimarse por sí mismos, ofreciéndose para entrar en la curia (Nov.89.2).

(iii) Un tercer modo de *legitimatio* era recurriendo al Emperador, el cual la otorgaba por un *rescriptum*. Fue permitida así por Anastasio, pero luego suprimida por Justino y Justiniano. Pero este último la reintrodujo (Nov.74 y 89), sólo si el casamiento subsiguiente no era posible, por la muerte o desaparición de la concubina, y siempre que el padre no tuviera descendientes legítimos.

§ 510. *Extinción de la patria potestas*. La *patria potestas* se extingue: a) por la muerte del *pater*, puesto que mientras viva la continúa ejerciendo; b) por haber sufrido el *pater* una *capitis deminutio* (así, haber perdido la libertad, *c.d.maxima*; o haber perdido la ciudadanía, *c.d.media*; o haberse dado en *adrogatio*, *c.d.minima*). Igualmente si los *fili* mueren o han sufrido una *c.d.* (así, si son entregados en *adoptio*, o en el caso de la hija, haberla casado *cum manu*). La forma directa de hacer salir un *filius* o una *filia* de la *patria potestas* es la *emancipatio*.

1. Muerte del "pater". En este caso hay que distinguir si éste es el padre o el abuelo. En el primer supuesto, los *fili* (incluida la *uxor in manu*) se hacen *sui iuris*. Pero si el *pater* es el abuelo y queda vivo su hijo, los nietos por parte de éste pasan a estar bajo su *patria potestas* (Gayo, 1.127).

2. *C.d. maxima*. En este caso, resulta obvio que siendo esclavo el *pater* pierde la *patria potestas*. Así, si había sido condenado a una pena infamante (*servus poenae*; Inst., 1.12.3).

Para el supuesto de que el *pater* (o el *filius*) cayera prisionero del enemigo, la *p.p.* se mantiene en suspenso, puesto que puede renacer por el *postliminium*. Si moría el *pater* siendo prisionero, en época de Gayo se discutía si la pérdida de la *p.p.* ocurría desde la muerte, o desde que fue tomado prisionero (Gayo, 1.129). Predominó el criterio, análogo al de la *factio legis Corneliae*, de que se lo consideraba muerto desde su captura (Ulp., D.49.15.18; Inst., 1.12.5).

3. *C.d. media*. Gayo (1.128) nos dice que la condena a la *interdictio aquae et ignis* del *pater* le hace perder la *p.p.*, "ya que sería inadmisibles que un hombre que está en condición de extranjero tenga bajo su *potestas* a ciudadanos romanos"; ocurría lo mismo si el *filius* sufría esta condena.

Justiniano, para su época, nos habla de la deportación a una isla (*deportatio in insulam*; Inst., 1.12.1), si bien admite que por la clemencia del príncipe, se lo podía restituir la *p.p.*, cuestión que estuvo discuti-

tida (v. Gordiano, C.9.51.6; Const., C.12.13). En cambio, la condena menor de la *relegatio in insulam*, permitía retener la *p.p.*, o continuar sujeto a ella (Inst., 1.12.2).

4. *Otras causas*. En la época antigua y clásica, los varones consagrados como sacerdotes de Júpiter (*flamines Diales*) y las mujeres escogidas como Vestales, dejan de estar sujetos a la *p.p.* (Gayo, 1.130; Ulp., 10.5; Aul.Gell., 1.12.9).

Justiniano también admite la extinción del poder paterno respecto de los que tenían la dignidad de *patrices* (C.12.3.5; Inst., 1.12.4). Y luego, también los cónsules, los prefectos del pretorio o de la ciudad, los *magistri militum* y los obispos (Nov. 81.3, año 539).

Igualmente, ya en el derecho bizantino, se pierde la *p.p.*, sin que el hijo sufra una *c.d.*, en caso de falta grave del *pater*: así, por exposición del hijo (C.8.52.2), por haber compelido a la hija a la prostitución (C.11.40.6), o por haber contraído una unión incestuosa (Nov.12.2).

§ 511. *Emancipación*. A) El caso voluntario por parte del *pater* de hacer cesar la *p.p.* (aparte de la adopción y de la *conventio in manu* de la hija), se llama *emancipatio* (emancipación).

La forma empleada es semejante a la ya vista a propósito de la *adoptio* (supra, §.508), donde se aprovechaba la regla de "lo que se da por la triple venta" (*mancipatio*) por parte del *pater* el *filius* quedaba libre de su *potestas*.

1. A diferencia de la *adoptio* (3 *mancipationes* seguidas de dos *manumisiones*), acá se realizan las 3 *mancipationes* y también 3 *manumisiones*, utilizándose a un amigo quien actúa como *pater fiduciarius*. Con la tercera *mancipatio* se rompe el vínculo de la *patria potestas*, y el que actúa como *pater fiduciarius* en estos ritos, lo saca de su *mancipium* por la tercera *manumisión* (Gayo, 1. 132).

2. La práctica de este sistema traía algunos inconvenientes. Así, el *pater fiduciarius*, al *manumitirlo* por tercera vez, se convertía en "patrono", quedando el hijo *sui iuris* emancipado sujeto a las reglas del patronato. Si el hijo era *alieni iuris*, quedaba en la tutela de dicho *pater fiduciarius*. Para mitigar estos efectos, este último, en lugar de *manumitirlo* se lo remancipa al *pater anterior*, siendo él quien lo *manumite*, por tenerlo en *causa mancipi*. Con ello no se eliminan los efectos ya mencionados, pero ahora el patrono o el tutor no será un extraño (Gayo, 1.140).

3. Al igual que para el caso de la *adoptio*, la emancipación de una hija, de un nieto o de una nieta, se efectuaba mediante una sola *mancipatio*, seguida de una *manumisión* (también se podía acá utilizar la remancipación). Se podía emancipar sólo al hijo, reteniendo al nieto, o bien emancipar a ambos (Gayo, 1.133).

En el derecho posclásico, sobre todo en las provincias orientales, las formas de la *emancipatio* clásica fueron decayendo. El emperador Anastasio (C.8.49(48).5, año 502) permite que se pueda emancipar por rescripto imperial, debiendo el acto anotarse (*insinuatio*) en los registros públicos (*emancipatio Anastasiana*). Justiniano le permite al *pater* emancipar, ya por la disposición de Anastasio, o también, sin rescripto, aboliendo las mancipaciones y manumisiones, mediante una presentación ante el magistrado competente (C.1.6, año 531; *emancipatio Iustiniana*).

B) Por regla general, la potestad de emancipar le corresponde al *pater*; no se lo puede obligar a hacerlo contra su voluntad (Inst., 1.12.10). Sin embargo, se admiten algunos casos excepcionales, en los cuales el *filius* pudo lograr su emancipación.

1. Así, si el *pater* maltrató a su hijo, por una disposición de Trajano se obligó al *pater* a emanciparlo (Pap., D.87.12.5); si se había adoptado a un impuber, el llegar éste a la pubertad, podía ser oído por el magistrado, acerca de que le convenía ser emancipado (Pap., D.1.7.32; Marciano, D.1.4.33). Igualmente se obligó a la emancipación, cuando ésta era una cláusula testamentaria o fideicomisaria (Ulp., D.35.1.92).

2. Además, si bien en un principio no resultaba relevante, se fue forjando la idea de la necesidad del consentimiento del *filius*. Paulo (2.25.5) decía que bastaba su no oposición. En la *emancipatio Anastasiana* (C.8.49(48).5), se pide el consentimiento ("que acomoden también su voluntad al propósito de sus ascendientes"), salvo para los infantes, en que no es necesario. Justiniano estableció que "no les está permitido a los padres disolver el *ius potestatis* contra la voluntad de los hijos" (Nov. 89.11 pr.).

C) En cuanto a los efectos de la *emancipatio*, éstos son fundamentalmente hacer cesar la *patria potestas*; de tal modo que el emancipado se hace *sui iuris*.

1. En un principio, la *emancipatio* era un recurso usado por el *pater* para reducir el número de sus herederos, de tal modo que el patrimonio familiar quedara en manos de un solo hijo. La situación del hijo emancipado, si bien como *sui iuris* tiene ahora un patrimonio propio, no era muy favorable, ya que se hallaba ahora fuera de su familia, sin bienes valiosos y sin derechos hereditarios (Gayo, 3.119). El *pater*, generalmente, se encargaba de subvencionar las necesidades alimentarias y en general patrimonial de los emancipados (así, permitiendo mantener un peculio o mediante legados a su favor).

2. Luego, se irá mejorando su situación; así, podrá conservar su peculio profecticio, si es que expresamente no le ha sido pedido (FV, 260), y por supues-

to el peculio castrense. Ya en el Bajo Imperio, también el peculio *quasi castrense*, adquiriendo además la propiedad de los dos tercios de los bienes adventicios, quedando el restante para el *pater*. Justiniano (C.6.61.6; año 528) sustituirá este tercio por el usufructo del *pater* sobre la mitad de los bienes (Inst., 2.9.2).

A su vez, desde el punto de vista sucesorio, el pretor le irá reconociendo un lugar en el llamamiento de la *bonorum possessio ab intestato*, concurriendo con los demás *sui heredes* (Gayo, 3.25-6). Ya por la Nov.118, habiéndose reemplazado el vínculo agnático por el cognático, el emancipado participaba en la herencia *ab intestato* igual que los otros hijos que estaban *in potestate*, debiendo cumplir con la colación de sus bienes propios (*collatio bonorum*), es decir, incorporarlos a los bienes hereditarios, puesto que de lo contrario estaría en mejor situación que los que habían quedado *in potestate*.

3. En la última época, como se consideraba que la *emancipatio* era un beneficio para los hijos, se la consideró revocable en caso de ingratitud (Constantino, FV, 258; Valentiniano, C.8.50(49).1).

4. También existió la *abdicatio* o *relegatio*, mediante la cual se castigaba al hijo expulsándolo de la casa por una causa grave o un crimen, pero no obstante ello no dejaba de estar *in potestate*. No hay que confundirla con el instituto griego del repudio (*apokérysis*), que liberaba al hijo de la familia, y que no existió en Roma; fue prohibida por Diocleciano (C.8.47(46).6).

II. Manus.

§ 512. Se trata del caso especial de la mujer casada, que podía entrar como *alieni iuris* en la familia de su marido, rompiendo sus vínculos con su familia originaria. De dicha mujer se decía que estaba *in manu*. Esta situación de tener a sus mujeres bajo la *manus* es propia de los ciudadanos Romanos (Gayo, I.108-109).

La *manus* no se identifica necesariamente con el matrimonio. De ahí que vulgarmente se suele hablar de matrimonio *cum manu* o *sine manu*. El efecto principal es la entrada de la *uxor* en la familia agnática de su marido, abandonando por ello los vínculos con su familia originaria. Con su ingreso, quedaba ubicada como hija de su marido (*in loco filiae*), y, por tanto, como hermana agnada de sus propios hijos. A su vez, si el marido era *alieni iuris*, la *manus*, que es siempre del marido, queda como absorbida en la *patria potestas* del *pater* de quien el marido dependía, quedando la *uxor*, ya como nieta o como bisnieta, según fuera su marido un hijo o un nieto.

Desde este punto de vista, sus efectos se parecen a los de la *adoptio* (si la mujer era

alieni iuris) o a los de la *adrogatio* (si la mujer era *sui iuris*). La *uxor in manu* se cuenta entre los *heredes sui* (Gayo, 3.3). Si la *uxor in manu* había sido *sui iuris*, al entrar en la familia de su marido, ingresaba sus bienes, pero no las deudas (por la *capitis diminutio* producida, igual que el caso del adrogado). Pero el pretor concedía a los acreedores anteriores de la mujer una *actio utilis* con fórmula ficticia (como si la *conventio in manu* no hubiera ocurrido), exactamente igual que para el caso de la *adrogatio* (Gayo, 4.84).

1. La expresión *in loco filiae mariti est*, no nos debe hacer pensar que se trataba de una situación igual a la de la *patria potestas*. Así, no se habla nunca de que el marido tuviera el *ius vitae necisque*, ni tampoco de que la pudiera vender. Más bien, lo que se quería expresar era que el ingreso a la familia, la transformaba en agnada en la familia de su marido, y, por tanto, en heredera de él, o en su caso del *pater* de quien dependiera. Aun reconociendo también los efectos patrimoniales (la *uxor in manu* era *alieni iuris*, y lo que adquiere ingresa al patrimonio familiar), la denominación no fue la de *potestas*, sino simplemente la de *manus*.

§ 513. Formas de adquirir la *manus*. Estas formas eran el *usus*, la *confarreatio* y la *coemptio* (Gayo, I.110).

A) El *usus* consistía en una adquisición automática de la *manus* y ocurría cuando la mujer casada hubiese permanecido conviviendo con su marido durante un año a partir de la celebración de las nupcias. Si ella no lo deseaba así, la ley de las XII Tabas le permitía evitar caer *in manu*, ausentándose durante tres noches ese año (XII Ts.6.4: *trinocitii usurpatio; trinocitium*).

1. Esta forma, que algunos consideran como la más antigua, establece claramente que el matrimonio no comporta necesariamente la *manus*, puesto que durante el transcurso del año, la mujer estaba casada y sin embargo no estaba aún *in manu*. Otros opinan que debió haber sido la forma de establecerla a falta del casamiento por *confarreatio* y ausencia de la *coemptio*.

2. Gayo (I.111) la describe como si la mujer "hubiera sido usucapida por una posesión anual". La costumbre era usar de la *trinocitii usurpatio* yendo a casa de sus padres durante las tres noches anteriores al vencimiento del año. Aulo Gellio (18.6) nos dice que la mujer que estaba *in manu* era denominada *materfamilias*; en cambio, la simplemente casada, *matrona*.

3. Este modo fue el primero en desaparecer. Cicerón (*pro Flacco*, 34.84) la continúa mencionando para su época. Pero ya Gayo nos la describe como

una institución del pasado que cayó totalmente en desuso (Gayo, I.111).

B) La *confarreatio* era una forma muy antigua de celebrar las nupcias, con un ritual muy complicado. Era con certeza un rito religioso, que se celebraba con la intervención de un pontífex y el *flamen Dialis*. El punto central de la ceremonia consistía en una ofrenda de pan de harina de trigo (*panis farreus*) dirigida a *Iuppiter Farreus*, y es de aquí de donde toma el nombre (Gayo, I.112).

1. La ceremonia estaba precedida de toda una serie de actos menores: la *traditio* de la mujer al marido en casa de aquella, el cortejo nupcial que acompañaba a los contrayentes, y la *deductio in domo* en la casa del marido, donde finalmente se celebraba el sacrificio. La presencia de diez testigos, número alto en comparación con otros ritos, nos habla de su antigüedad.

2. Se la continuó usando por las familias más conservadoras, aun para la época de Gayo (I.112). Según nos dice este autor resultaba necesaria en su tiempo, ya que los sacerdotes mayores, es decir, los de *Iuppiter* (*flamines Diales*), los de Marte (*Martiales*) y los de Quirino (*Quirinales*), así como el "rey de los sacrificios" (*rex sacrorum*), sólo podían ser designados entre aquellos que han nacido de nupcias celebradas por una *confarreatio*, y ellos mismos no podían ejercer su sacerdocio sin haberla efectuado.

Por otro lado, se sabe que el cargo de *flamen Dialis* quedó vacante, por falta de candidatos, desde el año 87 al año 12 a.C., y que por un senadoconsulto de esta última fecha, sólo se celebraba la *confarreatio* a los efectos sagrados (*ad sacra tantum*), pero que ello no afectaba al *ius civile* (Tácito, *Ann.*, 4.16).

3. Para extinguir la *manus* habida de la *confarreatio* era necesario un acto ritualmente opuesto, conocido por *diffarreatio*.

C) La *coemptio* era una forma ingeniosa de adquirir la *manus*, mediante una *mancipatio* en la cual se "vendía" (o "autovendía") la mujer. Para evitar que se la pudiera considerar meramente *in causa mancipi*, se modificaban las palabras usuales para que no hubiera dudas de que el acto se realizaba por causa de matrimonio (*matrimonii causa*), para adquirir la *manus* (Gayo, I.113).

1. Esta forma ya está en desuso hacia fines de la República. Cicerón (*de orat.*, I.56.237) nos dice que ya los oradores forenses ignoraban los detalles de esta ceremonia.

2. Gayo la sigue recordando, pero él mismo distingue entre la *coemptio* que se realizaba por "causa de matrimonio", de otra que se realizaba "por causa de fiducia", y es a ésta a la que presta total atención

(1.114). Así, por *causa fidei*, una mujer se daba *in manu*, no por matrimonio, sino para eludir una tutela. De este modo, la mujer *sui iuris* por medio de la *conventio in manu* se hacía "vender", con la *auctoritas* de su tutor, a un amigo o familiar de confianza, quien a su vez la remancipaba a un tercero, que quedaba como "tutor fideiarius" (Gayo, 1.114). Esta clase especial de *manus*, realizada con un extraño, no traía el efecto de que la mujer pasara a ocupar el *locus filiae*, como sucede con la efectuada *causa matrimonii* (Gayo, 1.115 b).

3. Para extinguir la *manus* habida por una *emptio* se recurría a una *remancipatio*. Así, en favor del padre de la mujer o en favor de un tercero fideiarius que luego la manumitía para volverla *sui iuris*. La mujer repudiada podía forzar su propia *remancipatio* (Gayo, 1.137).

§ 514. Si el matrimonio era *sine manu*, la mujer estaba casada con su marido pero no integraba la familia agnática de éste. Continuaba sometida a la *patria potestas* de su *pater*, y en caso de ser *sui iuris*, a la de su tutor.

Hasta el siglo I a.C., lo común era el matrimonio *cum manu*. A partir de allí, se va generalizando el matrimonio *sine manu*, que fue el usual de la época clásica. Justiniano borró toda referencia a la *manus* en su recopilación.

§ 515. Dominica potestas y mancipium (*remisión*). La *dominica potestas* es la que el *pater* ejerce sobre los esclavos (v. *supra*, § 165) o sobre las cosas (*dominium* o propiedad; v. *supra*, § 223 ss.).

El *mancipium* que se ejerce sobre los terceros que están *in causa mancipi* fue ya tratado (v. *supra*, § 502, c).

PARTE SEGUNDA

LAS RELACIONES PATRIMONIALES ENTRE EL PATER Y LOS ALIENI IURIS

§ 516. Principios generales. La familia romana tuvo desde un principio un carácter fuertemente unitario y monolítico. Lo que se tenía en vista era el interés familiar. De allí que sólo existía un *patrimonium*, cuya administración y disposición le corresponde al *paterfamilias*. Esto repercute sobre los principios que rigen tanto el aspecto "activo" (la adquisición de bienes), como el aspecto "pasivo" (las obligaciones de dicho patrimonio).

A) En cuanto al "activo", la regla podía ser enunciada así: los *alieni iuris* de la familia (hijos, hijas, esclavos) no tienen capacidad jurídica para ser propietarios de nada. Ciertamente que no obstante ello, tienen "capacidad de obrar", pero

todo aquello que adquieren por cualquier causa no lo adquieren para sí, sino que se revierte al patrimonio familiar.

1. Así, si los *alieni iuris* adquieren algo por *mancipatio* o por *traditio*, ya sea que provenga de una *stipulatio*, o de cualquier otra causa lícita, es adquirido por el *pater*, ya que aquel que está sometido a *potestas* no puede tener nada suyo. Si el *filius* es instituido heredero no puede aceptar la herencia sin el *inssum* (autorización) del *pater*; de este modo, es en realidad el *pater* el que adquiere por el *filius* (Gayo, 2.87; D.41.1.10; Inst., 2.9.1).

B) A su vez, si consideramos el aspecto del "pasivo" del patrimonio, el único que puede responsabilizar los bienes familiares es el *paterfamilias*. La regla general es que por medio de nuestros *alieni iuris* podemos "mejorar", pero no "deteriorar" nuestra situación (Gayo, 50.17.133). Esto significa que tratándose de la realización de negocios, el *pater* no resulta responsabilizado por las obligaciones contraídas por el *filius*. En cambio, tratándose de delitos, quien deberá responder de los cometidos por los *alieni iuris* es el *pater*, quien podrá ejercer el *ius noxae dandi*.

1. Si un *filius* contrae una obligación que no le ha sido autorizada por su *pater*, ésta no es necesariamente nula. Pero si tenemos en cuenta que no es propietario de nada, obviamente que carece de sentido entablar una *actio* contra él, porque sería de imposible cumplimiento, aun cuando hubiere mediado una sentencia. El *pater*, si quería podía voluntariamente satisfacerla, pero no está obligado a ello. Desde la época de Julio, estas obligaciones serán consideradas "obligaciones naturales".

Estos principios que rigen la vida patrimonial de la familia romana rigieron durante la época antigua y buena parte de la época republicana. Pero prontamente se irán conociendo excepciones, cada vez más importantes. Esto significó un lento pero sostenido deterioro de la primitiva familia monolítica, puesto que al lado del interés familiar, que lucía como exclusivo, hubo que admitir la existencia de intereses propios de los *alieni iuris*. Tal será el caso de los "peculios", que importarán excepciones a la regla del "activo". E igualmente, debido a la participación de los *filius* y de los esclavos en actividades económicas generadas por el *pater*, hubo necesidad de ir reconociendo la responsabilidad del *paterfamilias*, admitiendo el pretor la existencia de acciones que se podían intentar contra éste. Tal será el caso de las *actiones adiecticiae qualitatis*, que modificarán la regla inicial del "pasivo".

§ 517. Los *peculios*. La denominación viene

de *pecus* (pequeña cantidad de ganado; o de dinero = *pecunia*). Ulpiano define al *peculio* (*peculium*) como "pequeñísima cantidad de dinero o muy pequeño patrimonio" (D.15.1.5.3). Pero se lo debe entender como un "capital" (de *caput* = cabeza de ganado; no como patrimonio), que estaba separado de las cuentas del patrimonio del *pater* (Tubero-Celso-Ulp., D.f.d. 4).

A) El primero en aparecer fue el llamado "peculio profecticio" (*peculium profectici*; *quasi a patre profectum*; Justiniano lo denomina *paganium*, C.3.28.37 pr.). Consiste en una pequeña suma de dinero o de bienes que el *pater* entrega al *filius* o al esclavo para su libre administración y goce. Podía, por ello, hasta disponer de él, aunque no donarlo, por cuanto se entiende que lo tiene para su disfrute, no para perderlo (Ulp., D.39.5.7 pr.).

El *pater* se lo podía retirar en cualquier momento, pero generalmente se lo respetaba y hasta se lo reservaba, ya en caso de emancipación del hijo o de manumisión del esclavo. Igualmente era usual que se lo mantuviera en el testamento. A la muerte del *filius*, el *peculio* regresaba al *pater* como algo suyo, es decir, no por causa de herencia (*iure hereditatis*), sino por causa de *peculio* (*iure peculii*).

1. Este *peculium profectici* no sólo les podía ser concedido a los hijos y esclavos, sino también a las hijas. Así, una hija podía constituir en dote su *peculio* (Pomp., D.23.3.24) y la mujer *in manu* podía tener su propio *peculio* (Plauto, *Casin.*, II.2.26).

2. El esclavo podía también tener en su propio *peculio* a otro esclavo, bajo sus órdenes (*servus vicarius*). Esto le da un cariz particular a la condición personal del esclavo. Estos *peculios* de los esclavos podían en algunos casos alcanzar un monto muy apreciable. Así, se recuerda el de un esclavo que pagó 60.000 sestercios para alcanzar su manumisión (C.I.L. 40 5400), o el del monumento elevado a un esclavo de Tiberio por 15 *servi vicarii* suyos que formaban parte de su *peculio* (C.I.L. 6.5197).

B) Luego, desde la época de Augusto, se agregó el *peculium castrense*. Consiste en todo aquello que el *filius* obtenga como soldado (Macer, D.49.17.11). Ello representó un reconocimiento más importante de las posibilidades económicas de los hijos. En primer lugar, porque su monto no depende ya de la voluntad del *pater*, sino de su propia actividad. Además, los poderes de administración y disposición son más amplios (se los considera respecto del *peculio* castrense como si fueran *paterfamilias*; Ulp., D.14.6.2). Podían hacer testamento de dicho *peculio*, y en caso de sucesión *ab intestato*, los bienes le corresponden al *pater*, pero no *iure*

hereditatis, sino *iure peculii*, como si le hubiesen pertenecido en propiedad (Ulp., D.49.17.2).

1. Forma parte de este *peculio*, no sólo las ganancias que consiga como soldado, sino también lo que el *pater* le hubiera dado al *filius* cuando éste va a prestar servicio (Pap., D.40.5.23.2), las donaciones de la mujer al marido militar, la herencia de ésta, así como la de un camarada de armas (*commiles*); Pap., D.49.17.13; Tryfon., D.f.d. 19 pr.).

2. La posibilidad de hacer testamento les fue permitido por disposiciones de Augusto, Narva, Trajano y ampliado por Adriano a los veteranos (Inst., 2.12 pr.).

Respecto al caso de que el hijo muriera *dó intestato*, Justiniano introduce algunas reformas: así, al efecto de devolver el *peculio* al *pater* a título de *peculio* (*iure peculii*) se lo considera con efecto retroactivo; de este modo, el *pater* puede legar un esclavo del *peculio* castrense de su hijo, y si éste premuere en relación con el *pater*, y el *peculio* quedó en su poder, el legado es válido, considerando que por dicho efecto retroactivo, el *pater* era dueño del *peculio* (Ulp., D.30.44 pr. it.). Igualmente, premuerto el hijo, no vuelve directamente al *pater*, ya que lo preceden los hijos del *filius* y sus hermanos (Inst., 2.12 pr.).

C) Más adelante, a imitación del *peculium castrense*, surgió el *peculium quasi castrense*, organizado por Constantino, quien consideró que había que tratar con igual consideración a los hijos que luchaban en el campo de batalla y a aquellos que prestaban servicios en el Palacio, por todo lo que pudieran obtener los *filius* en dichas tareas (C.Th. 6.36.1 = C.12.30.1). Más tarde se le agregó también el caso de los ingresos provenientes de cualquier cargo público, artes liberales, eclesiásticos, donaciones del emperador o de la emperatriz (C.Th. 1.34.2 = C.1.51.7; C.Th. 2.10.6 = C.2.7.4; C.1.3.33(34); C.12.16.5 pr.).

D) *Bona materna*. También en la época de Constantino se operó una reforma respecto de los bienes pertenecientes a la madre y que por causa hereditaria fueran a parar a los hijos. Según la regla general de adquisición, estos bienes pasarían al *pater*. Esto ocasionaba perjuicio a los hijos, pues aparte de que éste podía disiparlos, en caso de que contrayera segundas nupcias, los hijos del primer matrimonio tendrían que compartirlos con los habidos en el segundo matrimonio.

Constantino, congruente con la reforma producida por el s.c. *Orphitianum*, admitiendo la sucesión de los hijos respecto de su madre *sui iuris*, decidió que dichos *bona materna* formarían una masa especial en la cual el *pater* gozaría de la administración y el usufructo, quedándole prohibido enajenarlos (C.Th. 8.18.1 = C.6.60.1, año 319).

1. Esta situación particular de los *bona materna*, que quedaban en poder del *pater*, gozando del usufructo, pero con reserva de la propiedad para los hijos, termina siendo considerada como de propiedad de éstos. Quizá la afirmación de Constantino de que los bienes pertenecen en dominio a los hijos, está sospechada de interpolación. Pero resulta indudable a partir de Theodosio (C.6.61.1). De todos modos, la decisión de Constantino conducía inevitablemente a esto.

Luego, Arcadio y Honorio (C.6.60.2, año 395) extendieron esta regla para todos los bienes que los ascendientes por línea materna hubiesen transmitido a título gratuito a sus nietos o nietas. Y también se agregaron a las donaciones realizadas por un cónyuge a otro que está *in potestate* (Theod. y Valent., C.6.61.1, año 426) e incluso entre esposos prometidos en matrimonio (León y Artemio, C.6.61.5, año 473).

E) Para la época de Justiniano la situación puede quedar resumida así:

a) Lo que los hijos adquieren a título de pecuho por concesión del *pater* (*peculium profectium*), es siempre del dominio de este último (Inst., 2.9.1).

b) Lo que los hijos adquieren por ellos mismos (*peculium castrense* y *quasi castrense*), éstos son del *filius* continuándose con las reglas anteriormente dichas a su respecto (C.6.61.6 pr. *in fine*).

c) Lo que los hijos adquieren por ellos mismos por transmisiones maternas (*bona materna*) o por las otras causas ya mencionadas, extendidas ahora a todas las adquisiciones de patrimonio que no sea el paterno (C.6.61.1; id. 8 pr.; Inst., 2.9.1).

1. El *pater*, si bien tiene la administración y el usufructo no puede enajenarlos ni hipotecarlos (C.6.61.4). Justiniano entiende que esta solución es equitativa: no se priva al *pater* del goce del usufructo, ni los hijos se lamentarán de ver que sus bienes tengan que ser compartidos con otros (C.6.61.6 pr.). El hijo no puede pedir rendición de cuentas del usufructo al *pater* (C.6.61.6.2). Muerto el *pater*, la masa de estos *bona* le es entregada al *filius*. Pero éste no puede enajenarlos, ni pignorarlos ni hacer testamento sin el consentimiento del *pater* (C.6.61.6.5).

2. Conforme a la disposición de Constantino, si el *pater* emancipara al hijo, podía quedarse con la tercera parte de los bienes adventicios, como precio de la emancipación. Justiniano, considerando esto un despojo, sólo le permite quedarse con el usufructo de la mitad de ellos (Inst., 2.9.2; C.6.61.6.3).

3. Sin embargo, hay ciertos casos en los cuales el *pater* no goza del usufructo sobre los *bona materna* y *adventicia*: a) si al hijo se le da un legado o una donación con la condición de que el *pater* no tenga el

goce de los bienes (Nov.117.1); b) si el hijo adquiere una herencia en contra de la voluntad de su padre (C.6.61.8.1); c) si concurre a una herencia juntamente con su padre (caso de la herencia del hermano; Nov.118.2). Luego se hablará de éstos casos como de *bona adventicia irregularia*.

De este modo, mediante este largo proceso, las excepciones a la regla general de la adquisición de bienes del *pater* por intermedio de los *alieni iuris*, va conociendo un deterioro muy serio. Cuando llegamos a Justiniano, se le está reconociendo que está posibilitado para tener un patrimonio. La antigua regla según la cual lo que adquieren los *alieni iuris* lo hacen para su *pater*, sólo se continúa aplicando: a) cuando el hijo realiza un acto de adquisición en nombre del *pater*; y b) cuando la adquisición es hecha con los bienes del *pater* (caso del *peculium profectium*), formado por cosas del *pater* (*ex re patris*). Salvo estos casos, el hijo es considerado propietario de lo que obtuviera, considerándose *inhumanum* que dichos bienes fueran adquiridos por el *pater* (Inst., 2.9.1).

§ 518. Las acciones adiecticiae qualitatís. En cuanto a la regla general de que sólo el *paterfamilias* puede obligarse comprometiendo el patrimonio familiar, de tal modo que no responde de las obligaciones contraídas por los *alieni iuris* —con excepción de las nacidas de delitos, con la posibilidad del *ius noxae dandi*—, también se comenzarán a producir excepciones. Éstas serán debidas a diversas ocupaciones empresariales ordenadas o autorizadas por el *pater*, o por aplicación de la equidad. Es así que el pretor irá concediendo una serie de acciones conocidas con el nombre de acciones adiecticiae qualitatís. Éstas tornaban al *pater* a veces plenamente responsable por el todo (*in solidum*), y a veces limitada a un monto determinado.

1. La denominación acciones adiecticiae qualitatís (= "acciones de cualidad agregada o añadida") no es propiamente romana. Proviene de los glosadores, quienes la tomaron del texto de Paulo (D.14.1.5.1), donde se indica que en estos casos "no se transfiere la acción, sino que ella es agregada —*adiicitur*—".

Lo que hay que resaltar es que, en principio, si las acciones eran dirigidas contra el *filius*, éstas caerían de practicidad ejecutiva (salvo que contara con un *peculium castrense* o *quasi castrense*). Pero en este caso se "agregaban" o se "añadían" estas acciones dirigidas contra el *pater*.

2. En la época clásica, la fórmula se redacta mediante la técnica de la "trasposición de personas", de tal modo que si bien aparece el nombre del *filius* o del esclavo en la *intentio*, el que resulta responsable en la *condemnatio* es el *pater*. Cuando desa-

parece el procedimiento formulario, la acción es dada directamente contra el *pater* (Inst., 4.7.8). A su vez, si bien el esclavo no podría realizar el negocio por carecer de capacidad, el pretor hacía desaparecer esta dificultad por una ficción de libertad (Jul., D.19.1.24.2; D.14.3.12; D.45.2.12).

§ 519. A) *Actio quod iussu*. Si el negocio lo realizaba el *filius* o el esclavo, pero cuenta con la orden o la autorización (*iussu*) del *pater* o del *dominus*, el pretor concede por el todo la *actio quod iussu* contra estos últimos. Acá la acción "agregada" se justifica plenamente, por cuanto quien celebró el negocio ha confiado más en el *pater* o en el *dominus* que en el *filius* o en el esclavo (Gayo, 4.70; Inst., 4.7.1; D.15.4; EP, § 104.2).

1. Si el *pater* o el *dominus* han querido realizar ellos mismos el negocio, utilizando al *filius* o al esclavo como meros instrumentos, entonces se concede la acción correspondiente en forma directa contra el *pater* o el *dominus*. Así, si para realizar un mutuo un *pater* envía a su *filius* a recibir el dinero en préstamo. Acá no corresponde recurrir a la *actio quod iussu*, ya que se entiende que el negocio lo realizó el *pater* (Paulo, D.15.4.5 pr.).

2. Tal como detalla Ulpiano (D.15.4.1 pr.) el *iussu* ocurre cuando se autoriza "ante testigos, o por carta, o por palabras, o por nuncio, ya en forma especial para un negocio o en forma general; y también si se hubiere hecho así, diciéndole al otro contratante: "El negocio que a mi riesgo quieras hacer con mi esclavo Stichus".

Incluso si el *pater* o el *dominus* ratificara con posterioridad el negocio efectuado por su *filius* o por su esclavo, también se obliga por la *actio quod iussu* (Ulp., D.15.4.1.6).

3. Aparece cuestionado el caso de si el *dominus* hubiere afianzado la obligación contraída por su esclavo sin su *iussu*, por medio de una *fideiussio*. Marcelo entiende que no corresponde la *actio quod iussu*, y si la acción por la *fideiussio*, porque en este caso afianzó como a cualquier extraño; e incluso, si la *fideiussio* fuere nula (*inutiliter*), tampoco corresponde la *actio quod iussu* (Ulp., D.15.4.1.5).

§ 520. B) *Actio exercitoria*. Ésta ocurre cuando el *pater* o el *dominus* ha puesto a su *filius* o a su esclavo al mando de una nave (*magister navis*) y como tal ha realizado negocios relativos a dicho fletamento. Los terceros pueden demandar al *pater* o al *dominus* por el todo de cada obligación (*in solidum*), por la *actio exercitoria* (Gayo, 4.71; Inst., 4.7.2; D.14.1; EP, § 101).

1. El *exercitor* es el empresario, dueño o fletador de la nave, que pone a otro (incluso un libre extraño o un esclavo ajeno) como *magister navis* al frente de

una nave. Se habla de esta decisión como un *praeposere*, y del encargado del negocio como de un *praepositus*. Acá la autorización no es como en el caso de la *actio quod iussu* por una obligación determinada, sino que es genérica respecto de todas las contraídas con motivo de la empresa marítima.

2. Entra en tal concepto todo lo relativo con el o los negocios encargados al *magister navis* (también por la carga, la reparación de la nave, los salarios de los marineros; incluso, si debió tomar dinero en mutuo, siempre y cuando lo haya hecho para emplearlo en el negocio del viaje (Ulp., D.14.1.1.7-9).

3. El *magister navis* debe obrar conforme a las instrucciones recibidas; si las excede el *exercitor* no responde (Ulp., D.14.1.12). Tampoco es responsable por los negocios realizados por los marineros, y no por el *magister*; aunque sí por los delitos cometidos por los marineros, ya que una cosa es la *causa contrahendi* y otra la *causa delinquendi*, puesto que se debe vigilar que no cometan "culpa" o "dolo" (Ulp., D.14.1.2).

§ 521. C) *Actio institoria*. Es un caso análogo al anterior. Tiene lugar contra aquel que ha puesto al frente de una tienda (*taberna*) a su *filius* o a su esclavo (o a un extraño, sea éste esclavo o libre) y se hubiera contraído con el propuesto como tal una obligación referente a dicho negocio. Es llamada así porque aquel que es puesto al frente de una tienda es denominado *institor*. La acción es dada contra el *pater* o el *dominus* por el todo de cada obligación (*in solidum*; Gayo, 4.71; Inst., 4.7.2; D.14.3; EP, § 102).

1. La variedad era muy amplia: así, para administrar un edificio, o para comprar trigo (Ulp., D.14.3.5.1); para prestar dinero a interés (Ulp., D.14.5.2); para vender mercaderías como vendedores ambulantes (Ulp., D.14.5.4; *circitores*); para dirigir un local de apresto o remiendo de ropa (Ulp., D.14.5.4; 5.6); etc. Estas formas —al igual que en el caso de la empresa marítima— eran muy corrientes en Roma, y permiten vislumbrar un verdadero derecho empresario.

2. El empresario sólo responde si la obligación está relacionada con la finalidad para la cual el *institor* fue propuesto (Ulp., D.14.5.11). Así, si se ha puesto a un *institor* para vender cosas, estará obligado en nombre de él por la *actio ex empto* (acción por lo comprado), o si lo ha puesto para comprar, por la *actio ex vendito* (acción por lo vendido); Ulp., D.14.5.12. Igualmente, salvo que se lo hubiese prohibido, si tomó dinero en préstamo, p.ej. para comprar mercaderías o para pagar el alquiler del local (Ulp., D.14.5.13); etc.

3. Tanto en el caso de la *actio exercitoria*, como en el de la *actio institoria*, el empresario podía emplear a un extraño (libre o esclavo ajeno). En estos supuestos, lo que adquirieran los "propuestos" no revertía automáticamente al patrimonio del empresa-

rio, como sucede con el *filius* o el esclavo propio, sino que el que adquiría era el extraño libre o el *dominus* del esclavo ajeno. Pero el empresario podía dirigir contra ellos una acción derivada ya del mandato o de la *negotiorum gestio*. A su vez, el pretor basado en la *fides*, otorga al empresario acciones contra los terceros que se obligaron con el *praepositus* (Ulp., D.14.3.1; Gayo, D.12.2 ss.).

Justiniano otorgó una *actio quasi in iustitia* establecida *ad exemplum* de la *actio in iustitia*. Se trataba del supuesto de aquel que encomendó a otro, no como *institor*, pero sí como agente suyo (*procurator*), la realización de un negocio; así, tomar dinero en mutuo (Pap., D.12.19.3) o la venta de un bien (D.19.1.13.25). Mediante ella se podía ir contra el "dueño del negocio". Estas gestiones realizadas por hombres libres ajenos a la familia, irá ampliando la responsabilidad por terceros, abriendo el camino a la idea de la representación.

§ 522. Dentro de la clase de *actiones adiecticiae qualitatis*, existían otras fórmulas que admiten una responsabilidad limitada por parte del *pater* o del *dominus*. Son éstas la *actio de peculio et de in rem verso* y la *actio tributaria*.

D) *Actio de peculio et de in rem verso*. En realidad es una sola *actio* con dos *condemnationes* alternativas distintas (EP, § 104.2). Para poder comprenderla hay que pensar en la existencia de un *peculium profectivum*. Si el detentador de él ha contraído obligaciones, dado que no se podría ejecutar contra él dichas deudas, el pretor concede esta *actio* contra el *pater* o el *dominus*, quienes deben responder, no siempre por el todo sino hasta el monto del peculio en el momento de la condena (Gayo, 4.72-74a; Ulp., D.15.1.1 pr. y ss.).

Para el cálculo del monto del peculio, hay que deducir los créditos que el *pater* o el *dominus* tuvieran respecto del *filius* o del esclavo (Gayo, 4.73; Inst., 4.7.4c). En cambio, hay que incrementarlo con lo que ellos debieran al *filius* o al esclavo, así como también lo que hubieran contraído del peculio, en perjuicio de los acreedores (Ulp., D.15.1.21.1).

1. Esta acción se refería al *peculium profectivum*. Tratándose del *castrense* o *quasi castrense*, al poseer el *filius* de una capacidad patrimonial, el *filius* puede ser directamente demandado (Meciano, D.49.17.18.5). Si espontáneamente el *pater* la soportare, deberá responder con todo su patrimonio, y no hasta el límite del peculio (Meciano, D. ibid.). En cambio, si responde el *pater* por la *actio de peculio*, si ha retenido el peculio *castrense* (o *quasi castrense*) que ha recibido *ab intestato*.

2. Los "créditos" y "deudas" intrafamiliares no resultan admisibles como obligaciones civiles, pero se las tomaban en cuenta para el cálculo del peculio, estableciéndose así los "descuentos" y "suplementos" ya mencionados (Ulp., D.15.1.41). Ya en el período clásico, van a ser consideradas obligaciones naturales* (Afric., D.12.6.38 pr.).

3. Los acreedores podrán ejercer esta *actio de peculio*, según el orden de las demandas. Esto significa que el *pater* no debe prorratar el monto del peculio entre todos los acreedores. El que lo hace primero cobra todo su crédito siempre y cuando existan fondos. Luego, se deberá pagar al segundo acreedor, y así hasta que se agote el peculio (Gayo, D.15.1.10).

4. Bajo la forma de *actio de peculio* es en principio "perpetua" mientras el *filius* permanezca *in potestate*, pero si muere, o sale de la *potestas* (así, por emancipación del *filius* o manumisión del esclavo), la acción se da solamente dentro del año (*actio annalis*; Ulp., D.15.2.1 pr.1).

5. Cuando los *fili* (no los esclavos) celebran un mutuo en dinero sin la autorización de sus padres, la *actio de peculio* se ve impedida por la *exceptio senatus-consulti Macedoniani*. El s.c. Macedoniano* prohibió los préstamos hechos a los hijos de familia. El pretor, ya denegaba la acción del mutuo (*actio —condictio— certae pecuniae*) o integraba la fórmula con la excepción señalada.

(ii) En el caso de la *condemnatio de in rem verso*, estamos en presencia de que el *filius* o el esclavo han enriquecido al *pater* o *dominus* con bienes obtenidos en el negocio realizado. Así, si el esclavo que había invertido el dinero que pidió en préstamo para pagar a un acreedor del *dominus*; o para refaccionar un edificio ruinoso, o comprar provisiones para la casa del *dominus*, o un fundo u otra cosa necesaria (Inst., 4.7.4). El valor del enriquecimiento en el momento de la condena determina el límite de la responsabilidad del *pater* o del *dominus* (Gayo, 4.72a; Ulp., D.15.3.1.1).

1. Esto es una aplicación del principio del "enriquecimiento sin causa", en virtud del cual nadie se puede enriquecer gratuitamente a costa de otro. El acreedor no puede pedir el total de la obligación, sino hasta el monto que demuestre que ha servido de enriquecimiento: así, tu esclavo pide prestado a Ticio 10 aureos, y emplea 5 para pagar a un acreedor tuyo, y lo restante en cualquier otra cosa; por la forma de *in rem verso* sólo quedas obligado a responder de los 5 empleados en tu beneficio, y de los otros 5 hasta donde alcance el peculio (Inst., 4.7.4).

Como dijimos, la *actio de peculio et de in rem verso* se trata de una sola acción con dos *condemnationes* distintas. Si el *pater* o el *dominus* se hubieran enriquecido quedan obligados a tener que devolver ese monto por la condena de *in rem verso*. El resto

por la condena de *peculio* (Inst., 4.7.4; Jul. Pomp. Ulp., D.15.3.2). La condena de *in rem verso* es perpetua (Ulp., D.15.1.1).

2. Según Justiniano (Inst., 4.7.4) parecería que por beneficio sólo se podría entender lo invertido en algo "necesario". Pero Ulpiano (D.15.3.3.2; D.15.4; D.15.4 pr. y 2) admite que el empleo haya sido "útil", y aun cosas de adorno (pero el acreedor puede sacarlas: Ulp., D.15.3.4). Se afirma como regla general la *actio de in rem verso* "en todos los casos en que el *procurator* tendría la *actio mandati*, o el gestor de negocios la *actio negotiorum gestorum*" (Ulp., D.15.3.2). Justiniano extenderá la acción admitiendo la responsabilidad por la actuación de una persona libre extraña (C.4.26.3, itp., *in fine*).

§ 523. D) *Actio tributaria*. Se trataba acá de un caso muy concreto. Si el *filius* o el esclavo empleasen todo o parte de su peculio en mercaderías, o lo hubiesen invertido en crear una empresa comercial o industrial (*merx peculiaris*), con pleno conocimiento del *pater* o del *dominus*, los acreedores podían pedir al pretor la distribución proporcional de los bienes de dicha inversión del peculio. Este concurso de acreedores podía ser encargado al *pater* o al *dominus*, quien debía pagar a prorrata a todos los acreedores. Si el *pater* o *dominus* tenían algún crédito que cobrar, también podían presentarse como simples acreedores; es decir, no pueden como en la *actio de peculio* descontar directamente dicho crédito (Ulp., D.14.4.1.pr.).

Si los acreedores se quejaban de que el *pater* o el *dominus*, actuando con dolo, los hubiera perjudicado en la distribución a prorrata, entonces el pretor concedía esta *actio tributaria* (de *tribuer* = distribuir) por el monto del perjuicio (Gayo, 4.72; Inst., 4.7.3; D.14.4; EP, § 103).

1. Gayo menciona la *actio tributaria* entre las *actiones adiecticiae qualitatis*. Pero sería una *actio in factum* directa contra el poderhabiente. Si bien se requiere el dolo, no es una acción de dolo, ya que lo que se reclama es la obtención de las cosas (*persecutio rei*), y no la inculpación del agente de él. Por ello es que se ejerce *in perpetuum* contra los herederos (Jul., D.14.4.8).

§ 524. Estas *actiones adiecticiae qualitatis* debían ser ejercidas de manera excluyente. Pero, si es posible demandar por la *actio quod iussu*, o por la *exercitoria* o la *institoria*, nadie dudaría en emplearlas en relación con las otras, puesto que van por el todo de las obligaciones (*in solidum*).

En cambio, en la *actio de peculio et de in rem verso*, había que probar, ya el monto del peculio o el enriquecimiento, y además la responsabilidad quedaba limitada a dichos montos.

La última preferencia debía quedar radicada en la *actio tributaria*, en la cual los acreedores son satisfechos a prorrata (Gayo, 4.74-74a; Inst., 4.7.5).

CAPÍTULO 2
EL MATRIMONIO

§ 525. El matrimonio romano, que es la base de la familia, presenta características que lo diferencian del que existe en el derecho moderno, inspirado en motivos cristianos.

Para los romanos, el matrimonio no es una relación jurídica, sino más bien un *factum*, una situación de hecho (*res facti*), aunque capaz de producir consecuencias jurídicas. De ahí que, sin perjuicio de su notable importancia, no existe una particular regulación jurídica de esta institución por parte de las leyes. Todo lo relativo a la celebración, disolución y protección del matrimonio pertenece fundamentalmente a los *mores* (costumbres), con las consecuencias éticas y sociales que ello implicaba.

1. Esta falta de regulación legislativa, salvo en algunos aspectos particulares en la época de Augusto, y posteriormente en el Derecho romano posclásico cristianizado, tal como se ve finalmente en la legislación justiniana, será una nota primordial del matrimonio en Roma.

2. Lo que nosotros llamamos hoy día "derecho matrimonial" aparecerá muy posteriormente. Será en principio obra de la Iglesia, a través del Derecho canónico, que se desarrollará en la Edad Media toda una regulación jurídica en torno de los requisitos, de la celebración, de los impedimentos y de la disolución, vía nulidad, del matrimonio. Obviamente, esta legislación canónica será tributaria de la doctrina cristiana, basada en los textos evangélicos y neotestamentarios. Surge así la concepción del "matrimonio sacramento", de carácter indisoluble. En la historia posterior, sobre todo después de la Reforma protestante, el matrimonio se irá lentamente laicizando, con el avance cada vez más sostenido de la intervención estatal. Se irá creando toda una legislación tendiente a regular prácticamente todos los aspectos, personales y patrimoniales de la vida matrimonial.

§ 526. I. Definición. Hay dos célebres definiciones de matrimonio en los textos romanos. La primera corresponde a Modestino. *Coniunctio maris et feminae et consortium omnis vitae, divini et humani iuris communicatio* (Unión del macho y de la hembra y consorcio de toda la vida, comunicación del derecho divino y humano; D.23.2.1).

1. En la primera parte, la palabra *coniunctio*, que es la que permite hablar de *coniux* (cónyuge), aparece vinculada con *iugum*, es decir, el instrumento rústico que es el "yugo", el cual permite a dos animales

bueyes, p.ej.— estar unidos a dicho aparato de madera que los liga por el cuello para el *labor agricolus*.

2. La palabra *consortium* es muy ilustrativa. Viene de *sors* (= suerte), ordinariamente la pequeña tablilla de madera que servía para responder a preguntas presentadas a los oráculos y también para tirar "suertes" en la división de tareas de los magistrados. De allí se llega fácilmente a la idea de "decisión de la suerte" o "suerte fijada a cada uno, destino".

De este modo, *consors* (= consorte) es "quien comparte la misma suerte". Cuando marido y mujer se casan arriesgan su *sors* en el futuro. Por eso son "consortes". Así podemos entender la frase de Tácito (Ann., 3.34) que nos habla de los matrimonios como *consortia rerum secundarum adversarumque* (consorcios de las cosas favorables y desfavorables). Y está también dicho del marido que "su cónyuge es socia que comparte sus preocupaciones y sus alegrías" (Ann., 12. 5). Quintiliano configura a la mujer casada —*uxor*— como "aquella mujer que es puesta por el varón en nupcias, y por ello en la sociedad de la vida" (*Demonst.*, 247).

3. Al decir que este *consortium* o *societas* (aquí tomado en un sentido muy lato; no en el del contrato de sociedad) o *coniugium* es "de toda la vida", se está significando que el propósito inicial es la duración vitalicia de la unión matrimonial.

Ciertamente que los romanos admitieron la idea del divorcio. Pero si ello acaece, aparece, no como lo pensado *ab initio*, sino más bien como una eventualidad accidental. A lo que apuntan los romanos es a no admitir las *nuptiae* como una simple unión *ad tempus*, o revocable por alguna imaginada cláusula resolutoria.

4. La feliz frase final, sospechada por algunos de alguna interpolación cristiana, presenta las características propias del matrimonio romano, donde esta unión, que es la más acorde con la naturaleza, significa algo más que lo "humano", puesto que en la unión de sexos y en la procreación, hay *factas* que vinculan lo divino a lo humano. En tal sentido no tendría necesariamente que ver con la posibilidad de la *manus* (y el ingreso de la *uxor* en los *sacra privata*

de la familia del marido), puesto que en la época de Modestino ya la *manus* gozaba de descrédito, así como también el viejo sentido de la religión familiar romana.

La otra definición es la que figura en las Institutas de Justiniano (1.9.1): "Nupcias o matrimonio es la unión del varón y de la mujer (*vir et mulieris coniunctio*) que contiene la costumbre indivisa de la vida" (*individuae vitae consuetudinem continens*).

5. Los bizantinos comienzan hablando de *nuptiae* (palabra que está siempre en plural; el matrimonio legítimo es llamado *iustae nuptiae*). Acá la unión está más referida a la mujer (la que es *nubilis* = casadera; *nupta* = la que está casada; son vocablos que derivan de *nubere* = velarse, por el velo que suele usar la novia). En cambio, *matrimonium* aparece viendo la unión del lado del marido, ya que éste adquiere una *uxor* para su casa (*ducit uxorem* = se lleva una mujer legítima).

6. Igualmente, se reemplaza la expresión *mas et femina* (macho y hembra), por la designación más espiritualizada de *vir et mulier* (varón y mujer). Y con la mayor economía de palabras se refieren a la finalidad de esta *coniunctio*. En la concepción de la "costumbre indivisa de la vida" queda referida la unión de sexos que viven unidos el uno para el otro, así como la idea de la procreación, para el caso de que ello fuere posible.

§ 527. *El carácter monogámico.* El matrimonio romano fue siempre invariablemente monogámico. Una mujer no puede tener dos maridos a la vez, ni un hombre puede tener dos mujeres a la vez (Gayo, 1.63; Inst., 1.10.6).

1. Lo que cuenta. Suetonio (*Caes.*, 52) acerca de que César quiso introducir la poligamia para solucionar el descenso de la natalidad, parece ser un rumor calumnioso. A su vez, el escolástico Sócrates (*Hist. eccl.*, 4.31) habla de una extraña ley atribuida a Valentiniano, provocada, según este autor, por el deseo del Emperador de casarse con la bella Justina, admitiendo la poligamia. De ser cierta la existencia de esta ley causa notable sorpresa, dado que la monogamia fue un principio liminar del Derecho Romano.

a) Sin embargo, no aparece, por lo menos hasta avanzada la época posclásica, el delito de "bigamia". En el derecho moderno y actual, las nuevas nupcias celebradas por un cónyuge subsistiendo el matrimonio anterior, tornaría nulas a las segundas. En cambio, la solución romana no era ésta. Si, p.ej., un hombre casado se volviera a casar de nuevo con otra mujer capaz de contraer nupcias, se interpretaba que el nuevo matrimonio disolvía *ipso facto* el anterior. Se explica esto porque dado el carácter monogámico

del matrimonio, no pueden existir nupcias simultáneas. Por ser el matrimonio una *res facti*, se entendía que la *maritalis affectio* respecto de la primera mujer había cesado, y, por tanto, el primer matrimonio quedaba automáticamente disuelto como una suerte de divorcio (cfr. Javol., D.24.1.64; Marcelo, D.23.2.33; Ulp., D.24.2.11.2).

Si un hombre tenía dos *uxores* al mismo tiempo, provocando incerteza social sobre la situación de hecho (no de derecho porque no se pueden aceptar dos uniones coetáneas), por el Edicto del Pretor era considerado infame (EP, §16; Jul., D.3.2.1; Ulp., D.3.2.13.1 y 4; Valeriano y Galieno: C.9.9.18, año 258; Diocl. y Maxim.: C.5.5.2, año 285).

2. Estas situaciones provocaban problemas de interpretación. Hay un caso famoso citado por Cicerón (*de orat.*, 1.40.183, 1.56.238). Un ciudadano romano, viviendo en España, se había casado con una española. Regresa a Roma dejando a su mujer encinta, y allí contrae nuevo matrimonio con una romana sin haber notificado de ello a su primera mujer. De la segunda tiene un hijo. Luego muere sin testamento. El problema que se plantea es cuál de los dos matrimonios es válido, y si debe heredar el hijo de la española o el de la romana.

La cuestión pasa por el valor que se dé a la falta de noticia de lo sucedido a la mujer española, lo cual para esta época pasaba por ser una costumbre de hecho y no por ninguna otra disposición jurídica. Si se interpreta que el aviso no era un requisito esencial, el segundo matrimonio es válido y ocasiona *ipso facto* la disolución del primero. En cambio, si se lo considera esencial, el segundo matrimonio sería un mero concubinato. En el primer caso, los dos hijos serían herederos; en el segundo, sólo el hijo habido con la española. Pero lo notable es que Cicerón, en momento alguno piensa en la bigamia. La segunda unión o era matrimonio o concubinato.

2. Por disposición de Augusto se ordena una forma especial para el divorcio (libelo llevado por un liberto y presentado a la mujer ante siete testigos; Paulo, D.24.2.9). Pero esta forma tenía el sentido de poder acusar a la mujer de adulterio, evitando que el marido cayera en un encubrimiento por "lenocinio", abriéndole la vía para entablar la acusación de adulterio (Ulp., D.48.5.2.8; Tryf., D.4.4.37.1; Ulp., D.48.5.4.1).

Pero aun así, si a una mujer casada no se le había enviado el libelo de repudio, y un tercero se casara con ella, no incurría en adulterio, puesto que no obró con dolo. En efecto, a él no le consta que la mujer hubiese sido repudiada por adulterio, y casándose con ella quedaba disuelto el primer matrimonio (Jul.-Gayo, D.48.5.43).

b) En cambio, en el derecho posclásico se sienta el criterio de que el segundo matrimonio

no invalida automáticamente el primero. Se considera que el consentimiento inicial daba origen al matrimonio que sólo podía ser disuelto por un divorcio formal (Theod. y Valentiniano, C.5.17.8 pr.). Siendo así, se abre la posibilidad del delito de bigamia, por cuanto el primer matrimonio continuaba, hasta pronunciado el divorcio, como válido. Bajo Justiniano podía ser castigado incluso con la pena de muerte (Theoph., 1.10.6 y 7).

§ 528. II. *Esponsales.* Los esponsales (*sponsalia*) son definidos por Florentino como *mentio et repromissio nuptiarum futurarum* (mención y promesas de futuras nupcias; D.23.1.1). Esto obedecía a la práctica generalizada de comprometer a las hijas en un futuro casamiento. De ahí que solía hacerse directamente por los *pater* (del *filius* y de la *filia*); o también entre el *pater* de la mujer y el joven que deseaba casarse con ella.

1. Esto, al comienzo, solía realizarse mediante promesas formales, utilizándose la figura de la *sponsio*. Cada una de las partes hacía la suya propia, y es de ahí que el acta recibe el nombre de *sponsalia*. Las partes recibían el nombre de *sponsus* (esposo) y *sponsa* (esposa); (Ulp., D.23.1.2; Florent., D.23.1.9). Hay que aclarar que la designación de esposos son para los novios comprometidos, y no para los casados, que son llamados *vir* y *uxor*.

2. La utilización actual de "esposos" para los que celebran el matrimonio arranca del Derecho Canónico posterior, que admite las bodas como "esponsales de presente" (a diferencia de los de "futuro").

a) En el derecho antiguo, incluso en la época republicana, se admitía una *actio de sponsu*, para el caso de que sin causa justificada una de las partes no se quisiera casar. Por ella se acudía a la justicia, no para obligar a la otra parte a celebrar las nupcias —el consentimiento debe ser libre—, sino para reclamar una suma de dinero por el incumplimiento. Al parecer, esto era de aplicación en los pueblos del *Latium* (Servio Sulpicio, en Aulo Gellio, 4.4.2; Varro, *de ling. lat.*, 6.70).

b) Cuando llegamos al derecho clásico, no obstante que la denominación de *sponsalia* subsiste, su realización no lo era por medio de las *sponsiones*, bastando un mero convenio formal entre las partes, sea que éstas estén presentes o aun entre ausentes (p.ej., por medio de un nuncio; Ulp., D.23.1.4; id.). Se reafirma más aún la idea de que, como los matrimonios deben contar con un consentimiento libre, no existe ninguna acción compulsoria para que las nupcias se realicen. A su vez, la vieja acción por una indemnización ha desaparecido ya en la

época de Cicerón, y si se hubiera estipulado una suma de dinero como cláusula penal, se consideraba que ésta era nula por ser *contra mores* (Paulo, D.45.1.134 pr.). A su vez, cualquiera de las partes podía desligarse de la promesa con una simple declaración (Gayo, D.24.2.2.2).

1. Parecen también clásicos los textos según los cuales, a pesar de que los *sponsalia* fueran celebrados por los *pater*, era necesario el consentimiento por parte de los futuros contrayentes (Jul., D.23.1.11). El *filius* podía disentir respecto de la decisión de su *pater* sin necesidad de expresar ninguna causa (Paulo, D.23.1.13). En cambio, respecto de la *filia*, debía aducir que su *pater* le había elegido un esposo indigno por sus costumbres, o que se trataba de una persona torpe (Ulp., D.23.1.12).

A su vez, si el tutor enviaba un mensajero para extinguir los *sponsalia* de la pupila, se necesitaba la voluntad concordante de ésta (Ulp., D.23.1.12).

2. Si bien es difícil establecer la autenticidad de los textos clásicos por las frecuentes interpolaciones, ya en esta época los *sponsalia* producían ciertos efectos secundarios: (i) un cierto estado de parentesco, que abarcaba no sólo el de los esposos entre sí, sino también afectaba al parentesco por afinidad (esposa y esposo con sus futuros suegros; Gayo, D.22.5.5); (ii) si la esposa hubiese constituido dote, el futuro marido tenía derecho a conservarla mientras se mantuvieran los *sponsalia* (Ulp., D.22.5.17.1); (iii) el que hubiere contraído promesa de matrimonio, no podía, sin romperla, celebrar otro con otra persona, bajo pena de infamia (Ulp., D.3.2.13.1-4); un hombre casado no puede contraer esponsales válidos (Valeriano, C.5.3.5; año 258).

c) En el derecho posclásico, sobre todo a partir de Constantino, por influencia oriental, y también cristiana, se admite el uso de las "arras" (*arrae sponsaliciae*). Consistían éstas, por lo general, en sumas de dinero, o también de otros presentes (p.ej., un anillo nupcial), que una de las partes o ambas recíprocamente se entregaban. Aquel que rehúsa contraer matrimonio perdía las arras que él ha entregado, debiendo restituir las que ha recibido, pero ya por el *quadruplum* (época prejustiniana; CTh.3.5.11; año 380), y a partir de Justiniano, por el *duplum* (C.5.1.5; itp.; Paulo, D.25.2.38 pr., itp. *in fine*).

1. La introducción de las *arrae* proviene del derecho semítico (ley de Hammurabi, Talmud, Biblia). Se consideraba que era el precio entregado por la compra de la prometida. Este principio habría sido sostenido por la Iglesia para favorecer la fuerza vinculativa de las arras. Pero indudablemente afecta la libre decisión de los contrayentes, por las consecuencias económicas que significaba. Es por esa razón que

luego, en el derecho moderno (caso de nuestro C.C.), están prohibidas, siendo de ningún valor.

2. Para el caso de que se tratara de un *minor*, la devolución era por el *simpulum* (C.5.1.5; *itp.*). La fuerza vinculativa de los *sponsalia* se perdía luego de dos años, si pudiendo hacersa el matrimonio, éste no se celebraba (C.5.1.2; año 332). La existencia de una cláusula penal, continuó siendo rechazada, incluso por Justiniano (C.1d., *in fine*), pero con posterioridad fue admitida por el emperador León el Sabio (Nov.18).

3. Además, Constantino, por dos constituciones (C.5.3.15; año 319; y C.1d.16; año 336), entiende que los regalos efectuados por las dos partes quedaban supeditados al matrimonio posterior. Si éste no se realiza, se debían devolver, pero quien se ha negado injustificadamente a casarse, carece de acción para la devolución. En el caso de que la esposa no pudiera casarse por muerte de su esposo, y siempre que haya mediado el beso de los esposales (*osculo interveniente*), sólo estaba obligada a restituir la mitad de dichos regalos o donaciones (*sponsalicia largitas*).

Ya desde la época posclásica, los *sponsalia* continuaban produciendo ciertos efectos secundarios que los asimilaban más aún al matrimonio. Así, (i) la infidelidad de la esposa es asimilada al adulterio (Ulp., D.48.5.13.8); (ii) el vínculo por afinidad entre los parientes próximos y entre los propios esposos es impedimento para contraer matrimonio (Inst., 1.10.9); (iii) el esposo puede accionar por la *actio iniuriarum* por cualquier ofensa dirigida contra la esposa (Ulp., D.47.10.15.24); (iv) la acción para reclamar la dote entregada por la esposa, queda asimilada a la *actio de dote* (Ulp., D.42.6.17.1 *itp.*).

§ 529. III. *Requisitos para contraer matrimonio*. Para celebrar las *iustae nuptiae* (llamadas también *iustum* o *legitimum matrimonium*), era necesario cumplimentar determinados requisitos:

A) *Capacidad natural*. Ésta se considera existente con la *pubertas*, que está significada por la *potestas generandi*. La mujer debía ser núbil, es decir, contar por lo menos con 12 años de edad; el varón debía, según el temperamento que prevaleció, tener 14 años.

1. Respecto del problema habido entre las escuelas sobre cuándo se alcanzaba la pubertad para los varones, v. *supra*, § 187.A.b.

B) *Conubium*. Consiste en el derecho de contraer matrimonio legítimo. Éste debía existir recíprocamente entre ambos contrayentes (Ulp., 5.2.7).

1. Según Ulpiano (5.3), el *conubium* es "la facultad (*facultas*) de tomar *uxor* de acuerdo con el *ius*".

En un comienzo sólo lo tenían los patricios, luego se le concedió a los plebeyos (*lex Canuleia*; año 445 a.C.).

El principio es que "los ciudadanos romanos tienen el *conubium* con ciudadanas romanas; en cambio, con los latinos y los peregrinos, si les fuera concedido", es decir, debía haber un otorgamiento expreso del *conubium* (Ulp., 5.4; Gayo, 1.56-57). También se les concedió a los veteranos (Gayo, 1.57). Ningún *conubium* existe con los esclavos (Ulp., 5.5).

Con el otorgamiento de la ciudadanía romana a todos los habitantes libres del Imperio por la *constitutio Antoniniana* (Caracalla, año 212 d.C.), esto pierde importancia. Sólo los esclavos (Ulp., 5.4-5), los bárbaros y ciertos condenados carecerán del derecho de acceder al matrimonio legítimo.

C) *Consentimiento de los contrayentes*. Aunque no sea considerado un contrato (como la *societas*), se necesita el consentimiento (*consensus*) de quienes lo celebran. Esto tendía a subrayar el carácter espiritualizado del matrimonio en oposición a la idea de que para existir él era necesario que se hubiera realmente consumado por medio de la unión sexual. Esto se expresa por la regla de *nuptias non concubitus, sed consensus facit* (Es el consentimiento, y no la unión sexual, lo que hace las nupcias; Ulp., D.35.1.15 = D.50.17.30); y también *non coitus matrimonium facit, sed maritalis affectio* (no es la unión sexual la que hace el matrimonio, sino el afecto marital; Ulp., D.24.1.32.13). El *consensus* debe ser dado por las partes con total libertad, sin violencia ni coacción (Ter. Clemens, D.23.2.21; C.5.4.14).

1. Se puede hablar de un consentimiento "inicial" para que se produzca el matrimonio. Pero como éste está referido a una comunidad de vida, era también necesaria la voluntad recíproca de mantenerla (*maritalis affectio*). De ahí que cuando ésta no perdura puede ocasionar el divorcio. Pero hasta tanto se manifieste esta voluntad de disolver el vínculo, el matrimonio continúa.

2. Los enfermos mentales no pueden casarse (caso del *furius* o de la *furiosa*; Paulo, 2.19.7), puesto que no pueden expresar el consentimiento. Pero esto se refiere al consentimiento inicial. Si luego de casados uno de los cónyuges se vuelve demente, si el otro mantiene su voluntad de seguir unido, el matrimonio continúa.

3. Tampoco se pueden casar los castrados (Ulp., 23.3.39.1 *itp.*). La denominación genérica de *spado* se refiere al *incapax generandi*. En los textos se diferencia entre el incapaz de engendrar natural, o que no puede engendrar fácilmente (*qui generare facile non possit*; Ulp., D.28.2.6 pr. y 1), que puede contraer matrimonio, y aquel a quien se lo ha castrado artificialmente, quien no se puede casar.

4. Para los romanos el matrimonio nunca fue considerado un contrato. Esta idea nace con los canonistas, para subrayar más aún el papel del "consentimiento". Por ello se hablará de "contrato-sacramento". El derecho moderno continuará esta línea, aunque con una significación laica progresivamente acentuada.

D) *Consentimiento de los padres*. Cuando los contrayentes son *alieni iuris*, aparte de su consentimiento, se requiere el de sus *patres* (Paulo, D.23.2.2).

1. En la época primitiva son los *patres* quienes determinaban el casamiento de los hijos e hijas. Pero luego se abre paso la idea del consentimiento necesario por parte de éstos. En la época de Augusto (*lex Iulia de maritandis ordinibus*; año 18 a.C.) se establece que en caso de negativa injustificada por parte del *pater*, la *filia* podía por un procedimiento *extra ordinem*, compelerlo a dar su consentimiento. En cambio, esta posibilidad no la tiene el *filius*. La razón de ello está dada porque, por las reglas de la agnación, los nietos que tendría por el casamiento de su hijo serán "herederos suyos" (*sui heredes*), y en Roma rige la regla de que nadie puede tener herederos contra su voluntad (Inst., 1.11.7).

En la época posclásica, por una constitución de Alejandro Severo y Antonino, se terminará por admitir el derecho a reclamar por el no consentimiento injustificado tanto al *filius* como a la *filia* (Marciano, D.23.2.19).

2. Es debido a esto que el consentimiento paterno respecto del *filius*, aun siendo militar, debe ser dado en forma expresa (Pap., D. 23.2.35), mientras que en el caso de la *filia* basta el no disenso por parte de su *pater*, es decir que guardando silencio respecto de tal circunstancia, se considera como dado (Paulo, D.23.1.7.1).

También en el caso del nieto que se quiere casar se necesita el consentimiento del abuelo (*pater*), pero también del hijo (padre del nieto) que deberá considerar a los descendientes habidos de la unión como herederos; en cambio, respecto de la nieta, basta el consentimiento (no disenso) del abuelo (Paulo, D.23.2.16.1).

3. Si el *pater* era un demente, se discutió respecto del *filius* (no de la *filia*, que podía casarse), pero Justiniano resolvió que en este caso podía contraer nupcias sin la intervención del *pater* (Inst., 1.10 pr.), debiendo obtener permiso del *praefectus urbi* o del gobernador de provincia, tras haber oído al *curator* del *pater* y familiares (C.5.4.25).

Si el *pater* está prisionero de guerra, no es necesario su consentimiento (Tryfon., D.49.15.12.3), pero Justiniano lo subordinó a un plazo de tres años (Ulp., D.23.2.9.1; Jul., D.1d.11 *itps.*).

4. El consentimiento del *pater* debe preceder al matrimonio (Inst., 1.10 pr.). Dado con posterioridad

se consideraba que no tenía efectos retroactivos, sino sólo efectos para el futuro. Sería un caso análogo a las nupcias de una mujer impúber, que sería válido a partir de que cumpla los 12 años (Pomp., D.23.2.4).

5. Finalmente, los hijos emancipados no necesitan del consentimiento paterno. Sin embargo, en el derecho posclásico, por constituciones de Valens y Valentiniano, y luego de Honorio y Teodosio, se le exigió respecto de la mujer menor de 25 años, aun emancipada. Si el *pater* había muerto, se debía recurrir al consentimiento de la madre y parientes próximos (C.5.4.18 y 20).

§ 530. IV. *Celebración del matrimonio*. Fuera del caso de la *confarreatio*, fuertemente vinculada con ritos religiosos, la celebración del matrimonio romano era un acto regulado por los *mores*, y no por el *ius*. Jurídicamente bastaba con el mero consentimiento, probado por amigos o vecinos (C.5.4.9). Se solía redactar un documento (*nuptiales tabulae*), y también otro sobre la regulación de la dote (*instrumenta dotaria*).

Sin embargo, dentro de la *festivitas nuptiarum*, que tenía un carácter netamente social, se considerará como requisito probatorio, aunque no esencial, de que las nupcias han ocurrido, la conducción de la novia a la casa del marido (*deductio in domo mariti*).

1. Los detalles nupciales son interesantes, ya que muchos de ellos permanecerán en la época cristiana y seguirán perviviendo en Occidente.

En la víspera, la novia preparaba sus atuendos: una túnica blanca que le llega hasta los pies (*tunica recta*), ceñida al talle con un cinturón de lana atado con un nudo especial (*nodus Hercules*), que será luego desatado por su marido cuando estén a solas. Cubría su cabeza con una cofia anaranjada. Y así se acostaba, aguardando el día nupcial.

El preparado de su cabello era muy meticuloso: se lo protegía con seis rodets postizos, entrelazados con cintas, que las Vestales llevaban siempre. Sobre su cabeza se ponía un velo de color delicado, anaranjado y reluciente —de aquí su nombre de *flammeum nuptiale*, como una llama—. Éste le cubría públicamente la parte superior de su rostro. Sobre el velo, solía usar una corona, que era un trenzado de mejorana y verbena, y en la época de César y Augusto de azahares, recogida por la misma novia. Del hecho de estar velada con el *flammeum*, se deriva *nubere* (velar) y *nupta* (novia que se va a casar).

2. Ya arreglada, rodeada de los suyos espera a su prometido que venía con familiares y amigos. Todos se trasladan al *atrium*, donde el padre de la novia ofrece un sacrificio para tomar los auspicios; éstos debían ser favorables, lo cual era señal de que los dioses aprobaban la unión, y comenzaban los ritos nupciales.

Se sellaban los instrumentos matrimoniales (*lobulae nuptiales*) que no eran jurídicamente obligatorios, en presencia de 10 testigos. Luego de ello, una matrona (*pronuba*) —que obraba como madrina, que casada, o viuda, no debía haber conocido más que un marido (*univira*), procedía a tomar las manos derechos de los novios apoyando la una en la otra (*dexterarum coniunctio*). Los presentes celebraban la unión clamando *Felicitate!* (Que la felicidad sea con vosotros). Había un nuevo sacrificio ofrecido por los novios y el regocijo culminaba con un banquete que se extendía hasta la noche.

3. En un momento determinado, todos comienzan a levantarse de sus triclinios. La novia, públicamente se refugia en brazos de su madre o de la *pronuba*, procediendo el novio a arrancarla del seno materno. Se organiza entonces el cortejo nupcial. El novio se adelanta para recibir a la novia en la puerta de su casa. La novia va acompañada por su madrina (*pronuba*), y la comitiva que la traslada demuestra su alegría en forma bullanguera y con picantes dichos y canciones. También se unían los niños, sobre quienes se arrojaban nueces, símbolo de fecundidad.

Al llegar a la casa, se adelantan tres amigos del novio. Uno de ellos, el padrino (*pronobus*) esgrime la antorcha nupcial. Otras tres amigas de la novia, la siguen llevando el huso y la rueca, emblemas de su laboriosidad. El novio ofrece a la novia una redoma de aceite con el cual ungía los goznes de la puerta, y un copo de lana, símbolo del trabajo de las antiguas *uxores*.

Antes de entrar, el novio le pregunta "¿Quién eres tú?". Y ella respondía *Ubi tu Gaius, ego Gaia* ("Donde tú eres Gayo, yo seré Gaia"), simple forma de expresar la comunidad de vida del matrimonio, confundiendo sus voluntades y sus vidas. Entonces, los amigos del novio proceden a levantarla e introducirla en la casa sin pisar el umbral, dedicado al dios *Ianus*. El marido le ofrece el agua y el fuego. Y luego de pronunciadas las preces a los dioses Lares, la *pronuba* la conduce hasta el lecho nupcial, donde la espera su marido, mientras que los concurrentes discretamente se van retirando.

4. La formalidad de la *deductio in domo mariti* por parte de la mujer aparece remarcada por Pomponio (D.23.2.5), de tal modo que, aun escindida de los festejos de la boda, se permite al novio ausente casarse por carta o por nuncio, siendo éste el encargado de llevar a la mujer a la casa del marido. En cambio, la mujer no podía casarse estando ella ausente "porque es menester que la conducción sea a la casa del marido, no a la de la mujer, como al domicilio conyugal".

Un caso curioso al respecto es el que menciona Cinnia (Ulp., D.23.2.6) —convertido en cuanto a su lectura—, pero que a la luz de lo ya afirmado por Pomponio (D.23.2.5), debe entenderse así: si un ausente recibió a su *uxor* en su casa (llevada por otro), y después de volver de cenar el marido falleció junto

al Tiber, "ha de ser llorado por su mujer", es decir que estaba efectivamente casado.

De este modo, la *deductio in domo*, aunque usual en las nupcias, tenía especial importancia cuando el marido que se casaba estaba ausente; como modo de expresar en forma indudable el consentimiento, que sigue siendo siempre el requisito fundamental de las nupcias.

§ 531. V. *Impedimentos*. Los romanos no contaron con un sistema de impedimentos para contraer matrimonio, aunque sí reconocieron ciertas prohibiciones para poder contraer nupcias.

1. La teoría sistematizada de los impedimentos será obra del Derecho Canónico posterior, y más tarde del derecho estatal de cada nación. Aprovechando la terminología actual, podemos hablar de impedimentos "absolutos", esto es, cuando alguien de un sexo no se puede casar con alguien del otro sexo (así, por estar ya casado; Inst., 1.10.6; Gayo, 1.63, *in fine*) o el haber celebrado voto de castidad, como las vestales en la época pagana, o en la Roma cristiana, por el orden sagrado (C.1.3.52.14; id., 147; Nov.5.8; 6.6, *in fine*) o de impedimentos "relativos", cuando nos impiden casarnos con una o varias personas del otro sexo; p.ej., por razón de parentesco.

a) Vinculadas con reglas que nacen del *fas* y condenan el incesto, hay prohibición de contraer nupcias con los parientes más cercanos. Así, en la línea recta, la prohibición abarca hasta el infinito (*usque ad infinitum*; Gayo, D.23.2.53; id., 68; Ulp., 5.6; Inst., 1.10.1; C.5.4.17). En la línea colateral, la prohibición se extendió hasta el tercer grado (Gayo, 1.61; Inst., 1.10.3); es decir, no se pueden casar los hermanos ni el tío o la tía con la sobrina o sobrino.

1. Para el cómputo del parentesco v. *supra*, § 499.3.

2. Según cuentan Suetonio (Claud., 26.3) y Tácito (Ann., 12.5 ss.), el emperador Claudio, debido a la mala suerte corrida en sus cuatro matrimonios anteriores, juró ante los pretorianos permanecer célibe. Pero seducido por Agripina, hija de su hermano Germánico, sobornó a los senadores, quienes en la primera sesión lo incitaron a casarse con ella bajo pretexto de que dicha unión era esencial para el Imperio. Esto provocó un s.c., válido también para los otros ciudadanos.

La arbitrariedad de él permitía que el tío se casara con la sobrina (era el caso de Claudio), pero se seguía manteniendo la prohibición de nupcias de la tía con el sobrino (Gayo, 1.62). El ejemplo suyo fue sólo seguido, según Suetonio, por un liberto y un centurón. Por una constitución de Constantino y Constante, del año 342, esta permisón fue abolida (C.Th.3.12.1).

2. Por influencia cristiana, a instigación del obispo San Ambrosio, se prohibió el matrimonio entre primos (C.Th.3.12.1). Pero luego, esta prohibición fue levantada, según lo demuestra una constitución de Arcadio y Honorio (C.5.4.19), lo cual será seguido por Justiniano (Inst., 1.10.4).

b) Los hijos adoptivos no se pueden casar entre sí ni tampoco con los otros hijos *in potestate*. Así, si una mujer ha llegado a ser hermana tuya por adopción, no te puedes casar con ella. Pero sí lo puedes hacer si el vínculo adoptivo se disuelve por la emancipación.

Igualmente, si alguno quiere adoptar a su yerno, debe antes emancipar a la hija; y si quiere adoptar a su nuera, debe primero emancipar a su hijo (Gayo, 1.61; Inst., 1.10.2); pues en ambos casos, estando *in potestate*, son hermanos.

c) El vínculo de parentesco por "afinidad" (*adfinitas*), es decir, el que une a un cónyuge con los parientes inmediatos del otro en la línea recta, también impide el matrimonio. Así, entre suegro y nuera, entre suegra y yerno; entre madrastra e hijastro; y entre padrastro e hijastra (Gayo, 1.63; Inst., 1.10.5-7).

Luego, en el Bajo Imperio, la afinidad se extiende también a los cuñados, o sea, entre el cónyuge y los hermanos del otro cónyuge. La primera cita corresponde a Constantino y Constante (C.Th.3.12.2; año 339), luego confirmada por textos posteriores que figuran en el Código de Justiniano (C.5.5.5, año 393; C.5.5.9, año 475).

1. Este impedimento rige una vez disuelto el matrimonio, puesto que mientras éste permanezca, es por otra razón que no se pueden casar los afines, puesto que una mujer no puede estar casada con dos maridos, ni un varón con dos mujeres (Gayo, 1.63; Inst., 1.10.5-7). La prohibición abarca tanto al supuesto de que el matrimonio se disuelva por muerte, pero también por divorcio. El motivo está señalado por estar consideradas "nupcias nefastas" (*nefas* = contrarias al *fas*; Modest., D.38.10.4.7; Paulo, D.23.2.14.4; Pap., D.23.2.15; id., D.12.7.5.1; Ulp., 5.6).

2. También se extendió la "afinidad" más allá del matrimonio válido, a los esposales, al *contubernium* y al concubinato (cf. los textos itps. de D.23.2.14.4; id., 12.1-2; id., 14.2-3; Inst., 1.10.10).

3. Igualmente, Justiniano habla de la prohibición de nupcias por parentesco espiritual, que comprende el caso del padrino o la madrina, con su ahijada o ahijado (C.5.4.26.2).

D) Fuera de estos casos de impedimentos matrimoniales por razón de parentesco, existieron otras formas impeditivas de las nupcias:

(i) Por un s.c. de la época de Marco Aurelio y de Cómodo (segunda mitad del siglo II), se dispuso que el tutor (o sus descendientes o as-

cendientes) no podían contraer matrimonio con su pupila, hasta que se hayan rendido las cuentas de la tutela (Paulo, D.23.2.59 ss.; Tryfon., D.23.2.67.2-3).

1. La razón está dada en que el tutor no se aproveche de las nupcias para no rendir cuentas, encubriendo cualquier acto perjudicial desde el punto de vista patrimonial (Calist., D.23.2.64.1). En el derecho posclásico la prohibición se extiende también al curador (Paulo, D.14.36).

2. Se daba una excepción cuando el padre de la pupila se la hubiese prometido como *uxor* al tutor, ya dándosele por los *sponsalia*, o habiéndolo declarado en un testamento (Paulo, D.23.2.36; id., 66 pr.).

3. El impedimento duraba mientras existiese la tutela o la curatela y no se hubiesen rendido cuentas de ella, o si se trataba del curador de una mujer hasta que ésta cumpliera los 25 años y ya no fuere posible la *restitutio in integrum* (Paulo, D.23.2.66; Tryfon., D.23.2.67.3-4).

(ii) Por mandatos imperiales se prohíbe el matrimonio del gobernador de provincia con una mujer nacida o domiciliada en el territorio en que ejerce su cargo (Paulo, D.23.2.38 pr.).

1. La razón de este impedimento es de índole política, a fin de evitar que los gobernadores, ligados por el vínculo matrimonial, favorecieran determinados intereses vinculados a la familia de su mujer. Pero, cesado el cargo (*post depositum officium*) se considera válidas las nupcias ya celebradas, si es que se mantiene la *affectio maritalis* (Paulo, D.23.2.65.1). Podía también celebrar esposales para casarse después de haber concluido su cargo (Paulo, D.14.38 pr.).

2. El impedimento afecta no sólo al gobernador, sino a su hijo (Marciano, D.23.2.57), pero no a su hija (Paulo, D.14.38.2).

(iii) Con el fin de mantener la disciplina militar, aunque el tema es bastante oscuro, los primeros emperadores habrían prohibido las nupcias de los soldados romanos (Dion Cassio, 60.64; Tácito, Ann., 14.27). A partir de Claudio, aun considerándola ilegítima, es tolerada, pudiéndose regularizar los efectos cuando se los licenciaba como veteranos, por un diploma militar. Ya hacia fines del siglo II, esta prohibición no existe más (Paulo, D.23.2.65 pr.).

(iv) La mujer viuda, durante el período clásico, no podía contraer nupcias antes de haber transcurrido 10 meses de la muerte de su marido. Sin embargo, el matrimonio ocurrido pese a la prohibición era válido, aunque la mujer quedaba afectada por la nota pretoria de infamia (Jul., D.3.2.1). En el derecho posclásico, el período se extiende a un año, aplicándose no sólo a

la viuda, sino también a la divorciada (C.5.9.2; C.5.17.8.4; id. 9).

1. El fundamento consiste en tratar de evitar dudas respecto de los hijos póstumos nacidos de viudas. Por eso, el plazo coincide en principio con el plazo máximo de concepción para atribuir la paternidad al marido fallecido. La prohibición cesa si la mujer da a luz antes de concluido dicho parto (Ulp., D.3.2.11.1-2).

§ 332. *Leyes dictadas por Octavio Augusto.* Con evidentes propósitos demográficos, así como también para corregir la corrupción de las costumbres, el emperador Octavio Augusto dictó la *lex Iulia de maritandis ordinibus* (año 18 a.C.) y la *lex Papia-Popaea* (año 9 a.C.), ambas luego conocidas como una unidad (*lex Iulia et Papia*). La legislación se completa con la *lex Iulia de adulteriis* (año 18 a.C.).

a) Conforme a este corpus legislativo, surgen ciertas prohibiciones de matrimonio. Así, a los ciudadanos ingenuos se les prohíbe casarse con mujeres de mala fama (prostitutas, alcahuetas, cómicas, etc.). Igualmente a los senadores se les prohíbe casarse con libertas. Los matrimonios contraídos pese a esta prohibición no son nulos, pero a los efectos de estas leyes, se los considera como no celebrados. Por un s.c. de la época de Marco Aurelio y Cómodo (segunda mitad del siglo II d.C.), se los declara nulos (Paulo, D.23.2.16 pr.).

b) Por otro lado, se establece la obligación de contraer matrimonio para los hombres mayores de 25 años y menores de 60 y para las mujeres comprendidas entre los 20 y los 50 años. Esto regía incluso para los viudos y divorciados, que debían casarse inmediatamente, mientras que las viudas y las divorciadas tuvieron un plazo, que se extendió a 18 meses y dos años, respectivamente.

Quedaban exentos de estas obligaciones los hombres y mujeres que hubieren procreado por lo menos tres hijos legítimos (*ius liberorum*); a los libertos y libertas, se les exige cuatro hijos (Gayo, 1.194; 3.44; Ulp., 16.1; Paulo, 4.9.1 ss.).

c) Además, se sancionaba a los solteros que no se casaban (*caelibes*) y a los casados que no tenían hijos (*orbi*). Los primeros no podían adquirir nada a título hereditario, mientras que los segundos; sólo la mitad. Lo que les hubiera correspondido era denominado *caducum*, y se adjudicaba a los demás herederos testamentarios o legatarios, que tanguen por lo menos un hijo. A defecto de éstos, se atribuyen los *bona caduca* al *aprarium*, y más tarde (Caracalla) al fisco.

Estas leyes augusteas no gozaron de simpatía en Roma. Fueron luego progresivamente suprimidas, a partir del siglo IV d.C. El motivo principal fue, a partir del Cristianismo, que sus principios favorecían el celibato religioso y desaconsejaban las segundas nupcias.

§ 333. *Los impedimentos en el derecho clásico.* Debido sobre todo a la influencia del Cristianismo, se van estableciendo nuevas prohibiciones o modificando las anteriores.

a) Justiniano prohíbe el matrimonio entre el rapto y la raptada (C.9.13.1).

b) El mismo emperador prohíbe las nupcias entre un hombre y una doncella o viuda consagrada al Señor, o tomar mujer a los sacerdotes, diáconos y subdiáconos. El matrimonio celebrado con anterioridad a la consagración subsiste, pero el celebrado con posterioridad, produce la pérdida de la función sagrada (C.1.3.43(44)).

c) El adúltero o adúltera podrá casarse, después de la muerte de su cónyuge, pero no con su cómplice en el adulterio (C.9.9.9).

d) También se prohíben las nupcias entre cristianos y judíos (CTh.3.7.2; C.1.9.6).

e) Importante es también lo relativo a las segundas nupcias. Según las leyes caducarias augusteas eran obligatorias. Pero, por influencia cristiana serán miradas de manera desfavorable, por lo que se tomaron medidas para proteger a los hijos del primer matrimonio.

Así, por un lado, todo aquello que hubiere obtenido el cónyuge binubo del otro, a título lucrativo, ya sea por donación nupcial, dote, o por vía hereditaria (*lucre nuptialia*), pasaba directamente a los hijos del primer matrimonio, reservándose el cónyuge binubo el mero usufructo.

Además, el binubo no puede dejar a su segundo cónyuge, que era la madrastra o el padrastro de sus hijos una parte superior a la que recibe el menos favorecido entre los hijos del primer matrimonio; el excedente se reparte entre los hijos del primer matrimonio (C.5.9.6 pr. y 4; id., 9; Nov. 22.27).

Si el cónyuge binubo enajenara los *lucre nuptialia*, el negocio es nulo, como también las enajenaciones verificadas con anterioridad al segundo matrimonio (Nov. 2.2; Nov. 22.26).

f) La unión realizada a pesar de la existencia de un impedimento es directamente nula: "no debe verse en ella ni marido ni mujer, ni nupcias, ni matrimonio, ni dote"; por tanto, los hijos son espurios (Inst., 1.10.12).

Por una constitución de Valentiniano, Theodosio y Arcadio, los bienes dotes o productos de una donación nupcial son reivindicados por el fisco (C.5.5.4).

Sin embargo, si una mujer hubiera por error creído que su matrimonio era válido (caso del actual "matrimonio putativo"), se le admitieron en algunos casos efectos. Así, la que se casó con su tío ignorando esta circunstancia, y estuvo 40 años viviendo en matrimonio y teniendo hijos, se consideró que éstos eran legítimos (Marciano, D.23.2.57.1). A su vez, los hijos de una mujer libre que se casó por error con un esclavo, si bien no son legítimos, se los considera nacidos libres (*spurii ingenui*), pudiendo además reclamar sus bienes; C.5.18.3.

Pero, según la constitución ya citada (C.5.54), los cónyuges que no quieren perder sus bienes y han celebrado el matrimonio prohibido por error, deben separarse desde el mismo momento en que conozcan el vicio.

EFFECTOS DEL MATRIMONIO

I. Efectos personales.

§ 334. El matrimonio produce determinados efectos tanto entre los cónyuges, como respecto de los hijos:

A) *Efectos entre los cónyuges.* Acá hay que distinguir si el matrimonio está acompañado o no de la *manus*.

a) Si el matrimonio es *cum manu* la *uxor* entra en la familia del marido como agnada. Es, por tanto, una *alieni iuris*, al igual que sus hijos, que a los efectos del parentesco serán sus hermanos ya que ella misma ocupa el lugar de hija (*in loco filiae*). Y si su marido es también *alieni iuris*, por estar bajo la potestad de su *pater*, será considerada nieta de éste. Carece de independencia patrimonial al igual que sus hijos. Pero tiene vocación hereditaria, ya que es *heres sua*.

b) Si el matrimonio es *sine manu*, lo cual será la situación común en la época clásica, sigue siendo agnada de su primitiva familia. Si vive su *pater* continúa sometida a su *patria potestas*. En caso de no ser así, estará sujeta a tutela, ya sea que su *pater* le haya nombrado tutor, o que se le haya dado uno (Gayo, 1.144). El marido no es su tutor legítimo ni tampoco se lo designa a éste como tutor de su propia mujer.

c) Sea el matrimonio *cum manu* o *sine manu*, las relaciones personales entre marido y mujer, por ser las *iustae nuptiae* un *factum*, no están reguladas por el *ius*, sino por las costumbres sociales. En determinadas circunstancias, la mujer goza del rango social del marido (*digitus mariti*): así, si éste es cónsul (Ulp., D.1.9.1.1) o pertenece a la clase senatorial (Ulp., D.1.9.8; C.10.39.9), obteniendo el domicilio del marido (Ulp., D.2.19; D.5.1.65; Papirio Justo, D.50.1.38.3).

d) Existía entre ambos cónyuges un deber de reverencia mutua. En virtud de él: (i) uno de ellos no puede accionar contra el otro sin permiso del pretor (Modest., D.2.4.13); (ii) no era admitida entre cónyuges la *actio de dolo* (C.5.12.2; año 201), ni la *actio furti* (salvo el caso de la *actio rerum amotarum*), por ser infamantes.

e) Sin embargo, existe cierta desigualdad. Así, respecto del deber de fidelidad, que es re-

primido respecto de la mujer, pero no del marido. Igualmente, el marido puede iniciar la *actio iniuriarum* por una ofensa hecha a su *uxor*, pero no la tenía ésta respecto de la inferida a su marido (Gayo, 3.221; Inst., 4.4.2).

1. El marido, durante la República, podía dar muerte a su mujer sorprendida en adulterio (no en cambio a la inversa; Aulo Gell., 10.23.5). Esto, luego, será prohibido por la *lex Iulia de adulteriis* (Paulo, Coll., 4.3.1; Pap., id. 4.30). Pero Antonino Pío perdonó al marido que mató a su mujer hallada en el acto adúltero, por considerar que estuvo motivado por la cólera del momento — hoy día emoción violenta — (Paulo, Coll., 4.3.6). También, no se la condenaba por ese hecho como un homicida a la pena capital o a la deportación, graduándose su pena hasta el exilio (*exilium*; Pap., Coll., 4.10). Más adelante, Constantino pronunció la pena de muerte contra la mujer adúltera (C.9.30.1). Justiniano, en cambio, la mandaba azotar, enviándola a un monasterio, donde debía permanecer, a menos que el marido la perdonara dentro del bienio (Nov.134.10).

2. Si la mujer hacía abandono del hogar conyugal, el pretor le otorgaba al marido los interdictos de *uxore ducenda et exhibenda*, para obligarla a volver (Epim., D.43.30.2; Lenel, *260*, n.12). Si está *in manu* se emplea el interdicto de *liberis exhibendis, item ducendis* (Ulp., D.43.30.1; EP, § 262).

B) *Efectos en cuanto a los hijos.* El efecto más importante es que los habidos de *iustae nuptiae* serán considerados hijos legítimos, quedando sujetos a la *patria potestas* (Gayo, 1.56; Ulp., 5.1). Forman parte de la familia civil del *pater*, es decir, son sus agnados. Respecto de la madre, sólo rige un parentesco por cognación, salvo que ésta sea *uxor in manu*, en cuyo caso los hijos serán también agnados suyos. (los tiene *loco sororis* = en el lugar de hermana; Gayo, 3.14).

Por otra parte, siguen la condición jurídica del *pater*: así, si éste es ciudadano romano, el hijo tendrá también la ciudadanía romana; y si fuera latino o peregrino, gozando del *conubium*, el hijo será también latino o peregrino (Gayo, 1.80; 1.89; Celso, D.1.5.19).

II. Efectos en cuanto a los bienes.

§ 335. Hay que diferenciar: a) si el matrimonio iba acompañado de la *manus* (matrimonio *cum manu*); b) si la mujer estaba libre de la *manus* (matrimonio *sine manu*). Y finalmente, c) las incidencias de la institución de la dote; así como las donaciones vinculadas con las nupcias.

§ 336. A) *Matrimonio cum manu.* Aquí

podía suceder que la *uxor* que se casaba fuera una *filiafamiliae*, y por ello *alieni iuris*; o al contrario, que fuese una mujer *sui iuris*.

a) Si la mujer *in manu* fuese *alieni iuris*, carece *per se* de capacidad patrimonial. Como agnada en la familia del marido, figura *loco filiae*. Todo lo que ingrese por causa suya con posterioridad (p.ej., por una herencia o un legado), incrementará el patrimonio del *pater* de la familia de su marido.

b) Si la mujer *in manu* era *sui iuris*, al contraer la *conventio in manu* se produce una *capitis deminutio*, pasando a ser *alieni iuris*. Su situación será igual que en el caso anterior. Pero como antes contaba con su patrimonio, los bienes de él serán absorbidos en forma total por el *pater* de la nueva familia (su marido, o su *pater* si el marido era *alieni iuris*). De este modo, el marido (o su *pater*) podía disponer libremente de ellos, ya por actos *inter vivos* o *mortis causa*.

1. Recordemos que respecto de las deudas de la mujer *sui iuris* que se casaba conviniendo la *manus*, éstas se extinguían por la *capitis deminutio*. Pero este efecto, propio del *ius civile*, será corregido por una *actio* con fórmula ficticia, concedida a sus antiguos acreedores, que de otra forma se verían burlados, implicando ello una *in integrum restitutio* (Gayo, 3.83ss.; 4.33).

§ 537. B) *Matrimonio sine manu*. Ya en la época clásica, cuando la *manus* desaparece, lo normal es el "matrimonio libre". El régimen de bienes de estas nupcias es el de la "separación de bienes". El marido y la mujer continuaban siendo propietarios de los bienes que tuviesen al contraer matrimonio. Cada uno de ellos adquiere los bienes para sí (o, en su caso, si son *alieni iuris*, para su *pater*). Igualmente ocurre respecto de las deudas: el marido no responde por las obligaciones de su mujer, ni ésta por las de su marido.

1. De este modo, si la *uxor* era *alieni iuris*, lo que adquiría era para su *pater*. Si era *sui iuris*, continuará detentando su propio matrimonio, ya inicial o acrecentando posteriormente, pudiendo administrarlo o disponer de él (con la *auctoritas* de su tutor mientras rigió la *tutela mulierum*; luego, cuando ésta cayó en desuso, de manera totalmente libre).

Este régimen del "matrimonio libre" (*sine manu*) estaba basado en un fuerte individualismo, ya que cada cónyuge administra y dispone de sus bienes. Al no existir un "régimen de comunidad de bienes matrimoniales", muchas veces no resultaba favorable a la mujer. Ésta no participaba en los bienes adquiridos por la ac-

tividad del marido durante el matrimonio ("gananciales" en la terminología actual), a pesar de que se los lograba muchas veces con la colaboración de la mujer, que prestaba su ayuda espiritual y material en la labor doméstica. Sin embargo, en la práctica, este sistema de independencia económica estaba morigerado por las costumbres:

a) Así, jurídicamente, el marido no está obligado a mantener a su mujer. Pero en la práctica es el marido quien suministra lo necesario para el mantenimiento de su mujer y sus hijos, costeados los gastos del hogar. Acá jugaba también un papel importante la práctica usual de la dote*, es decir, una suma de dinero o de determinados bienes que la mujer, o su *pater* o un tercero, entregaban al marido para contribuir a dichas expensas.

b) A diferencia de la *uxor in manu*, que por ser agnada en la familia de su marido será heredera legítima (*heres sua*) en la sucesión *ab intestato*, en el matrimonio libre, la *uxor* no es *heres legitima* de su marido, ni éste *heres legitimus* de su mujer a los efectos de la herencia *ab intestato*. Sin embargo, el pretor corregirá esta situación otorgando la *bonorum possessio sine tabulis* al cónyuge superviviente, sea el marido o la mujer, aunque solamente si carecían de parientes agnados y cognados (último llamamiento: *unde vir et uxor**).

Además, era costumbre que uno de los cónyuges instituyera al otro heredero, por lo menos *pro parte*, o le dejara un legado (Plinio, *Epist.*, 8.18.7.8).

c) Igualmente era usual en un matrimonio bien avenido (*bene concordans matrimonium*) que los cónyuges se comporten respecto de los bienes particulares como si fueran comunes. La mujer solía conferir al marido la administración de sus bienes propios. Se habla entonces de *bona extra dotem* (Pap., D.39.5.31.1), según el lenguaje clásico. Más tarde serán también llamados "bienes parafernales".

1. La denominación de *parafernales* es de origen griego (= fuera de la dote) y es ya usada por Ulpiano (D.23.3.9.3). Aparece también en papiros greco-egipcios de los primeros siglos del Imperio; entre los galos se los llamaba *peculium* (Ulp., D.16.1.1).

2. El régimen de tales bienes estaba regulado por la intención de la *uxor*. Generalmente era para su administración, como si fuera un mandato, o un depósito, debiendo ser devueltos a la disolución del matrimonio (Ulp., D.23.3.9.3). Si se trataba de créditos, el marido los podía cobrar aplicando los intereses o rentas en beneficio común. El capital debía reservarse para la mujer, estableciendo Justiniano que pesaba una hipoteca legal* en favor de ésta (C.5.14.11; año 530).

3. La mujer no estaba obligada a este régimen, pero era bastante usual. Entre los casos excepcionales se recuerda el de Terencia, la mujer de Cicerón, que retuvo para sí la administración de sus bienes, lo cual irritaba a su marido, sobre todo cuando éste se hallaba en apuros económicos, y fue una de las causas por las cuales se divorció de ella.

4. En cambio, el marido de Turia, según lo dice en su célebre *laudatio fúnebre*, su mujer le había otorgado la custodia de sus bienes (*laud. Thur.*, 37). Que la práctica era normal, lo demuestra una constitución de Teodosio y Valentinián, según la cual la mujer podía consentir esta administración marital, pero también prohibir al marido que se inmiscuyera en los bienes parafernales (C.5.14.8; año 450). En la época de Justiniano se denomina "parafernales" todos los bienes extradotales de la mujer (Nov.97.5), y si bien quedan fuera del régimen dotal, se entiende que cumplen una función semejante.

§ 538. C) *La dote*. La dote (*dos*) es una cantidad especial de dinero o de bienes hecha por la mujer (o su *pater* o un tercero) al marido para solventar los gastos del matrimonio (*onera matrimonii*; Paulo, D.23.3.56.1). Si bien no era obligatoria, las costumbres prácticamente exigían que el *pater* de la novia concediera al marido determinados valores patrimoniales en concepto de dote.

Con ello, se consigue una mejora de la situación de la mujer, por cuanto el marido estaba de hecho moralmente obligado a mantenerla, haciéndola participar del nivel de vida que éste tenía. Pero junto a esta finalidad de contribuir en las cargas matrimoniales, ya desde la época republicana se entendió que la dote cumplía una función protectora de la mujer para el caso de que el matrimonio se disolviera, ya por muerte o por divorcio, pudiendo en este caso solicitar su devolución.

1. Si el marido es *alieni iuris*, la dote es adquirida por su *pater*, pero a la muerte de éste queda siempre al marido, con exclusión de los otros herederos (Ulp., D.10.2.20.2).

2. Tal como dijimos, el uso inveterado de la dote era de hecho, y no de derecho. Pero a partir de Severo y Caracalla, la constitución de dote es una obligación para el padre o sus ascendientes, sancionada por el *ius civile* (Marciano, D.23.2.19).

§ 539. *Constitución de la dote*. El caso más frecuente era que fuera el *pater* quien constituía la dote. En este caso, se la llamaba *profecticia* (Ulp., 6.3; D.23.3.5. pr.). Pero también puede hacerlo la propia mujer, si es *sui iuris*, o un tercero cualquiera (*dos adventicia*; Ulp., 6.3).

1. La *dos profecticia* podía ser constituida por el padre o un ascendiente (Ulp., D. id., § pr.). En la

época clásica no hay una designación propia. Es en la época posclásica que aparece la denominación de *dos adventicia* para contraponerla a la otra. El nombre aparece justificado si el constituyente era un tercero, pero resulta impropia si la efectúa la propia mujer.

La dote se podía "dar" o "prometer", ya antes del matrimonio, ya después de constituido éste.

a) En el primer caso (*dotis datio*) era necesaria la celebración del acto de constitución en favor del marido. Como por lo general consistía en la propiedad (también podía ser un usufructo, una servidumbre, la extinción de un derecho real o de una obligación), se debía hacer una *mancipatio*, o una *in iure cessio*, o una *traditio*, según cada caso.

1. Si ocurría con anterioridad al matrimonio, el negocio quedaba supeditado a la celebración de éste. Si las nupcias no sucedían, se podía exigir su devolución por la *condictio causa data causa non secuta* (Ulp., D.23.1.10). Pero también podía ser constituida durante el matrimonio (o aumentada la ya dada); Paulo, 2.21b.1; FV., 110).

b) Por otro lado, se podía prometer. Esto se hacía mediante una estipulación (*promissio dotis*). Al respecto había también un forma verbal específica, que era la *dictio dotis* (Gayo, 3.96).

1. Mientras que en la *promissio dotis*, como en toda *stipulatio*, había una pregunta (del marido) y una respuesta (la del promitente de dote), en la *dictio dotis* la promesa era formulada directamente por el promitente, sin pregunta previa. Por ello, Gayo (3.96) dice que era *uno loquente* (= uno solo quien habla). Esta forma sólo podía usarla la propia mujer *sui iuris*, o su *pater* o un deudor de la mujer ordenado por ésta. Estas personas podían constituirla también por una *stipulatio*. Pero fuera de ellas, el promitente debía recurrir a la *promissio dotis*.

Cuando en la época posclásica desapareció la *dictio dotis*, sólo quedó la *promissio dotis*. Pero la práctica común era la redacción común de un "pacto dotal" (*pactum* o *instrumentum dotale*). Justiniano terminará por admitir fuerza obligatoria a este pacto (*pactum legitimum*), ya sea en forma escrita o aun oral (—algo así como una estipulación degenerada—; C.5.11.6 itp.; 5.12.31 pr.; 5.13.1.1d).

2. Los compiladores bizantinos emplearon la forma de la *dos tacita* (Paulo, D.23.3.30; Javol., D. id. 64; itps.). Este caso ocurría cuando la mujer, luego de divorciada, celebraba un nuevo matrimonio reconci-

hitorio, sin haber antes obtenido la restitución de los bienes dotales. Se consideraba que en forma tácita se constituía la dote. Esto está en contra de lo usual en el derecho clásico, en el cual la dote debe estar expresamente constituida.

§ 540. *La dote durante el matrimonio.* La regla general imperante en el derecho republicano y que se extiende durante el derecho clásico es que la dote corresponde en propiedad al marido (Paulo, D.23.8.1).

1. En realidad, lo más correcto es decir que el marido tiene sobre la dote el derecho que le ha sido conferido al constituirla. Podía consistir en un usufructo, con el cual los poderes son más limitados, y el régimen se acercaría al de los bienes "parafernales". Pero, por lo general, lo que se daba en dote era el *dominium*.

2. La expresión de la dote como *res uxoriae* ("cosas de la mujer") usada ya en la época clásica, hace sólo referencia al eventual derecho que tiene la mujer para recuperarla luego de disuelto el matrimonio. Así se concedía la *actio rei uxoriae*, que figura entre los *bonae fidei iudicia* (Gayo, 4.62; EP, § 113).

a) Durante todo este periodo primero, entregada en propiedad, el marido es el dueño de los bienes dotales. Puede usarlos, administrarlos y disponer de ellos, sin necesidad de ninguna autorización por parte de la mujer, quien no podía interferir en el actuar de su cónyuge.

b) Pero, considerando las causas particulares que rodean a la dote: la contribución a las cargas matrimoniales y también el constituir un fondo de reserva para la mujer luego de disuelto el matrimonio, se estableció una limitación importante en la denominada *lex Iulia de fundo dotali* (que en realidad no fue tal, sino un capítulo de la *lex Iulia de adulteriis*; año 18 a.C.; Paulo, 2.21b.2). En virtud de ella se prohíbe al marido enajenar los fondos fideicomisarios dotales, e incluso hipotecarlos ni siquiera con este consentimiento (Gayo, 2.63; D.23.5; Inst., 2, 8 pr.).

1. Si pese a la prohibición se efectuaba la venta, ésta no es válida (Pap., D.41.3.42), pero la nulidad se considera siempre en favor de la mujer, por lo que ésta tendría que actuar por la *actio rei uxoriae* (luego *actio de dote*; Paulo, D.23.5.3.1). Probablemente, la mujer contaría con una *rei vindicatio* con la ficción de que ella fuera propietaria.

2. En ciertos casos se permitirá la enajenación. Así, cuando fuera necesaria, por la partición provocada por el copropietario (Tryf., D.23.5.78.4; Paulo, D.23.5.1; Gordiano, C.5.23.2). También, si el bien hubiera sido previamente estimado, de tal modo que disuelto el matrimonio, el marido podía optar entre devolver el bien o su estimación (Afric., D.23.5.11).

3. Gayo (2.63) expresa sus dudas si la prohibición de la enajenación se aplica sólo a los fondos fideicomisarios o debe extenderse también a los fondos provinciales. Ya para el siglo V estas dudas aparecen descartadas, en el sentido de no permitirse ni la venta ni la hipoteca de inmuebles dotales provinciales (Fragm. Sinat., 5; donde se cita al Cód. Gregoriano y a Sabino).

Justiniano expresamente confirma esta extensión, al mismo tiempo que prohíbe la venta o la hipoteca de ellos, "y que ni lo uno ni lo otro pueda verificarse aun con el consentimiento de la mujer, por temor de que se abuse de la fragilidad de estas cosas" (*ex mulieribus fragilitas*), con perjuicio de su fortuna" (Inst., 2.8 pr.; C.5.13.1.15).

c) En la época posclásica se reafirmará la idea de que los bienes dotales son *res uxoriae* (= cosas de la mujer), denominándolos *quasi patrimonium uxoris* (como un patrimonio de la mujer; Ulp., D.11.7.16), es decir, en un sentido más fuerte que el mero derecho de la mujer a obtener su devolución luego de terminado el matrimonio. Justiniano acentuará esta tendencia, al establecer que las *res uxoriae* son tanto de la mujer como del marido: del primero, por "sutileza de las leyes" (*legum subtilitate*); de la mujer "por derecho natural" (*iure naturali*); C.5.12.30.1; año 529.

De este modo, si bien se reconoce la propiedad formal del marido, debido a las limitaciones, sobre todo de disposición, que tiene, su derecho sobre la dote es más bien la de un dominio fiduciario o la de un usufructo.

1. Ya en el Edicto del pretor figura una rúbrica *de re uxoria* (EP, Tit. 20), pero esto no es decisivo por cuanto se aplica a la dote que debe ser devuelta después de la disolución del matrimonio. En un texto de Tryfonino (D.23.3.75), discutido en cuanto a que sea clásico, se dice que "a pesar de que la dote esté entre los bienes del marido, es sin embargo de la mujer", lo cual se corresponde con un texto de Boecio comentando a Cicerón (*ad Cic. top.*, 17.65).

2. Como consecuencia de esta concepción de las *res uxoriae*, se fortalecen ciertas reglas: a) el marido debe poner especial diligencia en los bienes, la misma que pone en las cosas propias, respondiendo por dolo y culpa (Paulo, D.23.3.17 pr.); b) los frutos de los bienes dotales son, en principio, del marido, pero dado el carácter de *res uxoriae*, si se los da a la mujer para su alimentación, o aun excediendo esa finalidad, no se incurre en el régimen de prohibición de donaciones entre cónyuges (Ulp., D.23.3.7 pr. y 1); c) si la mujer sustrae bienes muebles dotales, no se considera ello *furtum*, si bien a los efectos de la restitución, se le concede al marido una *actio rerum amotarum* (Paulo, D.25.2.1; EP, § 115).

§ 541. *La dote después de la disolución del matrimonio.* Como dijimos, ya en la época

republicana se vino afirmando la función doble de la dote: la de contribución a las cargas matrimoniales y la de fondo de reserva para la mujer en caso de que la unión se disolviera.

A) En un principio se acostumbró celebrar una *stipulatio* precautoria (*cautio rei uxoriae*), en virtud de la cual el constituyente de la dote se hacía prometer la devolución de los bienes que la integraban cuando el matrimonio se disolviera. La dote era llamada *recepticia* (Ulp., 6.5) y daba lugar a una *actio ex stipulatu*.

B) Con posterioridad, y reafirmando el principio del fondo de reserva en favor de la mujer, se otorgó una *actio rei uxoriae*, por la cual se podía reclamar la devolución de la dote, aun no habiendo mediado la *stipulatio*.

1. El origen de la *actio rei uxoriae* es bastante oscuro. Gayo (4.62) la menciona como un *bonae fidei iudicium* (EP, § 113), si bien la redacción de la fórmula era particular: *quod melius aequius erit* (Cic., *top.*, 17.66, en lugar de *ex bono et aequo*). Pero el resultado era el mismo, puesto que le permitía al iudex otorgar a la mujer o a quien correspondiera, lo que por equidad entendía que debía ser devuelto.

2. También podía ocurrir que el marido dejara la dote por legado a su mujer (*dos relegata* o *praelegata*; D.33.4). Igualmente, si el marido le deja bienes por un legado a su mujer, ésta puede optar entre pedir dicho legado o bien reclamar la dote (*edicto de alterutro*; EP, § 114).

El marido condenado por la *actio rei uxoriae* estaba obligado a devolver los bienes inmuebles en forma inmediata; en cambio, si se trataba de cosas fungibles, las podía restituir en tres plazos de uno cada uno (*annua, bima, trima die*; Ulp., 6.8).

Además, gozaba de otros beneficios. Así, (i) tenía el *beneficium competentiae*, por el cual era condenado hasta el límite de su activo patrimonial (Mod., D.42.1.20); (ii) se quedaba con los frutos de los bienes dotales (Ulp., D.23.3.7 pr.); y (iii) podía efectuar determinadas retenciones.

3. En cuanto al régimen de restitución de la dote, podemos distinguir las siguientes circunstancias:

a) Cuando hay divorcio, la mujer tiene siempre el derecho de pedir la restitución de la dote. En caso de ser *alieni iuris* y vivir su padre, la devolución de la dote debía ser pedida por éste juntamente con su hija (*adjuvante filiae personae*; Ulp., 6.6). La acción no pasa a los herederos, salvo que al tiempo de la muerte de la mujer el marido estuviera ya constituido en mora (Ulp., 6.4 y 7).

Si el divorcio era causado por culpa de la mujer o de su padre, el marido podía efectuar ciertas retenciones: (i) *retentio propter liberos*, un sexto por cada hijo, pero en ningún caso podía exceder los tres sex-

tos, es decir, la mitad (Ulp., 8.10); (ii) *retentio propter mores*: un sexto en caso de haber incurrido en adulterio; un octavo por causas menos graves que hubieran provocado el divorcio (Ulp., 6.12).

b) Cuando muere el marido, la mujer o el constituyente de la dote puede reclamarla de los herederos, pero éstos no tienen derecho a efectuar las retenciones propias del caso de divorcio.

c) Cuando muere la mujer, si la dote es *adventicia* queda para el marido; y si es *profecticia* y vive el padre, éste puede reclamarla, pero puede retener un quinto por cada hijo (Ulp., 6.10).

A su vez, en todos los casos, el marido también puede retener: (i) el monto de los regalos hechos a su mujer (*retentio propter res donatas*); (ii) el valor de las mejoras necesarias efectuadas por el marido; las mejoras útiles, si fueron hechas con consentimiento de la mujer; pero no por las voluptuarias (*retentio propter impensas*); y (iii) el valor de las cosas sustraídas por la mujer (*retentio propter res amotas*).

C) En la época de Justiniano, la regla general fue la de que la dote nunca —salvo algún pacto especial al momento de constituirla— debía quedar al marido, quien debía restituir los bienes dotales a la mujer y a sus herederos, generalmente sus hijos (C.5.13).

1. La devolución de la dote a la mujer ocurría siempre, ya en caso de muerte del marido o de divorcio sin culpa de ella. Si era la mujer la que moría, los bienes iban a sus hijos. Por la Nov.98 (año 529), el marido viudo retiene el usufructo de dichos bienes.

2. Si el divorcio era por culpa de la mujer o por su capricho, el marido podía retener la dote (C.5.17.8.3-4), o si así se hubiere pactado.

3. El pater que hubiera constituido la dote de su hija *alieni iuris*, podía reclamar dicha *dos profecticia*, en caso de la muerte de aquélla. El constituyente extraño sólo la recibirá cuando por *stipulatio* o *pactum* así se hubiera convenido (C.5.12.31.1).

Además, en caso de haberse estipulado la devolución, no había dudas acerca de la restitución de ella. Pero Justiniano (C.5.13.1, año 530), sobre la base de que aun no existiendo ninguna *stipulatio*, estableció que cabía presumirla. Suprime la clásica *actio rei uxoriae*, creando para todos los casos una *actio ex stipulatu*, que curiosamente, para conservar los efectos de la anterior acción, será, no *stricto iure*, sino *bonae fidei* (C.5.13.1.2). Los compiladores, en el Digesto, la denominarán *actio de dote* (o *actio dotis*).

4. La refundición de la *actio rei uxoriae* en esta nueva *actio ex stipulatu* (o *actio dotis*), mantiene sin embargo ciertos caracteres anteriores. Así, (i) como lo dijimos, le otorgará a la nueva acción el carácter de *bonae fidei iudicium* (C.5.13.1.2; Inst., 4.6.29), a pe-

sar de qué la *actio ex stipulatu* era de derecho estricto; (ii) igualmente, le continúa otorgando al marido demandado el "beneficio de competencia", si no hubiera mediado dolo del marido en la administración (Inst., 4.6.37), (iii) en cuanto a la devolución, los inmuebles deben ser restituidos inmediatamente; los muebles en el plazo único de un año, lo mismo que los créditos (C.5.13.1.7).

5. El sistema de las *retentiones* queda suprimido como tal (C.5.13.1.5).

Respecto de las *res donatae*, el marido tendrá la *vindicatio* para reclamarlas, lo mismo que respecto de las *res amotas*, la *actio rerum amotarum*.

Respecto de los gastos empleados en mejoras (*impensae*), el marido puede disminuir el monto de la dote que debe restituir, si se trata de "necesarias"; si son "útiles", se le concede la *actio mandati* (si medió el asentimiento de la mujer en realizarlas) o la *actio negotiorum gestorum* (si hubiera mediado "utilidad", pero no asentimiento); si eran "voluptuarias", el marido podía retirarlas, si es que no quiere pagarse el importe.

En lo que se refiere a la *retentio propter mores*, se la considera innecesaria por las penas previstas para el caso de divorcio *ex iusta causa*, lo mismo que la *retentio propter liberos*, ya que se reconoce el derecho sucesorio necesario de los hijos en la herencia de sus padres.

6. La mujer podía pedir la restitución de la dote aun durante la vigencia del matrimonio, si el marido estaba en insolvencia o mostraba tendencia a la disipación patrimonial (C.5.12.29).

7. Igualmente se derogó el *edictum de alterutro*, de tal modo que si el marido le dejaba un legado a su mujer, ello se interpretaba como una liberalidad independiente de la dote, pudiendo la mujer reclamar ambos legados (el de dote y el otro dejado por su marido) (C.5.13.1.3).

Por una constitución del año 529 (C.5.12.30), Justiniano le permite a la mujer ejercer la *rei vindicatio* respecto de los bienes dotal. Con ello se reafirma su propiedad, según el *ius naturale*. Si para reclamarlos optaba por la *actio dotis*, le otorga un privilegio hipotecario sobre los bienes existentes; un año después, lo ampliará a una "hipoteca legal general y tácita" sobre todos los bienes del marido (C.5.13.1.1). Terminará por extenderla, de manera más exagerada, a un privilegio general que primaba incluso respecto de los acreedores del marido, aun por deudas anteriores al matrimonio (C.8.18.12; año 531).

D) *Donaciones matrimoniales*. Aquí tenemos que distinguir entre a) las donaciones entre cónyuges, y b) las realizadas con motivo de las nupcias.

§ 542. *Donaciones entre cónyuges*. La regla general es que las donaciones entre cónyuges están prohibidas (Ulp., D.24.1.1).

1. No se sabe bien cuándo surgió esta regla. Debó ser posterior a la *lex Cincia* (año 204 a.C.), puesto que ésta menciona al marido y a la mujer entre las personas exceptuadas de la prohibición de donar. Ulpiano (D., *ibid.*) habla de que "está admitido entre nosotros por la costumbre". Alguna parte de la doctrina entiende que la prohibición fue establecida por Augusto en la ley *Iulia et Papia Poppaea*; quizá pueda ser cierto que Octavio Augusto se haya referido a esta prohibición, para evitar que por medio de donaciones se evitaran las sanciones caducarias en las adquisiciones hereditarias.

2. Ulpiano (D.24.1.1) da como motivo un argumento que atañe a la moralidad romántica: "Para que recíprocamente no se despojases por su mutuo amor, no moderándose en las donaciones haciéndolas respecto de sí con dispendiosa facilidad". También Paulo (citando a Sexto Cecilio) nos habla de que "se disolverían los matrimonios, si no donase el que no pudiera, y por tal motivo acontecería que los matrimonios serían venales" (D.24.1.2).

Fuera de estas consideraciones, jugaba acá el criterio de evitar el enriquecimiento de una familia a costa de la otra. Por ello es que la prohibición no rige sólo entre cónyuges, sino también respecto de donaciones hechas por un cónyuge a miembros de la otra familia, que por razón de estar *in potestate* pudieran encubrir una donación entre cónyuges (así, si la madre dona al *filius* sometido a la *patria potestas*); Ulp., D.24.1.3.2ss.

Estas donaciones entre cónyuges son totalmente nulas. Si se hubiere prometido donar por una *stipulatio*, ella es ineficaz (Ulp., D.24.1.3.10). Si la cosa donada hubiera sido dada, el que donó tiene la *rei vindicatio* para recobrarla; y si la cosa se hubiera consumido, se puede ejercer la *condictio* (Ulp., D. id. 5.18). Sin embargo, la jurisprudencia clásica, seguida por los juristas posteriores, limitaron la prohibición, estableciendo algunas excepciones y permitiendo también una convalidación posterior a la disolución del matrimonio, ya por muerte o divorcio.

3. a) Así, se considerarán válidas las donaciones por determinados deberes sociales: p.ej., si se dona una sepultura, siempre y cuando se entierre en ella al cónyuge (Ulp., D. id. 5.8-9), o si se le hubiere donado un monumento funerario, luego que el lugar se hubiera vuelto religioso por el entierro del cónyuge (Ulp., D. id. 5.10). También, las donaciones por causa de divorcio (Ulp., D. id. 11.1.1). Y en general, las que no importan una disminución apreciable de los bienes propios o un enriquecimiento del donatario, que no se queda con lo recibido, sino que lo afecta a una finalidad razonable; así si la mujer recibe dinero

y hace un pequeño regalo a un pariente (Ulp., D. id. 5.16-17); también si el marido donó dinero a su mujer para reconstruir una casa suya incendiada (Paulo, D.24.1.14), o vestidos (Labeón-Pomp., D.24.1.29.1).

Justiniano admitirá que no son nulas las donaciones hechas en caso de deportación o exilio (Ulp., D. id. 13.1; 43 itps.). También permitirá las donaciones recíprocas entre el Emperador y la Emperatriz (C.5.16.26; año 529).

4. b) Las donaciones hechas para el caso de muerte o disolución del matrimonio sólo son eficaces una vez ocurrida la muerte o la disolución de éste. Cuando el donante moría antes que el donatario, la donación podía ser confirmada por un fideicomiso. Acá tiene importancia un s.c. de Caracalla (año 206, siendo corregente de su padre Septimio Severo: *oratio Antonini u oratio Severi*). Por él se determinó que si el donante hubiese perseverado sin revocar la donación antes de su muerte, y moría estando casado, la donación era válida de pleno derecho en el momento de su deceso, sin necesidad de fideicomiso confirmatorio. Se la consideraba donación *mortis causa*, ya que su silencio en vida para arrepentirse y revocarla, vale como una ratificación expresa, siendo inatacable por los herederos (Ulp., D.24.1.32 pr. y ss.).

5. Por una regla atribuida a Q. Mucio Scaevola, se consideraba que las adquisiciones en favor de la mujer por una causa no probada, eran donaciones de su marido (Pomp., D.24.1.51).

Esta *praesumptio Muciana* se debió haber aplicado con anterioridad al matrimonio *cum manu*. Generalmente, el marido dejaba a su mujer un legado, y siendo que si había cosas que detentaba ésta, ellas hubieran escapado al legado. Por medio de la "presunción Muciana", todo lo que había recibido en vida la mujer, salvo prueba en contrario, se entendía que le había sido dado por el marido, y por tanto, al ser una donación entre cónyuges y ser nula, no era de ella, pero entraba en el legado. Esto se extendió al matrimonio *sine manu*, y de este modo se interpretaba que lo dudoso era como donado por el marido, convalidándose la donación como *mortis causa*.

§ 543. *Donaciones ante nupcias* (*propter nuptias*). En la época posclásica, por influencia de una práctica de las provincias orientales del Imperio, aparece la costumbre de que el marido efectúe una donación a su futura mujer, cuya validez y efectos depende de la celebración y subsistencia del matrimonio. Es la llamada *donatio ante nuptias*, la cual aparece distinta de los regalos nupciales, generalmente más modestos. La función que tenía era la de constituir una reserva en favor de la mujer y de sus hijos.

Justiniano, aprovechando un antecedente de Justino, quien permitió que la donación fuera aumentada luego de celebradas las nupcias (C.5.3.19), ampliará las posibilidades, permitien-

do —no obstante la prohibición de donaciones entre cónyuges— que este tipo de donaciones puede celebrarse directamente luego de celebradas las nupcias. Debido a ello, cambia la vieja denominación y las denomina *donationes propter nuptias* (donaciones por causa de las nupcias; C.5.3.20; Inst., 2.7.3).

El papel que se le asigna es el de ser una contrapartida de la dote. De este modo, se confirma la costumbre oriental, cuyo nombre de *antiferna* (contradote) figura en C.5.3.20.2. Más aún, pasa a ser obligatoria para el marido o su *pater* (C.5.11.7.2) y finalmente, Justiniano estableció que su monto debía ser equivalente al de la dote (Nov.91.1).

1. Se le aplica el mismo régimen que a la dote (solventar las cargas del hogar y servir de fondo de reserva a la mujer y a los hijos). Durante el matrimonio el marido es considerado como propietario, si bien le está prohibido enajenar e hipotecar los inmuebles (Nov.61).

En caso de muerte del marido o de divorcio sin su culpa, la mujer retiene la donación, pero si tiene hijos, éstos son considerados los propietarios, si bien la madre tiene el usufructo (Nov.98.1). Termina por concederle a ésta una parte como a cada hijo (Nov.127.3). Si la madre viuda o divorciada llegara a contraer nuevas nupcias, la donación se reparte entre éstos, quedando la mujer excluida (Nov.2.1).

Si muere antes la mujer o es culpable del divorcio, el padre conserva el usufructo, siendo la propiedad de los hijos (C.6.61.4).

3. La *donatio propter nuptias* no está sujeta a la *insinuatio** (Nov.119.1; 127.2).

Al establecer la obligatoriedad de la dote y de la *donatio propter nuptias*, y que los montos fueran equivalentes, se tiende a establecer una igualdad entre los cónyuges. A diferencia de lo que ocurría en el matrimonio "libre", donde regía el principio de separación de patrimonios, ahora se tiende a un régimen de patrimonio conyugal común: la mujer aporta la dote y el marido la donación *propter nuptias* (como "contradote").

DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO

El matrimonio se disuelve:

§ 544. I. *Por la muerte de uno de los cónyuges* (Paulo, D.24.2.1).

1. Si uno de los cónyuges se ausenta durante largo tiempo, no teniéndose noticias de él, o habiendo llegado al otro cónyuge información de que ha fallecido, dicha ausencia queda en cierto modo equiparada a la muerte, lo que se explica por ser el matrimo-

no una *res facti*, cesando la intención de mantener la comunidad matrimonial (*affectio maritalis*; v. Pap., D.48.5.11.12).

§ 545. II. Por la cautividad en poder del enemigo (Paulo, D.24.2.1), aun en el supuesto de que hubiera caído prisionero uno solo de los cónyuges, sin darse la posibilidad del *postliminium*. Al quedar libre y regresar a Roma, si quieren volver al matrimonio, tenían que celebrar uno nuevo (Ulp., D.49.15.14.1).

1. La explicación de esto se debe a que se debe mantener la convivencia en forma continua. Por ser una *res facti*, no se recupera el anterior matrimonio por el *postliminium*, que sólo produce efecto respecto de los derechos. Esto ocurría aún cuando la mujer quedase en su patria viviendo en la casa del marido (Tryph., D.49.15.12.4).

2. Por un rescripto de Severo y Caracalla, en caso de que ambos cónyuges hubiesen caído prisioneros, conviviendo en cautividad, si la mujer daba a luz un hijo y luego ambos regresan libres, dicho hijo es legítimo, como si fuera consecuencia del *postliminium*. En cambio, si volvía sólo la madre, el hijo era considerado "espurio" (Marciano, D.49.15.25).

Justiniano variará el principio clásico, de tal modo que por la cautividad en guerra de uno de los cónyuges, el matrimonio no se disuelve. El que se ha quedado en Roma no puede contraer nuevas nupcias hasta después de 5 años desde la cautividad, y no se tengan noticias ciertas del cautivo. De lo contrario, se considera que de casarse sin el cumplimiento de estos requisitos, se incurre en divorcio *sine causa*, lo que ocasionaba las penas pecuniarias correspondientes (Nov.22.7; año 536).

3. También por otras causas de esclavitud se disolvía el matrimonio (Paulo, D.24.2.1). Justiniano suprimirá la esclavitud por penas infamantes (*servituti poenae; ad metalla*), de tal modo que el matrimonio existente se conservaba. En realidad, para su época sólo subsistían como causas de esclavitud: a) la del hombre libre mayor de 20 años que se hacía vender como esclavo (Inst., 1.3.4); y b) la del liberto ingrato (Mod., D.25.3.6.1).

§ 546. III. Por destierro. Por el destierro de uno de los cónyuges (*deportatio*) el matrimonio se disolvía en la época clásica (*capitis deminutio media*). Más tarde, según una constitución de Constantino (C.5.16.24.1; año 321), el matrimonio no concluía por esta causa, lo cual fue reafirmado por Justiniano siempre que el cónyuge que no soporta la pena mantenga la *affectio maritalis* (Nov.22.13).

1. Sin embargo, para la época clásica, hay textos como el de Ulpiano (D.48.20.5.1) donde se adhiere a la opinión de Marcelo según la cual si una *filia* era deportada, ello no disolvía el matrimonio si se mantenía por el marido la *affectio maritalis* y por parte de ella el *animus uxoris*. Pese a ello, está la opinión contraria de Paulo (D.24.3.56).

2. La constitución de Constantino fue considerada interpolada por los bizantinos, ya que no se corresponde con el texto que aparece en el C.Th. (9.42.1). De ser cierto ello, el principio clásico se impuso hasta Justiniano. Pero cabe la duda acerca de esto, pues no se ve la necesidad de que este emperador tuviera que citar un precedente que no existió.

§ 547. IV. Por impedimento sobreviniente. Esto ocurría cuando el *pater* adoptaba a su yerno o a su nuera. De este modo, los cónyuges pasaban a ser hermanos agnados, lo cual era un impedimento (Tryph., D.23.3.67.3; Gayo, D.23.2.17.1). Para evitar la disolución del vínculo matrimonial, en la época clásica, se aconsejaba al *pater* adoptante que emancipara a su hija o hijo, con lo cual el impedimento desaparecía (Gayo, *ibid.*). Este "consejo" es considerado obligatorio por Justiniano, de tal modo que antes de adoptar había que emancipar al hijo o hija (Inst., 1.10.2).

1. Otra hipótesis, más discutida, era aquella en la cual el marido de una liberta fuese elevado al rango senatorial, estando prohibido el matrimonio entre senadores y libertas por la ley *Papia Poppaea*. En el único texto referido a este caso (C.5.4.28 pr.), Justiniano mencionó que la cuestión le había sido presentada a Ulpiano, denotándose por el sentido del texto que la respuesta era positiva en cuanto a la disolución. Pero Justiniano decide lo contrario, "para que la felicidad del marido —elevado a la categoría senatorial— no se convierta en infortunio para la mujer".

2. Esto es acorde con el principio bizantino, atribuido al emperador Gordiano de que "el matrimonio contraído en forma no se puede viciar por un impedimento posterior". Acá aparece aplicado al caso de que a una mujer casada, con hijos, se le nombra curador al *pater* del marido. Si bien termina con el "consejo" de que se nombre a otro como curador, "para que desaparezca todo escrúpulo" (C.5.6.3).

§ 548. V. Divorcio. A) La vigencia de este modo de extinción de las nupcias, se explica fácilmente por ser el matrimonio romano una *res facti*, que se mantiene por la *affectio maritalis*. Al faltar éste, el vínculo cesaba por la voluntad de ambos o de uno de ellos (*divortium; repudium*).

1. La disolución por divorcio estuvo presente desde el inicio mismo de Roma. Así, Plutarco (*Rómulo*,

22) nos habla de una *lex regia* dictada por el fundador de Roma, según la cual se permite al marido el *repudium* de su mujer por causas muy determinadas: envenenamiento de la prole, sustracción de las llaves (las de la bodega, a propósito del tabú del vino para las mujeres?) y adulterio.

2. Pero hasta el siglo III a.C., no hay mención expresa de divorcios. Cicerón (*de re publ.*, 6.2.2) nos habla de que los antiguos quisieron mantener la estabilidad del matrimonio. Y tanto fue así, que los primeros divorcios llamaron la atención. Valerio Máximo (2.8.2) nos habla del de Lucio Annio, a quien por ello se lo privó de la dignidad senatorial, por haberlo hecho sin haber consultado el *consilium amicorum*. Y más citado es el caso de Spurio Carvilio Ruga, quien repudió a su mujer por ser estéril, jurando ante los censores que la había tomado por cónyuge para tener hijos (Aul.Gell., 17.21.44; Val.Max., 2.1.4).

3. En cambio, en el tiempo posterior, con el decaimiento de las viejas costumbres, los divorcios fueron más usuales. No solamente se admite el *repudium*, que en principio correspondía sólo al marido, sino también la decisión de divorciarse de la mujer, habiendo llegado esta costumbre a límites tales que motivaba las quejas de Séneca ("las mujeres ilustres y nobles no cuentan los años por los consulados —como era la costumbre— sino por el número de sus maridos, salen del matrimonio para casarse, y toman marido para divorciarse"; *de benef.*, 3.16.2). No había causas limitadas para producir la disolución ni tampoco forma solemne alguna.

B) Para la época de Augusto, no obstante las leyes caducarias dictadas, hay que señalar que estaban más bien dirigidas a solucionar el problema demográfico tendiendo a que los hombres y las mujeres se casaran y tuvieran hijos, sin prohibir la disolución de las nupcias por divorcio.

A comienzos del Principado, la costumbre era meramente el empleo de ciertas palabras (*comprobata verba*). Así, "Ten para tí tus cosas" (*Tuas res tibi habeto*), y también "ocúpate tú misma de tus asuntos" (*Tuas res tibi agito*); Gayo, D.24.2.2.1. Pero, por la *lex Iulia de adulteriis* (año 18 a.C.), Augusto estableció que el divorcio debía ser realizado de manera formal, por medio de un liberto del cónyuge, que debía anunciar al otro su voluntad de divorciarse, en presencia de siete ciudadanos púberes (Paulo, D.24.2.9). El divorcio sin el empleo de esta formalidad era inválido, pero aun así, la jurisprudencia mantuvo el criterio de por el mero desistimiento de la *affectio maritalis*, el matrimonio quedaba disuelto, si bien dando lugar a sanciones accesorias (Ulp., D.24.1.35; D.38.11.1.1; Paulo, D.24.2.9).

1. El propósito de esta formalidad era obligar al marido a divorciarse de su mujer adúltera, puesto

que de lo contrario incurría en el delito de *lenocinium* (inducir a la mujer casada a tener relaciones extramatrimoniales), así como también fijar la fecha para el inicio de la acción contra la mujer adúltera.

También, desde el punto de vista patrimonial, las donaciones *post divortium* (sin haberse observado las formas establecidas por Augusto) eran inválidas, aun cuando por su inobservancia se pudiera considerar no disuelto aún el matrimonio (Ulp., D.24.1.35).

2. En el comienzo de los tiempos clásicos, el *pater* podía disolver el matrimonio de sus hijos sometidos a su *patria potestas*. Esta superioridad manifiesta de dicha potestad fue derogada en tiempos de Antonino Pío (Paulo, 5.6.15) o de Marco Aurelio (C.5.17.5, Diocl.; Ulp., D.24.1.32.19; D.43.30.1.5).

C) Hasta el final de la época clásica regirá el principio general de la libertad para divorciarse. Por tanto, los pactos de que no fuera lícito divorciarse, ni las estipulaciones que aportaban penas al que se hubiese divorciado, no eran válidas (Paulo, D.45.1.134 pr.; Alej. Severo, C.8.39 (38).2; año 223).

1. Esta libertad quedaba limitada no tanto por las costumbres, como por las consecuencias económicas resultantes de la devolución de la dote. Hay mordaces sátiras al respecto: "Nada hay más intolerable que una mujer rica" (Juv., 6.460), y Marcial (S.12.1.2) declara que jamás tomaría por mujer a una mujer adinerada, porque no quiere vivir ahogado por el velo nupcial.

2. Si una liberta casada con su patrono se divorcia de éste, el acto es válido, pero la mujer perdía el *conubium* para contraer nuevas nupcias (C.5.5.1; C.6.3.9).

3. En cuanto al uso de las expresiones usadas, en un principio se había usado la palabra *repudium*, como derecho del marido. Cuando la mujer también se podía divorciar, se hablaba de *divortium*. Pero ya luego, los vocablos son utilizados ambivalentemente para el divorcio producido por el marido o por la mujer. Así, respecto de *divortium*: Gayo, D.24.2.2; D.50.16.191; Paulo, D.24.2.9; D.24.1.57. Y respecto de *repudium*: Quintiliano, *Declam.* 147; Ulp., D.24.2.4; C.5.17.9; C.5.17.8; etc.

D) Cuando comienza la época cristiana, la vigencia del divorcio continuó. Los emperadores, aun cristianos, no llegaron a la aceptación de la doctrina de los Padres de la Iglesia acerca de la indisolubilidad del matrimonio. En cambio, mantuvieron un criterio restrictivo —no en el caso de divorcio convenido por mutuo acuerdo— para el supuesto de separación unilateral, señalando penas económicas, y aun personales cuando se realizaba sin causa justificada. Además, se restringió la posibilidad de nuevas nupcias.

1. Así, Constantino (C.Th.3.16.1; año 331) permitía el repudio por parte del marido por tres causas justificadas: si la mujer era adúltera, envenenadora o alcahueta. Si fuera por otra causa, el divorcio es válido, pero debía devolver toda la dote y no se podía casar con otra; y si lo hiciera, la primera mujer podía entrar en la casa de su ex marido, y tomar para sí, por causa de injuria, toda la dote de la segunda mujer.

En cambio, la mujer no podía repudiar a su marido por ser bebedor, jugador o mujeriego, pero sí si probaba que era homicida, envenenador o violador de sepulcros. En estos casos, la mujer se quedaba con toda la dote. Pero si se separaba por otras causas, debía abandonar la casa dejando sus bienes, debiendo ser deportada a una isla, por su temeridad.

2. Por una constitución del año 421, los emperadores Honorio, Theodosio y Constantio, hablaron de una manera más general de causas graves y causas leves, sin mencionarlas expresamente.

Si el marido probaba causas graves, se quedaba con la dote recibida de su mujer y podía volver a casarse. Si sólo probaba causas leves, perdía la dote y no podía contraer nuevo matrimonio, sino luego de pasados dos años. Si se divorciaba sin causa alguna, perdía no sólo la dote sino toda donación nupcial (*ante nuptias*) hecha a su mujer, y por supuesto no podía casarse de nuevo.

Si se trataba de la mujer, en caso de que probara causas graves, recobraba la dote, pudiéndose volver a casarse luego de pasados 5 años, "porque entonces se verá que se separó más por aborrecimiento de su marido que por deseo de otro". Si probaba causas leves, perdía la dote y cualquier donación hecha al marido, estando impedida de celebrar nuevas nupcias. Si lo hacía podía ser acusada de adulterio por el anterior marido. Y finalmente, si se divorciaba sin causa, perdía la dote y las donaciones, no podía contraer matrimonio y era desterrada, sin derecho al *postliminium*.

3. Ya en el año 449, Theodosio II y Valentiniano III (C.5.17.8) restablecieron en el sistema de las *culpa*, admitiendo el divorcio por medio del envío de un nuncio que denunciara el *repudium*. Ahora las culpas admitidas y expresamente señaladas son las anteriormente denominadas graves. Es de destacar que desde ahora el adulterio, no sólo de la mujer, sino del marido, es causal grave. Con lo cual en este aspecto quedaban equiparados.

El marido culpable debe devolver la dote y pierde la donación *ante nuptias*. Su mujer puede casarse después de un año. La mujer culpable pierde la dote y la donación nupcial. Y no puede volver a casarse sino después de 5 años. Y si se casaba antes era declarada infame y la unión no era considerada matrimonio. El marido podía volver a casarse (C.cit.4-5).

4. El divorcio por mutuo consentimiento era lícito (C.cit.1). El emperador Anastasio (C.5.17.9, año 497) permitía que la mujer volviera a casarse luego de pasado un año.

E) Justiniano continuará la línea posclásica, pero con marcada restricción de la libertad de divorcio. En su régimen (Nov.22.4) había que distinguir las siguientes clases de divorcio:

a) *Divortium ex iusta causa*. Las causas van a ser enumeradas taxativamente, tanto para el marido como para la mujer.

1. El marido podía divorciarse *ex iusta causa*: a) si la mujer supiera de una conspiración contra el emperador y no le hubiese avisado al marido; b) por adulterio de la mujer; c) si la mujer hubiese atentado contra su vida; d) si, no queriendo el marido, comiera con extraños, o se bañara con ellos; e) si, no queriendo el marido, se quedara fuera de su casa, a no ser la de sus padres; f) si no sabiendo el marido, o habiéndoselo éste prohibido, asistiera al circo o al teatro, etc. (Nov.cit.8).

2. Las causales que podía invocar la mujer eran: a) si el marido hubiere conspirado contra el emperador, o sabiendo que lo estaban haciendo otros, no los hubiera denunciado; b) haber atentado contra su vida, o atentando otros no la hubiese defendido; c) si la hubiera incitado al adulterio, entregándola a otros hombres; d) si el marido la hubiese acusado falsamente de adulterio; e) si el marido viviera en otra casa con otra mujer, habiendo sido advertido por dos veces por sus padres, o los de la mujer, u otras personas dignas de fe (Nov.cit.9).

3. En cuanto a los efectos, si la mujer es la culpable *ex iusta causa*, pierde la dote y no puede exigir la donación *propter nuptias*, que queda en propiedad de su marido, o en usufructo si hay hijos (Nov.117.8 pr.).

El marido que es culpable *ex iusta causa*, debe devolver la dote y paga la donación *propter nuptias*. Ésta es adquirida por la mujer, y si hay hijos, éstos son los nudos propietarios, gozando la mujer del usufructo (Nov.117.9 pr.).

En caso de no haber dote o donación *propter nuptias*, el cónyuge culpable debe entregar al inocente una cuarta parte de sus bienes hasta un máximo de 100 libras de oro. Se aplica esto tanto respecto del marido como de la mujer (Nov.22.18, año 536).

b) *Divortium sine causa*, o sea, cuando uno de los cónyuges, de manera unilateral, y sin existir las causas graves enunciadas, se divorcia (Nov.22.4).

1. Acá las penas son mayores por cuanto no existen justas causas. La mujer que ha repudiado sin causa, pierde su dote, que pasa a su marido en propiedad, y si hubiera hijos, en usufructo.

Pero, aparte de ello, la mujer debe entrar en un monasterio "mientras viviere". Si tuviera hijos, debe darles los 2/3 de sus bienes y el tercio restante al monasterio. Si no tuviere hijos, debía dar dos partes

de sus bienes al monasterio y la otra restante a sus padres, salvo que teniéndola *in potestate* hubiesen dado su consentimiento al repudio sin causa, en cuyo caso todos los bienes van al monasterio donde deberá entrar (Nov.117.13, año 542).

Si el marido es el que ha producido el repudio sin causa, deberá devolver la dote así como la donación *propter nuptias*. Además, deberá darle de sus bienes un monto equivalente a la tercera parte de la donación nupcial. Si hay hijos, la mujer sólo tendrá de la donación, y de este agregado del tercio, sólo el usufructo (Nov.117.13, año 542).

2. Luego, en la Novela 134.11 (año 556), viendo que se continuaban los repudios sin causa, tanto si lo hubiera hecho el marido como la mujer, eran enviados a un monasterio. Si hay hijos, éstos se harán propietarios de los bienes. Si no los hay, los ascendientes recibían 1/3, yendo los 2/3 restantes al monasterio. Si tampoco hay ascendientes o éstos hubieran consentido en el repudio, todos los bienes van al monasterio.

3. Por una constitución del año 538, Justiniano estableció que si alguien tomaba mujer en matrimonio "poniendo la mano sobre las Sagradas Escrituras, o jurando en casas de oración" no podía repudiarla sin causa. Y si la echaba de la casa "prescindiendo de lo ordenado en la ley", la mujer podía enviarse el repudio y reclamar, incluso si el marido muriese antes, la cuarta parte de sus bienes, aunque se hubiese unido sin dote ("porque ¿qué otra cosa hará la que no tiene para dotarse, que entregarse ella misma por toda dote?"; Nov.74.5).

c) *Divortium communi consensu*, es decir, por acuerdo común (Nov.22.4). Pero luego, el divorcio por mutuo consentimiento queda abolido por Justiniano (Nov.117.10, año 542), salvo por razón de castidad. Esto significó una innovación respecto de la tradición anterior. Justino II, sucesor de Justiniano, lo volvió a restablecer (Nov.140, año 566).

1. Justiniano, en ese breve interludio en que prohibió el matrimonio por mutuo consentimiento, salvo por razón de castidad, estableció para este último caso que si el marido o la mujer que se hubieren divorciado contrae otras nupcias o vive lujuriosamente, se les entregue a los hijos, además de la dote y de la donación nupcial, "casi todos los bienes" del patrimonio del que incurrió en esa falta. Si no hubiera hijos los bienes van al fisco (Nov.117.10).

2. Justino, al restablecer el divorcio por mutuo consentimiento, declaró libre de penas a esta forma de disolución del divorcio.

d) *Divortium bona gratia*, o sea, cuando el divorcio no es imputable a una causa culpable de uno de los cónyuges. Este divorcio está libre de penalidades.

1. Esto ocurría: (i) por el ingreso de uno de los cónyuges en la vida monástica (Nov.22.5); (ii) por la impotencia del marido para realizar la unión sexual, luego de transcurridos tres años de matrimonio (Nov.22.6; C.5.17.10); no se habla de la imposibilidad de la mujer; (iii) el caso de cautiverio de un cónyuge, una vez transcurridos 5 años, siendo incierta la suerte de él (Nov.22.7); (iv) en favor de la mujer, la ausencia de su marido por causa de milicia, luego de haber transcurrido 10 años, con incerteza de la voluntad del marido de querer permanecer en matrimonio (Nov.22.14).

2. Luego, en la Novela 117.12 del año 542, reduce estas causas de divorcio *bona gratia* a solamente tres: a) impotencia del varón; b) entrada en la vida monástica de uno de los cónyuges; y c) cautividad de uno de ellos.

OTRAS UNIONES LÍCITAS

§ 549. I. *Concubinatio*. El concubinato es una comunidad de vida sexual duradera entre un hombre y una mujer, pero que es distinta del matrimonio. Por su carácter duradero se diferencia de una mera unión sexual transitoria. Desde esta punto de vista no tiene nada que ver con la mera "unión en pareja" de los tiempos actuales. Pero carece de la *affectio maritalis*, razón por la cual no se puede hablar del *honor matrimonii*, que es nota típica del matrimonio. Es, pues, una unión lícita, pero ilegítima (*licita consuetudo, causa non matrimonii*; C.6.57.5 in fine; Modest., D.48.5.34). Como lo dice Ulpiano (D.32.49.4), la única diferencia con el matrimonio es la *dignitas* debida a la mujer.

1. Aparte de no estar castigada legalmente, tampoco estuvo reprobado por las costumbres. Era ya conocido por los antiguos, según lo dice Massurio, refiriéndose a la unión con la que "no siendo mujer casada, vivía, sin embargo, con alguno, a la cual se la llama ahora con el nombre de *amica*", y algo más honestamente con el de *concubina* (Paulo, D.50.16.144). Incluso emperadores como Antonino Pío y Marco Aurelio, que no tenían nada de disolutos, tuvieron concubinas (*Script.Hist.Aug.*, Pío 8.9; Marco, 29.10).

A) No existió propiamente un tratamiento jurídico del concubinato, que más bien quedaba regulado por las costumbres. La legislación augustea le vino a dar incidentalmente un lugar.

En efecto, las leyes *Julia de adulteriis* y *Julia et Papia*, castigaban el *adulterium* (unión con una mujer casada) y el *stuprum* (unión sin matrimonio con ingenua o viuda respetable); Pap., D.48.5.6.1. Pero dejó sin sanción la unión no matrimonial con las mujeres de baja condición social, con las cuales (caso de la unión de

un senador con una liberta) existía una prohibición de matrimonio. De este modo, resultaba por ello posible unirse con ellas en concubinato.

1. Como el concubinato no es matrimonio, no hay ni *vir* ni *uxor*, ni dote, ni *patria potestas*. Los hijos habidos serán en principio *spuri* o *vulgo concepti*, aunque más tarde serán llamados *naturales liberi* (C.5.27).

2. El concubinato estaba exento de las penas de las leyes augusteas. Por ello, se podía tomar por concubina a mujeres de mala vida, actrices, e incluso mujeres adúlteras (Ulp., D.25.7.1.2; Marciano, D.íd. 3 pr.; Marcelo-Marciano, D. íd. 3.1). El gobernador de provincia podía tener una concubina habitante de ésta, aunque no se podía casar con ella (Paulo, D.íd. 5).

3. Por no estar comprendido en la *lex Iulia de adulteriis*, la concubina adúltera no puede ser perseguida por dicho adulterio (Marcelo-Marciano, D.25.7.3.1).

B) Con los emperadores cristianos comienza a existir una cierta necesidad de referirse al concubinato, al cual la Iglesia mira con disfavor.

Así, Constantino negó a los concubinos y a sus hijos toda posibilidad de sucesión patrimonial (donación o testamento; C.5.26.1, año 336). Esta medida fue luego revisada por Valentiniano (C.Th.4.6.4, año 371). Igualmente, como ya lo vimos, Constantino ofrecerá a los concubinos legítimos a sus hijos mediante el matrimonio subsiguiente.

La idea era que cumplimentando cristianamente la comunidad de vida, había que reconocer la unión, aun cuando faltara la voluntad de casarse. El concubinato es considerado como de categoría inferior a las nupcias (*inaequale coniugium*; C.5.27.3).

C) Justiniano suprimió la distinción entre mujeres *honestae* y *non honestae conditionis*, de tal modo que un hombre podía casarse con mujeres honestas o mantener un concubinato. La diferencia entre ambas uniones dependía de la intención del ánimo (*sola animi destinatione*; Paulo, D.25.7.4; *solo dilectu*; Paulo, 2.20). Si se trataba de una mujer ingenua y honesta, había que hacerlo saber por una declaración (*testatio*) que probara la ausencia de la *affectio maritalis*. De lo contrario, si no se casaba, se cometía *stuprum* (Marciano, D.25.7.3 pr., itp.).

Terminará por darle al concubinato todo un estatuto legal:

a) El soltero podrá tener sólo una concubina (Nov.18.5; 89.14.4 ss.); en cambio, le está prohibido al casado vivir también en concubinato (Constantino, C.5.26.1, año 326; Zenón, C.5.27.5 pr., año 477).

b) La concubina debía tener 12 años de edad (Ulp., D.25.7.1.4 itp.), rigiendo los mismos impe-

dimentos de parentesco y afinidad que respecto del matrimonio (Ulp., D.28.2.56; D.25.7.1.3).

c) La separación o disolución entre concubinos no tenía formas ni causas. Sin embargo, la concubina del paterno se podía separar contra la voluntad de éste, pero no podía contraer matrimonio posterior (Ulp., D.25.7.1 pr., itp.).

d) En cuanto a los derechos hereditarios, el padre puede testar en favor de la concubina y de los hijos, variando sus cuotas según la existencia de herederos legítimos. Lo mismo, en las Novelas, para el caso de la herencia *ab intestato* se le otorgará una cuota de 1/6 que se deberán repartir la concubina y los hijos naturales (C.5.27.12, año 530; Nov.18.5, año 536; Nov.89.12.4).

§ 550. II. *Matrimonio sine concubio*. Se trata de la unión matrimonial entre un hombre y una mujer, de los cuales uno de ellos no tiene el *concubium*. Así, entre un ciudadano romano y una latina, o una peregrina, o entre dos peregrinos. La unión es lícita, pero no produce los efectos de las *iustae nuptiae*.

Este matrimonio *sine concubio* podía, por determinados procedimientos, transformarse en *iustae nuptiae* (v. *supra*, § 503).

1. Los hijos habidos siguen la condición de la madre, de la cual es cognado. Según la *lex Minicia* (siglo II a.C.), si la madre casada con un extranjero era ciudadana romana, el hijo nacía, sin embargo, extranjera. Pero esto fue modificado por un s.c. de Adriano, de tal modo que es considerado ciudadano romano (Gayo, 1.77-78).

2. Cuando todos los habitantes alcanzan la ciudadanía romana este matrimonio resulta raro. Con Justiniano, que ha suprimido la categoría de latinos junianos, sólo resulta aplicable para el caso de perderse la ciudadanía por causas políticas (*deportatio*). Pese a que Paulo (D.25.3.56) indica que el matrimonio habido se extingue, en otros textos del Digesto se da la solución contraria, siempre que haya consentimiento entre marido y mujer (Ulp., D.48.20.5.1; C.5.17.1; Nov.22.13).

3. El matrimonio entre extranjeros se rige en principio por el derecho local. El marido puede acusar de adulterio a su mujer (Ulp., D.48.5.13.1).

§ 551. III. *Contubernium*. Es la unión entre esclavos o entre una persona libre y una esclava. Es considerada un simple hecho que está permitido; pero sin los efectos del matrimonio (Paulo, 2.19.6; C.7.16.3; C.6.59.9). A comienzos del Imperio se admitió una especie de *cognatio servilis* (Labeón-Ulp., D.2.4.4.3: para que el hijo nacido de concubinato no pudiera citar a su padre a juicio; Pomp., D.23.2.8; para impedir que el esclavo vuelto libre se pudiera casar con la madre o hermana de su mujer; D.íd.14.2-3; Inst., 1.10.19).

CAPÍTULO 3

TUTELA Y CURATELA

§ 552. Hay ciertas personas que no obstante ser *sui iuris* —y por ello poder tener bienes— de hecho se hallan incapacitados para poder desenvolverse en los negocios. Hoy día, se hablaría de que si bien tienen "capacidad de derecho", carecen de "capacidad de hecho". Siendo así, se les otorga una protección jurídica por medio de la tutela y de la curatela. Esta protección atiende al mismo tiempo el interés del patrimonio familiar.

La tutela se otorga a los incapaces por razón de edad, es decir, a los impúberes, sean varones o mujeres, que sean *sui iuris*. Es el caso de los huérfanos por haber muerto el *pater*, o por resultar emancipados antes de llegar a la pubertad. También —por lo menos hasta cierta época del derecho clásico— existirá una tutela para las mujeres *sui iuris*, cualquiera que fuere su edad (*tutela mulierum*).

En cambio, la curatela tiende a proteger ciertas incapacidades más anormales o accidentales. Así, las más antiguas fueron la de los dementes (*furiosi*) y la de los pródigos.

Atendiendo sus características propias, tutela y curatela mantendrán regímenes distintos. Pero a medida que se fue generalizando la curatela de los menores de 25 años, ambas instituciones irán aproximándose cada vez más, sobre todo en el derecho posclásico.

TUTELA

§ 553. *Concepto*. Según Servio Sulpicio Rufo (cónsul en el 51 a.C.), la tutela es "la fuerza y potestad sobre una persona libre, dada y permitida por el *ius civile* para proteger a aquel (o a aquella) que por razón de su edad (o de su sexo) no puede defenderse por sí mismo" (*vis ac potestas in capite libero ad tuendum eum (eam) qui propter aetatem (vel sexum) sua sponte se defendere nequit, iure civili data ac permissa*; Inst., 1.13.1; Paulo, D.26.1.1 pr.).

1. Tutela deriva del verbo *tueor*, una de cuyas acepciones significa "proteger". Por ello se habla de los tutores *quasi tutores atque defensores* (como protectores y defensores; Inst., 1.13.2).

2. La expresión *vis ac potestas* (fuerza y potestad) es una expresión técnica usada por los romanos. Así, respecto de las leyes: "Saber las leyes no es conocer sus palabras, sino su *vis ac potestas*" (Celsus, D.1.3.17); o respecto de un interdicto (Inst., 4.15.3), o de un codicilo (C.6.36.7), o de los metales empleados como intercambio cuando no había aún moneda (Gayo, 1.122).

3. Si bien la tutela es definida como una *potestas*, este poder difiere del de la *patria potestas*. El pupilo (*pupillus* = "muñequito", del latín *pupus*) que está *in tutela*, no está *in potestate*, puesto que es un *sui iuris*. El tutor no tiene como el *pater* el *ius vitae necisque* y el *ius vendendi*. Su poder se dirige a la protección del patrimonio del pupilo, así como a su cuidado personal y educación (Paulo, D.26.7.12 3; Gayo, D. íd., 13), aspectos, estos últimos, que pueden quedar relegados a la madre o a otro pariente.

4. La expresión "cabeza libre" no se refiere a hombres libres, sino a los libres que estén libres de *potestas*. Tal el caso de los impúberes, varones o mujeres, huérfanos o emancipados. O el de las mujeres *sui iuris* ya púberes, cualquiera que fuere su edad. Al desaparecer esta tutela de las mujeres, los bizantinos eliminaron toda referencia a ella, pero parece normal que los vocablos entre paréntesis, debieron haber estado en la definición de Servio Sulpicio.

5. Si bien se la encuentra en el *ius gentium*, por cuanto en todos los pueblos se protege a los incapaces por razón de la edad, y a veces también por razón de sexo, la tutela es dada y permitida por el *ius civile*. Por ello es que las reglas romanas le dan un régimen particular (Gayo, 1.139).

I. Tutela de los impúberes.

§ 554. La antigua tutela romana de los impúberes tenía un doble carácter. Por un lado, proteger al pupilo, pero por el otro el cuidado de que los bienes familiares no sean dilapidados. Es así que en los primeros tiempos, lo que existía era la tutela de los agnados, quienes eventualmente podían tener interés en la preservación de los bienes del pupilo, a quien, llegado el caso, podrían heredar.

Pero, a medida que trascurren los tiempos republicanos, la tutela se irá transformando, subrayándose el papel de protección del pupilo. A ello no es ajeno

que el pretor, a falta de tutor testamentario o legítimo, pueda dar un tutor al pupilo.

De este modo, pasará a ser una carga pública (*munus*), lo que conlleva la idea de un deber obligatorio para el designado (aunque por una justa causa se podía excusar de aceptarla). El tutor tiene un cargo privado—no público—. La función del magistrado se limita a una vigilancia en el cumplimiento de la tutela.

CLASES DE DACIÓN DE LA TUTELA

En el derecho clásico se distinguen tres clases de *tutela impuberum*, según la forma como ésta se define:

a) *Tutela testamentaria*: aquí el tutor es elegido y designado por la voluntad del *pater* en un testamento.

b) *Tutela legítima*: a falta de la anterior, la designación está dada por la ley de las XII Tablas, al agnado próximo.

c) *Tutela por decreto del pretor*: ello ocurre a falta de las anteriores.

§ 555. I. *Tutela testamentaria de los impúberes*. El *paterfamilias* puede dar en su testamento tutor a todos aquellos descendientes suyos que estén sometidos a su *patria potestas*; sean varones o mujeres, para el supuesto de que a su muerte sean impúberes (Gayo, 1.144; Inst., 1.13.3). Igualmente puede dar tutor a los hijos póstumos, ya que de haber nacido viviendo el *pater*, estarían también bajo su *potestas* (siempre y cuando nazcan con vida; Gayo, 1.147; Inst., 1.13.4).

1. Si se diera un tutor a un nieto o a una nieta, sólo tendría eficacia cuando luego de la muerte del testador no hayan de recaer en la *patria potestas* de su padre. Así, A tiene un hijo B *in potestate* y también un nieto C en esa situación. Si a la muerte de A el nieto C queda bajo la *potestas* de B, la dación originaria de tutor por parte de A carece de eficacia. La razón es simple: ya está protegido (Gayo, 1.146; Inst., 1.13.3).

En principio, la dación de tutor por testamento parece basarse en la *patria potestas* (Scaev., D.50.17.73.1). Sin embargo, por constituciones imperiales posteriores se permitió que el magistrado pudiera confirmar tuteladas dadas en un testamento por otras personas (madre, patrono, o incluso un extraño). También, aun cuando se hubiera dado tutor por el *pater* en un testamento irregular o en un codicilo no confirmado, el magistrado podía confirmar al tutor.

2. Los distintos casos pueden ser enunciados así:

a) El *pater* puede dar tutor al hijo emancipado,

o al dado en un testamento irregular o en un codicilo no confirmado (Inst., 1.13.5; Mod., D.26.3.1.1; D.f.d.3; id. 10). En estos casos de irregularidad se hace prevalecer la voluntad real del *pater* sobre los aspectos formales. De todos modos, el magistrado debía confirmar al tutor.

b) Si la madre instituye heredero a su hijo por testamento, podía también darle tutor. En este caso la confirmación del magistrado había que hacerla previa *inquisitio*, es decir, investigando las condiciones morales y patrimoniales del tutor dado y la conveniencia del pupilo (Neracio, D.26.3.2).

c) Si el patrono del impúber, o aun un extraño, lo institúa heredero, le podía también dar tutor. Acá, al igual que en el caso anterior, la confirmación del magistrado se debía hacer previa *inquisitio* (Paulo, D.23.3.4).

En todos estos casos, la tutela, no obstante la confirmación del magistrado, se interpretaba que era "testamentaria", y no *decretalis*, lo que permitía eludir la tutela legítima.

d) Justiniano (C.5.29.4, año 530) le permite al padre dar tutor a un hijo natural, siempre y cuando le hubiere dejado bienes en el testamento.

§ 556. El nombramiento del tutor testamentario debía ser producido en forma nominal: "Doy a Lucio Ticio por tutor de mis *liberi*" (Gayo, 1.149). Pero, al ir perdiendo importancia las formas, bastaba que la expresión de la voluntad resultara afirmativamente aceptable. Era siempre más libre que la de institución de heredero. Así, podía ser hecha bajo condición o con un plazo (hasta cierto tiempo o desde cierto día; Inst., 1.14.3). Incluso se la podía hacer antes de la institución de heredero, según la tesis proculeyana, que fue la que prevaleció (Gayo, 2.230-231; Inst., *ibid.*).

1. En caso de nombramiento de tutor bajo condición o plazo, durante el tiempo intermedio, el magistrado debía designar otro tutor que ejerciera la tutela, hasta que se dilucidara la condición o se cumpliera el plazo (Ulp., D.26.2.11. pr.).

2. Por testamento se puede dar como tutor al esclavo propio, siempre que se lo manumita. El problema se planteaba si se lo nombraba como tutor al esclavo del testador sin decir nada de su libertad. Paulo (D.26.2.32.2) entiende que al nombrarlo como tutor se le está otorgando directamente la libertad. Justiniano también se inclina por esta solución (Inst., 1. 14.1).

Pero si se trata del nombramiento de tutor de un esclavo ajeno, sólo es admisible con la condición de "cuando fuere libre" (Inst., 1.14.1). En el texto de Ulpiano (D.26.2.10.4), curiosamente, se establece que dicha condición está agregada implícitamente, y que se trata de una libertad dejada por fideicomiso.

3. Igualmente se termina admitiendo que el *pater*

puede en su testamento dar como tutor a un *filiusfamilias* (Inst., 1.14 pr.).

§ 557. El tutor testamentario—ocasionalmente llamado *tutor dativus*; Gayo, 1.154; Ulp., 11.14—comienza sus funciones desde que el testamento produzca sus efectos: si el pupilo es un *surus heres*, desde la muerte del testador; si es un heredero extraño, desde que acepte la herencia; y cuando sea necesaria la *confirmatio*, desde que ésta se produzca.

Dado el sentido de *fides* que sustenta su nombramiento, el tutor no puede ceder la tutela, aunque sí renunciar directamente (*abdicatione tutelae*; Ulp., 11.17). Sin embargo, desde la época de Claudio, se perfila el criterio de que el tutor testamentario sólo puede no hacerse cargo de la tutela si da razones valederas (*excusationes*). De este modo, el *ius se abdicandi* es reemplazado por el genérico *ius se excusandi* (Gayo, 1.182).

§ 558. II. *Tutela legítima de los impúberes*. En caso de no haber designación de tutor en un testamento, la ley de las XII Tablas (Ulp., 11.3) instituye como tutor al heredero varón más cercano al pupilo, es decir, a su "agnado próximo" (el hermano, el tío, etc.). En caso de no haber agnados, son llamados los gentiles (Gayo, 1.155 ss.; 1.164).

1. Vemos acá un neto paralelismo y vinculación entre tutela y herencia, ya que a ésta, siendo *ab intestato* y a falta de "herederos suyos", son llamados los agnados próximos. La única diferencia está dada en que las mujeres agnadas pueden ser herederas, pero no pueden ser tutoras, por ser un cargo viril.

2. Se sigue el orden de precedencia del grado, es decir, los agnados de grado más cercano desplazan a los más lejanos. Si hubieran varios del mismo grado, todos ellos la ejercen en forma conjunta (Gayo, 1.155; Ulp., 11.3). Se requería la *auctoritas* por parte de todos (Ulp., 11.26). Esto varió en la época de Justiniano, quien decidió que bastaba la *auctoritas* de uno solo de los tutores, salvo para un acto tan grave como la *adrogatio* del impúber, que extingue la tutela (C.5.59.5).

3. Si el agnado a quien le correspondiera la tutela era un impúber, el ejercicio de ella quedaba en suspenso hasta que llegara a la pubertad, pasando temporariamente al que continuara en grado.

4. El tutor legítimo no puede rehusar el cargo (*abdicare*); aunque luego se podrá acoger al régimen de las "excusaciones". Tampoco pueden ceder la tutela (Gayo, 1.168; Ulp., 11.8).

5. La tutela de los gentiles desaparece costáneamente con la declinación de la *gens*. En el Bajo Imperio, Anastasio (año 498) acuerda la tutela legítima a los hermanos emancipados del impúber, con preferencia a los agnados de grado más aleja-

do (C.5.30.4). Finalmente, Justiniano, en la Novela 118 (c.5), sustituye la cognación a la agnación, como fundamento de la tutela legítima. Se trata del mismo criterio que sigue con la herencia *ab intestato*.

§ 559. Casos especiales:

A) Estableciendo un paralelo con lo que decía la ley de las XII Tablas acerca de la herencia, por vía de interpretación se admitió la tutela legítima del patrono y de sus hijos respecto de los libertos y libertas impúberes (Gayo, 1.165; Ulp., 2.13; Inst., 1.17).

B) Además, *ad exemplum* del caso anterior, se considera tutor legítimo al *pater* respecto del hijo o nieto impúber emancipado (*tutor fiduciarius*; Gayo, 1.166; Ulp., 11.5; Inst., 1.19).

C) Si en el caso anterior el *pater* muere dejando hijos varones, éstos se hacen tutores "fiduciarios" del hermano o hermana impúber. Sin embargo, esta tutela que es "fiduciaria" no es, como en el caso de los hijos del patrono, una tutela legítima (Inst., 1.19).

1. Esta diferencia procede de que el hijo del difunto, si el *pater* no lo hubiera emancipado en vida, a la muerte de éste habría sido *sui iuris*, sin pasar a la potestad de sus hermanos, y por tanto, no está sujeto a la tutela legítima de ellos. Pero, en cambio, el liberto, si hubiera permanecido esclavo, siempre habría estado sometido a la *dominica potestas* de los hijos del *dominus* (Inst., 1.19).

2. Lo mismo sucedía si un tercero que tenía el hijo *in causa mancipii*, lo manumitía. El *manumissor extraneus* es considerado como tutor fiduciario, ya que entre él y el *pater* mediaba un pacto de fiducia para emanciparlo luego de la tercera venta (Ulp., 11.5). Esta forma no existe en la época de Justiniano debido a la desaparición de las viejas formas de la emancipación (v. *supra*, § 511).

§ 560. III. *Tutela constituida por el pretor* (*Tutela impuberum decretalis*). Si no había tutor testamentario, ni tampoco legítimo, en principio, el impúber *sui iuris* quedaba sin tutor. Fue así que por la ley *Atilia* (en realidad un plebiscito debido al tribuno L. Atilio Régulo; debió ser anterior al año 186 a.C.), el pretor urbano, asistido por la mayoría de los tribunos de la plebe, podía designar un tutor (*tutor Atilianus*), tanto en Roma como en Italia. Posteriormente, otra ley *Iulia et Titia* (año 81 o 25 a.C.), extendió esta autorización para que en las provincias los gobernadores pudieran dar tutor (Gayo, 1.185; Ulp., 11.24; Inst., 1.20 pr.).

1. Este tutor es denominado por Justiniano *tutor dativus* (en C. 1.3.51 pr.; no en Inst.). El término es

equivoco, ya que Gayo (1.154) distingue en la tutela testamentaria al *adivus* del *optivus* (cuando a la mujer se le dejaba optar por el tutor que quería). Sin embargo, el mismo Gayo (1.135) emplea el verbo *dare* para referirse al tutor abiliano.

2. Luego, por lo menos en Italia, por medio de un s.c. debido a Claudio (Suet., *Claud.*, 25) se dispuso que la nominación de tutores la efectuaran los cónsules (Inst., 1.20.3). Más tarde, Marco Aurelio y Lucio Varo crearon un pretor especial (*praetor tutelaris*), quien se encargaría en Roma de tales nombramientos (Inst., *ibid.*); en cambio, en las provincias esto recaía en los *iuridici* (FV, 232).

3. En la época de Justiniano, el nombramiento en la capital correspondía al pretor o al *praefectus urbi*. En las provincias, si la fortuna del impúber excedía de 500 sólidos, podía designarlos el gobernador por sí o por orden suya. Si era de monto inferior, los nombraba el *defensor civitatis*, asistido por el obispo y magistrados locales (Inst., 1.20.4-5; C.1.4.30, año 531).

4. El nombramiento era efectuado a petición de cualquiera, incluso del propio pupilo. En algunos casos, como p.ej. la madre, ésta estaba obligada especialmente a pedirlo, bajo sanción de perder los derechos hereditarios (Mod., D.26.6.2).

§ 561. *Excusaciones*. A) Con la aparición de esta nueva clase de tutela, se pierde el viejo sentido egoísta (tanto del testador, como de los parientes) para transformarse en un *munus publicum*, con lo que era una carga *onus* que interesa a la *cura publica* (Severo, en D.26.6.2.2). Por ello es irrenunciable. Tampoco pueden cederla a otro (Gayo, 1.168; Ulp., 1.1.6). Lo único que podían hacer los designados tutores es alegar motivos fundados (*excusaciones*) para no ejercerla, los cuales eran apreciados por el magistrado. Este régimen de excusaciones rige ahora para todas las tutelas.

1. En Inst., 1.25, hay una lista bastante larga de estas excusaciones. Así, a) por tener 3 hijos vivos en Roma, 4 en Italia o 5 en provincias (Inst., *id.* pr.); b) por ejercer una magistratura o ser funcionario (*id.* 3); c) por tener tres cargas de tutela (*id.* 5); d) por ser pobre (*id.* 6); e) por salud quebrantada (*id.* 7); f) por no saber escribir (*id.* 8); g) por ser mayor de 70 años (*id.* 13); etc.

2. El pedido de excusación hay que hacerlo ante el magistrado dentro del plazo de 50 días continuos a partir del momento en que conoció su nominación. Según una constitución de Marco Aurelio este plazo era concedido a los tutores designados que vivieran a menos de un radio de 100 millas del lugar en que ha sido nombrado. Si vivía más allá de dichas 100 millas, el plazo en principio era distinto: se contaba un día por cada 20 millas, a los que se agregaban 30 días más. Así, si vivía a 300 millas, tendría un plazo

de 15 días (300 millas divididas por 20) más 30 días más, o sea, un total de 45 días. Sin embargo, los juristas estimaron que en todos los casos el pretor designado no podía nunca ser inferior a 50 días (Mod., D.27.1.13.2), criterio que seguirá Justiniano (Inst., 1.25.15).

El mismo Marco Aurelio estableció que si alguien era nombrado tutor, no podía apelar. Debía invocar una causa de excusación; si ésta era rechazada, podía presentar una nueva, siempre dentro del plazo fijado. Sólo en caso de ser rechazada se podía apelar (Ulp., D.49.4.1.1; Inst., 1.25.16).

3. En la época posclásica, el designado como tutor podía descargarse del *munus* invocando el *ius nominandi tutoris*, es decir, señalando una persona solvente, honesta y preferible a él, a causa de su parentesco con el pupilo (FV, 157-8). Bajo Justiniano no se menciona esta posibilidad de la *potioris nominatio*.

B) Por ser un *munus virile*, las mujeres no pueden ejercer la tutela, ya que es un *officium* "superior al sexo de la debilidad femenina" (C.5.35.1). Pero desde Theodosio (año 390) se admite que la madre pueda ser tutora. Y Justiniano amplía aún más esta posibilidad.

1. La permisión a la mujer para ser tutora establecida por Theodosio y ampliada por Justiniano puede resumirse así: sólo la madre, o en su defecto la abuela viudas, podían ser tutoras de sus hijos legítimos y naturales, siempre y cuando lo pidieran y además cumplieran estos otros requisitos:

- a) que sean mayores de edad (25 años; C.5.35.2.3);
- b) que juraran no volver a casarse (C.1d.2 pr.); luego el juramento es reemplazado por una promesa, cuya inobservancia arrastra la conveniencia de que la mujer abandone la tutela (Nov.94.2); además, el hijo tendrá una hipoteca legal sobre los bienes del segundo marido (C.1d.2.2); y
- c) que renunciarán a los beneficios del s.c. *Velleianum* que protegía a la mujer que se obligara por terceros, otorgándose una *exceptio s.c. Velleiani* (Nov.118.5).

C) En forma gradual, algunas causas de excusación se fueron convirtiendo con Justiniano en incapacidades propiamente dichas. Así: a) los menores de 25 años, que antes podían excusarse, no pueden ser directamente tutores (Inst., 1.25.13; C.5.30.5); b) lo mismo ocurre con los obispos y los monjes (Nov.123.5); c) y también si el tutor designado es acreedor o deudor del pupilo (Nov.72.1); si callaba esa circunstancia, siendo acreedor no podrá reclamar el crédito, y siendo deudor del pupilo no podrá alegar ningún pago que hiciera figurar en las cuentas (Nov. 72.3-4).

EJERCICIO DE LA TUTELA

§ 562. I. Obligaciones anteriores al ejercicio.

A) *Inventario*. El tutor debe hacer ante todo un inventario de los bienes del pupilo. En la práctica esto está conectado con la obligación posterior de la rendición de cuentas. Si el tutor, sin excusa válida, no ha hecho el inventario, resulta responsabilizado por dolo, debiendo indemnizar al pupilo de todo perjuicio que le pudiera haber causado. La indemnización resulta fijada por la estimación bajo juramento del pupilo (Ulp., D.26.7.7 pr.).

B) *Cautión*. Algunos tutores debían prestar garantía (*cautio rem pupilli salvam fore*) para asegurar que el patrimonio que van a administrar no ocasionaría perjuicios por sus actos (Gayo, 1.199; Inst., 1.24 pr.). Los que debían prestar esta cautión eran principalmente los tutores legítimos. Los tutores testamentarios no están obligados a dar esta cautión "porque la *fides* y la *diligentia* están reconocidas por el propio testador" (Gayo, 1.200; Inst., 1.24 pr.). En cuanto a los designados por el magistrado, generalmente tampoco se les exige cuando ha mediado *inquisitio*, porque el magistrado ha entendido qué se trata de personas idóneas (Inst., *ibid.*).

Como se sabía el eventual monto por el cual debería responder el tutor, la *cautio* no consistía en una cosa o en un monto de dinero, sino que se daban garantes (*fideiussores*) que se comprometían por los actos del tutor que significaran responsabilidad (Ulp., D.46.5.7).

1. La *lex Atilia* no decía nada de la *cautio*. Parece haber sido introducida por los cónsules (Inst., 1.20.3), siendo reglamentada por constituciones posteriores. Si el tutor rehusaba dar la *cautio*, puede ser forzado a ello por toma de bienes en prenda (*pignus*) en favor del pupilo (Inst., 1.24.3).

2. Para dar la *cautio*, el o los garantes se la prometían al propio pupilo. Si éste estuviera ausente o era un *infans*, uno de sus esclavos estipulaba por él. Si no lo tenía se podía usar un esclavo público (Ulp., D.46.6.2; Gayo, D.1d.6). Luego se admitió que los garantes designados por el tutor, que dejaban inscribir sus nombres en actas públicas sin oponerse, quedaban obligados como tales (Ulp., D.27.7.4.3).

3. Si por testamento, o el magistrado *ex inquisitione*, han sido dados varios tutores, uno de ellos podía dar la *cautio* a fin de ser preferido en la administración de la tutela a los otros; éstos, a su vez, también la podían ofrecer para participar en el ejercicio de la tutela.

Si nadie la ofrece, el designado para ejercerla en el testamento era el que administraba. Si no había nadie designado para tal función, el tutor es designa-

do por la mayoría o en último caso por el pretor. El mismo procedimiento se hacía en caso de dar el tutor el pretor (Inst., 1.24.1).

4. Para el caso de designación del tutor por el magistrado, en caso de pupilos cuya fortuna no fuera grande (500 sólidos de oro para Justiniano; Inst., 1.20.5), el procedimiento era *sine inquisitione*, debiéndose dar cautión suficiente. Si los magistrados no la pedían o la aceptaban en forma insuficiente, existe una acción subsidiaria contra dichos magistrados. Así resulta de un s.c. de Trajano (C.5.75.5), resultando responsabilizados también sus herederos (rescripto de Antonino Pio, Ulp., D.27.8.6). En cambio, para las tutelas de mayor cuantía, como la designación se hacía *ex inquisitione*, nunca fueron responsabilizados (Inst., 1.24.4).

§ 563. II. *Ejercicio de la tutela*. En principio, el tutor tiene un amplio poder para administrar y disponer de los bienes del pupilo. Se lo considera *domini loco* (en lugar del dueño; Jul., D.47.2.56.4; Ulp., D.50.17.157 pr.).

Los modos por los cuales puede actuar el tutor son dos: la *gestio* y la *auctoritas*.

A) *Gestio*. Cuando se trataba de un *infans* (o de un impúber ausente), los actos y negocios eran realizados directamente por el tutor. Dado que no se conocía en los tiempos antiguos, ni tampoco en el derecho clásico, la idea de representación directa, la *gestio* del tutor involucraba que los actos eran realizados por él, y los efectos recaían en su cabeza, ya como propietario, deudor o acreedor. Luego, al finalizar la tutela, el tutor debía transferir esas situaciones al pupilo.

1. Esto traía inconvenientes para el pupilo, sobre todo en dos clases de actos:

a) cuando se debía actuar en juicio. En el sistema de las *legis actiones* se permitió al tutor actuar por el pupilo; en el sistema formulario, el tutor podía actuar como *procurator*, dando la pertinente fianza. Y

b) cuando el pupilo era nombrado heredero. No había problema si el pupilo era *heres suus et necessarius*, ya que la recibía de pleno derecho. Pero si era instituido como heredero extraño, ni el pupilo ni el tutor podían aceptar la herencia, por lo menos mientras éste fuera *infans*.

2. Existía el procedimiento de que el tutor ordenara al esclavo del pupilo la realización de un acto jurídico, con lo cual los efectos recaían en el pupilo. Pero esto estaba limitado a los actos que no fueran personales ni que significaran empobrecimiento.

Sin embargo, en el derecho posterior se fue admitiendo un progreso que tendía a una cierta representación del pupilo por parte del tutor. Así:

a) Se admitió que el pupilo pudiera adquirir

la posesión por actos del tutor (Neracio, D.41.1.13 i.º; Paulo, D.41.2.1.20).

b) Igualmente, por una constitución del año 426, Theodosio y Valentiniano decidieron que el tutor podía aceptar la herencia para el pupilo, en el supuesto de que éste fuera aún *infans* (C.6.30.18.2).

c) También se consideraba que el pupilo es el que ha transmitido la cosa por venta o adquirido por compra, cuando el tutor hace o recibe la tradición del bien. O cuando, por cuenta del pupilo, celebra un mutuo, ya sea recibiendo dinero o prestándolo (Paulo, D.26.7.46.5).

d) Igualmente, por los negocios realizados por la *gestio* del tutor, se daban *actiones utiles* y excepciones, ya en favor del pupilo o en su contra por parte de terceros (Ulp., D.26.7.9 pr.; D.12.2; D.21.2.4.1).

De este modo, la *gestio* del tutor aparece en la época final bizantina como un negocio símil de la *negotiorum gestio*, figurando entre los denominados *quasi ex contractu* (Inst., 3.27.2).

B) *Auctoritas*. Es el acto por el cual el tutor completa la persona del pupilo aprobando expresamente aquello que hace el impúber. Este procedimiento se debía hacer cuando el pupilo fuera un *maior infans*, considerando que tenía un don de entendimiento superior al del mero *infans*. De este modo, se considera que el acto es realizado directamente por el pupilo. Pese a ello, si estuviera ausente o fuere conveniente por cualquier otra circunstancia, el tutor podía usar de la *gestio*.

No es un consentimiento ordinario, sino que está sometido a algunos principios:

a) El tutor interpone la *auctoritas* estando presente en el acto que realiza el pupilo. No puede ser dada por un mensajero, ni por carta, ni tampoco con posterioridad al acto (Gayo, D.26.8.9.5).

b) Aunque el acto celebrado (p.ej., obligarse por una *stipulatio*, sea condicional o a plazo), la *auctoritas* que se interpone debe ser pura y simple, no pudiendo comportar una condición o un plazo (Ulp., D.26.8.8).

c) Es totalmente voluntaria por parte del tutor. No puede ser compelido por el magistrado, pues el tutor es el que analiza la conveniencia o no del acto y en consecuencia decide. Si con su rechazo le causara un perjuicio al pupilo, responderá de las consecuencias de su actitud (Paulo, D.26.8.17).

1. Podía darse el supuesto de que el tutor tuviera un proceso con el pupilo, o se tratara de un acto en el que tuviera un interés directo. Obviamente, no podía dar su *auctoritas*. Entonces el pretor le designaba un tutor especial (*tutor praetorius*; Gayo, I.184; Ulp., 11.24). En tiempos de Justiniano se designaba un curador.

2. También era dado un tutor especial cuando el designado por testamento lo había sido bajo condición o plazo, mientras estas modalidades no se cumplieran (Gayo, 1.188; Inst., 1.20.1). Y cuando el tutor hubiera caído prisionero del enemigo, hasta tanto volviera y recobrase su carácter por el *postliminium* (Gayo, 1.187; Inst., 1.20.2).

§ 564. La *auctoritas* se tornaba necesaria para todos aquellos actos que eventualmente podían comprometer al pupilo. Así, para aceptar una herencia, pedir la *bonorum possessio** o recibir una herencia por fideicomiso (Inst., 1.21 pr. y 1).

Pero en ciertos casos, el pupilo podía realizar los actos por sí mismo sin la *auctoritas* del tutor. La regla es que el pupilo obrando sólo pueda mejorar su situación, pero si la empeora, es necesaria la *auctoritas* del tutor (Gayo, 2.83; Inst., 2.8.2; 1.21 pr.). Así, puede sin *auctoritas* ser acreedor (no deudor) por una *stipulatio*; recibir el pago de una deuda o adquirir un bien (Gayo, 1.83-84; Inst., 2.8.2). En cambio, no puede obligarse, ni transmitir un bien, entablar un proceso, o aceptar una herencia sin la interposición de la *auctoritas* del tutor (Inst., 1.21 pr. y 1).

Esto traía a los negocios una serie de ventajas y desventajas:

a) *Caso del mutuo*. Si el pupilo recibe dinero en préstamo sin la *auctoritas*, se convierte en propietario de él, pero el negocio en sí es inválido y el prestamista no tiene acción contra el pupilo.

Dada la inequidad de la situación, un rescripto de Antonino Pio decidió que el pupilo quedaría obligado hasta el monto del enriquecimiento (Ulp., D.26.8.5 pr.).

b) *Caso del pago de una stipulatio*. Si el deudor le paga al pupilo lo debido por una *stipulatio*, adquiere la propiedad de las monedas. Pero como la obligación sigue en pie hasta que el deudor no fuera liberado por la *acceptilatio**, se podía accionar contra él. Aquí también se decidió por equidad que si al recibir el pago el pupilo se enriqueció, el deudor accionado tendría una *exceptio doli mali* (Gayo, 2.84).

Justiniano decidirá (C.5.27.25) que el deudor que quería efectuar el pago debía acudir al juez y obtener una resolución favorable. Haciéndolo así, estaba en plena y entera seguridad. Si no cumple con esta disposición podrá ser demandado por la deuda y sólo contará con la *exceptio doli mali* si el pupilo aún conserva las monedas o se ha aprovechado con ellas. Pero si las gastó inútilmente* o se las robaron, no podía oponer la excepción y era condenado, porque ha pagado con imprudencia, sin conformarse a la disposición imperial (Inst., 2.8.2).

c) *Caso de la compraventa*. Si el pupilo sin la *auctoritas* vende una cosa, resulta acreedor por el precio, pero no está obligado a la entrega de la cosa. Al revés, si compra una cosa, tiene acción para que se le entregue, pero contra él no hay acción por el precio.

Es fácil comprender que en ambos casos la aplicación de la regla general resultaba inequitativa. En la época clásica, la solución se tornaba espínosa. Si el bien vendido o comprado o el precio no había sido entregado, estaba la posibilidad de oponerse a cumplir la contraprestación hasta que se pagara el precio o se entregara la cosa. Pero si la entrega había ocurrido, no había remedio contractual.

Basado en el principio de que nadie puede enriquecerse sin causa a costa de otro (D.50.17.206), se terminó solucionando la cuestión de tal modo que se permiten las respectivas acciones por el precio y por la cosa vendida cuando medió enriquecimiento y hasta el monto de ésta (Ulp., D.26.8.5.1 i.º).

§ 565. No obstante que la regla originaria era la libertad de apreciación y de decisión por parte del tutor, ya sea usando de la *gestio* o interponiendo la *auctoritas*, se fueron fijando restricciones a ese poder tan amplio.

A) El tutor no puede ni por *gestio* ni por *auctoritas* realizar ni consentir en donaciones de ninguna clase (Jul. Ulp., D.27.3.1.1), ni aun como regalo de bodas a su madre (Labeo-Ulp., D.12.1.5), ni para dotar a una hermana. Se permiten sólo los presentes de uso, proporcionados a la fortuna del pupilo (Paulo, D.26.7.12.3 y 22).

B) Por un s.c. de Septimio Severo (*oratio Severi*) se prohibió la enajenación de inmuebles rústicos o suburbanos del pupilo —que eran los más valiosos—, así como hipotecarlos (Ulp., D.27.9.1 pr.; 1-2). Las ventas e hipotecas eran nulas.

1. Sólo se permitía en casos muy excepcionales. Así, si el *pater* en el testamento, por el cual el pupilo recibía bienes, hubiera ordenado la venta (Ulp., D.12.1.2); si el inmueble estaba indiviso con un tercero, o hipotecado por el testador (Ulp., D.12.1.2); si fuera necesario para pagar deudas apremiantes y no haber otros bienes, pidiéndoselo al pretor (Ulp., D.12.1.2).

En cuanto a la hipoteca resultaba válida si el inmueble había sido comprado al fisco, resultando ella de este negocio (Paulo, D.12.2).

2. Constantino extendió la prohibición a los fundos urbanos, como también a los inmuebles preciosos (C.5.37.22, año 326).

C) Además, el poder de vigilancia sobre la tutela se ve en la obligación que tiene el tutor cuando dispone de un patrimonio solvente del pupilo. Debía invertir en inmuebles o en prés-

tamos a interés. Tenía un plazo de seis meses en cuanto a las sumas que contó al inicio de la tutela (Paulo, D.26.7.15) y de dos meses respecto de aquellas que recibió en el curso de la tutela (Ulp., D.12.7.11).

1. A falta de inversión, el tutor debe los intereses a la tasa anual del lugar. Y aun a una tasa legal superior si descuidó el empleo, pese a la advertencia del magistrado, o si empleó el dinero para su uso personal (Ulp., D.26.7.7.10).

§ 566. III. *Responsabilidad del tutor*. Contra los abusos cometidos por el tutor en el ejercicio de la tutela existieron varias acciones por las cuales resultaba responsabilizado.

A) *Accusatio suspecti tutoris*. Se trata de una *actio popularis* que podía ejercer cualquiera contra el tutor testamentario, acusándolo de mala administración de los bienes, ya por actos dolosos o realizados con culpa grave.

Figuraba en la ley de las XII Tabas (Ulp., D.26.10.1.2; Inst., 1.26 pr.) y se basaba en el incumplimiento de la *fides* con que lo había distinguido el testador. Termina con una eventual sentencia que declara esa pérdida de la confianza, removiéndoselo del cargo.

1. Esta acción continuará en el derecho clásico, siendo admitida por Justiniano (Inst., 1.26; D.26.10.1.2). Como dato curioso, Ulpiano comienza esta sección diciendo que "es frecuente y muy necesaria, porque diariamente son acusados de sospechosos los tutores" (D.12.1.2).

2. La acusación podía ser hecha por cualquiera, admitiéndose a las mujeres vinculadas por una razón de *pietas* (madre, nodriza, abuela, hermana, etc.: rescripto de Severo y Caracalla; Inst., 1.26). La acción es calificada de *quasi publica* (Inst., *ibid.*), porque no se admite la acusación del pupilo (Inst., 1.26).

3. El acusado es suspendido en sus funciones mientras dura el juicio (Inst., 1.26). Si se lo encuentra incurso en dolo es declarado infame, pero no si sólo hubiere actuado con culpa (Inst., 1.26). Si muriese el tutor antes de la sentencia, cóncluela el comitamiento de la causa (Inst., 1.26).

4. Si bien esta acción comenzó contra el tutor testamentario, luego se extendió a toda clase de tutores (Inst., 1.26; Ulp., D.26.1.5 i.º).

También, antes del ejercicio de la tutela el pretor lo podía rechazar por sospechoso cuando le conste por "evidentísimos argumentos", aunque ofrezca dar la *cautio* (Ulp., D.26.10.3.4; D.12.1.5). Igualmente el pretor podía proceder a la simple remoción del pretor cuando encontraba que era simplemente inidóneo para el cargo.

B) *Actio rationibus distrahendis*. Esta acción (literalmente de "separación de las cuentas" del

tutor y del pupilo) era contra el tutor legítimo que hubiere cometido actos de sustracción de bienes del pupilo (Paulo, D.27.3.2 pr.). Éste debía interponerla al finalizar la tutela, siendo la condena por el *dupluni* (Ulp., D.27.3.1.24; Tryfón., D.26.7.55.1; Paulo, D.27.3.2.1).

Era también de la época de las XII Tablas (Tryfón., D.cit.). Y si bien resulta dudoso que en la época clásica se haya extendido a otra clase de tutelas, ello resulta cierto para Justiniano (Ulp., D.27.3.1.19 (itp.?). Dado su carácter penal, no se ejercía contra los herederos del tutor (Ulp., D.46.1.23).

C) *Actio tutelae*. Los remedios anteriores permitían separar al tutor sospechoso, o perseguirlo penalmente por bienes sustraídos. Pero no cubría de manera total una mala administración del tutor que hubiese sido perjudicial al pupilo. Por ello, hacia fines de la República (la menciona Cicerón, haciendo referencia a Q.M.Scaevola, *de off.*, 3.17), el pretor concedió una acción tendiente a responsabilizar al tutor por el ejercicio de su *gestio*. Se la denominó *actio tutelae* y era un *bonae fidei iudicium* (Gayo, 4.62; EP, § 124), siendo de carácter infamante (Gayo, 4.182).

1. Al parecer, surgió a propósito del tutor *Atilianus*, pero se la extendió al tutor testamentario y finalmente se la extendió a todos los casos de tutela. En principio, responsabilizaba al tutor por la *gestio* (por ello se asemeja a la *actio negotiorum gestorum*). Justiniano termina por clasificar la *gestio* del tutor entre los cuasicontratos (Inst., 3.27.2).

2. En un comienzo sólo abarcaba la *gestio* del tutor, pero luego se la extendió a ciertos actos de interposición de la *auctoritas* (así, por donaciones; Jul.-Ulp., D.47.3.1-2).

A) El pupilo podía interponer la *actio tutelae* (*directa*) luego de finalizada la tutela. De este modo obligaba al tutor a rendir cuentas, pedirle la devolución de sus bienes y también a la reparación de todos los perjuicios ocasionados, tanto por dolo como por culpa (Ulp., D.27.3.1 pr.; D.50.17.23 pr.).

En la época de Justiniano, la responsabilidad del tutor es juzgada más severamente, ya no por dolo o culpa, sino por los actos en los cuales no empleó la máxima *diligentia*, como si se tratara de sus propias cosas (*diligentia quam in suis rebus*; Ulp., D.27.3.1 pr. itp.).

B) El tutor podía ejercer un *iudicium contrarium* (*actio tutelae contraria*), para obligar al pupilo a pagar los adelantos o gastos hechos por él con fondos fuera de la tutela, y a propósito del ejercicio de ésta (Gayo, D.47.7.5.1; Ulp., D.27.4.1 pr. y ss.).

1. Ya desde la época clásica se concedió una *actio tutelae utilis*, contra el tutor dado por el magistrado que permaneciera inactivo, responsabilizándolo por los perjuicios ocasionados (FV, 155). Marco Aurelio, a su vez, decidió que todo tutor designado por el pretor en Roma que supiera esa situación y que luego de cierto plazo no presentara una excusación, no comenzara la tutela, y cesaba asumiendo la responsabilidad de su inacción (*periculo suo cessare*), por lo que contra él se podía dirigir *actio tutelae utilis* (Ulp., D.46.6.4.3; D.26.7.1 pr.).

2. También se menciona una *actio protutelar* para el caso de que resulte incierto de que alguien haya administrado como tutor o protutor, es decir, sabiendo que no lo es.

Contra el tutor falso, es decir, el que administra los bienes del pupilo sin ser tutor o sin saberlo, se daba la *actio de falso tutore* (Ulp., D.27.6.1 ss.; EP, § 122).

§ 567. Para darle total seguridad al pupilo éste contaba también con otros medios:

a) Un privilegio de preferencia para ser pagado antes que los acreedores quirografarios (no los hipotecarios) del tutor (Pap., D.26.7.42; Paulo, D.23.3.22; Hermog., D. id.25). Constantino le otorgó al pupilo una hipoteca tácita y general sobre todos los bienes del tutor, cuyo rango se considera a partir del comienzo de la tutela (C.5.37.20, año 312).

b) Cuando ha mediado fianza (*cautio*), el pupilo puede ejercer la *actio ex stipulatu* ya contra el tutor o los fiadores de la tutela (D.46.6.1 y 9). La responsabilidad es *in solidum*, y los *fideiussores* no cuentan con el derecho de división de la obligación (D. id.12).

c) Si el pupilo no puede lograr cobrarse ni con el tutor ni con los fiadores, por un s.c. de Trajano cuenta con una *actio subsidiaria* contra los magistrados encargados de exigir *cautio* que han omitido hacerlo o lo han hecho insuficientemente. Esta acción alcanza también a los herederos de los magistrados (Inst., 1.24.2; C.5.75.5).

d) También los pupillos tienen el beneficio de la *in integrum restitutio*, pudiendo pedir la rescisión de actos económicamente perjudiciales, ya fuera cumplido por la *gestio* o por la *auctoritas* del tutor (Mod., D.4.4.29; Scaev., D. id.47).

II. Tutela de las mujeres.

§ 568. Durante el derecho antiguo y también en la época clásica, las mujeres púberes que fueran *sui iuris* (es decir, no sometidas a la *patria potestas*, ni a la *manus*, ni estuvieran *in causa mancipi*) quedaban sujetas a una tutela especial de por vida, denominada vulgarmente "tutela de las mujeres" (*tutela mulierum*).

1. La razón más común de esta tutela se la suele encontrar en la protección de la mujer, respecto de la cual se decía que no resultaba perfectamente habilitada para los negocios jurídicos a causa de su "ligereza de espíritu" (*levitas animi*; Gayo, 1.144) o de su *infirmetas sexus* (*infirmetas* = no firmeza, inconstancia; Cic., *pro Murena*, 12.27). Incluso, otros hablan de *imbecillitas* (Val.Max., 9.1.3; Séneca, *Controv.*, 1.6.5). Pero esta razón, bastante especiosa por lo que realmente ocurrió, ya que las propias mujeres demostraron mayor habilidad que la que les negaban, no resultaba tan cierta como la de los intereses del heredero-tutor (v. Gayo, 1.192).

2. Se trataba de una institución del *ius civile*, no del *ius naturale*. Gayo (1.190) la descalifica: "no se ve ninguna razón seria", destacando que, tal como funcionaba en Roma, no se la encuentra en los otros pueblos. Sin embargo, nos habla de la existencia de una *quasi-tutela*, como p.ej. en Bithinia, según la cual la mujer que contrataba debía requerir la autorización de su marido o de su hijo púber (1.193).

3. Las sacerdotisas Vestales, por honor a sus funciones, quedaban libres de toda *potestas* —y, por ende, de esta tutela—, tal como lo estableció la ley de las XII Tablas (5.1).

§ 569. Esta *tutela mulierum* es deferida como la de los impúberes. Ello significa que podía ser, ya testamentaria, ya legítima o también dativa, cuando el tutor era nombrado por el magistrado (Gayo, 1.144; 157; 165-166; Ulp., 1.118).

1. Los tutores legítimos en este caso —y a diferencia de la tutela de los impúberes— podían cederla ante el magistrado (*in iure cessio tutelae*), siendo denominado el que la ejercía "tutor cesionario" (*cessicius tutor*). Si éste moría o sufría una *capitis diminutio*, la tutela volvía al cedente. Pero si el que moría o sufría la *capitis diminutio* era el cedente, la tutela escapaba del "cesionario" y recaía en el agnado si-guiente en grado después del cedente (Gayo, 1.168-170; Ulp., 1.16-7).

§ 570. El tutor de una mujer púber *sui iuris* no actuaba por la *gestio*, sino solamente por la *auctoritas*. Pero ésta estaba limitada a aquellos actos que podrían resultar perjudiciales a los herederos *ob intestato*. Así, para enajenar *res mancipi* (las más valiosas), para hacer testamento, para contraer obligaciones, para remitir por *acceptilatio* una deuda, o para sostener un *legitimum iudicium* (Gayo, 1.192; Ulp., 1.127).

En cambio, gozaba de una capacidad mayor que la de los impúberes, puesto que obrando sin la *auctoritas* de su tutor, podía enajenar *res nec mancipi*, prestar dinero, hacer o recibir un pago (Gayo, 2.81 y 85).

§ 571. Hacia fines de la época republicana, esta *tutela mulierum* comienza un insistente deterioro. Ya en la época clásica, Gayo nos habla de que las mujeres mayores traían por ellas mismas los negocios, siendo la *auctoritas* de su tutor una mera formalidad. Más aún, la mujer aun contra la voluntad de su tutor, se podía dirigir al pretor para constreñirlo a darla (Gayo, 1.190).

1. Lo que ocurre es que el papel social que tuvo la mujer romana fue más amplio que en otras sociedades antiguas. Un buen ejemplo es el de Terencia, la mujer de Cicerón, que aun sin estar *in manu* administraba libremente sus bienes con la ayuda de su liberto, sin siquiera mencionarse al tutor.

2. Por esta mayor libertad en el ejercicio de la tutela, a la mujer no se le concede, como a los impúberes, la *actio tutelae* (Gayo, 1.191).

Los principales pasos de la declinación de la *tutela mulierum* son los siguientes:

a) Desde el siglo II a.C. se le permite al marido dejar por testamento a su mujer *in manu* la opción de elegir el tutor que ella quisiera (*tutor optivus*; Gayo, 1.150-3). Con lo cual la mujer aprovechaba esta oportunidad para optar por un tutor que se llevara bien con ella y fuera complaciente con el otorgamiento de su *auctoritas*.

b) Poco más tarde se utilizó el procedimiento de una *coemptio fiducia causa*. La mujer *sui iuris* se mancipaba a aquel que ella elegía, quien se comprometía a emanciparla, convirtiéndose en su *tutor fiduciarius* (Gayo, 1.115).

c) En la época de Augusto, las leyes *Iulia et Papia Poppaea* dispensaron de la tutela a las mujeres que gozaran del *ius liberorum*, es decir, a las ingenuas que tenían tres hijos y a las libertas que tuvieran cuatro (Gayo, 1.194; Ulp., 29.3).

d) Por la ley *Claudia* (de la época de Claudio) se suprimió la *tutela mulierum* legítima, es decir, la de los agnados (Gayo, 1.171; Ulp., 1.18).

Ya para esta época, las únicas tutelas que gozaban de alguna práctica eran la del patrono y la del *parens manumissor* (ascendiente que emancipaba a la mujer; caso de la *coemptio fiducia causa*).

Persistió, muy debilitada, hasta comienzos del Dominado. Pero ya entre el siglo IV y el V, cayó en desuetud, sin necesidad de una ley que la abrogara formalmente. Por una constitución de Honorio y Theodosio se concedió el *ius liberorum* a todas las mujeres, aun a las que no tuvieran hijos (C.8.59.1, año 410). En el Código Theodosiano no se la menciona, y los compiladores bizantinos eliminaron del *Corpus Iuris* toda referencia a esta *tutela mulierum*.

LAS CURATELAS

§ 572. El curador (*curator*) es el que tiene la potestad de administrar los bienes de ciertos incapaces (así, los dementes, los pródigos, los menores de 25 años, etc.). Mientras que en la tutela se tiende a completar la persona del impúber (o de la mujer), en la curatela predomina el aspecto de la administración de los bienes. De ahí la regla de que "se da tutor a la persona, curador a los bienes" (*tutor datur personae, curator rei*; Marciano, D.26.2.14).

1. Esta regla aparece dentro del contexto de los dos párrafos anteriores (Ulp., D. id. 12; Pomp., D. id. 13) en los cuales se habla de que no se puede dar tutor por testamento para una cierta cosa o negocio (cfr. Inst., 1.14.4).

2. En el derecho clásico nos encontramos con ciertos casos en que se daba un tutor para ciertas causas en particular. Así, la mujer podía elegir un *tutor optivus* para todos sus negocios o para solamente uno o dos (Gayo, 1.150) O darse un tutor para aceptar una herencia (Gayo, 1.176). O para constituir una dote (Gayo, 1.178, 180; Ulp., 11.22), etc. Pero en la época justiniana para los casos de negocios particulares se hablará de curadores.

§ 573. I. *Curatela de los furiosos*. La curatela más antigua es la que protege al demente (*furiosus*). Figuraba en la ley de las XII Tablas (5.7a), donde se indicaba que en este caso tanto el insano como sus bienes pasaban a estar bajo la potestas de sus agnados (y a falta de éstos, de sus gentiles).

A) Esta curatela de los agnados (la de los gentiles desapareció ya en tiempos de la República) era automática y no requería nombramiento. Pero ya en la época clásica, faltando los agnados, el pretor (o el gobernador) designaba uno (Gayo, D.27.10.13).

1. No existe la curatela testamentaria del *furiosus*. Sin embargo, el magistrado le da preferencia en el nombramiento a aquel que ha propuesto el testador (Pryfen., D.27.10.16 pr.; Inst., 1.23.1).

2. Ya en el derecho posclásico, todo curador debe ser confirmado por el magistrado. Para Justiniano, el orden prioritario era: primero el indicado en el testamento por el padre o la madre, y luego la persona idónea señalada por el magistrado (C.5.70.7).

B) La determinación de la demencia era una cuestión de hecho (Cic., Top. 12.51). La denominación genérica era la de *furiosus*. El empleo de una diferenciación con el *mente captus* no es empleada por los clásicos, aunque sí por los bizantinos (Inst., 1.23.3-4). Este último es el insuficiente mental (mogólico).

1. El interés de la distinción estaría dado por la posibilidad de existencia en ciertos casos de demencia de los llamados "intervalos lúcidos". Evidentemente el *mente captus* no los podía tener. En la época clásica, los juristas debieron conocer la existencia de ellos, pero no le prestaron ninguna atención. Un antecedente lo veríamos en un rescripto de Marco Aurelio y Cómodo (Macer, D.1.18.14), donde la existencia de un intervalo lúcido podía empeorar el caso criminal allí tratado.

2. Ya en la época posclásica, Paulo (3.4a.3) considera válido el testamento hecho por un *furiosus* en un intervalo lúcido. Y Diocleciano parece admitir la validez de una venta en esas condiciones (C.4.38.2, año 286).

El problema parece centrarse en saber si el curador continuaba o no sus funciones, o si las recobraba si el *furiosus* recaía en la locura. Justiniano determinó que durante el intervalo lúcido quedaba "suspendida" la curatela, quedando el *furiosus* con plena capacidad, incluso para hacer testamento; pero el curador recobraba su cargo si se recaía en la demencia (C.5.70.6.1; C.6.22.9, año 530).

C) El curador del *furiosus* tenía que cuidar de la persona a cargo y administrar su patrimonio. Dada la incapacidad total del demente, el curador sólo puede actuar por la *gestio*. Su responsabilidad está reglada por la *actio negotiorum gestorum* (Paulo, D.27.3.4.3).

1. En los primeros tiempos, la potestad del curador del *furiosus* era muy amplia. Pero luego, al igual que en el caso del tutor del impúber, tendrá luego restricciones, sobre todo en lo relativo a la venta de inmuebles (s.c. de Severo; D.27.9.1 pr. y 1; Ulp., D. id. 8.1).

3. En tiempo de Justiniano el curador debe prestar garantía y hacer inventario. En favor del incapaz se le da una hipoteca general y legal sobre los bienes del curador (C.5.70.7.5a/6c).

§ 574. II. *Curatela del pródigo*. La ley de las XII Tablas consideraba como pródigos a aquellos que disipaban los bienes provenientes de la sucesión *ab intestato* de su padre o de su abuelo (Paulo, 3.4a.7; Ulp., 12.2-3; D.27.10.1 pr.). Para impedir la dilapidación del patrimonio familiar se sancionaba con una *interdictio* pronunciada por el magistrado (originariamente los cónsules, luego el pretor y el gobernador de provincia), siendo el pródigo colocado bajo la curatela legítima de sus agnados, y en su defecto de los gentiles.

Con posterioridad, el pretor amplió el supuesto de la ley decenviral, abarcando en la *interdictio* tanto el caso del libertó que dilapidaba sus bienes (Ulp., 12.3), como el del ingenuo que había sido instituido heredero por testa-

mento (Val. Max., 3.5.2); y en general, a todo aquel que se mostraba dilapidador de sus bienes (Gayo, 1.63; Ulp., D.26.5.12 pr.).

1. En estos casos el pretor dictaba la *interdictio*, designando un curador a su discreción (*curator honorarius*). En la época de Antonino Pío se le otorgó incluso al hijo respecto de su padre (Ulp., D.26.5.12.1), y se atendió el pedido de la madre pidiendo un curador respecto de sus hijos pródigos.

2. El fundamento de la prodigalidad antigua (intereses de los herederos), se conjuga ahora con el resguardo de los *mores* (Ulp., *D. ibid.*; Paulo, 3.4a.7). Las viejas virtudes de la *gravitas* y de la *austeritas* parecen aquí estar defendidas frente al atentado de la dilapidación.

El curador de un pródigo tiene la potestad de administrar los bienes de éste por la *gestio* —está asimilado al *furiosus*— (Pomp., D.50.17.40; Ulp., D.47.10.1 pr.; D.45.1.6). Sin embargo, el pródigo, si bien carece de capacidad para obligarse y para enajenar, puede realizar actos que puedan mejorar su situación económica; incluso, aceptar una herencia, pese a las deudas (Ulp., D.29.2.5.1).

Así como esta curatela se abre con la *interdictio* del magistrado, cesaba con el levantamiento de ella por el magistrado.

3. Ulpiano (D.27.10.1, *in fine*) habla de que también finaliza cuando el pródigo se hubiera enmendado, sin necesidad de decreto (*ipso iure*), lo mismo que al loco que hubiera recobrado la salud mental. El texto resulta sospechado de interpolación. De ser así, esta solución sería válida para la época justiniana.

§ 575. III. *Curatela de los menores*. La tutela sobre un varón *sui iuris* cesaba cuando éste llegaba a la pubertad. A partir de ese momento era plenamente capaz para realizar todos los actos y negocios jurídicos.

Pero esta conclusión de una lógica primaria, que no siempre concuerda con la realidad jurídica, de equiparar la capacidad de engendrar dada por la naturaleza, con la capacidad de realizar actos jurídicos, resultaba equivocada. El púber *sui iuris* no contaba con la experiencia del mundo de los negocios, y por ello podía realizarlos de manera inconveniente y hasta en forma dañosa para su patrimonio.

A) Fue así que se sancionó la *lex Laetoria* (no *Plaetoria*, como equivocadamente se dice en un único texto, la *lex Iulia municipalis* = *Tabula Heracleensis* 112) aproximadamente a comienzos del siglo II a.C. En ella se estableció una acción penal y popular contra todo aquel que se hubiera aprovechado económicamente en un ne-

gocio con los menores de 25 años. Es la primera oportunidad en que aparece esta denominación de *minores*.

1. Esta ley protegía a todos los menores (sean varones o mujeres, *sui iuris* o *in potestate*; y en el caso de las mujeres, sin considerar si estaban o no en tutela). La *actio popularis* podía ser ejercida contra el tercero que se aprovechaba fraudulentamente consiguiendo ventajas económicas de la inexperiencia de un *minor* (*circumscriptio*). Si ello se demostraba, aparte de la pena, que desconocemos, el tercero era tachado de infamia (Cic., *de nat. deor.*, 3.30).

B) Como la *lex Laetoria* no anulaba el negocio celebrado, es decir, era "imperfecta", el pretor intervino aportando dos nuevos remedios:

a) una *exceptio* que podía oponer el *minor* al tercero que se había aprovechado de su inexperiencia y pretendía por una *actio* hacer efectivo el negocio celebrado (Paulo, D.44.1.7.1; EP, § 279);

b) una *in integrum restitutio*, que podía pedir el *minor* que sufrió una lesión patrimonial por causa de su edad, y por medio de la cual se consideraba al negocio como no sucedido, restableciendo las cosas en su estado primitivo (Ulp., D.4.4.1.1).

El pretor atendía el pedido del menor previa cognición de la causa (*cognitio causae*). Había que probar:

(i) que el *minor* había sufrido un perjuicio, o hubiese dejado de alcanzar un beneficio que pudieron adquirir (Ulp., D.4.4.4.4; D. id. 7.6 ss.);

(ii) que se hubiese producido por defecto de la edad (*infirmis aetatis*; Ulp., D. id. 1 pr.);

(iii) que el menor no tuviera otro recurso jurídico (Ulp., D. id. 16 pr. y 1; D. id. 4.4; D. id. 7.6); y

(iv) que no hubiera mediado dolo o delito por parte del *minor* (Ulp., D. id. 9.2) o que el daño ocurriera por caso fortuito (Ulp., D. id. 11.4).

De este modo, el pretor socorría a los *minores* "en todos los asuntos en que se han equivocado" (Gayo, 2.163; 4.57).

C) Estos tres remedios (*actio*, *exceptio* e *in integrum restitutio*), si bien aparecen como beneficios del *minor*, en realidad le aportaron una seria desventaja, puesto que debido a la eventual rescisión que podían hacer los menores, los terceros evitaban negociar con ellos.

Para solucionar la situación, fueron los mismos *minores* los que solicitaron un *curator* que los asistiera en el acto a realizar (Pap., D.26.5.13.2). Al estar asistidos por un *curator*, no se podía alegar la *infirmis aetatis*, con lo cual los terceros podían negociar con ellos sobre una base más firme.

En un principio el pedido de curador era para un negocio en particular (C.5.31.7; Ulp., 4.4.7.2). Pero desde la época de Marco Aurelio (Vita Marci, 10 fin.; Ulp., 12.4), el menor pedía un *curator* permanente para todos los actos. Con lo cual estaba reconociendo su propia incapacidad. De este modo, por una constitución de este emperador, la "curatela de los menores" (*cura minorum*) se convirtió en una institución legal

1. El *curator minorum* es muy distinto del tutor. Así: a) El pedido de un *curator* es siempre optativo para el *minor*, y no obligatorio como la tutela del impúber. b) El obrar del curador es simplemente el de un consejo y consentimiento, pero no se trata de una *cuctoritas*, ~~da sólo su consensus~~. c) Tampoco es por sí un administrador del patrimonio del menor, salvo que éste lo nombre su mandatario (Pap., D.26. 7. 39. 18), posiblemente con intervención del magistrado. d) No resulta responsabilizado por las acciones de la tutela; si ha sido designado mandatario, lo será por la *actio mandati** o la *actio negotiorum gestorum*.*

D) En la época posclásica se fue tornando inevitable una aproximación cada vez más creciente entre la *cura minorum* y la tutela. Al curador de los menores se le van extendiendo las reglas de la tutela sobre las excusaciones, la caución, limitaciones para disponer, etc. (Hermog., D.27.1.41).

El texto interpolado de Ulpiano (D.4.4.1.3) revela que prácticamente se los compelia a los menores a tener un *curator*, aunque en Inst., 1.23.2, se conserva el principio clásico de que no los podían tener contra su voluntad. Lo normal en las interpolaciones fue recurrir al agregado del curador cada vez que se mencionaba al tutor (*tutor vel curator*). De hecho, fue un incapaz (en Ulp., D.36.4.5.20, su lo ubica entre las "personas indefensas").

1. Como característica especial, considerando que la edad de 25 años podía resultar excesiva, se otorgó la *venia petitis* (autorización de libre administración). Esto ocurrió ya en el siglo III (C.2.44 (45).1; año 274; Constantino, C.2.44 (45).2; año 321).

Se exigía que el varón tuviera 20 años y la mujer 18. No podían hacer donaciones ni tampoco vender bienes que estaba prohibido hacerlo a los tutores.

Con este beneficio cesaba la curatela. El menor habilitado no podía pedir la *in integrum restitutio* por razón de la edad, salvo en los casos en que esta medida extraordinaria le era concedida a los mayores de edad (C.2.45).

2. Aun existiendo la *cura minorum*, se amplía también la *in integrum restitutio* aun en el caso de que el menor hubiera actuado con el *consensus* del curador (Alej. Severo, C.2.25.2, año 223).

Esto traía la lógica inquietud para los terceros. Justiniano, siguiendo el consejo de Triboniano, decidió (al igual que para el pupilo de la tutela) que en caso de un pago efectuado por un acreedor, para no sentirse expuesto a la *in integrum restitutio*, podía presentarse al juez y obtener una sentencia por la cual se lo autorizaba a pagar, y entonces el pago era inatacable (C.5.37.25, año 531; Inst., 2.8.2; *supra*, § 564 b).

§ 576. IV. Otras curatelas especiales. En el Edicto estaban admitidas algunas curatelas especiales:

a) Se le daba un curador al pupilo de una tutela que tiene un pleito con su tutor (Gayo, 1.184; Inst., 1.21.3); lo mismo que si el tutor es inidóneo, o está enfermo, en lugar de sacarlo, se le puede dar un curador, o si el tutor se ha excusado en forma temporaria (Inst., 1.23.5-6).

b) Para la protección del hijo concebido se le puede dar un *curator ventris* (Ulp., D.27.10.8).

c) Para los sordos, mudos y los que padecen una enfermedad perpetua y no pueden desempeñarse en sus negocios (Inst., 1.23.4).

Y así, para todos los otros casos en que haya necesidad de administrar bienes de alguien que está en dificultades para hacerlo. Los casos que en el derecho clásico eran solucionados mediante un tutor especial, ahora serán realizados con la intervención de curadores (*supra*, § 572.2).

PARTE SEXTA DERECHO HEREDITARIO

CAPÍTULO 1
NOCIONES FUNDAMENTALES

§ 577. *Concepto de sucesión.* "Suceder" significa ocupar el lugar que anteriormente tenía una persona. Así, en la herencia hay una sucesión porque el heredero pasa a ocupar la posición jurídica del que fallece (*in locum et in ius succedere*; Paulo, D.2.13.9.1; Ulp., D.8.4.13 pr.).

En el Derecho moderno y actual se habla de que la sucesión puede ser "a título universal", así, cuando un heredero, p.ej., adquiere todo el patrimonio de alguien que ha fallecido. Pero también a "título particular": así cuando alguien adquiere la propiedad de una o varias cosas que eran de otro; p.ej., se dice que el comprador sucede a "título particular" la cosa comprada al vendedor.

En el Derecho romano, los autores clásicos sólo conocen la sucesión "a título universal", desconociendo la sucesión "a título particular", que solamente será conocida en la época posclásica.

1. Gayo, en sus Institutas, cuando habla de la adquisición de cosas (2.18 ss.) distingue la adquisición de las cosas particulares y la adquisición de toda una universalidad (2.97). Pero sólo en este último caso habla de *successio* (2.157; 3.77; 3.92).

2. La "sucesión universal" puede ocurrir por actos *inter vivos* o *mortis causa*, aun cuando Gayo no emplea esta terminología. La sucesión universal *mortis causa* es primordialmente la "herencia" (*hereditas*).

En cambio, por actos *inter vivos*, la sucesión universal puede ocurrir en los siguientes casos:

- a) en la *adrogatio*, ya que la totalidad de los bienes del adrogado, aunque no las deudas, pasan al *pater adrogante*;
- b) en la *conventio in manu* por causa de matrimonio de una mujer *sui iuris*, ya que al igual que en el caso anterior, quien detenta la *manus* adquiere la totalidad de los bienes, pero no de las deudas;
- c) cuando alguien adquiere los bienes en la *venditio bonorum*, pero se obliga a pagar las deudas en una determinada proporción;
- d) también cuando una persona libre *sui iuris* cae en esclavitud (caso del hombre libre que dolosamente se hace vender como esclavo, o la mujer libre que mantiene relaciones sexuales con un esclavo *ayeno* —s. c. Claudiano—).

3. En cambio, la expresión *successio* no es empleada por los clásicos respecto de las cosas singulares.

Gayo (2.97) habla simplemente de *adquirere singulas res*. La expresión "sucesión a título particular" es desconocida en el derecho clásico. Incluso respecto de los legados, se emplea el giro "adquirir cosa en particular" (Gayo, *ibid.*).

Fueron los posclásicos los que emplearán la forma *successio in singula re*. Así, en los textos interpolados del Digesto (39.2.24.1; 43.3.1.13) se habla de sucesor de una cosa en particular (*successio in unam rem*).

4. Por tanto, la división de la sucesión en "sucesión universal" y "sucesión particular" es de origen posclásico y se mantuvo después, por ser muy del gusto de los modernos.

Así, se suele hablar de:

I. Sucesión universal, que puede ser:

- a) *mortis causa* (caso de la *hereditas* y de la *bonorum possessio*), o
- b) *inter vivos* (p.ej.: en la *adrogatio*, la *conventio in manu* de una mujer *sui iuris*, *bonorum venditio*, caída en esclavitud de un *sui iuris*).

II. Sucesión particular, que puede ser:

- a) *mortis causa* (p.ej., en los legados o en los fideicomisos a título particular), o
- b) *inter vivos* (p.ej., en la compraventa o en la donación, donde el comprador o el donatario es sucesor particular del vendedor o del donante en la cosa vendida o donada).

§ 578. *Evolución histórica de la hereditas.*

I. La sucesión hereditaria estuvo siempre ligada en Roma a la familia. Así, en los primeros tiempos, la vinculación fue muy estrecha. Hasta tal punto que familia sirve para designar el patrimonio familiar que se transmite por herencia.

Por ello se cometería un grave error si la *hereditas* fuera considerada únicamente desde el punto de vista económico, sobre todo en estos primeros tiempos.

Debemos partir de la idea de la familia "personne" (la del "ayer", la del "hoy" y la del "mañana") y de la correspondencia que ésta tiene con la *religio*. Las ideas de *familia*, *patrimonium* y *hereditas* están tan conectadas entre sí, que resulta imposible explicarlas en forma aislada, sino que cada una de ellas está en función de las otras. Resulta esto claro en Cicerón (*de leg.*, 2.19-20), quien dice así: "La religión prescribe

que los bienes y el culto de cada familia sean inseparables; y que el cuidado de los sacrificios sea siempre dado a aquel a quien corresponde la herencia.

Dada esta complejidad, más que ver la *hereditas* como una fortuna que pasa de una mano a otra, ese conjunto de bienes tiene algo de inmóvil, como son inmóviles el hogar y la tumba de los Maiores. Al contrario, el que pasa es el hombre, y a medida que la familia desarrolla sus generaciones, cada *pater* torca el timón que el deber le impone de continuar el culto (los *sacra privata*), y continuar el patrimonio.

Es debido a esto que lo relativo a la herencia en la Roma primitiva aparece como un capítulo del Derecho de Familia. Muerto el *pater*, la familia se desintegra en tantas unidades familiares como herederos *sui iuris* agnados haya en el momento de su muerte. La costumbre primitiva era que, sin embargo, los bienes se mantuvieran en forma indivisa, formando una comunidad (*erectum non cito*; Gayo, 3.154a). En ella era probable que uno de los herederos condujera la administración del patrimonio, manteniéndose la religión familiar de los *sacra privata*.

II. Sin embargo, esta comunidad hereditaria arrastraba problemas muy particulares. Así, con el crecimiento de la familia el patrimonio común se va tornando insatisfactorio para atender las necesidades de todos sus miembros. Y también resulta muy difícil mantener la armonía y concordia de los miembros. Por ello, ya en la época de las XII Tablas se permite a cada uno de los herederos la posibilidad de ejercer la acción de partición de la herencia (*actio familiae erciscundae*), de tal modo que quedaba dividida en tantas partes como herederos había.

Cuando ello sucede, se ve prontamente que la división automática entre los herederos domésticos, cuando éstos eran más o menos numerosos, fraccionaba el patrimonio. Se tornaba así difícil que la pequeña economía agrícola pudiera realizar sus finalidades propias, ya que el desmenuzamiento de los bienes (piénsese en un único campo familiar) tornaba la explotación insuficiente para una familia.

Se siguió el camino de hacer prevalecer a uno de los hijos para que quedara como único heredero. La solución podía consistir en excluir al resto de los hijos e hijas. Así, emancipándolos, o dando en adopción a otra familia, y si fueran hijas, dando éstas en matrimonio *in manu* y dotándolas.

Un recurso muy efectivo comenzó a ser la práctica de testar, de tal modo que el *pater* instituía heredero a uno de los hijos, desheredando a los demás: aunque en este último caso, podía ayudarlos por medio de legados.

III. Aun así, la vinculación entre herencia y familia resulta muy significativa. La prosecución de los *sacra privata*, se sigue manteniendo en cabeza del hijo por quien haya optado el *pater*, pero también lo continuarán los otros herederos en tanto que agnados.

De todos modos, según la ley de las XII Tablas, a falta de este heredero testamentario, quedaban siem-

pre sus otros hermanos. A falta de ellos, se prescribía que la herencia debía ir al "agnado próximo", y si éste (o éstos) no aceptaban la herencia, iba a parar a la *gens*. El interés religioso y económico familiar se ve plenamente plasmado en este orden sucesorio, donde prevalece el parentesco agnático.

Incluso, se permite que un extraño, aun sabiendo que no es heredero, pudiera usucapir la herencia (*usucapio pro herede*), y ello era permitido, entre otras finalidades, para mantener el culto familiar de los *sacra privata* (Gayo, 2.55).

IV. Ya en plena época republicana la costumbre era respetar la voluntad del *pater*, quien en su testamento podía manifestar sus decisiones de instituir herederos, desheredarlos, beneficiar a otros con legados, distribuyendo el patrimonio familiar a su antojo.

Esta plena supremacía de la voluntad de testar, que ocasiona la práctica testamentaria y la hace prevalecer en cuanto a su uso a la herencia intestada, motivó serias reacciones. En efecto, el tradicionalismo romano no podía permitir que los intereses de los herederos domésticos quedaran librados al capricho del testador.

De ahí la aparición de reglas que imperaban respecto de la voluntad del testador. Podía instituir herederos a sus hijos e hijas o desheredarlos, pero no podía preterirlos, es decir, omitirlos en el testamento. De hacer esto último, el testamento podía ser nulo (caso de los hijos) o las preteridas mujeres podían obtener una cierta satisfacción por parte del pretor. Ya a fines de la República se utiliza la *querella inofficiosa testamenti*, que limita la facultad de testar en interés de ciertos parientes próximos. Igualmente, por leyes especiales se limitó la facultad de legar, para evitar que el *pater* despilarrara en legados el contenido de la herencia.

A su vez, en la herencia intestada, al ir perdiendo fuerza la vieja constitución agnática de la familia, comienzan a surgir casos inequitativos. Fue el pretor quien comienza a dar importancia al vínculo cognático, otorgando la posesión de la herencia (*bonorum possessio*) a los hijos emancipados en forma conjunta con sus hermanos agnados. Y después de haber satisfecho a los parientes agnados, admite directamente a los cognados, así como al cónyuge superviviente de un matrimonio libre.

V. Luego de diversas disposiciones de la época clásica y posclásica tendientes a afirmar el parentesco cognático, Justiniano terminará por negar todo derecho al vínculo agnático, determinando que la herencia intestada le corresponde solamente a los cognados.

Vemos así como en toda la historia romana el desarrollo de la constitución de la familia y la herencia marcharon estrechamente unidos, siguiendo la misma línea: en los primeros tiempos, basando el parentesco apto para la herencia intestada en los agnados; luego una cierta admisión de los cognados y finalmente el triunfo de este último parentesco.

HEREDITAS Y BONORUM POSSESSIO

§ 579. I. *Hereditas*. Cuando se habla técnicamente de "herencia" (*hereditas*) se está haciendo referencia a la institución hereditaria conforme al *ius civile*. De este modo, "heredero" (*heres*) es el "sucesor por causa de muerte según el *ius civile*".

El que fallece es denominado *de cuius* (es la abreviatura de *is de cuius hereditate quaeritur, o agitur*): de aquel de que se trata la herencia, o se acciona (Inst., 3.2.6; Ulp., D.38.1.11; Pomp., D.38.6.5 pr.). También es llamado "causante" (en el sentido de aquel que causa la herencia).

A) *Situación del heredero*. El *heres* sucede al *de cuius* ocupando la misma posición que tenía éste en el momento de la muerte, en cuanto a los derechos y obligaciones que lo sobreviven.

La sucesión del heredero es siempre a título universal (*per universitatem*). Aun siendo varios los herederos, ya sea por partes iguales o desiguales, la cuota parte que recibe cada uno es a título universal. Mientras no se pida la partición de la herencia por la *actio familiae erciscundae*, rige un estado de comunidad hereditaria.

1. La herencia se divide entre los romanos no conforme a un criterio decimal, sino duodecimal, es decir, partiéndola en doce porciones: 1/12 (*uncia*), 2/12 (*sextans*), 3/12 (*quadrans*), 4/12 (*triens*), 5/12 (*quincus*), 6/12 (*semis*), 7/12 (*septims*), 8/12 (*bes*), 9/12 (*dodrans*), 10/12 (*dextans*), 11/12 (*deunx*) y 12/12, es decir, la totalidad de la herencia (*as*).

a) El heredero sucede al causante en todas las relaciones privadas que éste tenía, siempre y cuando éstas sean transmisibles. Así, si el *de cuius* era propietario de un fundo, ahora lo pasa a ser el heredero; si era acreedor, el crédito pasa ahora en cabeza del heredero.

En cambio, por ser intrasmisibles, hay ciertas situaciones que no recaerán en el heredero. Así, ciertas acciones penales* por delitos, o el contrato de sociedad* o de mandato*, tampoco el usufructo* y el uso*, ni determinadas relaciones familiares, tales como la paternidad o la *manus**.

1. La situación se produce respecto de las situaciones de derecho (así, la propiedad). Pero no respecto de las situaciones de hecho (así, la posesión). Por eso debe tomar la posesión de los bienes que posea el causante para ser considerado poseedor, si bien a los efectos de la usucapción, podrá sumar el tiempo de posesión del causante al suyo propio (*successio possessionis*).

b) Por ser sucesor, el heredero será responsable de todas las deudas transmisibles del *de*

cuius. La responsabilidad por las deudas hereditarias obliga al heredero a responder no solamente con los bienes del activo de la herencia, sino que se extiende, en caso de no ser suficiente, también respecto de los bienes propios del heredero (principio de responsabilidad *ultra vires hereditatis* = "más allá de la cuantía de la herencia").

1. Éste es el principio clásico. En ciertos casos ocasionaba inconvenientes al heredero (si la herencia era dañosa y las deudas superaban al activo hereditario: *hereditas damnosa*; Pomp., D.50.16.119), así como a los acreedores (si lo eran de una herencia solvente y ésta iba a parar a un heredero insolvente cargado de deudas).

Si se trataba de un heredero doméstico (*sui heres*) en caso de no convenirle podía ejercer el *ius abstinendi*.

Si se trataba de un heredero extraño, es decir, no doméstico, en caso de no convenirle, no aceptaba la herencia y la repudiaba. O llegaba a un acuerdo con los acreedores estableciendo que aceptará la herencia, siempre que se convenga una reducción proporcional de las deudas. O les exigía un mandato para aceptar la herencia, con lo cual se precavía de todo perjuicio, ya que como mandatario tenía la *actio mandati contraria* para reclamar por lo que hubiera tenido que gastar por el mandato.

2. Justiniano establecerá, en favor de todos los herederos, la posibilidad de ejercer el *beneficium inventarii**, que les permite limitar su responsabilidad al monto de los bienes hereditarios (principio de la responsabilidad *intra vires hereditatis*: "dentro de la cuantía de la herencia").

Asimismo, le concederá a los acreedores de la herencia el poder usar de la *separatio bonorum**, de tal modo que podrán con preferencia a los acreedores del heredero, cobrar sus créditos con los bienes hereditarios.

B) *Formas de deferir la hereditas*. La herencia se defiere por la voluntad del testador (*herencia testamentaria*) o por la ley (*herencia ab intestato*).

Lo primero que hay que averiguar cuando muere un *sui iuris* es si ha dejado testamento válido, en cuyo caso se abre la herencia testamentaria, siguiendo lo establecido en el testamento.

Si el *de cuius* no ha hecho testamento, o éste es inválido o ineficaz, entonces se abre la herencia *ab intestato*.

Por lo herencia, en principio, es testada o intestada. No podría ser "en parte testada, y en parte intestada" (regla *Nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest*; Inst., 2.14.5; Ulp., D.29.1.6).

1. De este modo, si un testador instituya varios herederos asignando a cada uno de ellos una cuota determinada, el total de ellas debe agotar el caudal hereditario. Si sumando todas las cuotas fijadas no se alcanza el total de dicho caudal, el remanente no va a los herederos *ab intestato*, sino que acrece proporcionalmente las cuotas de los herederos instituidos.

Así, en un testamento se instituyen heredero a A por 1/3 y a B por otro tercio. Queda 1/3 aparentemente libre. Pese a ello no se abre la herencia intestada por dicho 1/3, sino que pasa a acrecer, es decir, a aumentar, las cuotas de A y de B, que pasan ahora a ser herederos por la mitad cada uno de ellos.

Igualmente, si el testador instituya heredero a A por la mitad, sin disponer de la otra, A es heredero universal por la totalidad (*ex asse*; Inst., 2.14.5).

2. La regla mencionada sufre algunas excepciones cuando se trata de la sucesión contra el testamento, pues allí ciertos herederos legales pueden impugnar el testamento que los perjudica (sucesión "forzosa"), aunque sin suprimir totalmente los efectos de dicho testamento.

Tampoco se aplica a los testamentos militares (Ulp., D.29.1.6).

§ 580. II. *Bonorum possessio*. La hereditas es una institución del *ius civile*. El pretor no puede, por ello, hacer a nadie heredero, puesto que éste es fijado por el testador en la herencia testamentaria o por la ley en la herencia *ab intestato* (Gayo, 3.32; Inst., 3.9.2).

Pero interviene en esta materia, sin inmiscuirse en la atribución de heredero y de propiedad de la herencia. Lo que hace es conceder a determinadas personas la "posesión de la herencia" (*bonorum possessio*). De este modo los protege, no como herederos sino como *bonorum possessores*. Éstos quedan ubicados no como "herederos", sino cada uno "en lugar de heredero" (*heredis loco*; Gayo, 3.32).

1. El *bonorum possessor* es, por tanto, el sucesor *mortis causa* conforme al *ius praetorium* (Ulp., D.37.1.3.2). Es una construcción pretoriana análoga a la *possessio*. Ésta se diferencia del *dominium* que es del *ius civile*, así como acá la *bonorum possessio* se diferencia de la hereditas.

Hay que tener cuidado en diferenciar al *bonorum possessor* del mero *possessor*, que detenta la posesión de cosas corporales. Acá la *b.p.* se refiere a la posesión de la hereditas, que es una *res incorporalis* aunque en su contenido existan cosas corporales: fundos, bienes, dinero, y también créditos y obligaciones (Gayo, 2.14; Lab-Ulp., D.37.1.3.1).

A su vez, se diferencia del *heres* en que éste es sucesor conforme al *ius civile*, mientras que el *bonorum possessor* lo es por el derecho pretoriano.

A) Casos de *bonorum possessiones*:

a) El pretor puede otorgar la *b.p.* a un *heres* que necesite entrar en la posesión de la herencia. Con ello no hace sino confirmar el *ius civile*, "ayudando" (*adiuvandi iuris civilis gratia*) a la persona señalada por el derecho civil, quien aparte de las acciones y defensas del *ius civile*, contará con los remedios pretorianos. Este caso habría sido el primero en aparecer (Cic., 2a. in Verr. 1.44; pro Cluentio, 60; Gayo, 3.34).

b) Pero, más tarde, también puede conceder la *b.p.* a alguien que no es heredero civil. Así, si no existe ningún heredero civil, está supliendo una laguna del *ius civile* (*supplendi iuris civilis gratia*). De hecho esta situación será en este caso definitiva para el *bonorum possessor*, puesto que nadie, basado en un título civil, podría impugnarle su situación.

c) Y además, si para solucionar una situación que le parece inequitativa concede la *b.p.* a alguien que no es heredero civil, aun existiendo este último, entonces el pretor actúa "corrigiendo" al *ius civile* (*corrigendi iuris civilis gratia*).

Se puede producir el conflicto entre el heredero y el *bonorum possessor*. Unas veces (Ulp., 28.13), el pretor hace prevalecer al *bonorum possessor* respecto del *heres* (la *b.p.* es llamada entonces *b.p. cum re*). Otras, mantiene la hegemonía del heredero civil, quien podía reclamar la herencia poseída por el *bonorum possessor* y vencerlo (la *b.p.* es llamada entonces *b.p. sine re*).

B) Clases de *bonorum possessiones*: Si bien los casos particulares los veremos al presentar las situaciones concretas, a los efectos de tener una idea de la terminología empleada, podemos distinguir las *bonorum possessiones*, según la manera como actúa el pretor en:

(i) *b.p. edictalis*: ésta ocurre cuando el pretor contempla directamente en su edicto los casos en que la concederá; y

(ii) *b.p. decretalis*: cuando, sin estar considerada en el edicto, el pretor la concede a quien la pide, luego de haber examinado su petición (*causa cognita*) por medio de un *decretum*.

A su vez, por las causas de atribución a los peticionantes, se habla:

a) *b.p. secundum tabulas*, es decir, la que se concede al heredero instituido en las tablas de un testamento;

b) *b.p. contra tabulas*, es decir, en contra de lo que dicen las tablas del testamento. Así, p. ej., para el caso de una *filia* preterida por su *pater* en el testamento;

c) *b.p. ab intestato* (*sine tabulis*). El pretor otorga en el edicto la *b.p.* en la herencia intestada, a veces confirmando lo que dice el *ius civile*, y en otras produciendo correcciones

(así, al admitir al hijo emancipado, que no es heredero civil) e innovaciones (al admitir a los cognados, luego de haber ofrecido la *b.p.* a los herederos civiles y no haberse éstos presentado).

C) En todos los casos, la concesión de la *b.p.* no es automática, sino que hay que peticionarla al magistrado.

1. La petición se debía hacer en la época clásica ante el pretor en Roma y ante el gobernador en las provincias. Según Theóphilo (Parafr. 3.9.10) el que pedía la *b.p.* debía decir: "Dame esta *bonorum possessio*" (*Da mihi hanc bonorum possessionem*).

2. El plazo estaba fijado en el edicto. Era de un año para los ascendientes y descendientes, y de 100 días para todos los demás (Inst., 3.9.8). Se debía contar únicamente los "días útiles", es decir, solamente aquellos en que estaba permitido presentarse ante el magistrado (EP, § 165; Inst., 3.9.10). Mediante este plazo se quería proteger a los acreedores, los legatarios y otros interesados, obligando a los que pudieran pedir la *b.p.* a no dejar indefinida la situación de la herencia. Quien dejara vencer el plazo sin pedir la *b.p.* perdía el derecho a reclamarla.

La situación del *bonorum possessor* es la siguiente:

a) Queda equiparado al heredero, en el sentido de que puede ejercer las acciones que tendría éste. El pretor utilizará fórmulas ficticias ("si fuera heredero"), tanto si se trata de una *rei vindicatio*, como del reclamo de un crédito. Igual-

mente podrá ser demandado mediante fórmulas análogas (Gayo, 4.34).

b) Goza de la protección interdictal. Así, del interdicto *quod legatorum* contra los legatarios que se apoderen de las cosas legadas sin su permiso (EP, § 67). Y también del interdicto *quorum bonorum* (Paulo, D.43.2.1 pr.) para reclamar los bienes de la herencia respecto del poseedor del patrimonio hereditario (no de un bien a título singular).

c) Respecto de las cosas hereditarias, por ser la *b.p.* una institución pretoriana, no son adquiridas *ex iure Quiritium*, sino que las tenía *in bonis*, pudiendo usucapirlas desde el día en que entren en posesión (Gayo, 3.80).

El sistema pretoriano de la *b.p.* seguirá practicándose en toda la época clásica y comienzos de la posclásica. Por una constitución de Constantino, la *b.p.* se puede pedir no solamente a los magistrados sino también a los jueces, suprimiéndose toda solemnidad de palabras (C.6.9.9; año 339). Por otra del mismo emperador, se excusa a aquellos que por ser rústicos, o por ignorancia o ausencia, no la pidieron; la *b.p.* no es necesario pedirla, bastando una aceptación de hecho (C.6.9.8). Ésta será la regla general: "Que nadie se inquiete por formular una petición de *b.p.*, sino que manifestando de cualquier manera, pero dentro del plazo fijado, su intención de aceptarla, ellos adquieren todo el beneficio" (Inst., 3.9.10). De este modo, si bien se continúa la diferencia terminológica entre *b.p.* y hereditas, en la realidad efectiva las dos instituciones tienden a confundirse.

CAPÍTULO 2

HERENCIA AB INTESTATO

§ 581. Muerta una persona, lo primero que hay que averiguar es si ésta ha dejado un testamento válido, en cuyo caso hay que abrir la herencia testamentaria según lo establecido por el testador. Esto significa una precedencia jurídica de la herencia testamentaria respecto a la herencia *ab intestato*.

Pero, aun aclarado ello, resulta conveniente conocer en forma previa cómo era el orden sucesorio *ab intestato*, tanto el legítimo del *ius civile* como el del orden pretoriano, sobre todo por las variadas implicancias jurídicas que el testamento podía tener respecto de dichos herederos legítimos *ab intestato*.

A) Se abre la herencia *ab intestato* cuando: a) no existe testamento; o b) cuando existente éste, no resulta válido, por no cumplirse las formalidades o darse otras circunstancias; o c) cuando no obstante ser válido el testamento, éste se torna ineficaz porque los herederos instituidos no han aceptado la herencia (Inst., 3.1 pr.; Ulp., D.28.26.1; Paulo, 4.8.1).

B) La herencia *ab intestato* no se abre desde la muerte del *de cuius*, sino solamente cuando resulta cierto que no hay herencia testamentaria (Inst., 3.1.7). Así, si el causante no ha hecho testamento o éste resulta desde el principio nulo o inválido por cualquier motivo antes de su deceso, entonces la herencia *ab intestato* se abre en el momento mismo del fallecimiento, porque hay certidumbre de que no habrá herencia testamentaria. En todos los otros casos, existiendo un testamento y siendo posterior la causa de invalidez o ineficacia: así, por no haber aceptado la herencia el heredero voluntario instituido, la herencia *ab intestato* no se abrirá sino a partir del momento en que ocurran esos eventos y sea cierto de que no hay heredero por testamento (Inst., 3.2.6).

C) Consecuentemente con ello, la existencia y la capacidad de los herederos *ab intestato* serán consideradas a partir de la apertura de esta clase de herencia. Así, puede suceder que quien sea heredero en el momento de la muerte no lo sea, por muerte o incapacidad, en el de la apertura de la herencia *ab intestato*, y a la inversa, que los herederos *ab intestato* en el momento de la apertura de esta herencia sean

parientes que por el orden y rango no lo hubieran sido en el momento de la muerte del *de cuius*.

I. En la herencia *ab intestato*, si no existir voluntad válida del *de cuius*, es el *ius* el que determinará el orden sucesorio. O mejor este orden es el fijado normalmente por el *ius*, a menos que el causante hubiera fijado una voluntad distinta en el testamento. El *ius* seguirá las reglas fundamentales de la constitución de la familia romana en el decurso de las distintas épocas. Haciendo un bosquejo histórico del desarrollo de este orden legítimo, podemos distinguir estas etapas:

2. a) En el viejo derecho de la ley de las XII Tablas se establece la neta supremacía del vínculo "agnaticio". Éste se caracteriza por ser artificial, estando netamente vinculado con la concepción de la primitiva familia romana, prácticamente una organización jurídico-política en la cual se conservan los *sacra privata*.

3. b) Con el correr del tiempo, ya a fines de la época republicana se va produciendo una transformación de la familia. Se van debilitando las viejas tradiciones y el "vínculo agnaticio", de tal modo que el parentesco natural por sangre; es decir, el "vínculo cognaticio", que estaba subyacente, comienza a emerger. De ahí que aparecen situaciones que en esta nueva época lucen como inequitativas.

Estas *iuris inaequitates* merecerán la atención del pretor, que si bien no puede derogar los principios del *ius civile*, corregirá sabia y prudentemente los defectos producidos por medio de la *bonorum possessio*.

4. Una brecha más importante para el reconocimiento de la cognación, por afectar directamente a la *hereditas*, se producirá por los s.c. Tertuliano y Orficiano. Finalmente, Justiniano, en las Novelas 118 y 127, dispondrá el orden sucesorio únicamente basado en el parentesco por sangre, con total desconocimiento de la desaparecida familia agnaticia.

I. Sucesión intestada de la Ley de las XII Tablas.

§ 582. La ley de las XII Tablas establecía: "Si se muere intestado, no conociéndose a herede-

déro suyo» (*suus heres*), que el agnado próximo tenga la familia. Si no se conociera agnado, que la familia la tengan los gentiles" (XII Ts. 5.4-5; Ulp., 26.1; Ulp., D.50.16.195.1; Paulo, 4.8.3; D.28.29.2).

§ 583. A) Los que heredan en primer lugar son los *sui heredes*. Estos son todos los descendientes que estaban *in potestate* del *pater* en el momento de su deceso, sin distinguir entre varones y mujeres ni entre naturales y adoptivos, o lo hubieran estado de haber vivido el *pater* (hijos póstumos); Gayo, 3.1.2 y 4; Inst., 3.1.2; Ulp., D.28.26.1; Paulo, 4.8.1.

Igualmente es *sua heres* la *uxor in manu* del causante marido, pues está ubicada como su hija (*in filiae loco*), del mismo modo que la nuera que está *in manu* del hijo, ubicada en lugar de nieta, pero en este caso sólo será *sua heres* si su marido no esté bajo la *potestas* del *pater* al momento de su muerte (Gayo, 3.3).

Los nietos y nietas habidos del hijo, o el bisnieto y la bisnieta habidos del nieto también son eventualmente *sui heredes*, pero únicamente en el caso de que la o las personas que los preceden hayan premuerto o dejado de estar *in potestate*, como p.ej. por haber sido emancipados (Gayo, 3.2; Inst., 3.1.2).

a) De este modo, podemos establecer la regla de que los que están en primer grado (p.ej., hijos e hijas) desplazan a los que están en grado ulterior (nietos y nietas). Y en principio, la división de la herencia se hace *per capita*, es decir, cada uno tendrá una cuota igual.

1. Así, el siguiente caso: Muere A dejando a su mujer A' *in manu*, de la cual ha tenido tres hijos B, C y D. La herencia se divide en cuatro partes iguales para A', B, C y D.

Si C y D han sido emancipados, y por ello dejado de ser agnados, los herederos serán A' y B por partes iguales.

b) Pero si un hijo ha premuerto o dejado de estar *in potestate*, habiendo dejado nietos, la parte que le hubiera correspondido al hijo fallecido le es atribuida a sus hijos y su *uxor in manu* (Gayo, 3.8; Inst., 3.1.6; Ulp., 26.2; Paulo, 4.8.9). Se habla acá de "representación" de los descendientes en la cabeza de su antecesor.

De este modo, la herencia se divide en principio considerando cuántas cabezas de *sui heredes* había, incluido el hijo premuerto (división *per stirpes*). La porción de este último se distribuye *per capita* entre sus hijos; que son nietos del causante.

1. Así, en el mismo caso anterior: muere A dejando a su mujer A' *in manu* y a tres hijos B, C y D:

Pero B ha premuerto dejando nietos. La herencia se divide en cuatro partes (*per stirpes*), siendo los herederos A', C, D, y la parte que le hubiera correspondido a B se subdivide *per capita* entre los nietos.

No se requiere la aceptación de la herencia por parte de los *sui heredes*, ya que éstos la adquieren automáticamente (*ipso iure*); Inst., 3.1.3.

§ 584. B) De no haber *sui heredes*, la herencia va al agnado o agnados que se hallen en grado más próximo (*proximus agnatus*); Gayo, 3.9.11; Inst., 3.2.1). Los agnados son aquellos unidos por una cognación legítima, es decir, el vínculo legítimo por vía masculina. Así, los hermanos o hermanas del *de cuius*, el tío o la tía paterna respecto del sobrino o sobrina y recíprocamente, luego los primos, etc. (Gayo, 3.10; Inst., 3.2.1; Ulp., D.38.16.2.1). Se siguen estas reglas:

(i) Se da al "agnado próximo" que esté vivo no en el momento de la muerte del causante, sino en el momento en que resulte cierto que ha muerto intestado (Gayo, 3.13; Inst., 3.2.6). A su vez, debe aceptarla, ya que la adquisición no es automática.

(ii) Si no la acepta o ha muerto antes de aceptarla, la herencia no pasa a los agnados en grado posterior, ni tampoco existe derecho de "representación" (Gayo, 3.12; Inst., 3.2.7). Por ello, si hay varios agnados en el mismo grado que han aceptado la herencia, la división es siempre *per capita* (Ulp., 26.4).

1. La agnación va siempre por la línea masculina (Paulo, 4.8.13). Los más próximos son los hermanos (2º grado), los tíos (3º grado) y los primos (4º grado) (Gayo, 3.10; Inst., 3.2.1).

Se podía dar el siguiente caso: hay dos hermanos que han premuerto y ambos han dejado hijos (es decir, sobrinos del causante). Si del hermano A hay tres sobrinos y del hermano B sólo uno, se discutió en un principio si la división de la herencia debía que hacerla *per stirpes* (acá habría dos: la de cada hermano) o *per capita*. Pero el criterio que predominó fue este último, y por ello tantas fueran las personas, tantas serían las partes (Gayo, 3.16; Inst., 3.2.4).

2. En un principio no se distinguía entre varones y mujeres. Pero luego, quizá por la ley *Voconia** (Paulo, 4.8.22), solamente se admitió a las mujeres agnadas que fueran hermanas del *de cuius* (Gayo, 3.14; Paulo, 4.8.20). Por ello dice Justiniano, respecto de esta época, que "así, sucedas tú a la hija de tu hermano, o de tu tío paterno, o a tu tía paterna, pero ellas no te suceden a ti" (Inst., 3.2.3).

El pretor, sin embargo, sin modificar el concepto de agnado, admitirá que las mujeres puedan pedir la b.p., más allá del grado de fraternidad, en el llamamiento *unde cognati**. Justiniano, volviendo a lo establecido por la ley de las XII Tablas, determinará

que las mujeres serán llamadas al igual que los varones, sin distinción, a su rango de agnación (C.6.58.14, año 531). Señalemos que la agnación será luego reemplazada por la cognación conforme a lo establecido en las Novelas 115 y 127, que veremos después.

§ 585. C) A falta de *sui heredes* y de agnados, la herencia va a los gentiles. Siendo la *gens* una unión agnática de familias, parece incongruente la expresión "Si no se conociera agnado", puesto que existente la *gens* debía haber agnados —la agnación es considerada *in infinitum* (Ulp., D.38.16.2.1). En cambio, la regla tiene sentido cuando el agnado próximo rehusaba la herencia. Dado este caso, le corresponde la herencia a la *gens*, siendo administrada por uno de sus integrantes. Este llamamiento a la *gens* desapareció cuando ésta perdió vigencia ya a fines de la República (Gayo, 3.17; Coll., 16.2.17; 16.4.2; Ulp., 26.1a).

II. Sucesión de la *bonorum possessio ab intestato*.

§ 586. El orden sucesorio de las XII Tablas era congruente con la vigencia de la familia agnática. Con el debilitamiento de ésta comenzaron a existir situaciones inequitativas. Así, el hijo emancipado, por no ser agnado no es *suus heres*. Tampoco la madre (si no era *uxor in manu*) puede ser heredera de sus hijos, ni tampoco éstos herederos de ella. Y por supuesto, los demás cognados tampoco tienen vocación hereditaria (Gayo, 3.19-24; Ulp., 27.5). Tampoco los agnados, si el agnado próximo no aceptaba la herencia (Gayo, 3.12; 28; Inst., 3.2.7; Ulp., 26.5).

Estos inconvenientes serán paliados por el pretor. Cumplimentando un verdadero ejemplo del *ars iuris*, trabajará no sobre la *hereditas* (el pretor no puede hacer herederos; Gayo, 3.32; Inst., 3.9.2), sino sobre la *bonorum possessio*, que por ser una creación pretoriana, le permitirá dar la posesión hereditaria (no la titularidad de heredero y la propiedad de la herencia) a las personas que, por equidad, considera que pueden estar "en el lugar de los herederos" (*loco heredium*; Gayo, 3.32; Inst., 3.9.2). Todo esto conducirá al orden sucesorio *ab intestato* por carriles distintos de los señalados por el *ius civile*.

1. El orden establecido por el pretor no significa la supresión de la herencia civil. Así, el heredero civil predominará en caso de reclamo respecto del *bonorum possessor*. Generalmente la b.p. era en este caso concedida *sine re* (salvo para el caso del llamamiento primero *unde liberi*, que se otorgaba *cum re*).

2. La *bonorum possessio* se daba dentro del año, si se trata de ascendientes y descendientes; y dentro

de los 100 días para los demás, contados desde que pudieran pedirla (EP, § 165; Inst., 3.9.8).

§ 587. *Bonorum possessio edictalis*. El pretor, en el Edicto, llama en orden sucesivo a los beneficiarios, los cuales están agrupados en varias clases de llamamientos.

1. Así, si alguien que no está en una clase no hace uso de la b.p. que le es ofrecida, aprovechan de ella los otros de la misma clase, que de este modo acrecentarían su parte. Si todos los de una clase no la piden o la repudian, entonces se pasa al orden siguiente.

Los llamamientos efectuados por el pretor guardan el siguiente orden:

§ 588. I. *Llamamiento unde liberi* (D.38.6). En primer término se llama a los "descendientes" (*liberi*). Se entiende comprendidos no solamente a los *sui heredes*, sino también a todos los descendientes en general por la vía de varón, aunque no estén en la *potestas* del *pater* (Ulp., D.1.9.10; D.50.16.56.1 itp.). No tiene lugar respecto de la herencia de mujeres, pues éstas no tienen *sui heredes*.

Con ello, el pretor en parte confirma el llamamiento primero de la ley de las XII Tablas al llamar a los *sui heredes*, pero lo corrige llamando a los hijos emancipados.

1. Por tanto, entran en este llamamiento no sólo los *sui heredes*, sino en general los *liberi* (descendientes), y es por ello que se llama a los emancipados.

En cambio, no son llamados los hijos dados en adopción, pues están en otra familia. Pero si antes de la muerte de su padre sanguíneo han sido emancipados, entonces pueden pedir este llamamiento, ya que se los considera como si emancipados por su padre sanguíneo, no hubiesen nunca pasado a una familia adoptiva (Gayo, 2.137; Inst., 2.13.4; 3.1.10-12). Esto no rige si hubieren sido emancipados después de la muerte del padre sanguíneo, ya que se los considera como extraños al *pater* adoptivo, sin tener ningún derecho como hijo a la sucesión del padre sanguíneo (Inst., 3.1.10).

2. Lo mismo que en la sucesión civil, no se hace diferencia de sexo, de tal modo que varones y mujeres se hallan equiparados. Existe el "derecho de representación". Así, hay dos hijos: A, que es *suus heres*, y B, emancipado, pero este último ha premuerto. Entonces la b.p. se divide de este modo: A tendrá la mitad y la restante se divide entre los dos hijos de B.

3. Se daba un caso especial cuando el *pater* había emancipado a su hijo habiendo retenido *in potestate* a los nietos habidos de él. Así, p.ej., X tiene un hijo A que le ha dado dos nietos B y C. Al morir X, el único que podía pedir la b.p. era A, excluyendo por

rango más lejano a B y a C. Esto fue corregido por Juliano, que introdujo el principio (*nova clausula Iuliani*), según la cual entre el emancipado y sus hijos retenidos *in potestate* se debía hacer concurso, de tal modo que en el ej. dado el padre emancipado quedaba con la mitad, y B y C por la otra; debiéndose repartir un cuarto para cada uno (EP, § 146; Marcelo, D.37.8.3; Ulp., D.37.9.1.13).

4. En un principio la b.p. del emancipado debió haber sido *sine re*, pero luego fue *cum re*, es decir, podía rechazar por una *exceptio doli* el reclamo de los herederos legítimos. En el caso previsto por Juliano debió ser en principio *sine re*, pues de lo contrario rechazaba los derechos legítimos de sus hijos. Con la *nova clausula Iuliani* se le concede *cum re* respecto de la mitad, reservando la otra mitad a B y a C, que de este modo no quedaban excluidos.

§ 589. Colación de bienes (*collatio bonorum*). En el caso del hijo emancipado se producía un caso de desigualdad. En efecto, éste al ser *sui iuris* ha tenido oportunidad de tener su patrimonio, mientras que los que quedaron *in potestate* no la tuvieron. De este modo, al pedir el emancipado la b.p. recibía una parte igual a la de sus hermanos y retenía su propio patrimonio.

Para solucionar esta situación injusta el pretor obliga al emancipado que pida la b.p. que efectúe la "colación de bienes", es decir, que se obligara a dar al o a los hermanos *sui heredes* una razonable parte de sus propios bienes (EP, § 144).

1. La entrega de los bienes no se realizaba de manera efectiva. De hacerlo así, tenía el inconveniente de que el emancipado podría correr el riesgo de no reencontrarse con sus bienes. A los efectos de la colación vale el cálculo contable. Realizado éste, el emancipado se obliga por una *stipulatio* a aportar el valor de los bienes que correspondían.

2. Los bienes colacionables no son, como se suele creer, la totalidad de los bienes del emancipado, sino una suma representada por el cálculo de sus bienes en relación con las cuotas de los *sui heredes*. Así, si hay tres hijos, dos *in potestate* y el tercero emancipado, siendo el patrimonio de éste de 300. Lo que se debe colacionar es 200, reteniendo para sí 100. En efecto, como son tres los que piden la b.p., los 300 se dividen por tres, colacionando el emancipado las partes de los otros dos (Ulp., D.37.6.1.24).

3. Si fueran varios los emancipados, cada uno de ellos debe estipular la parte que le corresponde. Pero a los efectos de determinar la cuota de colación se considera una sola porción, que se debe dividir entre los obligados a ella.

Así, en el ej. anterior, siendo un *sui heres* y dos emancipados, se consideran dos porciones, una por el *sui iuris* y otra por los emancipados. Estos deben colacionar cada uno de ellos la mitad de su patrimonio

(Ulp., D.íd.). Los emancipados no colacionan entre sí.

4. Consideremos este caso planteado por Juliano (D.37.6.3.2), aunque variando alguna cifra: La herencia es de 400, existiendo cuatro hijos, A y B, que estaban *in potestate*, y C y D, que habían sido emancipados. C tiene un patrimonio de 90 y D uno de 60. Como son cuatro los que reclaman la b.p., a cada uno de ellos les corresponde una cuarta parte. Pero como sólo se considera como uno a los emancipados, la colación de éstos es por un tercio por parte de cada uno de ellos.

De este modo.

A obtiene su porción de la cuarta parte de la herencia, es decir, 100. Y a su vez consigue de C un tercio de sus bienes propios (90 dividido 3 = 30) y de D también un tercio (60 dividido 3 = 20). Por ello consigue el total de 150.

B obtiene igual que A, por los mismos cálculos, la suma de 150.

C obtiene una cuarta parte de la herencia (= 100), reteniendo de su patrimonio un tercio (es decir, 30), pues los 2/3 restantes se los debe colacionar 1/3 (30) a A y 1/3 (otros 30) a B. Consegue, pues, la suma de 130.

Siendo así, considerando el cálculo de lo que recibe por la cuota hereditaria y lo que debió colacionar a ambos *sui heredes*, es decir, 60, ello significa que al pedir la b.p. logrará un beneficio neto de 40 (recibe 100 - 60 = 40).

D obtiene una cuarta parte de la herencia (= 100) reteniendo de su patrimonio 1/3 (es decir, 20), pues los 2/3 restantes se los debe colacionar 1/3 (20) a A y 1/3 a B (otros 20). Por ello consigue la suma de 120.

Considerando el monto de la colacionado (40), podemos ver como el beneficio neto que obtiene al pedir la b.p. es de 60 (100 - 40 = 60).

5. Por ello, el emancipado debía tener cuidado de hacer estos cálculos, puesto que en algún caso, en lugar de obtener un beneficio lo logrado era una pérdida. El riesgo de aportar más de lo que se adquiere de la herencia lo debe soportar el emancipado.

§ 590. Colación de la dote. Un problema análogo se presentaba en el caso de que el *pater* hubiese dotado a su hija emancipada. La dote, en principio, le pertenece al marido, y no a la mujer, pero si se disolvía el matrimonio por la muerte del marido o por divorcio, a ella le corresponderá la dote.

Por ello, en el Edicto hubo que prever que si la hija dotada se presentaba a pedir la b.p., el pretor la obligaba a tener que dar una *cautio* por medio de una *stipulatio* de que cuando llegue a adquirir la dote, la compartirá con los *sui heredes*, en proporción a sus cuotas hereditarias, según reglas análogas a las ya vistas de la *collatio bonorum*. A esta forma de colación se la denominó *collatio dotis* (D.37.7; EP, §§ 145; 283).

Por un rescripto de Antonino Pío se determinó que, aun fuera del caso del llamamiento *unde liberi* de la b.p., cuando se pidiera la división de la herencia por la *actio familiae erciscundae*, se debía producir la *collatio dotis* (Ulp., D.37.7.1 pr.). A su vez, el emperador Gordiano extenderá el beneficio de esta colación, que en principio era en favor de los *sui heredes*, también a los hijos emancipados (C.6.20.4; año 239).

§ 591. En la época posclásica, la colación de los emancipados perdió justificación debido a la ampliación de la capacidad patrimonial de los hijos (*supra*, § 517, E). Pero se generalizó la obligación de colacionar todas las donaciones efectuadas por el *pater* a sus descendientes. Se entendió que quiso tratar por igual a todos sus descendientes, por lo que las donaciones efectuadas en vida debían imputarse a la respectiva cuota hereditaria, como adelanto de la herencia (C.3.28.29; año 479; C.6.20.20; año 529; Nov. 18.6; año 536).

§ 592. II. Llamamiento *unde legitimi* (D.38.7). En caso de no haber *liberi*, o no haberse éstos presentado a reclamar la b.p., el pretor abre el segundo llamamiento al agnado o agnados próximos (no los más lejanos; Gayo, 3.28). Acá, el pretor no se aparta en nada, sino que confirma plenamente el orden sucesorio de la ley de las XII Tablas.

Esta b.p. era concedida *sine re*, por lo que un heredero civil con mejor derecho (así el *sui heres* o agnados en grado más próximo), podían reclamar con éxito la herencia (Gayo, 3.37).

§ 593. III. Llamamiento *unde cognati* (D.38.8). El pretor, luego de haber hecho los dos primeros llamamientos (*unde liberi* y *unde legitimi*) ya ha agotado la nómina de los herederos civiles, basados en el parentesco agnático. Ahora puede, por tanto, si éstos no se han presentado, seguir haciendo otros llamamientos, con los cuales completará lo establecido por el *ius civile* (*supplendi iuris civilis gratia*). Adviene acá la gran innovación al admitir a los cognados.

Entran en este llamamiento los parientes cognados hasta el sexto grado, si bien se computará también el séptimo grado para los hijos de los nietos del tío (*consobrini nepotes natí*). El orden está dado por la regla según la cual el de grado más cercano excluye al más lejano. Si hay dos o más en igual grado, se dividen la b.p. *per capita* entre ellos (Ulp., D.38.8.1.5 ss.; *id.*, 10). Esta b.p. es *sine re*, es decir, cede ante el reclamo de los herederos legítimos (Gayo, 3.27; 37; Ulp., 23.6; 28.13).

1. No interesa si la cognación se produce por el lado paterno o materno, a diferencia de la agnación que sólo computa a los descendientes por la línea masculina. El parentesco adoptivo es equiparado al sanguíneo, reteniendo su parentesco con su padre natural (Ulp., D.38.8.1.4). Igualmente se computa al póstumo, siempre y cuando nazca vivo (Ulp., D.íd. 1.8).

2. Los hijos de los tíos (primos carnales, 4° grado) son llamados *consobrini*, y los nietos de ellos (6° grado) son llamados *consobrini nepotes*. Acá, en el caso excepcional del 7° grado, se considera a los hijos de éstos.

§ 594. IV. Llamamiento *unde vir et uxor*. A falta de los anteriores se llama finalmente al cónyuge supérstite, sea la *uxor* que sobrevive a la muerte del marido, o al *vir* en caso de ser éste el sobreviviente. Lo que se requiere es que el matrimonio subsista al tiempo de la muerte del cónyuge respectivo (Ulp., D.38.11.1).

1. Hay que tomar en cuenta que se debe tratar de un matrimonio *sine manu*. Caso contrario, la *uxor in manu* podría pedir como *sua heres* la b.p., ya por el llamamiento *unde liberi* y eventualmente por el *unde legitimi*. En cuanto al marido supérstite respecto de su *uxor in manu*, no puede heredar nada de ella, puesto que es *alieni iuris*.

§ 595. A los efectos de la b.p., ya destacados en cada caso, podemos decir que la regla general es que frente a los "herederos legítimos" era otorgada *sine re*, lo cual significaba que si éstos reclaman la herencia triunfan respecto de los *bonorum possessores*.

El único caso que se concede *cum re* es respecto de los que la obtienen por el primer llamamiento (*unde liberi*). Así, X ha dejado un *sui heres* A y un emancipado B. Si ambos han pedido la b.p., ambos la tienen *cum re* respecto de la mitad. Incluso B, que no es *sui heres* respecto de A. Respecto del caso especial de la *nova clausula Iuliani* ver *supra*, § 588.3.4).

En el caso de los agnados, su posesión era *sine re* respecto de los *sui heredes*, que pueden reclamarle y triunfar en la petición de la herencia. En cambio, si el agnado, p.ej., aceptó la herencia, pero no pidió la b.p., y ésta era solicitada por un cognado, la de este último es *sine re*, y cede frente al reclamo del agnado (Gayo, 3.37).

Finalmente, los llamados *unde cognati* y *unde vir et uxor*, la obtendrán *sine re*. Pero se pueden sentir relativamente seguros porque significa que no se han presentado los de *legitimum ius* que los precedían. Por supuesto que si existen y se presentan estos últimos tienen prevalencia sobre los cognados y el cónyuge supérstite.

§ 596. Bonorum possessiones decretales. Había ciertos casos especiales en los cuales el pretor, previo examen (*cognitio*) de la situación, podía otorgar una b.p. por medio de un decreto:

a) Cuando en el momento de pedir la b.p. un hijo impúber, se discutiera por parte de los otros herederos su vocación hereditaria, se estableció por el *Edicto Carboniano* (D.37.10) que el pretor le concedía provisionalmente la b.p., difiriendo el problema de la discusión de su situación para cuando llegara a la pubertad (Ulp., D.37.10.1 pr.).

1. Se aplicaba tanto a los varones como a las mujeres que descendiesen por vía masculina (Ulp., D.id.1.2). Y ello tanto si se discutiera su *status familiae*, como si se pusiera en tela de juicio su libertad (Juliano, rescripto de Antonino Pio, D.37.10.1.6), o también si se discutía que se tratara de un hijo adoptivo (Juliano, D.37.10.7 pr.).

2. Por una constitución de Diocleciano (C.6.17.1; año 293) se dispuso que el impúber cuestionado debía dar previamente una caución (*satisfactio*).

b) La *uxor* del causante que estuviera embarazada podía pedir la b.p. en nombre del concebido que tuviera eventuales derechos hereditarios (*b.p. ventris nomine*), debiendo pedir la designación de un *curator ad ventrem* (Ulp., D.37.9.1 pr.; D.id.1.27). Esta b.p. era provisional y cesaba si la mujer estaba equivocadamente embarazada o que el *nasciturus* se hallara sin vida (Ulp., D.37.9.1.27).

c) El curador del demente, quien obviamente no podía aceptar la herencia, podía también pedir en su nombre la *bonorum possessio furiosi nomine*. Si el demente recobraba la razón tenía libertad para aceptar o repudiar la herencia. Si la repudiaba o si hubiera fallecido antes de recuperar las facultades mentales, esta b.p. cesaba (Pap., D.37.3.1; C.5.70.7.3).

III. Reformas del Derecho Imperial.

§ 597. Por lo que hemos visto, frente a lo dispuesto por el *ius civile* que basa la vocación hereditaria según el parentesco "agnático", la creación pretoriana de la *bonorum possessio ab intestato* había producido las innovaciones ya mencionadas, admitiendo que se pudiera pedirla según el parentesco "cognático" (caso del hijo emancipado en el llamamiento *unde liberi*; y en general de los cognados en el tercer llamamiento *unde cognati*).

La evolución posterior en el Derecho Imperial significará la admisión del vínculo cognático, es decir, por sangre, dentro del sistema jurídico del *ius civile*. Con ello, lentamente y no siempre en forma clara, los cognados serán admitidos, no sólo a los llamamientos de la b.p., sino a la hereditas.

§ 598. A) Dos senadoconsultos del siglo II, introducen reformas en cuanto a la hereditas mejorando la sucesión entre madre e hijo.

1. Para poder comprender esto hay que recordar que en el caso de que la madre estuviera sometida a la *manus*, es decir, fuera una *uxor in manu*, entraba como agnada dentro de la familia de su marido, ubicándose en lugar de hija (*in loco filiae*). Siendo así, la madre y sus hijos eran *sui heredes* del pater fallecido. Además, según el derecho pretoriano podían pedir la b.p. en el primer llamamiento *unde liberi*.

2. Pero si la madre había contraído "matrimonio libre" (*sine manu*), según el *ius civile* ni la madre podía heredar a sus hijos ni éstos a la madre, porque simplemente se los considera cognados, ya que, como sabemos, la agnación se transmite por vía masculina, y no por la femenina. En cambio, por el derecho pretoriano podían acceder al tercer llamamiento (*unde cognati*) de la b.p. *ab intestato*.

3. Como la *manus* fue cayendo en desuso desde comienzos de la época clásica, la situación recíproca de la vocación hereditaria se fue tornando inequitativa, incluso para el propio *ius civile*. Y ésta es la razón de las reformas que se irán produciendo.

§ 599. I. S.c. Tertullianum. Por el s.c. Tertuliano (época de Adriano, sobre la base de un precedente de Claudio; Inst., 3.3.1-2), se estableció que la madre podía heredar *ab intestato* a sus hijos, aunque con ciertos condicionamientos y siempre y cuando tuviera el *ius liberorum* (la madre ingenua con tres hijos y la liberta con cuatro; Inst., 3.3.2; Ulp., D.38.17.2 pr.; C.6.56.1).

1. Esta sucesión le es concedida a la madre, no a la abuela (Inst., 3.3.2). Pero la madre sólo heredaba a sus hijos si no existían descendientes del hijo, el padre de éste que lo hubiese emancipado (*parens manumissor*) o hermanos consanguíneos del hijo. En efecto, éstos excluían preferentemente a la madre (Ulp., D.38.17.2.14; D.id.2.16-17).

2. Si el hijo fallecido sólo tenía hermanas consanguíneas éstas concurren con la madre (Ulp., 26.7; D.38.17.18; Inst., 3.3.3). En cambio, si el hijo tenía un hermano y una hermana, la madre quedaba excluida y la herencia se distribuía por sus respectivas partes entre el hermano y la hermana (Inst., 3.3.3).

3. Fuera de estas personas que la podían excluir o limitar, la madre será preferida respecto de los otros cognados. No interesa si el hijo es legítimo o natural (*vulgo conceptus*; Paulo, 4.10, Inst., 3.4.7).

4. La madre es considerada "heredera voluntaria", de tal modo que debía aceptar la herencia (*aditio hereditatis*). Si la madre se hallaba *in potestate*, la aceptación de la herencia debía hacerse con autorización de su pater (Inst., 3.3.2).

Si la madre tenía un hijo impúber, se debía ocupar de pedir dentro del año un tutor para dicho

hijo, o ya su reemplazo en caso de que el tutor se hubiera excusado o hubiera sido removido. Caso contrario era rechazada de la sucesión de estos hijos que mueren impúberes (epístola de Septimio Severo; Modestino, D.26.6.2.2; Inst., 3.3.6).

5. Finalmente, Justiniano dejó a un lado la exigencia del *ius liberorum*, otorgando la herencia a la madre aunque el hijo fallecido fuera el único que tenía (C.8.59.2, año 528; Inst., 3.3.4). Además, será considerada heredera con preferencia a todos los herederos legítimos con excepción del padre sanguíneo y de los hermanos y hermanas del hijo. Si sólo quedaban hermanas (agnadas o cognadas), la madre tendrá la mitad y las hermanas se deben repartir la otra mitad. Pero si queda uno o varios hermanos solos, o con ellos hermanas, la división será *per capita* (C.6.56.7 pr. y 1; Inst., 3.3.4). Luego, por la Nov.22.47, también será *per capita* en el caso de la concurrencia de la madre con las hermanas.

§ 600. II. S.c. Orphitianum. Por el senadoconsulto Orficiano, del año 178, siendo cónsules Orfito y Rufo, por iniciativa de Marco Aurelio y Cómodo, la herencia de la madre no sometida a la *manus* de su marido, corresponde a sus hijos, excluyendo a sus consanguíneos y a los otros agnados (Ulp., 26.7; Inst., 3.4 pr.).

1. Este s.c. Orficiano dejaba sin resolver el caso siguiente: Cuando moría la madre, la herencia *ab intestato* podía ser pedida por la abuela sobreviviente por el s.c. Tertuliano, pero también por los hijos por el s.c. Orficiano.

2. La solución fue dada por una constitución de Graciano, Teodosio y Valentiano, según la cual la herencia les debía corresponder a los hijos, con exclusión de la madre de la causante, o sea, la abuela materna (C.6.57.4, año 383).

§ 601. B) Constituciones imperiales posteriores fueron ampliando las disposiciones de los s.c. mencionados. Se nota en ellas un claro avance del parentesco cognático.

I. Caso de los nietos nacidos de una hija. Por el principio de la agnación, estos nietos serán herederos legítimos de su pater, sea éste su padre o su abuelo paterno. Pero respecto del abuelo materno, sólo estaban unidos por la cognación. Si la madre premorfa en relación con su abuelo, los nietos por la vía materna sólo podían pedir como cognados la b.p. *unde cognati*.

Por una constitución de Valentiniano, Teodosio y Arcadio (C.6.55.9), se admite la vocación hereditaria de dichos nietos, de tal modo que podían reclamar, pero sólo hasta las 2/3 partes lo que hubiera correspondido a la madre en la herencia de su abuelo, correspondiendo el tercio restante a los otros hijos del abuelo materno (C.6.55.9, año 389). Esta limitación fue suprimida por Justiniano, de tal modo que

a los nietos les correspondió el todo de lo que hubiera correspondido a la madre (C.6.55.12, año 528).

II. Caso de los hermanos y hermanas cognados. Éstos eran los hijos e hijas emancipados, por lo que no eran herederos legítimos. Por un edicto del emperador Anastasio (*constitutio Anastasiana*, C. 5.30.4, año 498), éstos concurren con sus hermanos agnados, desplazando a los herederos de grado más lejano, si bien con la limitación de que sólo percibían la mitad de la cuota en la división *per capita*. Esta limitación será también suprimida por Justiniano, de tal modo que todos los hijos concurren en total igualdad (C.6.58.15.1, año 534). Con ello se confirma por el *ius civile*, lo que había establecido el pretor en el llamamiento *unde liberi*.

III. Caso de los hijos adoptivos. Si el hijo adoptivo era emancipado por su pater después de la muerte de su padre sanguíneo, en principio no podía heredar ni a su pater adoptivo, ya que no pertenecía a su familia, ni a su pater sanguíneo, cuya herencia ya había sido cobrada por otros herederos. Tampoco podía pedir la b.p. por no ser ni agnado ni cognado.

Un remedio para este problema fue dado por un s.c. Sabinianum (Inst., 3.1.14; C. 8.48.10.3, pero que al parecer su denominación era la de s.c. *Africanum*). Éste dispuso que el adoptado emancipado, que fuera uno de tres hijos varones, tenía derecho a reclamar en la herencia *ab intestato* del adoptante una cuarta parte de la herencia (*quarta Sabiniana* o *quarta Africana*).

Justiniano, al cambiar el régimen de la adopción (C.8.48.10) estableciendo dos clases: *plena** y *minus plena**, dio una solución total al adoptado para la herencia *ab intestato*. En efecto, si la adopción era *minus plena*, es decir, cuando el adoptante no era un ascendiente, el adoptado puede suceder al adoptante, pero no pierde su vocación hereditaria respecto de su padre sanguíneo, como si no hubiera sido adoptado. A su vez, si la adopción era *plena*, es decir, realizada por un ascendiente, aun emancipado, no deja de ser agnado, pudiendo pedir la b.p. *unde liberi* (C.8.48.10, año 530; Inst., 3.1.14).

IV. Sistema de las Novelas 118 y 127.

§ 602. Por las constituciones del período posclásico y por diversas decisiones tomadas por Justiniano, se había logrado ir conformando un sistema más equitativo de la herencia que el vigente en el *ius civile*, que arrancaba de la ley de las XII Tabas. Pero estos sucesivos retoques ofrecían un panorama muy complicado y confuso. Preocupado por ello, el mismo Justiniano determinó establecer con mayor claridad cómo debía ser el orden sucesorio de la herencia *ab intestato*. Para ello dictó dos Novelas, la 118

(año 544), completada y corregida por la 127 (año 548).

En lo fundamental, se abandonará totalmente el vínculo agnático, para dar total y única admisibilidad al parentesco cognático. La atribución de la *hereditas* (aparece fundido el sistema pretoriano de la *b.p.* con el del nuevo *ius civile*), será en la forma siguiente:

§ 603. I. *Primer orden: Descendentes*. Muerto alguien intestado, lo suceden sus descendientes, con estas características:

A) Ante todo están los hijos, sin distinción de sexo, sean legítimos o adoptivos, sean *sui iuris* o *alieni iuris*. Estos desplazan por estar en primer grado de consanguinidad a los de grado posterior. La división se hace *per capita*. Así, p.ej., si hay tres hijos, a cada uno le corresponde un tercio.

B) Si uno de los hijos ha premuerto, y ha dejado nietos o nietas del causante, éstos, por el "principio de representación", ocupan el lugar de su padre (*in patris locum succedunt*; Nov. 118.1), de tal modo que se reparten también *per capita* la porción que le hubiere correspondido a su padre premuerto.

1. P.ej.: hay tres hijos, A, que vive; B, que ha premuerto y dejado dos nietos; y C, que ha premuerto y dejado dos nietas y un nieto. Por ser tres los hijos, la herencia se divide en tres porciones: 1/3 va a A; 1/3 va a los hijos de B, que se deberán dividir dicha porción por mitades; y finalmente 1/3 va a los hijos de C, que se deberán dividir ahora por tercios dicha porción.

C) Si no hay hijos, la herencia va al grado siguiente, es decir, directamente a los nietos. Éstos, por ser ahora del mismo grado, se la reparten *per capita*.

1. Eventualmente los bisnietos podrían desplazar a sus padres (nietos), en caso de no existir ninguno de éstos. Si un nieto premuere en relación con el causante, en este caso sus descendientes pueden pedir su parte por el "derecho de representación".

§ 604. II. *Segundo orden: Ascendientes y hermanos bilaterales*. Si no existen descendientes, la herencia va a los ascendientes, pero con la particularidad de que podrán concurrir con ellos los hermanos y hermanas bilaterales (hermanos) y sus hijos.

A) Primera hipótesis: Sólo hay ascendientes. En este caso, los de primer grado (padres) desplazan a los de segundo grado (abuelos):

(i) Si están el padre y la madre del causante, ambos se dividen la herencia *per capita* (la mitad al padre; la otra a la madre). Pero si sólo vive uno de ellos, se queda con toda la herencia,

desplazando a los abuelos, quienes no tienen el "derecho de representación".

(ii) Si no están los padres, la herencia va a los abuelos. Pero la herencia se reparte *per stirpes*: así, la línea paterna y la línea materna.

1. Así, p.ej., muerto el causante, no habiendo descendientes, pero existiendo el abuelo y la abuela paternos y sólo la abuela materna, la herencia se divide en dos partes: una, para la línea o estirpe paterna (que se dividirán *per capita* los dos abuelos paternos) y la otra para la línea o estirpe materna (la abuela); Nov. 118.2.

(iii) Pero esto cambia si aparte de los ascendientes existen hermanos germanos del causante, es decir, que hayan nacido del mismo padre y de la misma madre.

1. En la terminología de Justiniano (Nov. 84; año 539) se habla de *germani* para designar los hermanos "bilaterales", es decir, los que tienen el mismo padre y la misma madre. En cambio, para referirse a los hermanos "unilaterales" (o "medios hermanos"), la terminología es la de *consanguinei* (para los que tienen el mismo padre, pero distinta madre) y la de *uterini* (para los que tienen la misma madre, pero distinto padre).

2. Esta denominación de "hermanos germanos" aparece en el Código Teodosiano (2.9.1), pero allí la aplicación es distinta: los "bilaterales" son denominados *fratres consanguinei*, mientras que los "unilaterales" son llamados *fratres germani* (los que tienen el mismo padre, pero distinta madre) y *fratres uterini* (los que tienen la misma madre aunque distinto padre). Simplemente hay que tener cuidado cuando se manejan estas dos fuentes distintas, es decir, el Cód. Teodosiano y los textos justinianos.

De este modo, si hay ascendientes y también *germani* (o *germanae*), todos ellos concurren a la herencia, que se dividirá *per capita*, y no *per stirpes*.

3. Así, p.ej.: existe el abuelo paterno, ambos abuelos maternos y tres hermanos germanos. La herencia se divide *per capita* en seis partes iguales.

4. Esto no estaba previsto en la Nov. 118, pero fue completado por la Nov. 127, que estableció también que en caso de un *germanus* o de una *germana* premuertos, sus hijos ocupaban su lugar conforme al "principio de representación".

(iv) Si no existen ascendientes, pero sí *germani* (o *germanae*), entonces éstos heredan directamente, dividiéndose la herencia *per capita*. Y si uno de ellos ha premuerto y dejado hijos, éstos pasan a ocupar su lugar por el "principio de representación".

§ 605. III. *Tercer orden: Medios hermanos*. Si no hay descendientes, ni ascendientes ni hermanos germanos, la herencia va a los "hermanos unilaterales" (o "medios hermanos"), ya sean "consanguíneos" (del mismo padre, pero de distinta madre) o "uterinos" (de la misma madre, pero de distinto padre). Ya sean varones o mujeres, se reparten la herencia *per capita*, y si uno de ellos ha premuerto y dejado hijos, éstos pasan a ocupar su lugar, por el mencionado "principio de representación".

§ 606. IV. *Cuarto llamamiento: Colaterales*. A defecto de los anteriores, la herencia va a los colaterales, siguiendo el principio de que el que está en grado más cercano excluye al que está en grado más lejano. Si hay varios en el mismo grado se dividen la herencia *per capita* (Nov. 118.3.1).

1. Curiosamente no se menciona un límite para los colaterales; cabe pensar que Justiniano quiso seguir el viejo orden pretoriano del llamamiento *unde cognati* para la *b.p.* (6° grado, salvo el supuesto ya señalado del 7° grado, *supra*, § 593).

§ 607. Técnicamente acá concluye el orden sucesorio establecido por las Novelas 118 y 127. Pero es necesario agregar ciertos casos especiales que resultaban vigentes:

A) *Cónyuge supérstite*. Aunque no esté mencionado en las Novelas, deja subsistente el llamamiento *unde vir et uxor*, para que el cónyuge supérstite no divorciado pudiera pedir la *bonorum possessio*, la cual no fue derogada por ninguna disposición anterior (Inst. 3.9.7; C.6.18).

1. Además, Justiniano establece un lugar sucesorio para la "viuda pobre" y sin dote, siempre que su marido hubiere ostentado una buena situación económica (*locuples*). Podía heredar a su marido aun cuando hubiera otros herederos. Si los que concurrían con ella eran tres o menos de tres herederos, hereda una cuarta parte de la herencia (*quarta uxoria*). Si son cuatro o más, solamente una parte viril. Si concurre con sus hijos, esta cuarta parte le es atribuida en usufructo. Además, en ningún caso podía recibir más de cien libras de oro (Nov. 53.6 pr., año 537; Nov. 117.5, año 541).

B) *Hijos naturales*. Los hijos naturales nacidos de un concubinato (o nacidos *vulgo concepti*), eran cognados respecto de su madre y de los parientes maternos, de tal manera que en las sucesiones respectivas de éstos eran herederos.

Pero Justiniano fue más lejos respecto de los hijos naturales nacidos de un concubinato. Por la Novela 89 (año 539) podían heredar *ab intestato* a su padre concubino. Si muerto éste no tenía descendientes legítimos, la concubina y sus hijos naturales tienen acceso a una sexta parte de la herencia, cuota que se debían repartir *per capita* (Nov. 89.12.4 y 6); recíprocamente le corresponde lo mismo al padre concubino en la herencia de estos hijos (Nov. id. 13). Si en cambio tenía descendientes, sus hijos naturales y la concubina tenían la posibilidad de obtener alimentos, según el monto de la herencia.

C) Además, a falta de otros herederos, se mantienen ciertas disposiciones del Derecho imperial, acerca de que ciertas corporaciones podían obtener la herencia *ab intestato*:

a) Así, la curia en la sucesión de los decuriones (Theod. II y Valent. III, C.6.62.4, año 429); b) la legión y la *vexillatio* (cuerpo de caballería), en la sucesión de sus legionarios o caballeros (Const. C.6.62.2; año 347); c) las corporaciones de los *cohortales*, *navicularii* y *fabricenses*, en la sucesión de sus miembros (Const. C.6.62.3, año 349; Theod. II y Valent. III, C.6.62.5, año 438); d) las iglesias en la sucesión de los clérigos que estaban en ella en el momento del deceso (Theod. II y Valent. III, C.1.3.20, año 434).

D) Por último, a falta de otro con título a la herencia *ab intestato*, ésta va a parar al fisco (Ulp., 28.7; Honorio y Theodosio, C.10.10.1, año 421).

APÉNDICE

V. Sucesión de los libertos.

§ 608. I. *Herencia del liberto ciudadano romano*. Para completar el sistema hereditario romano conviene tener en cuenta las alternativas que tenía la herencia de los libertos ciudadanos romanos. Ésta siguió las líneas generales de la herencia del ciudadano romano ingenuo, pero se veía alterada por la existencia del "patronato". Por esta circunstancia, el patrono tenía también vocación hereditaria en la herencia del liberto.

A) *Herencia del liberto ciudadano romano según el ius civile*. Según la ley de las XII Tablas, la herencia *ab intestato* del liberto ciudadano romano iba: a) a los *sui heredes* del liberto (Ulp., 27.1); b) al patrono o a la patrona; c) a los descendientes agnáticos del patrono; y d) a los gentiles del patrono (Gayo, 3.40; 46; 49; 51; Ulp., 27.1 ss.).

1. De este modo, el orden sucesorio era favorable para el patrono, y ello estaba bien, pues gracias a éste consiguió el liberto su libertad y por ello el patrimonio que haya podido conseguir.

Peró el patrono se veía desplazado: a) en caso de que el liberto hubiese hecho testamento instituyendo a un heredero extraño; y b) por los *sui heredes* del liberto. Según lo explica Gayo (3.40), esto se entendía bien si se trataba de hijos legítimos del liberto, pero no se justificaba si el liberto había adoptado un hijo o una hija, o tomado una *uxor in manu*. Estos últimos eran, por supuesto, *sui heredes* del liberto, pero parecía inequitativo que desplazaran al patrono (cfr. Inst., 3.7 pr.).

B) *Sistema pretoriano*. El pretor, sobre la base de la b.p., irá corrigiendo el orden del *ius civile*: Protegerá al patrono; no haciendo nada en favor de la patrona, debido a la tendencia puesta en vigor por la ley *Voconia*, que se mostraba hostil al enriquecimiento de las mujeres. Tampoco se ocupó del patrono de una liberta, puesto que ésta no lo afectaba, ya que por un lado no podía testar sin su *auctoritas*, y por el otro no podía tener *heredes sui* (Gayo, 3.43). De este modo sus medidas se refieren a la herencia testada o *ab intestato* de un liberto varón. La regla general es que consideró inicuo que el patrono pudiera ser excluido de la herencia del liberto por la sola voluntad de este último.

1) Si el liberto había hecho testamento, dejando como heredero a un extraño, debía dejarle al patrono (no a la patrona; Gayo, 3.41; 3.49) la mitad de sus bienes. De no ser así le otorgaba la b.p. *contra tabulas* por esa porción (Gayo, 3.41). Pero si existían descendientes sanguíneos (naturales) del liberto instituidos (o preteridos), éstos tenían preferencia para pedir la b.p. respecto del patrono (Gayo, 1er. y 3er. párrs. de 3.41).

2) Si la herencia del liberto era *ab intestato*, el orden de los llamamientos a la b.p. era así (Ulp., 28.7):

(i) *unde liberi*: todos los descendientes *in potestate* o emancipados del liberto. En caso de hijos o hijas legítimos del liberto, éstos desplazan al patrono, pero si se trataba de hijos o hijas adoptivos o de la *uxor in manu*, el patrono (o sus descendientes varones; Gayo, 3.45) puede pedir la b.p. por la mitad de los bienes en contra de lo que corresponda a éstos (Gayo, 3.41, 2º párrafo).

(ii) *unde legitimi*: los herederos legítimos según las XII Tablas (patrono, patrona y descendientes agnados varones —no las mujeres— del patrono; Ulp., 29.4);

(iii) *unde cognati*: los cognados próximos del liberto, según las mismas reglas y hasta los mismos grados de la b.p. del ingenuo;

(iv) *unde familia patroni*: la familia del patrono era: la patrona, los *liberi* del patrono, no los de la patrona (Gayo, 50.16.196.11. Se los vuelve a llamar, puesto que por alguna causa

(*capitis deminutio*) no pudieron presentarse al segundo llamamiento (EP, § 169);

(v) *unde patronus patroni*: se refiere al supuesto de un segundo patrono de un liberto manumitido; y a los descendientes de este segundo patrono (Coll.16.9; EP, §.160);

(vi) *unde vir et uxor*: el cónyuge superstitente del liberto, no estando la *uxor in manu*; en caso contrario, entra en el primer llamamiento;

(vii) *unde cognati manumissoris*: parientes cognados del patrono, incluido el propio patrono que era nuevamente llamado (Ulp., D.33.2.47.17).

C) La ley *Papia Poppaea* mejorará la situación de los patronos. Si un liberto era opulento (*locupletior*), es decir, dejaba un patrimonio de al menos 100.000 sesteracios (*centenarius*) y tenía menos de tres hijos, ya sea que muriera testado o intestado, de esos bienes le era debida al patrono una parte viril. Así, si dejaba un solo hijo o hija, le correspondía al patrono la mitad; si dejaba dos hijos, un tercio. Pero si dejara tres, el patrono es excluido (Gayo, 3.42).

1. Esto ocurría respecto de la herencia de los libertos varones. Si se trataba de libertas mujeres, la ley *Papia Poppaea* otorgó el *ius liberorum* a las que tenían cuatro hijos. Por ello, se liberaba de la tutela del patrono y podía hacer testamento sin la *auctoritas* de éste. Pero le otorga al patrono siempre una parte viril. Así, si le sobreviven 4 hijos a la liberta, la herencia se divide entre ellos y el patrono *per capita*, es decir que al patrono le corresponderá 1/5. De no quedar ningún hijo vivo cuando muriera la liberta, la herencia pertenece al patrono (Gayo, 3.44; Ulp., 29.3). Este sistema se aplica también al hijo, al nieto habido del hijo, etc., del patrono (Gayo, 3.45).

2. En cuanto a las hijas, nietas y bisnietas agnadas del patrono, conforme a la ley de las XII Tablas, podían ser desplazadas por los *sui heredes* del liberto. El pretor, como lo hemos visto, no las protegió, puesto que sólo atendió a los descendientes del sexo masculino. Pero según la ley *Papia Poppaea* se las benefició, siempre y cuando tuvieran tres hijos (*ius liberorum*). Podían pedir la b.p. *contra tabulas* o *ab intestato*, en la misma forma y proporción que el patrono o sus descendientes masculinos (Gayo, 3.46-47; Ulp., 29.5).

3. En cuanto a la patrona, la ley *Papia* mejorará la situación que tenían por la ley de las XII Tablas.

a) Si se trataba de una patrona ingenua que tuviera el *ius liberorum*, queda en la misma situación que el patrono, por lo que podían pedir una "parte viril" en la herencia testada o en el caso de los libertos "centenarios". Esto no se concedía a la patrona liberta, aunque tuvieran 4 hijos (*ius liberorum*); Gayo, 3.50; Ulp., 29.6.7.

b) Si la patrona ingenua tenía dos hijos o una patrona liberta que tuviera tres hijos, se les concede la posibilidad de pedir la b.p. *contra tabulas*, es decir,

se las asimilaba a los patronos en cuanto a la protección concedida por el pretor (Gayo, 3.50; Ulp., 29.5).

En cuanto a la herencia *ab intestato* de las libertas, la ley *Papia Poppaea* no estableció nada en relación con las patronas, por lo que se les sigue aplicando el régimen de la ley de las XII Tablas: reciben la herencia excluyendo a los hijos de la liberta, puesto que ésta no puede tener *sui heredes*. Es el mismo sistema que respecto de los patronos (Gayo, 3.51).

D) Por un senadoconsulto de la época de Claudio (Inst., 3.8.3) se permitió que el patrono pudiese asignar (*adsignatio liberti*) ya en testamento o fuera del testamento (Inst., *ibid.*) el liberto o libertos a uno solo de sus hijos, excluyendo a los demás. Éste queda como único patrono, y si premuriera sus descendientes. Pero si no deja herederos, se regresa a la regla normal, de tal modo que los bienes van, en su caso, a todos los otros hijos del patrono (Inst., 3.8 pr.).

1. El patrono puede elegir de entre sus hijos *in potestate* aquel a quien le otorgaba la *adsignatio*. Si el *filius* beneficiado con la asignación del liberto o libertos, hubiese luego sido emancipado, su derecho se desvanecía, por lo que es inhábil para ser heredero del liberto (Inst., 3.8.2).

§ 609. II. *Herencia de los libertos latinos iunianos*. Los latinos iunianos*, es decir, aquellos que por la ley *Iunia Norbana* alcanzaban una "libertad de hecho", cuando morían estaban asimilados a los esclavos, por lo que sus bienes pertenecen a los manumisores, a quienes volvían por una especie de "derecho de peculio" (Gayo, 3.56; Inst., 3.7.4).

1. Por un s.c. *Largianum* (año 42 d.C.) se estableció que sobre los bienes hereditarios de un latino iuniano correspondía una especie de herencia en lugar del derecho de peculio, en beneficio de los hijos del patrono. Se estableció, así, que en primer lugar les corresponden a los manumisores; luego, a sus *liberi* que no hubieran sido desheredados en forma nominativa, según el grado pertinente de parentesco. Y finalmente a los otros herederos del patrono manumisor.

Esto significaba que en el supuesto de que el patrono hubiere premuerto en relación al liberto, dejando otros herederos aparte de sus hijos, los bienes provenientes del liberto latino iuniano no volvían como peculio para integrar el total del acervo hereditario, sino que serían recogidos sólo por los hijos, como una especie de derecho hereditario, con exclusión de los otros herederos que pueda tener el manumisor. Solamente si no hay *liberi*, pasan en tercer lugar a los herederos del manumisor (Gayo, 3.63-71; Inst., 3.7.4).

2. El emperador podía otorgar a un liberto latino el *ius civilis*. Pero si este favor le era concedido al liberto latino, en contra de la voluntad del patrono o ignorándolo, Trajano, por medio de un edicto, estableció que a la muerte de dicho liberto latino quedaba a salvo el derecho del patrono y sus hijos (*salvo iure patroni*; Gayo, 1.72).

Ello significaba que este liberto, mientras viviera será igual que los otros libertos ciudadanos romanos; así, los hijos que procrea serán legítimos, pero a su muerte, sus bienes pertenecerán al patrono y sus descendientes conforme al *ius Latinum*. Los hijos del liberto no son herederos suyos y el liberto cuenta con la *testamenti factio* sólo para instituir como heredero al patrono, pudiéndolo sustituir por otro si éste no quisiera serlo.

Hadriano mitigó en parte los efectos del edicto de Trajano por medio de un senadoconsulto que dispuso que si el liberto latino iuniano pidió la ciudadanía habiéndosele concedido el emperador con la ignorancia o en contra de la voluntad de su patrono —y caía por ello en la aplicación del edicto de Trajano—, hubiese obtenido con posterioridad la ciudadanía romana por alguno de los métodos regulares (Gayo, 1.29 ss.; Ulp., 3.1 ss.), como p.ej. por la "prueba del hijo de un año" (Gayo, 1.29), entonces se lo consideraba directamente como liberto ciudadano romano.

§ 610. III. *Herencia de los libertos que se cuentan en el número de los dedicticios*. Éstos eran los esclavos a título de pena (*servi poenae*; Gayo, 1.13 ss.; Ulp., 1.5; 11). Su situación era la peor entre los libertos (*pessima libertas*; Gayo, 1.25; *pessima condicio*; Gayo, 3.75). En cuanto a la herencia, la regla general es la misma que les corresponde a los patronos (Gayo, 3.74).

Si se los manumitía como ciudadanos romanos, así p.ej. por una forma solemne como la *vindicta*, en caso de muerte no pueden testar (Gayo, 3.75; Ulp., 20.14) y sus bienes son atribuidos a sus patronos, como si fueran libertos ciudadanos romanos (Gayo, 3.75). Si hubieran sido manumitidos por alguna forma no solemne, p.ej. *inter amicos*, se los liberaba como latinos iunianos, y los bienes, a su muerte, les son atribuidos a los patronos como si hubiesen muerto latinos (Gayo, 3.76). La ley *Aelia Sentia* no era muy clara al respecto (Gayo, 3.76, *in fine*).

§ 611. *Reformas de Justiniano*. Justiniano suprime la categoría de liberto latino, así como la ley *Iunia*, el edicto de Trajano y demás disposiciones referidas a los latinos (C.7.6.12, año 531), así como la de los libertos dedicticios (C.7.6.5, año 530). Habrá una sola categoría de libertos, la de los libertos ciudadanos romanos.

Reformará el sistema de la herencia de los libertos (C.6.4.4; Inst., 3.7.3). No hará más di-

herencia entre el patrono y la patrona, tampoco entre hijos e hijas, ni entre la herencia de un liberto o de una liberta. El orden sucesorio, que será el mismo para todos, se puede resumir así:

A) Herencia testamentaria:

(i) Si el liberto no era "centenario", puede disponer por testamento de su patrimonio sin necesidad de instituir herederos o legatarios ni al patrono ni a la patrona ni a los hijos de éstos.

(ii) Si el liberto era "centenario" (dejaba 100 aureos o más = 100.000 sestercios), en caso de haber testamento, entonces el patrono tiene derecho a reclamar, ya no la mitad, sino un tercio de la herencia, pudiendo reclamarlo por la *b.p. contra tabulas*.

Esta porción le corresponde siempre y cuando no existan descendientes del liberto o que hubieran sido justamente desheredados.

B) Herencia *ab intestato*:

En caso de herencia intestada del liberto, el orden sucesorio era el siguiente:

(i) siguiendo el principio que venía de las XII Tabas, primero heredan sus hijos;

(ii) luego, el patrono o la patrona, y a falta de éstos, sus hijos agnados, dividiéndose la herencia *per capita*, y no *per stirpes*;

(iii) los parientes colaterales cognados del patrón o de la patrona hasta el quinto grado, podía heredar siempre que no hubiera *liberi* del liberto.

De este modo, el orden sigue pautas cercanas a la herencia del ciudadano romano ingenuo: un primer orden está configurado por los herederos suyos del liberto; luego, un segundo orden, el de los agnados, representado por el patrono o la patrona; y finalmente el tercero compuesto por los parientes colaterales del patrono o de la patrona, hasta el quinto grado (Inst., 3.7.3; C.6.4.4.14).

VI. Sucesión de un ingenuo emancipado.

§ 612. El hijo emancipado se convierte en cabeza de su propia familia. Sus agnados serán sus propios descendientes *in potestate*. Puede hacer testamento, pero en caso de morir intestado, al *pater emancipator* se le da un tratamiento análogo al del patrono.

De este modo, el orden de la herencia *ab intestato* del emancipado es así: a) los *heredes sui* del emancipado; b) el *pater emancipator*, si había tomado la precaución de reservarse este

derecho (*contracta fiducia*); de no ser así, se trataba del caso de que la emancipación se producía cuando el tercero que lo tenía *in mancipio**, luego de la tercera *mancipatio*, lo manumitía; era un *manumissor extraneus*, quien tenía el lugar del patrono y sucedía en segundo grado.

Pero el pretor otorgaba con precedencia al *manumissor extraneus* un llamamiento especial otorgando la *bonorum possessio* a los parientes cognados más cercanos del emancipado (padres, abuelos, hijos, nietos, hermanos), que contando ambos sexos eran diez (el llamamiento era *unde decem personae*; Coll. (Ulp.) 16.9.2).

Bajo Justiniano, dadas las formas nuevas de emancipación, desaparece la figura del *manumissor extraneus*, e igualmente este llamamiento de la *b.p.* (Inst., 3.9.5). Estableció un nuevo orden para la herencia *ab intestato* del emancipado, que queda así: a) primero los herederos suyos o asimilados a éstos; b) los hermanos y hermanas del emancipado; y c) al ascendiente emancipador. En el caso segundo, los bienes van como adventicios a los hermanos y hermanas, teniendo el ascendiente el usufructo de ellos (C.6.58.13-1, año 531).

VII. Sucesión de un *filiusfamiliae*.

§ 613. En principio el *filiusfamiliae* no tiene patrimonio. Pero a medida que se va profundizando la vigencia de los *peculios*, sobre todo: el *peculium castrense**, el *quasi castrense** y los *bona adventicia**, cuando no había dispuesto de dichos bienes por testamento, ellos volvían al *pater*, no a título de heredero, sino *iure peculio*.

En la época justiniana se llega a la práctica a admitir que los *filiifamiliae* pueden tener su patrimonio, estableciendo en consecuencia la posibilidad de una verdadera sucesión. Determinará (C.6.59.11, año 529) para el caso de los *bona adventicia* el siguiente orden para dichos bienes: a) los hijos y descendientes del causante; b) los hermanos y hermanas; y c) el *pater*, quien ahora recoge sus bienes *iure successionis*. Respecto de los *peculios* *castrense* y *quasi-castrense*, el texto da Inst., 2.12 pr., establece que "si mueren *ab intestato*, sin dejar hijos ni hermanos, su *peculio* pertenecerá, según el derecho común, al *pater*". Queda la duda de si el *pater* los recibe *iure peculio* o *iure successorio*. En general, se lo interpreta así, si bien Théophile se refiere en este lugar diciendo que la expresión "según el derecho común" debe ser leída como "un derecho de *peculio*". Lo que resulta indudable es que después de la Novela 118 del año 544, el padre es ciertamente heredero.

CAPÍTULO 3

HERENCIA TESTAMENTARIA

§ 614. *Testamento: concepto y caracteres*. El testamento es un negocio jurídico solemne y de última voluntad, por el cual se instituye uno o varios herederos.

El testamento puede contener otras cláusulas, tales como una manumisión, una dación de tutor, un legado, pero éstas son consideradas como adicionales y subordinadas a la existencia de la "institución de heredero" (*heredis institutio*), que según Gayo es "la cabeza y el fundamento de todo el testamento" (*caput et fundamentum testamenti*; 2.229).

Si la *heredis institutio* falta o resulta inválida, en principio y en la época clásica, acarrea la nulidad de las otras cláusulas, que están dependiendo de ella. En cambio, la invalidez de p.ej. un legado, su nulidad no afecta la institución de heredero, y en consecuencia el testamento es válido.

1. En los textos romanos figuran dos definiciones de testamento:

Ulpiano (20.1) nos dice que "el testamento es la justa declaración de nuestra intención, hecha de manera solemne, para que valga después de nuestra muerte".

Modestino (D.28.1.1): "el testamento es la justa expresión de nuestra voluntad, respecto a lo que cada cual quiere que se haga después de su muerte".

Pero ambas son inexactas, en tanto que no nos hacen conocer que lo esencial del testamento es la *heredis institutio*. El mismo Ulpiano (D.28.5.1.3) nos dice, subrayando la importancia de esta institución, que con sólo tres palabras se puede hacer un testamento. Así: *Lucius heres esto* (Que Lucio sea heredero).

2. Podemos decir que los caracteres del testamento son:

a) es un negocio *mortis causa*, es decir, de última voluntad para que valga después de nuestra muerte; b) es solemne (en las definiciones dadas *iustum testamentum* significa testamento hecho conforme a formas solemnes);

c) es revocable, ya que el testador puede variar su contenido hasta el último momento de vida (Ulp., D.34.4.4). La regla que se sigue es que un testamento válido posterior revoca a otro anterior.

3. Etimológicamente, *testamentum* deriva de tes-

tis (testigo), por cuanto una de las solemnidades es que sea realizado ante testigos.

I. Formas de hacer testamento.

§ 615. En el derecho antiguo hubo dos formas de hacer testamento (Gayo, 2.101):

A) *Testamentum calatis comitiis*. Consiste en la posibilidad de un ciudadano romano de hacer testamento ante los *comitia calata* (*calare est vocare*; Théoph., 2.10.1), es decir, los comicios curiados presididos por un *pontifex*. Éstos se reúnen el 24 de marzo y el 24 de mayo de cada año.

1. En doctrina se discute si en este caso el *populus* intervenía para aprobar el testamento como si fuera una *lex*, o simplemente actuaba como testigo calificado.

Dada la necesidad de los comicios, que intervenía en uno u otro carácter, al igual que con la *adrogatio**, el testamento asume cierto carácter público (el *populus* garantiza atestiguando; o el *populus* le concede validez legal). Lo más significativo es la presencia del control del *pontifex*. Éste no hacía la propuesta sin el consentimiento del testador, y éste necesitaba de aquél para convocar los comicios. El control pontifical debió haber ido sentando las reglas que se debía observar en cuanto a la *heredis institutio*.

2. Esta forma originaria irá desapareciendo. Al igual que ocurrió con la *adrogatio*, en lugar de la aprobación de los comicios, se realiza una declaración hecha ante los treinta *lictors* que representaban las *curias* (Cic., *adv. Rull.*, 2.12). Ya para mediados del siglo II a.C., Cicerón no la menciona, hablando del testamento *in procinctu* y del *per aes et libram* (de orat. 1.53.228).

B) *Testamentum in procinctu*. Se hacía ante el *populus* armado para ir al combate. Tuvo el mismo valor que el anterior, puesto que el ejército, compuesto por los ciudadanos romanos, daba valor jurídico a lo declarado por el testador.

1. Por ello, Gayo (2.101) podía decir que el primero se hacía *in pace et in otio*, mientras que éste se

hacia por causa de guerra (*cum belli causa*), cuando los soldados estaban formados militarmente.

La expresión *in procinctu* es un tecnicismo para designar al ejército preparado para marchar en campaña (Gayo, 2.101); proviene del *cinctus Gabinus* que usaban, donde iba calzada la espada (Festo, 252.19; Virg., *Aen.*, 7.612).

2. Dadas sus características, se permitía hacer testamento antes de entrar en combate. Se lo aplicó hasta el siglo II a.C. (Vell. Patern., 2.5.2). No hay que confundirlo con el testamento militar (*testamentum militis*), que comenzará en la época de Julio César, y se irá estructurando con posterioridad con reglas especiales, pero empleando la forma del testamento *per aes et libram*.

§ 616. *Testamentum per aes et libram*. En la época también antigua, surgió la necesidad de poder hacer testamento fuera de los dos días señalados para hacerlo *in calatis comitiis*, o cuando se iba a la guerra. Apareció entonces una tercera forma: el *testamentum per aes et libram*, llamado así porque se utilizaba una *mancipatio*, es decir, un acto donde intervenían el cobre y la balanza (Gayo, 1.102).

Tuvo una evolución interna que culminó con una de las más inteligentes interpretaciones de la mente jurídica romana:

a) Según nos lo dice Gayo, si aquel que no había hecho testamento en los comicios calados *in procinctu* se hallaba amenazado de una muerte súbita, celebraba una *mancipatio* de todo su patrimonio (*familia*) con una persona de su confianza (*familiae emptor*), encomendándole que luego de su muerte, siguiendo las instrucciones que le impartía, procediera al reparto de los bienes (Gayo, 2.102).

1. Gayo es nuestra única fuente respecto de este negocio. Técnicamente no es un "testamento", ya que no hay institución de heredero, sino una muy particular *mancipatio* apoyada en una *fiducia*, por la cual se trata de aprovechar este negocio para alcanzar resultados económicos similares a los del testamento.

2. El *familiae emptor* no es un "heredero", pero a la muerte del mancipante "ocupa el lugar del heredero" y rechaza la partición de los bienes en la forma indicada por aquél (Gayo, 2.103).

Siendo que normalmente la *mancipatio* es *inter vivos*, lo curioso acá es que se establece que los efectos se produzcan *mortis causa*. No se podría imaginar —salvo el caso de la "amenaza de muerte súbita" de que habla Gayo— que un *pater* transmitiera todo su patrimonio presente y futuro para una muerte más impensada. Si sucediera que el mancipante recobrara su salud, cabe pensar que podía revocar la *mancipatio*.

3. A la muerte del causante, el *familiae emptor*, ocupando el lugar del heredero, era en realidad un

"propietario fiduciario", que debía ejecutar las instrucciones dadas. Es algo parecido a lo que luego será, en el derecho actual, un "albacea", figura que no tuvo luego desarrollo en el Derecho romano.

4. Como se ve, se trata de una forma oblicua de alcanzar los efectos económicos de los bienes hereditarios, pero sin hacer propiamente testamento. Existen siempre eventuales inconvenientes, al igual que siempre ocurre jurídicamente cuando se quiere hacer cumplir a un negocio efectos que en realidad corresponden a otro.

b) En fecha desconocida, posiblemente desde el siglo II a.C., se aprovecharon las formas *per aes et libram* de la *mancipatio*, pero ahora el punto de gravedad se desplaza de la fórmula que pronunciaba el *familiae emptor*, cuyo papel es meramente formal, a la declaración del mancipante (*nuncupatio*); quien aprovecha la oportunidad para instituir heredero. Ahora sí, pues, se puede hablar propiamente de *testamentum per aes et libram* (Gayo, 2.103-104; Inst., 2.10.1).

1. Según lo narra Gayo (2.104), el procedimiento era así: debían estar presente, al igual que en toda *mancipatio*, los cinco testigos, el *libripens* y el *familiae emptor*. Este "pro-forma" dice que compra la herencia —es decir, participa en el acto— para que se pueda hacer testamento. Pero luego, el otorgante, teniendo en sus manos las tablas del testamento, dice así: "Conforme a lo que está escrito en estas tablas y en esta cera, yo doy, lego y testifico, y por tanto vosotros, quírites, dadme testimonio de esto".

2. Lo que decía públicamente el testador es llamado *nuncupatio* (= nominatio solemne). En realidad, en una *mancipatio* no es usual que hable el mancipante, pero podía hacerlo, ya que se lo permitía una vieja regla que estaba en las XII Tabas: "Cuando se haga un *nexum* o una *mancipatio*, todo lo que se diga con la lengua en la *nuncupatio*, que todo ello sea *ius*" (6.1; Id. 5.3).

3. Al hacer la *nuncupatio*, el testador podía designar los herederos en forma verbal, pero para mayor seguridad, como lo indica Gayo en el párrafo mencionado, ya lo tenía escrito en las tablas del testamento.

Estas tablas eran de madera endurecidas con cera. El uso era que fuesen de tamaño desigual, de tal modo que una de ellas, donde figuraba el nombre del testador, quedaba con una parte superior donde se leía quién lo había dado. Con las siguientes, se terminaba formando el testamento, quedando enfrentadas a la primera y de este modo ocultas. Se las ligaba con un hilo o una cinta. Luego eran presentadas a los testigos, quienes la sellaban (*obsignatio*), con sus nombres a la vista (*superscriptio*).

El secreto no era obligatorio. De un texto de Horacio (*Sat.*, 2.5. 51 ss.), podemos ver cómo por cortésia, el testador proponía a los testigos leer las

tablas, pero éstos rehusaban, si bien el poeta aconsejaba lanzar, al mismo tiempo que rehusaban, una rápida mirada para ver el nombre del heredero puesto al comienzo.

§ 617. *Testamento pretoriano*. El *testamentum per aes et libram* fue la forma normal de testar conforme al *ius civile* durante todo el período clásico, de tal modo que las formas de la *mancipatio* se tornaban obligatorias.

Sin embargo, muy prontamente (Cic., *in Verr.* 2a., 1.45), el pretor, no solamente concede la *bonorum possessio* a quienes han sido instituidos herederos en un *testamentum per aes et libram* regular, sino que considerando que lo importante era la *nuncupatio* del testador, realiza un paso más atrevido, reconociendo el valor de la voluntad sobre las formas de la *mancipatio*. En su edicto, ofrece —no la *hereditas*— la *bonorum possessio secundum tabulas* a quien aparezca como heredero en un testamento cuyas tablas mantuvieran los sellos de siete testigos, que fueran abiertas ante él. Con ello hace una simplificación de las formas del testamento civil, ya que ese número de siete resulta de los necesarios al acto de la *mancipatio* (los cinco testigos, el *libripens* y el *familiae emptor*, ahora reducido al nivel figurado de testigo).

A esta forma se la acostumbró llamar "testamento pretoriano" (Gayo, 2.119; Ulp., 28.6; Inst., 2.10.2; EP, § 149).

1. La medida luce prudente dentro de las posibilidades que tiene el pretor. No les concede la *hereditas* (que es del *ius civile* y hubiera requerido el testamento *per aes et libram*), sino la *bonorum possessio* (posesión de la herencia, que es del derecho pretorio).

2. Además es *secundum tabulas*, por cuanto los beneficiados son los que figuran en las tablas del testamento.

En un comienzo los herederos legítimos *ab intestato* podían reclamar la herencia de los que poseían por este modo la *bonorum possessio* (Gayo, 2.119). Ello significaba que la *b.p.* era *sine re*, es decir, cedía ante el heredero legítimo.

Pero por un rescripto de Antonino Pio, los que han recibido esta *b.p.* en un testamento pretoriano, no hecho según las reglas del *ius civile*, pueden defenderse por una *exceptio doli* de los herederos legítimos que reclamen la herencia *ab intestato*. De este modo, la *b.p.* pasa a ser *cum re* (Gayo, 2.120; Paulo, 4.8.1).

§ 618. *Testamento en la época posclásica*. Las formas testamentarias del período clásico se fueron tornando un tanto confusas. Sin embargo, cabe notar que el formalismo del *ius civile* y del *ius praetorium* tendieron a amalgamarse.

Theodosio II y Valentiniano III ordenaron

esta cuestión, estableciendo cómo debía hacerse un testamento (C.6.23.21; año 439). El testador debía presentar las tablas del testamento (ya abiertas, haciendo conocer su contenido o cerradas con un hilo o una cinta, diciendo que allí estaba su testamento) ante siete testigos romanos púberes. Estos debían sellar las tablas y además firmarlas (*subscriptiones*). Igualmente, el testador debía firmar en la parte restante de las tablas. Todo ello debía suceder en un mismo y único acto.

Este testamento será conocido por Justiniano como *testamentum tripartitum* (Inst., 2.10.3), ya que en él se reunían requisitos: a) del *ius civile*: la "unidad del acto" en el cual el testador presenta el testamento a los testigos (Ulp., D.28.1.21.3); b) del *ius praetorium*: el número de los siete testigos y sus sellos; y c) del *ius imperiale*: la nueva costumbre de las firmas de los testigos y del propio testador.

1. La unidad del acto no se rompe si el testador presenta un testamento hecho con anterioridad, bastando con que todos los testigos en el mismo acto sellen y firmen como tales (C.6.23.21.2).

Luego Justiniano disculpará como no perjudicando la "unidad del acto" una breve interrupción —así, indisposición de un testigo— cuando ello venga impuesto por una necesidad evidente (C.6.23.28.3-4).

En el caso —bastante frecuente— que el testador fuera analfabeto o no supiera firmar, había que recurrir a un octavo testigo que firme por él (C.6.23.21.1).

2. Aparte del testamento escrito, se permite el testamento *nuncupativo*, es decir, el expresado no en forma escrita, sino oral ante siete testigos (C.6.23.21.4).

3. Como particularidad, y esto para Occidente, Valentiniano III (*Nou.Val.* 21.2, año 446) permitirá:

a) El testamento *hológrafo* (*per hologram scripturam*), es decir, el redactado de puño y letra por el propio testador. Esta forma no exige la presencia de testigos. No será aceptado por Justiniano, pero luego tendrá desarrollo en el Derecho occidental posterior hasta nuestros días.

b) Igualmente, el mismo Valentiniano, en la disposición citada, permitirá el testamento recíproco entre cónyuges, que será un precedente del contrato sucesorio.

4. Justiniano aceptará la forma del *testamentum tripartitum*, tanto en la forma escrita como oral.

Se acepta también una forma "pública", cuyo origen está en el siglo V (Honorio y Teodosio; C.6.23.19, año 413). Ocurría cuando se formalizaba su presentación ante el juez o el funcionario municipal. Quedó equiparado a éste el testamento entregado al emperador.

§ 619. *Testamentos especiales*. Hay ciertos testamentos que tienen reglas especiales. De entre ellos debemos destacar:

I. *Testamento de los militares* (*Testamentum militis*). Desde la época de Julio César, luego continuado por diversos emperadores, se les permitió a los soldados hacer testamento sin cumplimiento estrictamente no sólo las formalidades, sino incluso dispensarlos de ciertas reglas de fondo.

El motivo expresado es su *imperitia* (Gayo, 2.109; Inst., 2.11 pr.). Pero más bien cabe denotar un propósito político de complacer a las milicias, estimulándolas con privilegios. En el *mandatum* de Trajano se expresaba de manera muy clara: "Hagan, pues, sus testamentos del modo que quieran, o de la manera que pudieren, y baste para hacer la división de sus bienes la nuda voluntad del testador" (Ulp., D.29.1.1 pr.), y lo mismo dice Gayo (2.114): "les está permitido hacer testamento como quieran o como puedan". Resulta suficiente que la voluntad del militar esté expresada de cualquier modo; siendo así, "el testamento es válido por el solo efecto de esta voluntad" (Inst., 2.11 pr.).

1. Están comprendidos todos los soldados y marinos (Ulp., D.37.13.1); durante toda la duración del servicio (Ulp., D.29.1.42), aunque Justiniano lo limitó al período de una efectiva expedición militar, y no haciendo vida de guarnición (C.6.21.17, año 529).

El testamento de los soldados era válido hasta un año después de haber sido licenciados, siempre que ello hubiere sido por causa honesta (*missio honesta*; Paulo, D.29.1.38 pr.), pero caducaba si era dado de baja por causa ignominiosa (Macer, D.1.26).

2. Las formas podían ser muy amplias. Se les permitió testar confiando su última voluntad a un compañero de armas, escribiendo con sangre su escudo, o escribiendo con la punta de su espada en la arena (C.6.21.15).

Lo que se exige en el testamento militar es que la institución de heredero sea clara, precisa e imperativa. Tal cual se dice en la constitución de Trajano, este es en beneficio de los propios soldados, "pues de otro modo no sería difícil que a la muerte de un soldado se hallasen testigos que asegurasen haberle oído decir que dejaba sus bienes a tal o cual persona, según su antojo; y que de este modo se suplantasen las verdaderas intenciones del testador" (Inst., 2.11.1).

3. Pero cumplimentado este requisito esencial, las dispensas que tenían eran muchas. Así:

a) pueden instituir herederos a quienes no tienen la *testamenti factio passiva*, como, p.ej., a los extranjeros o a los latinos iunianos (Gayo, 2.110);

b) pueden desheredar o preterir tácitamente a sus hijos y nietos (Inst., 2.19.6);

c) en contra de la regla general pueden morir en parte testados y en parte intestados (D.29.1.6; Id.15.4; Id., 37);

d) pueden morir con varios testamentos, no ri-

giendo el principio de la validez del último, que revocaría a los anteriores (Ulp., D.29.1.19 pr.);

e) no rige para ellos la prohibición de instituir heredero a los célibes establecida por la ley *Julia et Papia Poppaea* (Gayo, 2.111);

f) pueden también legar más de lo permitido por la ley *Falcidia* (Gayo, D.29.1.17.4);

g) pueden instituir herederos en codicilos (Pap., D.29.1.36 pr.);

h) no se admite contra ellos la *querella inofficiosa testamenti* (Ulp., D.5.2.27.2); etc.

II. *Otros casos especiales*. En el derecho posclásico se permitirá la disculpa de ciertas formalidades atendiendo a casos extraordinarios:

1. Así, en tiempo de epidemia, para evitar el riesgo del contagio, se permitió que los testigos no estuvieran reunidos simultáneamente, tal como lo exigía la "unidad de acto" (Diocl., C.6.8, año 290).

2. Justiniano permitió que si el testamento se hiciera en zona campestre, resultaba suficiente la presencia de sólo cinco testigos, y si algunos no saben o no pueden firmar, es lícito que otros firmen por ellos (C.6.23.31, año 534).

3. Si el testador es ciego, se le permite otorgar testamento escrito si dicta su voluntad a un escribano (*tabularius*), o si éste falta, a un octavo testigo. Quien redacta el testamento, lo debe leer ante los testigos y el testador, debiendo éste confirmarlo (Justiniano, C.6.22.2, año 521; Inst., 2.12.4).

4. En ciertos casos se permiten disposiciones de última voluntad aunque no sean estrictamente testamentos. Así, si el *pater* distribuye los bienes entre los herederos *ab intestato*, por cuotas o bienes determinados, siempre que no existan disposiciones en favor de terceros. Es llamado *testamentum parentis inter liberos* (Constantino, C.3.36.26, año 321; Theod. Valent., C.6.23.21.3, año 439). Justiniano exigirá una determinación clara de las personas y de las cuotas, admitiendo disposiciones en favor de terceros (Nov. 107, año 541). Continúa siendo una forma imperfecta, ya que es válida aunque falten otras formalidades, por lo que no es propiamente un testamento.

Una variante distinta de la anterior es la llamada *divisio parentum inter liberos*, que tampoco es un testamento. Se trata de fijar reglas para la división hereditaria, cabiendo incluso que pueda hacerse *inter vivos* (Nov. 18.7; Nov. 107).

Además, por razones de favorecimiento a las iglesias y obras pías, se determinó una simplificación de las formas testamentarias, a veces hasta disculpando su omisión (C.Th.16.2.4 = C.1.2, año 321; C.1.2.13; Id.25(26), año 530).

II. Capacidad para testar y para ser instituido en un testamento.

§ 620. La expresión *testamenti factio* sirve para designar (a) la capacidad para otorgar testamento, así como también (b) la de ser instituido heredero o legatario o tutor, y (c) igualmente la de poder actuar como testigo en la solemnidad del testamento. Los autores posclásicos hablaron de *testamenti factio activa* cuando se refieren a la capacidad del testador, y de *testamenti factio passiva* respecto de la capacidad para recibir por testamento.

I. *Testamenti factio activa*. Como principio general para poder hacer testamento se requiere ser ciudadano romano *sui iuris*. Por ello carecen de la *testamenti factio activa*, por un lado los extranjeros (no gozan del *ius commercii*), y por el otro los sometidos a la *potestas* del *pater*, ya que siendo *alieni iuris* no tienen patrimonio propio sobre el cual puedan testar.

1. Sin embargo, hay que tener en cuenta las siguientes circunstancias:

a) Los extranjeros no pueden hacer testamento civil, si bien podrán testar conforme a su ley local (Ulp., 20.14).

b) Tampoco pueden testar los latinos iunianos, por cuanto están descalificados por la ley *Iunia Norbana* (Gayo, 1.23; Ulp., 20.14). Igualmente los dedicios tampoco pueden hacer testamento ni siquiera según su ley local (Ulp., 20.14).

c) El *filius*, pese a ser *alieni iuris*, podrá hacer testamento en lo que concierne a su *peculio castrense* (y luego, también en cuanto al *quasi-castrense*); Gayo, 2.106; Ulp., 20.10; Inst., 2.12 pr. Respecto de los bienes que tuviere el *filius* por otros modos (*peculio profecticio*, *bona adventicia*), no puede testar aun contando con el consentimiento del *pater* (Gayo, D.28.1.6 pr.).

d) Respecto de las mujeres *sui iuris* cuando en un principio estuvieron sujetas a la tutela de los agnados no podía testar (Gayo, 1.115a). Pero la mujer podía emplear el recurso de realizar una *coemptio fiduciaria*, de tal modo que con ello cesaba la agnación (Gayo, *ibid.*). Luego, por un s.c. de Adriano, las mujeres ingenuas que tuvieran 12 años podían testar sin necesidad de realizar la *coemptio fiduciaria*, aunque por estar en tutela necesitan la *auctoritas* del tutor (Gayo, 2.112). Como lo indicará el mismo Gayo, las mujeres estaban en mejor situación que el varón menor de 14 años, ya que éste no podía testar ni aun con la *auctoritas* del tutor; en cambio, la mujer pupila mayor de 12 tenía la *testamenti factio* (1.113).

e) A su vez, tampoco pueden hacer testamento los impúberes (Ulp., 20.13; Inst., 2.12.1); los dementes (Ulp., 20.13), salvo que lo hiciera en un intervalo lúcido (Inst., 2.12.1) y los pródigos (Ulp., 20.13), salvo

que lo hubiera hecho antes de la interdicción (Inst., 2.12.2).

El mudo tampoco puede testar, ya que no puede pronunciar las palabras de la *nuncupatio*, y lo mismo ocurre con el sordo que no puede oír las palabras del *familias emptor* (Ulp., 20.13). Justiniano admite que los que fueran mudos o sordos, no de nacimiento, sino por un acto sobreviniente puedan hacer testamento escribiéndolo con su propia mano (C.6.22.10; año 531; Inst., 2.12.3).

El ciego, a partir de Justino (C.6.22.5), podrá hacer testamento (v. *supra*, § 619.II.3).

En cambio, el esclavo público (*servus populi Romani*) tiene el *ius* de hacer testamento hasta la mitad (Ulp., 20.16).

II. *Testamenti factio passiva*. Se trata de la idoneidad para ser beneficiario del testamento, es decir, para ser heredero, legatario o tutor en un testamento.

No la tienen:

a) Los extranjeros (*peregrini*) y por supuesto los dedicios. Tampoco pueden adquirir *mortis causa* los latinos iunianos (Ulp., 20.14).

b) Las mujeres, a las cuales por la ley *Voconia* se les prohibió ser instituidas herederos por quienes figuraban en el censo con más de 100.000 ases de fortuna (Gayo, 2.274), si bien pudieron adquirir legados hasta una cantidad no mayor a la recibida por los herederos (Gayo, 2.226). Esto luego cayó en desuso, sobre todo por el decaimiento del censo (comienzos del Imperio, siglo I).

c) Las *incertae personae*. En la época clásica son los *postumi alieni*, es decir, los que vayan a nacer fuera de la familia del testador (Gayo, 2.241-242; 287). En cambio, no hay incapacidad para los *postumi sui* (ver *infra*, § 629.B.iii). Posteriormente, en la última época, se admitió una mayor liberalidad respecto de todos los *postumos* (C.6.48.1; Inst., 2.20.26; 28, 3.9 pr.).

d) También son consideradas *incertae personae* las municipalidades y otras corporaciones (Ulp., 2.25), aun cuando más adelante se les reconoció capacidad para adquirir *mortis causa* (C.6.24.12; C.11.32.3).

e) Los hijos de los traidores (*Ilex Maiestatis*: C.9.8.5.1), y luego, en la época cristiana, los apóstatas (C.1.7.3), los herejes (C.1.5.5) y los judíos (C.1.9.1).

En cambio, se puede instituir herederos a los esclavos, ya suyos o ajenos.

Si son suyos, hay que concederles la manumisión (Gayo, 2.186; Ulp., 22.12), aunque luego, con Justiniano, se interpretó que por el hecho de haber sido instituidos herederos, se los estaba manumitiendo (Inst., 2.14 pr.; C.6.27.5; año 531).

Si son ajenos necesitan, lo mismo que los *alieni iuris* ajenos instituidos, la autorización del que los tiene en potestad, lo cual se explica por la responsa-

bilidad de las obligaciones hereditarias (Gayo, 2.186; Ulp., 22.12).

III. *Ius capiendi*. Una situación distinta de la *testamenti factio* es la "capacidad para adquirir" (*ius capiendi*) introducida por las leyes matrimoniales de Augusto (*lex Iulia de maritandis ordinibus* del año 17 a.C. y *lex Papia Poppaea* del año 9 a.C.).

1. Ver sobre esto *supra*, § 532. En lo relativo propiamente a este *ius capiendi*, recordamos brevemente que: a) los *caelibes* no podían adquirir nada *mortis causa*. Su parte se volvía caduca en favor del erario público (luego del fisco); b) los *orbi*, es decir, los casados sin hijos sólo podían adquirir *mortis causa* la mitad, y la otra se volvía caduca; c) a su vez, los casados sin hijos sólo pueden adquirir *mortis causa* entre sí, una décima. Esta porción se acrecienta por una décima por cada hijo sobreviviente de una unión anterior (Ulp., 15.1.3).

III. Contenido del testamento.

§ 621. A) La institución de heredero. Lo esencial de un testamento es la "institución de heredero" (*heredis institutio*). El testamento puede contener otras disposiciones (desheredaciones, legados, fideicomisos, dación de tutor, manumisiones, etc.). Pero la fuerza jurídica de todas ellas arranca de la existencia de la "institución de heredero". Es su piedra angular y Gayo podrá decir que es "cabeza y fundamento de todo el testamento" (*caput et fundamentum totius testamenti*; 2.229).

1. En la época clásica, la institución de heredero debe hacerse en latín, empleando la palabra *heres*. Los romanos quisieron que la institución fuera clara y no diera lugar a dudas. Así, decir simplemente: "Ticio debe tener todos mis bienes", no es suficiente, puesto que de este modo parece que las obligaciones no estarían a cargo de Ticio. Pero aun haciendo relación a éstas, tampoco valdría. Lo que interesa es la afirmación de que alguien es heredero, como continuador de la persona.

La institución debe ser expresada en términos directos e imperativos. Así, *Titius heres esto* ("Que Ticio sea heredero"), admitiéndose también "Ordene que Ticio sea heredero" (*Titium heredem esse iubeo*). En cambio, "Quiero que Ticio sea heredero", lo mismo que "Instituyo a Ticio como heredero" o "Hago heredero" no resultaban aceptadas en la época clásica (Gayo, 2.117; Ulp., 21).

2. Igualmente, la institución de heredero debe figurar al comienzo del testamento, de tal modo que otras disposiciones que figuraran antes (legados, manumisiones, etc.) eran inútiles y se consideraban no escritas (Gayo, 2.229 ss.).

Sin embargo, se admitió alguna excepción. Así, si instituyo heredero a mi esclavo, lo debía al mismo tiempo manumitir: "Que mi esclavo Stichus sea libre y sea mi heredero" (Gayo, 2.186). Labeón y Próculo opinaban que una "dación de tutor" —dado que en nada disminuye el monto de la herencia— podía figurar antes de la institución de heredero (Gayo, 2.231). Pero esta opinión no prevaleció en los tiempos clásicos, aunque luego será admitida por Justiniano (Inst., 1.14.3).

3. En el derecho posclásico, por una constitución de Constantino (C.6.23.15, año 339), se suprimió la obligación de utilizar formas solemnes para instituir herederos, pudiéndose hacerlo ya con palabras imperativas y directas, o con palabras indirectas. También, por una disposición de Teodosio (C.6.23.21.6, año 439), se puede utilizar el griego.

Se podían emplear formas no admitidas anteriormente: "Hago heredero" o "Instituyo" o "Quiero" o "Mando" o "Deseo", bastando el uso de "cualesquiera palabras", siempre "que sea evidente la intención de la voluntad". Estas formas estarán vigentes con Justiniano. Este emperador había establecido que, para prevenir fraudes, el nombre del heredero debía ser escrito por el propio testador o alguno de los testigos (C.6.23.29), pero luego dio marcha atrás, suprimiendo este requisito (Nov.119.9).

I. Se puede instituir heredero a una sola persona, pero también a varios señalándoles o no una parte de la herencia (Inst., 2.14.4).

1. Si el heredero es uno, o si son varios a los que se le ha asignado cuotas, podía ocurrir que la suma de todas las cuotas no agotara la totalidad de la herencia. Tal como ya lo dijimos, como había que respetar la regla de *nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest*, en este supuesto no se abre la herencia *ab intestato* por el sobrante, sino que éste acrecienta las cuotas de los herederos.

Del mismo modo, si con el cómputo de las cuotas se hubiera superado el total del caudal hereditario, los herederos verán disminuidas en forma proporcional las partes fijadas a cada uno de ellos (Ulp., D.28.5.13.3-6; Inst., 2.14.5-7).

2. Pero el testador podía instituir heredero sin asignarle una porción —*sine parte*—. Así, si Ticio es instituido por 1/4 y Gayo sin indicación de parte, este último se quedará con las 3/4 partes restantes (Ulp., D.28.5.17 pr.).

Pero si las asignaciones de partes completan el monto total de la herencia, y hay además otro heredero *sine parte*, se presume que el testador ha querido dividir el patrimonio en dos *ases* (*as* = total de la herencia), de tal modo que la mitad va a los asignados por partes, y la otra al que no la tenía (Ulp., D.cit.; Inst., 2.14.3).

II. El heredero instituido, ya único o juntamente por partes con otros, lo es siempre a

"título universal". Lo que no podía ocurrir era instituir heredero en relación a una cosa determinada (*ex re certa*). Así, p.ej.: "Que Ticio sea mi heredero respecto de mi fundo Tusculano". Técnicamente acá no hay heredero universal, con lo cual parecería que sería un legado, aparte de que dicho heredero no aparece responsabilizado por las deudas. Sin embargo, ya desde la época de Cicerón se tendió a "interpretar" la voluntad del testador acerca de la institución de heredero, considerando sin valor su limitación a cosa cierta.

1. En principio el testamento era nulo, pero empleando el *favor testamenti*, se consideraba válida la institución de heredero, teniendo por no escrita la mención de institución por la cosa.

Así, es interesante cómo los juristas clásicos resolvieron distintas hipótesis:

a) Si el heredero era único: así, "Que Ticio sea mi heredero en cuanto al fundo Tusculano", se consideraba que Ticio era el sucesor universal, y la expresión al fundo Tusculano, como no escrita (Ulp., D.28.5.1.4).

b) Si había dos herederos *ex re certa*: así, "Que Ticio sea mi heredero en cuanto al fundo Cornelianus y Seyo en cuanto al fundo Iuliano", se considera que ambos son herederos por la mitad de la herencia, teniendo por no escritas las expresiones referentes a los fondos (Sabino-Paulo, D.28.5.10).

c) En este otro caso, variante del anterior: "Que Ticio sea mi heredero por un 1/3 del fundo Cornelianus y Seyo por los 2/3 del mismo fundo, Ticio será considerado heredero por 1/3 y Seyo por 2/3 de la herencia (Celso-Sabino-Ulp., D.28.5.9.13).

d) "Sea Atcio mi heredero del fundo Cornelianus, y los dos Ticios herederos de tal casa": Atcio será heredero de la mitad de la herencia y los dos Ticios de la otra (Próculo-Javoleno, D.28.5.11).

e) "Que Ticio sea mi heredero excepto en cuanto al fundo Cornelianus". Ticio será heredero por el todo, sin tener en cuenta la excepción (Gelo Aquilio-Licinio Rufo, D.28.5.74).

2. Además, se fue considerando por la jurisprudencia que en caso de dos o más herederos *ex certa re*, el juez en la *actio familiae erciscundae* debía adjudicar a cada uno de ellos la cosa designada por el testador como si fuera un "prelegado". En este caso, siendo dos los herederos lo serán por la mitad, tanto en los bienes como en las deudas (Ulp., D.28.5.35 pr. y 1; Pap., D.id.78 pr.).

Justiniano, continuando esta solución, considerará que los herederos lo serán por partes iguales, pero las cosas asignadas valdrán como "prelegados" en favor del heredero respectivo (C.6.24.13).

III. La institución de heredero puede hacerse pura y simplemente, pero también bajo condición (así, "Que Ticio sea mi heredero si viene

una nave del Asia"). En cambio, no se la puede hacer desde un plazo fijo (así, "Que Ticio sea mi heredero cinco años después de mi muerte"), ni hasta un plazo fijo ("Que Ticio sea mi heredero pero sólo hasta cinco años"); Inst., 2.14.9.

En efecto, se entiende que la institución de heredero debe ser perpetua, conforme a la regla *semel heres semper heres* (aquel que es heredero debe continuar siéndolo). De haberse puesto estas modalidades prohibidas, se entiende que pese a ello el testamento no cae: la institución es válida y la cláusula es superflua y es como si no estuviera escrita (Pap., D.28.5.34; Inst., 2.14.9).

1. Se debe tratar de una condición suspensiva, no de la llamada "resolutoria": "Que Ticio sea mi heredero, pero dejaría de serlo si viene una nave del Asia", pues afectaría el principio del *semel heres semper heres*.

El efecto es retardar la apertura de la herencia hasta que se cumpla el hecho futuro e incierto. Si éste ocurre, el heredero será efectivamente tal. De no ocurrir el hecho condicional, el testamento cae y la herencia podrá ser reclamada por los herederos *ab intestato*. Hasta ese momento éstos no tienen ningún derecho a la herencia, sino sólo una esperanza (Paulo, D.50.17.80).

Para determinar cuándo la condición se considera cumplida, hay que tener en cuenta la voluntad del testador según lo expresado por éste en el testamento (Pap., D.35.1.101 pr.).

2. Dados los inconvenientes que se presentaban mientras la condición estaba pendiente, el pretor concede al heredero instituido la *bonorum possessio secundum tabulas*, pero debía dar caución de devolver los bienes si la condición no se cumpliera (Ulp., D.28.12; Pap., D.46.5.8).

3. No se admiten las condiciones imposibles ("si tocara el cielo con las manos") o inmorales ("si cometiere un homicidio"). Se las considera no escritas, siendo válida la institución de heredero como si fuera pura y simple (Paulo, 3.4b.2; Inst., 2.14.10).

Tampoco se admiten las llamadas condiciones "captatorias", es decir, aquellas que impliquen una institución supeditada a una liberalidad futura del heredero o legatario. Así, "Que Ticio sea mi heredero si mostrarse y probar que instituyó a Mevio como heredero suyo en su testamento" (Pap., D.28.5.70; Paulo, D.id.71; Gayo, D.30.64). Se habla de que esto fue dispuesto por un senadoconsulto desconocido, quizá el s.c. Liboniano.

4. Si se trata de un plazo incierto, así "Que Ticio sea mi heredero cuando Seyo muera", según Papiniano (D.35.1.75), queda asimilado a una condición, entendiéndose que lo que se quiso decir es "Que Ticio sea mi heredero si sobrevive a Seyo".

§ 622. B) Sustituciones de herederos. El testador, para precaverse de que la herencia

vaya a aquellos que él desea, podía tomar la precaución de instituir heredero en primer grado, y si éste no llega a serlo, ya por morir antes que el testador o porque no quiera serlo y rehúse la herencia, entonces instituya a otro en segundo grado. A éste se le denomina "sustituto". Había tres clases de sustituciones:

A) *Sustitución vulgar* (*Substitutio vulgaris*). Sería el caso normal expuesto: "Que Ticio sea mi heredero. Si no llegara a serlo, que lo sea Seyo". No había límites para las sustituciones: así, en el ejemplo dado, se podía instituir a Sempronio como sustituto de Seyo en tercer grado, y así sucesivamente. En último caso, y como recurso subsidiario, el testador podía instituir a uno de sus esclavos como heredero necesario (Gayo, 2.174; Inst., 2.15 pr.).

Igualmente, se podía sustituir a uno en lugar de otro, así como a varios en lugar de uno (Gayo, 2.175; Inst., 2.15.1).

1. Una de las formas de "sustitución vulgar" era la siguiente: "Lucio Ticio, sé heredero y haz la *cretio** dentro de los 100 días siguientes a aquel en que tengas conocimiento y puedas practicarla. Y si así no te decidieras, sé desheredado. Entonces, que Mevio sea heredero y haga la *cretio* dentro de los 100 días, etc.". Si L. Ticio no hace la *cretio* en tiempo oportuno, queda excluido por la desheredación. Mevio será entonces el heredero (Gayo, 2.174 y 176).

2. Pero si no hubiera cláusula de desheredación, es decir, si se decía simplemente: "Si no te decides, entonces que Publio Mevio sea heredero", en la época de Gayo había que distinguir. En efecto, si Lucio Ticio no había aceptado la herencia por la *cretio*, pero había actuado como heredero (*pro herede gestio*), que era una forma tácita de aceptación, tanto él como el sustituto eran herederos por partes iguales (Gayo, 2.177).

Luego, el emperador Marco Aurelio decidió que en este caso el heredero que ha actuado por la *pro herede gestio*, por lo menos durante el plazo de la *cretio* desplazaba al sustituto y se quedaba con toda la herencia (Ulp., 22.34).

3. La sustitución podía ser mutua o recíproca, en el caso de que habiendo herederos se instituye a éstos recíprocamente para el caso de que uno de ellos no lo fuera.

En este caso, si los herederos habían sido instituidos por partes desiguales, pero no se habló de partes en la sustitución, por una constitución de Antonino Pio, se entendió que dio en la sustitución la misma parte que le había dado a cada heredero en la institución (C.6.26.1, año 146, Inst., 2.15.2).

4. Un caso distinto era si se había instituido a dos herederos A y B, estableciendo que B era sustituto de A y además que un extraño C era sustituto de B. Si B hubiera premuerto entonces C pasa a ser

sustituto de A, y si éste no acepta la herencia, entonces C pasa a ser el heredero, como sustituto de ambas partes. Así fue decidido por un rescripto de Severo y Caracalla (Inst., 2.15.3; Jul., D.28.6.27).

5. Si se ha instituido heredero a alguien, no se le puede dar un sustituto para luego de un cierto plazo. Así: "Que mi mujer fuera mi heredera. Pero cuando mis hijos alcancen los 25 años, que lo sean ellos". Se iría contra la regla del *semel heres semper heres*. Sin embargo, se recurrió a la solución del fideicomiso: "Mi mujer será la heredera, pero le impongo el fideicomiso de traspasar los bienes luego que mis hijos alcancen los 25 años de edad. Éstos no son propiamente herederos, aunque quedaron asimilados a ellos (Gayo, 2.184; Inst., 2.16.9).

B) *Sustitución pupilar* (*Substitutio pupillaris*). Se daba este caso cuando el testador instituyó como heredero a su *filius*, tomando la precaución de que si éste falleciera antes de alcanzada la pubertad, estando bajo tutela, entonces el heredero sería otra persona como heredero sustituto (Gayo, 2.179, Inst., 2.16 pr.).

1. El pupilo no puede hacer testamento ni aun con la *auctoritas* de su tutor mientras permanezca impúber. Por tanto, si muriera antes de la pubertad el camino era abrir la herencia *ab intestato*. Precisamente para evitarla es que el *pater* recurre a esta "sustitución pupilar". Por medio de ella le está instituyendo heredero a su hijo para el caso de que muriera impúber.

2. La fórmula que nos da Gayo (2.179) es así: "Que mi hijo Ticio sea mi heredero. En caso de que no fuera mi heredero o de que siéndolo muriera antes de haber concluido su tutela, entonces que el heredero sea Seyo".

Acá podemos señalar: a) la institución del hijo como heredero; b) si no llegara a serlo, p.ej. por haber premuerto respecto del *pater*, Seyo es el sustituto; y c) este mismo Seyo es instituido heredero del hijo siempre y cuando que éste muriera antes de acabada la tutela, es decir, siendo impúber.

Pero el mismo Gayo nos dice que la institución de heredero del hijo no era necesaria, puesto que hasta podía producirse esta "sustitución pupilar" aun a los desheredados (2.182), por lo que cabe pensar que se podría hacer directamente sin la institución de heredero del hijo, bastando su desheredación, y sin la sustitución vulgar. La forma más simplificada sería: "Que mi hijo Ticio sea desheredado. Y si muriera antes de que terminara su tutela, entonces que lo sea Seyo".

3. Según nos dice Gayo (2.131), para evitar que el pupilo se viera expuesto al peligro de ciertas asechanzas después de la muerte del *pater*, se utilizaba el procedimiento de utilizar tablas separadas en el testamento, de tal modo que en las primeras (*primae tabulae*) se consignaba la institución de heredero del

hijo y la sustitución vulgar, para el caso de que no llegara éste a ser heredero por su premuerte en relación al testador. A su vez en las tablas inferiores (*secundae tabulae*), selladas con un hilo y cera especiales, se consignaba la "sustitución pupilar", advirtiendo el testador que no debían ser abiertas estando vivo el hijo y en tanto sea impúber.

El mismo Gayo nos dice que es más seguro consignar ambos géneros de sustituciones en las tablas inferiores del testamento, ya que si han sido selladas y separadas como ya dijimos, se puede deducir de la primera, que en la segunda la misma persona ha sido sustituida.

4. El heredero sustituto será heredero del *pater* en el supuesto de que el hijo no llegara a ser heredero (sustitución vulgar). Pero si el hijo es desheredado o se produce el caso de la sustitución pupilar, el heredero sustituto no es heredero del padre y del hijo, sino directamente heredero de este último (Gayo, 2.180). En cierto modo hay dos testamentos, uno del *pater* y otro del *filius*, como si éste instituyese su heredero. Pero como dice el mismo Gayo, en realidad es un solo testamento, pero de dos herencias (2.180; Inst., 2.16.2).

Más adelante se llegó a entender que si un *pater* hacía una *substitutio vulgaris* respecto de su hijo, ello suponía tácitamente la procedencia de la *substitutio pupillaris* (Const. de Marco Aurelio y Varo; Modest., D.28.6.4 pr.).

Vinculado con esta clase de sustitución figura la célebre *causa Curiana*.

C) *Sustitución cuasi pupilar* (*Substitutio quasi pupillaris*). Justiniano estableció un nuevo caso (*ad exemplum pupillaris substitutionis*). El *pater* que tenía un descendiente *mente captus*, podía instituirlo heredero y designarle un sustituto a los efectos de que no muriera intestado (Inst., 2.16.1; C.6.26.9).

1. Esto fue concedido por *humanitas*. El beneficio lo tenían los ascendientes (también la madre), y como sustituto se debía llamar a *certainae personae* que debían ser púberes: hermanos, hermanas del incapaz, y, en su defecto, a cualquier otro.

2. También se admitía respecto de un *furiosus*, pero si éste recobraba la razón, se invalida la sustitución (Inst., 2.16.1). Según un texto de Paulo, igual solución se había dado, por vía imperial, si se trataba de un descendiente mudo (D.28.60.43 pr.).

IV. Invalidez e ineficacia de los testamentos.

§ 623. A) *Invalidez*. El testamento puede adolecer de ciertos vicios o defectos que lo invalidan como tal. La terminología usada por los juristas romanos en los distintos casos es la siguiente:

a) El *testamentum non iure factum* (llamado también *iniustum* o *imperfectum*) es aquel (a) que ha sido confeccionado por alguien que carece de la *testamenti factio*, o (b) que teniéndola ha otorgado el testamento sin haberse guardado las formalidades necesarias (Gayo, 2.114); o finalmente que no hubiese instituido en forma al heredero (Gayo, 2.116; Inst., 2.20.30).

b) Si un testamento guarda todas las formalidades ya señaladas pero el *pater* hubiese preterido al *filius* (es decir, lo hubiese omitido, sin mencionarlo en el testamento, ya para instituirlo heredero o para desheredarlo) se dice que el testamento es "inútil" (Gayo, 2.123; Inst., 2.13 pr.: *testamentum inutile*).

c) Un testamento que hubiese observado todas las formalidades señaladas en los dos primeros casos se puede invalidar por una preterición futura de un heredero familiar (*heres suus*). Así, si el *pater* tiene un nuevo *filius*, ya por las nupcias o por haberlo adoptado (Gayo, 2.138; Inst., 2.17.1), o ha convenido la *manus* con su mujer (Gayo, 2.139; Ulp., 23.3), o por haber nacido un *filius* después de la muerte del testador que pareciera preterido en el testamento (Gayo, 2.130 ss.; 138 ss.; Inst., 2.13.1-2). En este caso se habla de que el testamento se "rompe" (*testamentum ruptum*).

d) El testamento se torna inválido si el testador sufriera una *capitis deminutio* posterior, de lo que se deduce que la *testamenti factio* se debe tener no sólo en el momento de otorgar el testamento, sino además continuar teniéndola hasta el momento de la muerte, que es cuando produce sus efectos. Se dice entonces que el testamento es "irrito" (*testamentum irritum*; Gayo, 2.145; Inst., 2.17.4).

1. Quien ha hecho testamento y luego sufre una *capitis deminutio*, ya fuera ésta "máxima", "media" o "mínima" (Ulp., D.28.3.6.4 ss.), torna a éste "irrito". Si por alguna circunstancia recobrara la capacidad, no por ello el testamento se convalida. La solución por el *ius civile* es hacer en ese caso un nuevo testamento.

2. Pero el pretor, aun cuando haya faltado la continuidad de la *testamenti factio*, si el testamento reúne los requisitos exigidos por el edicto (sellos de siete testigos), le concede validez a los efectos de otorgarles a los herederos allí señalados la *bonorum possessio secundum tabulas*.

Para ello, obviamente, el testador en el momento de su muerte debía gozar de la *testamenti factio*: ser ciudadano romano y *sui iuris*. La *b.p.* es *sine re*, es decir, puede resultar vencido por el reclamo de un heredero legítimo *ab intestato* (Gayo, 2.147-149; Ulp., 23.6; Inst., 2.17.4).

3. Además, en el caso de que la *capitis deminutio* se haya producido por haber caído el testador

como esclavo prisionero del enemigo, rigen reglas especiales: a) Si hiciera testamento estando prisionero, éste es inválido, ya que carece de la *testamenti factio*, y ello aun cuando regrese; si quiere debe hacer nuevo testamento (Gayo, D.28.1.8 pr.; Inst., 2.12.5).

b) Pero si regresa, goza del *ius postliminii* el testamento otorgado, siendo libre con anterioridad (Inst., 2.12.5). Y c) en caso de no regresar y morir prisionero del enemigo, el testamento que hizo siendo libre tendrá validez en virtud de la *fictio legis Corneliae* (Jul., D.28.1.12; Paulo, 3.4a.8; Inst., 2.12.5).

4. En el caso del testamento de un soldado que sufre una *c.d. minima* (p.ej., fue adrogado o emancipado), el testamento sería *irritum*. Pero si manifiesta su voluntad de mantenerlo tendrá valor "por la nueva voluntad del militar" y será considerado como si no se hubiese hecho *irritum* por la *capitis deminutio* (Inst., 2.11.5).

B) *Ineficacia*. Un testamento que sea válido se puede tornar ineficaz. Es el caso del *testamentum desertum* o *destitutum*. Ello ocurre cuando: a) el o los herederos han premuerto en relación con el testador; b) o han perdido la *testamenti factio*; o c) no han aceptado o han repudiado la herencia.

1. En caso de ser varios los herederos, el testamento continúa siendo eficaz si sólo uno o varios, pero no todos están en alguna de las situaciones mencionadas. Los otros pueden aprovecharse del testamento que no sería *desertum* respecto de ellos conforme a las reglas del acrecentamiento o, en su caso, de la sustitución de heredero.

§ 624. *Revocación del testamento*. Todo testamento puede ser revocado por uno posterior. Esto significa que el testador puede cambiar de parecer respecto de lo ya afirmado en el primer testamento, expresando ahora la actual en uno nuevo. Como lo dice Ulpiano: "variable es la voluntad del difunto hasta el último momento de vida" (D.34.4.4).

El tema de la revocación testamentaria presenta muchos problemas en el Derecho clásico, donde rigen las reglas del *ius civile* (respecto de la *hereditas*) y las del *ius praetorium* (respecto de la *bonorum possessio*). Así, podemos considerar los siguientes casos:

I. Un testamento hecho conforme al *ius civile*, es decir, *per aes et libram*, es revocado por otro testamento hecho también según las formas del *ius civile*. El que está vigente es el segundo testamento, siempre y cuando guarde todas las formalidades y requisitos. El primero ya no rige, pues está revocado.

Y ello sin interesar si el heredero instituido en el segundo, rehusare serlo, o premuriera respecto del testador o falleciera antes de aceptar

la herencia, etc. En todos estos casos, el testamento se vuelve *desertum*, y lo que corresponde, a falta de testamento, es abrir la herencia *ab intestato* (Gayo, 2.144; Inst., 2.17.2).

1. Para ejemplificar los distintos supuestos:

a) El testamento I es perfectamente válido. Luego el testador otorga el testamento II, y éste igualmente cumple todos los requisitos. El vigente es el testamento II.

b) Está el testamento I perfectamente válido. Pero el testamento II no ha respetado las reglas de validez (salvo si se tratara de un testamento militar). El vigente es el testamento I.

c) Hay un testamento I y un testamento II, ambos plenamente válidos. El primero resulta revocado y en principio el vigente es el testamento II. Si el o los herederos instituidos en éste no llegan a aceptar la herencia y llegamos al *testamentum desertum*, se debe abrir la herencia *ab intestato*.

II. Hay un primer testamento hecho con todos los requisitos y formalidades del *ius civile*. Con posterioridad, se otorga un testamento pretoriano. El pretor le concede la *bonorum possessio secundum tabulas* a los herederos instituidos en el testamento pretorio. Ésta era en principio *sine re*, es decir, los beneficiarios pueden ser vencidos ante el reclamo de un heredero legítimo *ab intestato*, pero luego de la disposición de Antonino Pio, será *cum re*, y los *bonorum possessores* podrán defenderse con una *exceptio doli* al reclamo del heredero legítimo *ab intestato* (Gayo, 2.119-120).

1. Un testamento no puede ser invalidado por la sola intención del testador de querer que no valga más. Así, si el testador ha roto la cinta o el hilo del testamento o, más aún, ha quemado voluntariamente las tablas, o tachado los nombres.

a) Si se trataba de un testamento civil, es decir, *per aes et libram*, seguía conservando su validez, ya que para el *ius civile* lo esencial era un acto oral y las tablas cumplían un papel probatorio. Por ello, Gayo asegura su validez "no obstante que la prueba sea difícil" (2.151).

b) Sin embargo, el pretor concederá la *bonorum possessio* a los herederos legítimos *ab intestato* y les otorga una *exceptio doli* si alguno de los inscritos en el testamento pidiera la *b.p. secundum tabulas* (Gayo, 151a, Ulp., D.28.4.1.3). Se interpreta que éstos "no tienen a su favor la voluntad del testador" (Ulp., 36.6.1.8). Al heredero instituido en esas condiciones se lo considera como indigno (*quasi indigno*), y se abre la vía para la herencia *ab intestato* (rescripto de Caracalla, Gayo, 2.151a; Coll., 16.3.1; Paulo, 3.1).

§ 625. Ya en la propia época clásica se le irá dando una importancia fundamental a la inter-

pretación de la voluntad del testador, tratando de dilucidar su verdadera intención.

1. Marco Aurelio, decidiendo un caso dudoso, resolvió que aunque el testador hubiera tachado los nombres de los herederos, había que cumplir los legados (Marcelo, D.28.4.3).

Luego, por una constitución de Alejandro Severo se reconoce eficacia a una carta que había revocado la institución de un heredero (C.6.35.4; año 223).

2. Theodosio II y Valentiniano III sancionaron, aparte de la forma pura y simple de revocación, otra que denominaban *testamentum posterius imperfectum*. Se trataba del caso de un primer testamento en el cual se instituya a herederos extraños. Éste era revocado por un segundo testamento que resultaba inválido por no cumplir las reglas. Pero como se instituya en él como herederos a los legítimos *ab intestato*, el acto aunque imperfecto tenía validez. Se exigía que la voluntad fuera atestiguada por cinco testigos, bajo pena de considerarse válido el primer testamento (C.6.23.21.5; año 439; Ulp., D.28.3.2 trp.).

En la época de Justiniano, la revocación se puede producir: a) por un nuevo testamento válido; b) por la apertura intencionada del testamento, con la ruptura de las cintas y sellos, o su destrucción; o c) por la voluntad expresada ante tres testigos o ante la autoridad judicial. Si queriendo revocar el testamento anterior (C.6.23.27; año 530).

En todos los casos se le da una importancia esencial a la voluntad del testador, sobre todo en el caso de destrucción material del documento, según se pruebe la voluntad deliberada de revocar o que fue debida a otra causa (C.6.23.30; año 531).

3. Debido a ello algunos textos del Digesto fueron manipulados. Así, había que distinguir entre lo que se borra o tacha voluntariamente, que lo torna inválido, y lo que se borra o tacha por descuido o involuntariamente, que sigue valiendo (Ulp., D.28.4.1 pr.). Lo mismo si el testador ha roto el hilo o cuerda de las tablas, su voluntad revocatoria queda probada. Pero si ello ocurrió por un tercero, o se hubiesen podido las tablas por antigüedad, por moño, o por haberla roído los ratones, entonces el testamento es válido (Ulp., D.37.11.1.11).

4. La sola voluntad del testador no basta para invalidar el testamento, de tal modo que si uno hubiese comenzado a hacer un segundo testamento sin llegar a acabarlo porque lo sorprendió la muerte o porque desistió de ello, por una constitución del emperador Pertinax se decidió que el primero continuaba siendo válido (Inst., 2.17.7).

5. Igualmente, Justiniano derogó una disposición de Theodosio y Honorio que hacía perder fuerza a

los testamentos luego de un decenio. Para Justiniano era válido, salvo que el testador lo revocara por un acta hecha ante la autoridad judicial o ante tres testigos (C.6.23.27; año 530).

§ 626. *Apertura del testamento*. El testador confiaba el testamento a un amigo o lo depositaba en un templo. A partir de la *lex Iulia vicesimaria* de Augusto (año 6 d.C.) se estableció un impuesto del 5 % sobre la herencia y los legados.

Según nos narra Paulo (4.6.1-3), la apertura del testamento se producía entre el tercero y quinto día luego de la muerte del *de cuius*. En Roma, se hacía en presencia de los testigos testamentarios, o de la mayor parte de ellos, quienes debían reconocer sus sellos. Luego, se rompe el hilo, se lee el testamento y se hace una copia; se lo sella con el sello público y se lo deposita en los archivos, a fin de que si la copia se deteriora, sea posible recurrir a él. Si se trataba de testamentos hechos en los municipios, colonias, etc., debía ser leído en el foro o en la basílica, en presencia de los testigos o de hombres honorables; igualmente se le sacaba una copia y era de nuevo sellado.

Corresponde al pretor constreñir —a pedido de parte— a quienes pusieron sus sellos como testigos, a hacerles comparecer para ver si los reconocen o no (Ulp., D.29.3.4; Paulo, D.1d.5; EP, § 167). Bastaba que fueran reconocidos la mayoría de los sellos. Respecto de los ausentes, no era necesaria su presencia, sino que bastaba que se les enviara el testamento al lugar en que se hallaban (Gayo, D.29.3.7).

1. La disposición del edicto del pretor era general y voluntaria. Aquellos que lo querían, tanto en su nombre como en el de otro, promete examinar (*inspiciendi*) el testamento, o sacar una copia (*describendi*); Ulp., D.29.3.8.

2. Si había dudas sobre la muerte del testador, el pretor se debía preocupar por averiguarlo, no permitiendo que el testamento sea abierto cuando se verificaba la existencia del testador (Ulp., D.29.3.2.4).

3. Si aquel que tenía las tablas del testamento rehusa presentarlas, era constreñido a ello. Si niega tenerlas, el pretor daba contra él un interdicto de *tabulis exhibendis* (Ulp., D.29.3.2.8; D.43.5.1).

4. Podía suceder que ciertas disposiciones no fueran abiertas, si así lo había dispuesto el testador, como, p.ej., cuando había sustituciones pupilares selladas aparte. También el pretor no consiente que se copie ni que se vea la fecha (día y nombre del cónsul) del testamento, para que no se haga una falsificación (Ulp., D.29.3.2.8).

5. A partir de Alejandro Severo (C.6.32.1; año 223) la apertura se hace ante el juez competente, quien ordenará que el testamento sea presentado.

§ 627. Los *codicillos*. Los *codicillos* (*codicilli*) son cartas o notas informales que se dejaban escritas en tablas o en papiro, donde se expresaban ciertas disposiciones de última voluntad.

No podían contener ni una institución de heredero ni una desheredación. Parece haber tenido su origen en el ruego que el testador hacía al heredero instituido de que cumpliera un fideicomiso*, que como veremos es un negocio no formal, que sólo obligaba moralmente por la *fides*. En un principio, no tuvieron valor jurídico, pero a partir de una decisión del emperador Augusto, tuvieron fuerza vinculativa (Inst., 2.25 pr.).

1. La palabra *codicilli* (diminutivo de *codex*) está empleada siempre por los clásicos en plural (Gayo, D.50.16.148). El empleo en singular (*codicillus*) denota un empleo posclásico posterior.

2. Según narra Justiniano (Inst., 2.25 pr.), fue Lucio Léntulo, el mismo que dio origen a los fideicomisos, el que introdujo esta forma de los *codicillos*. Estando próximo a morir, en África, escribió *codicillos* que confirmó en un testamento. En ellos rogaba al propio Augusto que hiciese alguna cosa por fideicomiso y habiéndolo hecho éste, los demás siguieron su ejemplo, y así la propia hija de L. Léntulo pagó legados a los cuales no estaba obligada en derecho estricto.

Se dice que entonces Augusto consultó una comisión de prudentes, entre los que estaba Trebacio, quien opinó que eran muy útiles y necesarios "a causa de las grandes y prolongadas peregrinaciones que hacían entonces, durante las cuales, si había imposibilidad —por las formas y requisitos— de hacer un testamento, al menos podrían hacerse *codicillos*".

Luego, habiendo hecho *codicillos* el mismo Labeón —el fundador de la escuela proculeyana, quien no era afecto a Augusto— ya nadie dudó acerca de su efectividad jurídica.

§ 628. En los *codicillos* hay que distinguir diversas clases, según sus aplicaciones y efectos:

a) Puede haber *codicillos ab intestato*, en los cuales, sin establecer ninguna institución de heredero, se puede imponer a los que reciben la herencia determinadas mandas como fideicomisos. Paulo dice que los herederos *ab intestato* quedan obligados a cumplirlas, pues estos *codicillos* valen "haciendo las veces de un testamento" (D.29.7.16).

b) Están los *codicillos* "confirmados por testamento" (ya sea éste anterior y previendo la validez de *codicillos* ulteriores; o posterior, confirmando el testamento los *codicillos* anteriores).

1. No pueden contener institución de heredero, ni desheredación, ni sustituciones (Gayo, 2.273; Marciano, D.29.7.6 pr.; Pap., D.1d.10). En cambio, pueden contener legados (Gayo, 2.270a; Ulp., 25.8), fideicomisos, manumisiones, daciones de tutor (Inst., 2.25.2; Ulp., D.26.2.3 pr.).

c) A su vez, había *codicillos* "no confirmados por testamento". En principio no son obligatorios, salvo que fueran luego confirmados (Pap., Inst., 2.25.1; D.29.7.5). Luego por rescripto de Severo y Caracalla se decidió que por medio de *codicillos* anteriores al testamento, era posible dejar fideicomisos, que son válidos si es que aparece que quien ha hecho un testamento posterior no se ha separado de la voluntad expresada en los *codicillos* (Gayo, 2.270a; Inst., 2.25.1).

1. Una innovación interesante es la aplicación en el testamento de la denominada "cláusula *codicillaris*". Por ella se determinaba que "si el testamento no valiese como tal, quiero que valga como *codicillo*". Esta cláusula debe ser expresa por cuanto no se la presume (Paulo, D.28.1.29.1; Pap., D.28.6.41.3; Ulp., D.29.7.1).

De este modo servía como remedio para salvar la omisión de los requisitos de los testamentos, impidiendo que se tornaran ineficaces. La institución de heredero debía ser interpretada como un fideicomiso que grava a los herederos *ab intestato*. Los legados y otras cargas deberán ser cumplidos por quien detente la herencia. La cláusula sólo sirve para disculpar errores formales, pero no la capacidad para hacer testamento, pues en ese caso no se puede hacer *codicillos* (Marciano, D.29.7.6.3), u otros vicios de contenido sustancial, como la preterición de herederos.

El uso de los *codicillos* creó cierta confusión en la época posclásica y del Derecho vulgar en materia testamentaria. Constantino prescribió para los *codicillos ab intestato* (C.Th. 4.4.1) y Teodosio (C.Th. 4.4.7) en toda clase de ellos el número de siete testigos, igual que para los testamentos. Justiniano los redujo a cinco, ante quienes debía el otorgante firmar y sellar (C.6.23.28.6).

CAPÍTULO 4

LA SUCESIÓN LEGÍTIMA CONTRA EL TESTAMENTO

§ 629. Según las viejas reglas del *ius civile*, el testador tiene la más amplia libertad en la confección de su testamento (*latissima potestas*, Pomp., D.50.16.120). Puede instituir heredero a quien quiera, tanto a sus herederos domésticos como a extraños. Incluso respecto de los primeros los puede desheredar sin dar razones.

Pero esta libertad tan amplia comenzó a ser limitada, precisamente en orden de proteger a los herederos legítimos. De lo que se trataba era del conflicto entre la amplia voluntad del *pater* para disponer de los bienes familiares y del otro lado las viejas costumbres que sostenían el fundamento de la herencia familiar para sus integrantes.

Las medidas tomadas fueron elaboradas, de manera muy prudente, por los jurisconsultos clásicos y continuada por los posteriores. En el fondo se trataba de lograr una cierta afirmación por parte de los herederos legítimos (que no lo eran testamentarios, p.ej.: por haber sido desheredados), aun en contra de la voluntad del *pater* expresada en el testamento.

Debemos acá distinguir varias etapas:

I. Caso de la preterición testamentaria según el *ius civile*.

§ 630. Cuando el *pater* hace testamento, dentro de la libertad que goza, puede instituir herederos a sus *sui heredes*, o desheredarlos. Sin embargo, de lo que debe cuidarse es de no silenciarlos. Si ocurre esto último, se dice que los ha "preterido". Ello se consideraba contrario al deber paternal.

Los efectos de esta preterición son distintos según los casos:

A) Si se trata de un hijo *in potestate*, debía ser instituido heredero o desheredado "nominativamente" (*nominatim*). Esto último significa que en la cláusula de desheredación había que designarlo por su propio nombre. Así, p.ej.: "Que mi hijo Ticio sea desheredado", aunque también, si tenía un solo hijo, valía la forma "Que mi hijo sea desheredado", ya que aunque no se agregara "el nombre propio no había ninguna duda de quién era el desheredado (Gayo, 2.127). En cambio, si se lo silenciaba, es decir, se lo

pretería, o siendo dos o más no hubiesen sido desheredados "nominativamente", el testamento es nulo (*inutile*), debiéndose abrir la herencia *ab intestato* (Gayo, 2.123).

B) Si se trata de los demás *sui heredes* (hijas, nietos o nietas, la *uxor in manu*) podían ser desheredados mediante una cláusula general colectiva. Así: "Que todos los otros sean desheredados" (Gayo, 2.128). Si en lugar de desheredarlos se los preteriese, el testamento es válido, y las personas preteridas concurren con los herederos instituidos del siguiente modo.

(i) Si habían sido preteridos respecto de los *sui heredes* varones que habían sido instituidos herederos, concurren a la herencia por una parte viril (Gayo, 2.124).

1. Así, si el testador tiene dos hijos A y B instituidos herederos, y una hija C que preterió, ésta recibe 1/3 de la herencia, al igual que cada uno de los hermanos. Se entiende por "partes viriles" aquellas que son iguales entre sí (Paulo, 3.2.3).

2. Si lo hacemos más complejo, en el mismo caso: A fue instituido por 2/3, B por 1/3, y C fue preterida, esta última recibe 1/3 respecto de la porción de A y 1/3 de la porción de B, las cuales sumadas serían igualmente 1/3 de la herencia.

(ii) Si habían sido preteridos respecto de un "heredero extraño", p.ej. un amigo del testador instituido heredero, entonces reciben la mitad de la herencia (Gayo, 2.124).

1. Así, p.ej., el testador instituye heredero a su amigo Ticio, y preteriere a su única hija. Ésta obtiene la mitad de la herencia, quedando la otra mitad para Ticio. Acá recibiría una cuota inferior a la que le correspondería si la herencia hubiera sido intestada, por cuanto por ser la única heredera debería haber recibido el todo.

2. En este otro ejemplo: El testador instituye heredero a su hijo A y a su amigo Sempronio por mitades, preteriendo a su única hija B. Ésta obtiene de su hermano A una parte viril, es decir, la mitad de la cuota de éste, y por el otro lado, la mitad de la cuota de Sempronio. En total, la cuota que le hubiera correspondido *ab intestato*, por cuanto por ser dos *sui heredes* (ella y su hermano) le correspon-

día la mitad de la herencia. Curiosamente acá, el hermano A instituido heredero sólo recibirá un cuarto.

(iii) En el caso de un hijo póstumo suyo, es decir, aquel concebido por el *pater* pero nacido después de su muerte, debía ser instituido o desheredado (Gayo, 2.130; Inst., 2.13.1).

Los póstumos de sexo masculino debían ser instituidos o desheredados nominativamente. Los de sexo femenino, lo podían ser ya nominativamente o en forma colectiva, pero se les solía dejar algún legado, para que se considere que no fueron preteridas por olvido (Gayo, 2.132; Inst., 2.13.1).

Esto era una excepción al principio de que no se podía instituir o desheredar herederos a personas inciertas, como lo eran los póstumos. Pero se permitió ya que la preterición, sin importar el sexo, hacía que el testamento cayera no porque no fuera inválido, sino porque la agnación del póstumo o de la póstuma, lo anulaba (*testamentum ruptum*; Gayo, 2.130-131; Inst., 2.13.1).

1. En un principio, la expresión de *postumi sui* se refiere propiamente a los hijos e hijas nacidos del *pater* que había hecho testamento, pero que nacían luego de su muerte.

Estos "póstumos" hubieran estado sometidos a la inmediata *patria potestas* y por ello eran "herederos suyos" del testador, de tal modo que habiendo nacido después de la muerte del *pater*, en principio "rompen" el testamento.

Por ello es que para este caso, los juristas admitieron que el testador pudiese de antemano instituir heredero o desheredar al póstumo suyo que naciera de su mujer dentro de los diez meses después de su fallecimiento. Esto fue así, para evitar la "ruptura" del testamento por la preterición de dicho póstumo (Gayo, 2.130-131; Inst., 2.13.1).

2. Pero esta significación de "póstumo" (que viene de *post humum*, es decir, que nace luego de estar enterrado el *pater*), se amplió a otros casos. Así, si el *pater* tiene un hijo al cual instituye heredero, pero este hijo le ha dado un nieto o una nieta, estos últimos, no obstante que están sometidos a la *patria potestas* del testador, no eran aún *sui heredes* de este, puesto que los precedía su *pater*.

Cuando el testador moría, sus nietos pasan a ser herederos suyos respecto de su padre. El problema se presentaba si hecho ya el testamento del *pater* su hijo moría antes del fallecimiento del testador o era emancipado: los nietos pasaban a ser directamente *sui heredes* del *pater*, y como en principio no figuraban en el testamento éste se rompía por la preterición de dichos nietos. Se empleaba ahora la expresión de *quasi postumi*, ya que llegan a ser herederos por una *quasi agnatio* (Gayo, 2.133; Dig., 28.3.13; Inst., 2.13.2; Ulp., 23.3). Ahora la palabra "póstumo" pasa a tener el sentido de "posterior".

3. Ya desde la época republicana, se trató de encontrar una solución para evitar la ruptura del testamento. El jurista Aquilio Galo, contemporáneo de Cicerón, inventó una fórmula para el caso siguiente: El *pater* tiene un hijo, del cual espera un nieto por cuanto su mujer está embarazada. Para evitar que por la premoriencia del hijo se rompiera el testamento, entonces se le permite instituir condicionalmente al nieto que nazca después de la muerte del testador:

La fórmula sería así: "Si mi hijo muriese viviendo yo, si de él me hubiese nacido un nieto o una nieta después de mi muerte, en los diez meses inmediatos a cuando muriese mi hijo, sean herederos" (Scev., D.28.2.29 pr.). De este modo se prevenía que el testamento no se rompiera. A estos póstumos se los llamó *postumi-Aquilianii*.

4. Los casos anteriores (*postumi sui* y *postumi Aquilianii*) se refieren a nietos nacidos luego de la muerte del testador. Quedaba aún el problema de los nietos nacidos en vida del testador habiendo premuerto su padre. Según el *ius civile*, si el *pater* hubiese hecho testamento, éstos quedaban preteridos y ello conduciría a su ruptura. Ciertamente se podía hacer nuevo testamento instituyéndolos herederos a los nietos.

Pero por la ley *Iunia Vellaea* (año 28 d.C.) se permitió, en su capítulo primero, que el testador pudiese instituir heredero o desheredar al nieto o a la nieta "póstumos" que nacerían antes de su muerte, a fin de dispensarlo de hacer nuevo testamento (*postumi Vellaeani*); Ulp., 22.19; Scév., D.28.2.29.11-12; Ulp., D.28.3.3.1.

La situación estaba perfectamente resumida por Ulpiano (22.19): "Aquellos que están en el útero, si nacidos fueran futuros *sui heredes* nuestros, los podemos instituir herederos. Si es que nacen después de nuestra muerte, conforme al *ius civile*. Si en cambio ocurre estando nosotros vivos, conforme a la ley *Iunia*".

Si bien Ulpiano habla de los "que están en el útero", llegaría a creer que este primer capítulo se refiere a los concebidos, el texto de Scaevola (D.28.2.29.12) habla de nietos póstumos en general, concebidos al tiempo del testamento o con posterioridad. Éstos son los llamados *postumi Vellaeani*.

5. Observemos que en el primer capítulo, la ley *Iunia Vellaea* se ocupa del caso de los nietos no nacidos en el momento de la facción del testamento. En cambio, en el segundo trata el caso de aquellos que ya existían cuando se hizo el testamento, pero que aún no son propiamente *sui heredes*, porque están precedidos por su padre.

Pero si éste premuere, o por otra causa (p.ej., emancipación) sale de la familia, resultaría que quedaría preterido en el testamento. Según el *ius civile* el testamento caía por ser *ruptum*. Pero la ley *Iunia Vellaea* no quiere eso (Scev., D.28.2.29.15).

Si vemos bien, no se trata acá de verdadero

"póstumo", puesto que el nieto ha nacido después de la facción del testamento, pero adquiere la calidad de *suius heres*. Por eso se dice que está en "lugar de póstumo" (*loco postumi*) y eran denominados *quasi postumi Vellaeani*. Era inútil que la ley le permitiera instituirlo heredero, puesto que esta facultad la tenía, ya que a diferencia del póstumo era una persona cierta. Por ello se limita a declarar que estos *quasi postumi* no rompían el testamento si eran preventivamente instituidos herederos o eran desheredados, para el supuesto de la muerte o emancipación de su padre (Gayo, 2.134; D.28.3.13; Inst., 2.13.2; Scév., D.28.2.29.15).

La razón de todas estas disposiciones, planteadas en A, B y C, fue la de tratar de salvar la herencia para los herederos domésticos (*sui heredes*). Sin llegar todavía a impugnar el testamento por la desheredación injusta, los juristas plantearon el supuesto de la preterición. Si se trataba de un hijo (o de un póstumo), arribaron a la invalidez del testamento, y en los otros casos a una solución de compromiso.

En todos estos casos en que el testamento continúa válido y los preteridos piden su parte, hay una combinación entre herencia testada y *ab intestato*, significando ello una excepción a la regla *Nemo pro parte testatus pro parte intestatus decedere potest*.

II. La *bonorum possessio contra tabulas* de los *liberi*.

§ 631. La segunda fase de este problema estuvo representada por la actividad del pretor. Hacia finales de la República, este magistrado, sintiendo menos escrúpulos en este tema, concede una preferencia al parentesco consanguíneo respecto del agnático.

Por ello establece que a los efectos del ordenamiento pretoriano la obligación de instituir o desheredar herederos no sólo abarca a los *sui heredes*, como establecía el *ius civile*, sino en general a todos sus descendientes (*liberi*) que serían herederos suyos si no hubiesen sufrido una *capitis deminutio* (así, p.ej., los que han sido emancipados).

1. El pretor los admite por medio de una ficción: "como si no hubiere sucedido la *capitis deminutio*, y por ello fueran *sui heredes* (EP, § 142; Paulo, D.37.1.6.1; Ulp., D.37.4.3.5; D. id.3.14). Esto se aplica a los emancipados. En cuanto a los dados en adopción, por pertenecer ya a otra familia agnática, se los considera extraños, salvo que, mientras viviera el padre natural, hubieran sido emancipados por el padre adoptante (Gayo, 2.135; 136; Inst., 2.13.3-4).

De este modo cambia ahora el fundamento que sostenía el régimen anterior del *ius civile*, basado en la protección de la familia tradicional fundada en la agnación, para amparar a todos los descendientes que lo eran por vínculo de sangre. El modo de protección era otorgar la *bonorum possessio contra tabulas*, la cual era siempre *cum re*, es decir, susceptible de ser defendida aun contra los herederos instituidos en el testamento (Gayo, 2.125). Esta reforma era ya conocida por Labeón, a comienzos del Imperio (Ulp., D.37.4.8.11).

Podemos observar los siguientes supuestos:

(i) Si el testamento era nulo por el *ius civile* (caso de la preterición de un hijo varón *in potestate*), por no haber testamento, era necesario abrir la herencia *ab intestato*. Los *liberi* —incluido los desheredados y los emancipados— podían acudir al primer llamamiento de la *b.p. ab intestato*, es decir, el *unde liberi**. La división se hace *per capita*, si bien los emancipados debían hacer colación de sus bienes (*collatio bonorum*); Marciano, D.28.2.32; Ulp., D.38.6.1.9.

(ii) Si la preterición no hacía nulo el testamento por el *ius civile* (caso de la preterición de la hija o de los nietos o nietas), éstos y los demás *liberi* (descendientes emancipados) preteridos pueden pedir la *b.p. contra tabulas*. Conforme a ésta los preteridos (no los desheredados) pueden conseguir una cuota exactamente igual a la que corresponde a la *b.p. ab intestato unde liberi*.

Como esta *b.p. contra tabulas* es *cum re*, los herederos inscritos en el testamento, salvo que fuesen *liberi*, quedan excluidos (Marciano, D.28.2.32 pr.; Africano, D.28.6.34.2; Ulp., D.37.4.10.5; D.38.6.1.9).

1. Así, el testador tenía un hijo A y una hija B. Instituye heredero a A y pretere a B. Ésta puede pedir la *b.p. contra tabulas*, pero ésta no le es concedida por el total hereditario, puesto que figurando entre los *liberi* su hermano A, el pretor lo auxiliaba *ex commissio per altum edicto*, es decir, se le aplicaba el "edicto por acto de otro" (en este caso, de su hermana: Ulp., D.37.4.3.11, D. idem, 8.14; Lenel, § 142). De este modo, cada uno de ellos obtenía la mitad de la herencia.

2. Solamente pueden pedir la *b.p. contra tabulas* los descendientes *in potestate* y emancipados que hubieran sido preteridos. No la pueden pedir los desheredados. En cuanto a los emancipados preteridos, se sigue la regla de que a los varones hay que desheredarlos "nominativamente", y a las mujeres, tanto en forma nominativa como en forma colectiva (Gayo, 2.135; Ulp., 22.23; Inst., 2.13.3).

De este modo, si bien en principio la *b.p. contra tabulas* otorga las cuotas de la *b.p. ab intestato*, podía suceder que por efecto de la desheredación los otros *liberi* podían obtener una porción mayor. Así, p.ej., si